ÁLVARO MOREIRA
CARLOS FRAGA

DIREITOS REAIS

Segundo as prelecções do Prof. Doutor C. A. da Mota Pinto ao 4.º Ano Jurídico de 1970-71.

LIVRARIA ALMEDINA
Arco de Almedina, 15
R. Ferreira Borges, 121
COIMBRA

ÁLVARO MOREIRA
CARLOS FRAGA

DIREITOS REAIS

Segundo as prelecções do Prof. Doutor C. A. da Mota Pinto ao 4.º Ano Jurídico de 1970-71.

LIVRARIA ALMEDINA
Arco de Almedina, 15
R. Ferreira Borges, 121
COIMBRA

ÁLVARO MOREIRA

CARLOS FRAGA

DIREITOS REAIS

Segundo as prelecções do Prof. Doutor C. A. da Mota Pinto ao 4.º Ano Jurídico de 1970-71.

LIVRARIA ALMEDINA
Arco de Almedina, 15
R. Ferreira Borges, 121

Todos os exemplares deverão ser numerados e rubricados, pelo menos, por um dos Autores.

N.º 19[illegible]

NOTA PREVIA

Estes apontamentos correspondem ao conteúdo das lições do Curso de Direitos Reais proferidas ao 4.º Ano Jurídico pelo Prof. Doutor Carlos Alberto da Mota Pinto, e recolhidas em fita magnética por autorização do Professor.

O texto agora publicado reproduz, pràticamente intocado, a versão extraída directamente da gravação, a que foram introduzidos, aqui e ali, alguma modificação e um

ou outro aditamento, a título de nota, feitos pelo Professor, sempre que lhe expusemos qualquer dúvida relativa ao texto gravado.

Agradecemos ao Professor a boa vontade com que acolheu e apoiou a iniciativa de procedermos a este trabalho e a colaboração inestimável que sempre nos prestou quando e onde lha solicitamos, assim como a autorização para publicar um texto primordialmente destinado e que cremos útil para os alunos, sem porém erguer, com base no carácter não especialmente elaborado das considerações expostas, um obstáculo a uma futura versão mais cuidada e desenvolvida dessas mesmas prelecções.

Coimbra, em Março de 1971

Álvaro Moreira

Carlos Fraga

BIBLIOGRAFIA GERAL

I - NACIONAL

a) ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 1966

Prof. Dr. PIRES DE LIMA - Lições de Direito Civil (Direitos Reais), prelecções recolhidas e publicadas por David A. Fernandes, 4.ª edição, Coimbra 1960.

Prof. Dr. DIAS MARQUES - Direitos Reais, parte geral, vol. I, Lisboa, 1960.

Prof. Dr. L. PINTO COELHO - Lições de Direitos Reais, publicadas por Maria Júlia Lopes Cardoso e outros, Lisboa, 1943.

Prof. Dr. L. da CUNHA GONÇALVES - Da Propriedade e da Posse - Lisboa, 1952.

b) POSTERIOR AO CODIGO CIVIL DE 1966

Prof. Dr. OLIVEIRA ASCENSÃO - Lições de Direitos Reais, versão policopiada, edição da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1966.

Prof. Dr. ORLANDO DE CARVALHO - Direito Civil (Direito das Coisas), Lições ao 4.º Ano Jurídico de 1969/70, versão dactilografada e policopiada (em publicação).

Dr. M. HENRIQUE MESQUITA - Direitos Reais, sumários das lições ao Curso Jurídico de 1966/67, Coimbra-1967, versão dactilografada e policopiada.

II - ESTRANGEIRA

CARBONNIER, Jean - Droit Civil, 3 - Les Biens - Collection Thémis, 1970.

PLANIOL, RIPERT, RICARD - Traité Pratique de Droit Civil Français - Tome III, Les Biens, 2.ª edição, Paris, 1952.

L. BARASSI - I Diritti Reali e il Possesso, Milão, 1952.

ALBALADEJO, Manuel - Instituciones de Derecho Civil -Tomo II - Derecho de Cosas, Barcelona, 1964.

FRITZ BAUR - Lehrbuch des Sachenrechts, München und Berlin, 3.ª edição, 1966.

LENT-SCHWAB - Sachenrecht, 11.ª ediçao, München und Berlin, 1966.

ORLANDO GOMES - Direitos Reais, 2.ª edição, São Paulo, 1962

* * *

INTRODUÇÃO

CAPITULO I

AMBITO DE APLICAÇAO E SENTIDO DA DISCIPLINA DOS DIREITOS REAIS

1 - Este curso tem como objecto o estudo dos Direitos Reais, uma expressão já conhecida, que surge integrada na classificação quadripartida das relações jurídicas do Direito Civil elaborada pela pandectística alemã: direitos das obrigações, direitos reais, direitos de família e direitos das sucessões.

Este esquema constitui simultâneamente uma divisão do Direito Civil e uma classificação das relações jurídicas pois os direitos das obrigações, os direitos das coisas, os direitos de família e os direitos das sucessões são ao mesmo tempo tipos de relações e conjuntos de normas — isto porque como classificação ou como ordenação a efectuar dentro do direito objectivo, tem como critério a natureza das relações a que se aplica.

Numa outra tentativa de situação da matéria, podemos também dizer que a disciplina dos direitos reais, ou seja, do Direito das Coisas, se insere na disciplina do direito civil patrimonial, o que pode traduzir-se na inserção do Direito das Coisas naquele conjunto de normas que visa regulamentar os fins económicos das pessoas, tutelar os

seus interesses avaliáveis em dinheiro; é portanto dentro da massa ampla de normas com este sentido que podemos situar os direitos reais. O direito civil patrimonial será assim, dentro do direito civil, aquele conjunto de normas atribuidoras de bens e definidoras da sua utilização, abrangendo outrossim aquelas regras que regulam a troca dos bens entre as pessoas e a cooperação prestada por estas umas às outras — bens e cooperação avaliáveis em dinheiro.

Isto será o direito patrimonial, não todo o direito civil, pois que dentro deste, existem domínios estranhos ao âmbito definido, v.g., os direitos pessoais de família, a regulamentação dos direitos da personalidade, que não se inserem nem nas normas que regulam a troca de bens e a cooperação através de serviços avaliáveis em termos económicos, nem nas normas que definem a atribuição dos bens e a sua utilização.

Definido assim o direito civil patrimonial, há ainda, no entanto, dentro dele uma importante distinção a fazer, constante também da já conhecida classificação da pandectística alemã — a distinção entre direitos das obrigações e direitos reais.

Inserindo-nos numa caracterização funcional, será correcto dizer-se que o direito das obrigações visa disciplinar a dinâmica patrimonial; as obrigações, como relações jurídicas, são meios ou instrumentos da dinâmica patrimonial propiciando a mobilidade do circuito económico, da vida económica em geral. De seu lado, os direitos reais visam, num sentido oposto, disciplinar a estática patrimonial, e isto porque não é através dos direitos reais que se processa a troca dos bens nem a cooperação das pessoas, nos termos acima referidos. O que os direitos reais fundamentalmente visam é disciplinar a utilização dos bens pelas pessoas, ou seja, no mundo económico, os direitos reais não estão no próprio cerne do circuito económico, não são instrumentos desse circuito, mas antes regulam as situações anteriores, as situações prévias da qualidade de proprietário, da de titular do direito de servidão, que v. g., se aliena; essas situações prévias e os resultados, diremos, sedimentados, posteriores à movimentação dos bens; regularão a qualidade de proprietário que se adquiriu, mas não o próprio modo de aquisição e de troca dos bens. Em resumo, será pois função dos direitos reais regular, quanto aos bens económicos, as situações prévias e os resultados posteriores da movimentação dos bens.

Pode dizer-se que os direitos reais são relações de manutenção e defesa do "statu quo" e não, ao contrário das

obrigações, direitos de prestação, relações pelas quais se processe a alteração da composição quantitativa ou qualitativa das esferas patrimoniais.

Ao dizer que se trata de relações de manutenção e conservação do "statu quo" patrimonial, temos de fazer uma certa reserva quanto ao rigor do juízo no que se refere aos direitos reais de aquisição. É que, quando se fala em direitos reais, existe a tendência para considerar apenas os direitos reais de gozo (propriedade, usufruto, enfiteuse, servidão), e talvez, também, os direitos reais de garantia (hipoteca, penhor), mas há uma outra categoria, aliás com uma natureza jurídica controvertida — a dos direitos reais de aquisição, de que se pode apontar como exemplo mais flagrante o direito real de preferência, um direito ao serviço de uma aquisição, por força do qual o seu titular vai adquirir um bem, dando tanto por tanto em relação a um negócio com terceiro.

Este direito real de aquisição parece, em princípio, que poderá escapar um pouco à afirmação de que os direitos reais são direitos de conservação e manutenção do "statu quo"; mas, feita esta reserva, os direitos reais, nos seus paradigmas mais correntes — os direitos de gozo —, são inquestionàvelmente instrumentos de manutenção e defesa do "statu quo ante".

Concluir-se-á assim que os direitos reais, e a sua disciplina, resolvem o problema que se põe a qualquer sociedade, que é o da atribuição e da utilização dos bens. Como e por quem são os bens apropriados? A quem são atribuídos? Como e por quem são eles utilizados? É na resposta ao problema do domínio, mais pròpriamente do domínio dos bens económicos, que se traduzem os direitos reais (1).

2 - Tudo isto significa que os direitos reais regulam o domínio dos bens, disciplinam a sua atribuição e a sua utilização.

A prossecução dessa finalidade é realizada com referência às directrizes de um sistema sócio-político-económico determinado; exprime as concepções e os princípios de um sistema cultural "lato sensu", històricamente determinado. O conteúdo e o regime dos direitos reais não será algo que valha duma forma intemporal. Uma consideração da História revela-nos profundas mutações neste domínio da vida social, desde a época feudal até aos nossos dias, e

(1) - Domínio, expressão utilizada aqui, não no sentido etimológico que está ligado à propriedade (dominus = =proprietário), mas domínio no sentido de poder sobre as coisas, que também existe numa servidão, num usufruto, etc., o domínio abrangendo os poderes dum usufrutuário e do titular de uma servidão, que não é idêntico ao domínio do proprietário.

nem sequer no mesmo momento histórico, muito em particular no momento e na época em que vivemos, constitui um problema passível de ser objecto de soluções unívocas e universalmente coincidentes. Aqui se reflectem, fortemente e de maneira muito viva, as grandes opções de sistema sócio-económico - político, muito especialmente, como se sabe, a problemática da apropriação dos bens de produção, clivagem fundamental entre dois grandes sistemas económicos em que o mundo hodierno está dividido — o sistema capitalista e o sistema socialista.

Embora sujeito a posterior desenvolvimento, considere-se, desde já, que a forma como os direitos reais tomam uma feição concreta corresponde a características de sistemas sócio-político-económicos diversos na História e no espaço. Como nota genérica fique-nos, por agora, a ideia de que o critério que está por detrás dos direitos reais arranca directamente, está ligado em via directa, às directrizes de um determinado sistema económico e cultural, historicamente determinado; será orientado por essas directrizes que este ramo do direito cumpre a sua missão — definir a atribuição e a utilização das coisas, do domínio sobre elas.

3 - Poderíamos também pensar os direitos reais segundo uma outra fórmula, também conhecida, segundo a qual os direitos reais contêm o "estatuto jurídico das coisas". Não nos parece correcta, inteiramente rigorosa, esta formulação, e isto porque o "estatuto jurídico das coisas" é, em bom rigor, antes aquela definição das categorias em que se inserem as coisas, a classificação e definição destas, a sua distinção interna entre móveis e imóveis, coisas consumíveis e não consumíveis, benfeitorias, frutos, partes integrantes e componentes, coisas simples e compostas — tudo isto é que será o estatuto jurídico das coisas, no fundo, a definição das características das coisas.

O estudo desta matéria não é, evidentemente, o estudo dos direitos reais, nem rigorosamente cabe dentro destes, mas sim num capítulo da Teoria Geral da Relação Jurídica, dentro do pensamento de que os problemas ligados ao estatuto jurídico das coisas são problemas que têm relevo não apenas no campo dos direitos reais, mas também noutros domínios. O problema de serem as coisas móveis ou imóveis, será algo que releva, por exemplo, para efeitos de sabermos se se exige ou não escritura pública para o negócio de alienação dessa coisa, e este é um problema que cai dentro do campo do direito dos contratos, do direito das obrigações, não do dos direitos reais. Idênticas con-

siderações se poderão tecer para a determinação de uma coisa como móvel ou imóvel relevar para avaliar do âmbito dos poderes do administrador dos bens do casal, que resultarão diferentes em resultado daquela determinação; isto põe-nos face a um problema de relações patrimoniais entre os cônjuges, que cai no âmbito dos direitos de família. Apenas exemplos significativos para a rejeição da ideia de serem os direitos reais o "estatuto jurídico das coisas"; este é constituído por aquelas normas que no Código Civil actual estão nos artigos 202º e seguintes (2), e essas normas inserem-se, não na teoria dos direitos reais, mas na teoria do objecto da relação jurídica, sendo as coisas a manifestação mais frequente e mais importante do objecto da relação jurídica.

(2) - Todos os artigos enumerados sem qualquer indicação dizem respeito ao novo Código Civil.

CAPITULO II

EXEMPLIFICAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO LEGAL E TERMINOLOGIA

4 - Caracterizados os direitos reais, poderemos começar por uma referência à fenomenologia em que eles se oferecem. De certo modo foram já algo exemplificados nas considerações feitas.

Assim, a matéria do direito das coisas está regulada no Livro III do Código Civil, onde se contêm várias figuras — a posse, a propriedade, o usufruto, o uso e habitação, a enfiteuse, o direito de superfície, as servidões prediais —, havendo depois outras figuras no capítulo da propriedade — a dos imóveis em geral, a compropriedade, a propriedade horizontal, a propriedade das águas. Isto não implica uma regulamentação exaustiva e total das figuras dos direitos reais nestas disposições do artigo 1251º e seguintes, pois há matérias pertinentes a este ramo de direito que são reguladas fora do Livro III, desde logo a ma-

tória dos direitos reais de garantia, tradicionalmente conhecidos como garantias reais das obrigações, matéria que vem regulada no artigo 656º e seguintes do Código Civil(3).

Há ainda outras matérias que têm interesse para o estudo dos direitos reais, mas que se encontram regulamentadas fora do Código Civil. É o caso dos registos (há um Código do Registo Predial de 1967, um decreto que regula o registo de automóveis e outro o registo comercial). (4)

A chamada propriedade intelectual, que abrange tanto o direito de autor como a propriedade industrial, é referenciada pelo artigo 1303º do Código Civil apenas para efeito de remissão do seu regime para legislação especial (5).

---

(3) - Isto uma vez que a prestação de caução (artº 623º e ss.) e a fiança (art.º 627º e ss.) não são garantias reais das obrigações (direitos reais de garantia), mas garantias pessoais; só constituem garantia real das obrigações as figuras da consignação de rendimentos, do penhor, da hipoteca e dos privilégios creditórios especiais.

(4) - Mais rigorosamente: o registo predial está hoje regulado no Código do Registo Predial (Decreto-Lei n.º 47611, de 28/3/67); o registo de automóveis no Dec.-Lei n.º 47952, de 22/9/67 e pelo Decreto n.º47953, da mesma data; e o registo comercial no Dec.-Lei n.º 42644, de 14/11/59 e pelo Decreto n.º 42645, da mesma data.

(5) - O Código do Direito de Autor actualmente vigente foi aprovado e faz parte integrante do Dec.-Lei n.º 46980, de 27/4/66, e o Código da Propriedade Industrial consta do Decreto n.º 30679 de 24/8/40. O nosso país é, aliás, signatário de convenções internacionais nestes domínios — Convenção de Berna e Convenção Universal sobre o Direito de Autor, Acordo de Madrid e Convenção de Paris

A própria caça e a pesca, que também, de algum modo, se prendem com os direitos reais, embora referenciadas pelo artigo 1319º , são-no apenas com o mesmo fim de remissão para legislação especial (6).

Esta indicação visa sòmente fornecer uma panorâmica geral das fontes, do assento das disposições legais referentes à matéria dos direitos reais. Essas disposições encontram-se, fundamentalmente, no Livro III do Código Civil, onde se regulam os direitos reais de gozo, no artigo 656º e seguintes do mesmo diploma (direitos reais de garantia) e as restantes matérias estão contidas em legislação avulsa. Dentro desta parte residual há a referir em especial a propriedade intelectual, que não constitui, em toda a sua dimensão, um direito real; embora se fale de propriedade literária, artística e científica, o direito de autor contém ainda em si o direito moral de autor, que dá a esse direito um carácter diverso do direito das coisas.

Diversamente a propriedade industrial; esta está já mais próxima dos direitos reais. No Código da Propriedade Industrial regulam-se os valores do comércio (nome do estabelecimento, a insígnia, as marcas, as patentes, os mo-

---

(6) - Código da Caça consta do Decreto n.º 47847, de 14/8/67 e sobre a pesca rege a Lei n.º 2097, de 6/6/59.

delos industriais,etc.),toda uma série de valores incorpó reos, objecto de direitos patrimoniais, e que levam portantd a que a propriedade industrial se aparente mais com os direitos reais do que o direito de autor, precisamente porque neste existe um elemento de ordem moral, que o faz aparentar-se também com os direitos da personalidade.

Focando, por último,a caça e a pesca, domínios que também se prendem com os direitos reais, na medida em que são operações jurídicas, actos materiais desencadeadores de efeitos jurídicos, que se traduzem na aquisição da pro priedade por ocupação. Numa sociedade como a de hoje em que não abundam as "res nullius"— as "res nulius" podem resultar,p.ex.,do abandono de uma coisa móvel,mas as pessoas não abandonam frequentemente coisas móveis,para delas se desfazerem— essas actividades revestem-se de um especial significado económico quase único neste campo da aquisição da propriedade por ocupação; traduzem-se, fundamentalmente, nos termos do artigo 1319º,na captura ou ocupação dos animais bravios (não forçosamente animais bravos, mas sim animais não domésticos) que se encontram no seu estado natural.

5 - Tendo nas considerações preliminares usado indistintamente duas expressões — direitos reais e direitos das coisas — com referência a uma mesma realidade,impõem-se acentuar a possibilidade de similitude ou de divergência entre elas existente e concretamente optar por aquela que com rigor traduza a noção jurídica que se pretende.

Ora as expressões podem ser usadas, e iremos usá-las doravante, em perfeita sinonímia, uma vez que convencionalmente têm o mesmo sentido. Ambas designam um ramo de direito que regulamenta o tipo de relações jurídicas destinadas a proporcionar a utilização e o domínio das coisas, sendo esse ramo designado tanto por Direitos Reais como por Direito. das Coisas, assim como às próprias relações em si tanto se lhes pode chamar direitos reais como direitos das coisas. Entre nós tem a chancela da tradição a expressão direitos reais, manifestando-se neste sentido a orientação doutrinal.

A expressão direito das coisas corresponde à terminologia utilizada por certas línguas estrangeiras, apresentando, de um ponto de vista lógico-analítico rigoroso, alguns inconvenientes. Na verdade,Direito. das Coisas melhor seria aquela conjunto de normas que regulam o estatuto das coisas — artigo 202º e seguintes. Estas,não sen

do a ordenação dos direitos reais, mas antes a mera definição de coisas móveis e imóveis, consumíveis e não consumíveis, fungíveis e não fungíveis,etc,é que melhor seriam o Direito das Coisas.

A expressão direitos reais será mais apropriada para designar a relação jurídica e menos para designar o ramo de direito que disciplina esse tipo de relação, mas de qualquer forma, e fiando-nos no valor convencional de ambas as fórmulas, vamos empregá-las em perfeita sinonímia, não distinguindo nem atribuindo a uma ou outra expressão um qualquer sentido preferencial. São perfeitamente sinónimos, Direitos Reais e Direito das Coisas, como designativos do ramo de direito que regulamenta este tipo de relações.

* * *

TITULO I

NOÇÕES GERAIS

CAPITULO I

CONCEITO DE DIREITO REAL

6 - Reportando-nos agora a alguns tipos de relações jurídicas, nomeadamente a propriedade, a servidão, a hipoteca, e outros de que adiante se fará uma enumeração exaustiva, e que se inserem na extenção da noção de direito real, um elemento comum se nos patenteia — a existência de uma coisa. Em todas essas situações surge-nos uma coisa e uma ligação entre esta e o titular do direito.

Ora estes elementos que ressaltam assim numa abordagem fenomenológica, numa mera aproximação da situação(não através de uma analítica rigorosa, esgotante, mas mediante uma captação intuitiva da realidade), estes elementos que assim ressaltam são os únicos relevantes de acordo com a concepção tradicional ou clássica de direito real.

A teoria clássica do direito real vê este como um poder directo e imediato sobre uma coisa certa e determinada. Para este ponto de vista, a destrinça entre direito real e direito de crédito é fácil e esquemática. O direito real é um poder que incide directamente sobre uma coisa; o direito de crédito é o poder que uma pessoa tem de exigir de outrém uma prestação. Quer dizer, enquanto o direito real confere o poder jurídico e material de retirar directamente todas ou parte — consoante o tipo de direito real — das utilidades económicas de uma coisa, havendo ainda entre esta e a pessoa uma ligação imediata, o direito de crédito pode desde logo dirigir-se, não à prestação de uma coisa, mas à de um facto, positivo ou negativo, uma acção ou omissão; mas, mesmo quando se dirige a uma coisa, quando é o direito a uma coisa, dirige-se ao comportamento do devedor, que é a sua entrega, interceden do entre o titular activo e a coisa a mediação de um comportamento do devedor que é a prestação.

Esta oposição entre direito real e direito de crédito, nos termos em que a faz a teoria clássica, está molda da na oposição que os romanos conheciam entre "actio in rem" e "actio in personam". "Actio in rem", assim chamada porque a fórmula em que era concedida não mencionava o nome do réu e, "mutatis mutandis", "actio in personam"

por nela se fazer essa menção. Era esta uma acção contra uma certa pessoa, enquanto que naquela a acção não era dirigida contra uma certa pessoa mas contra todos.

Dissemos que esta distinção entre direitos reais e direitos de crédito se molda na oposição romana entre "actio in rem" e "actio in personam" e não na distinção entre dois tipos diversos de "jus". Tal linhagem reflecte a concepção romana do direito em que se fazia avultar o aspecto processual. Assim, no cerne do pensamento jurídico romano, orientado para o processo, para a acção judicial, encontrava-se, não o direito material, mas a "actio". O ordenamento jurídico surge-nos, desta forma, como um conjunto de "actiones", mais do que um conjunto de normas atribuidoras de direitos materiais ou substantivos.

Sintetizando a concepção ou teoria clássica, podere mos afirmar ser o direito real uma relação entre uma pessoa e uma coisa, um poder directo que liga a pessoa a uma coisa, e o direito de crédito uma relação entre uma pessoa e outra pessoa.

Que posição tomar face a esta teoria ou concepção clássica do direito real? Qual a crítica que se pode fazer para a sua valoração positiva ou negativa?

7 - Desde logo se poderia dizer que a atribuição à prestação, nos direitos de crédito, de um significado decisivo não é uma posição totalmente isenta de dificuldades ou de dúvidas.

Senão vejamos. Para a posição clássica, a obrigação traduz-se no direito a uma prestação, enquanto que o direito real se traduz em um direito sobre uma coisa. Ora, também nos direitos de crédito o que interessa ao credor não é o comportamento, a actividade do devedor em si, especto que avulta de um ponto de vista estrutural. O que satisfaz o interesse do credor é a própria coisa, o "bem" que corresponde à prestação ou seja, nas obrigações de prestação de coisa, a coisa que tem a receber, nas de prestação de facto, o resultado da prestação. É esse "bem", e não o comportamento do devedor, que corresponde ao interesse do credor e tanto é assim que, se se exceptuarem as obrigações de prestação de facto não fungíveis, o credor pode pedir, com vista à satisfação do seu direito, a execução específica por virtude da qual a coisa é apreendida e entregue ao credor, obtendo este, sem que seja o devedor a efectuar a prestação, satisfação. Pode também o cumprimento ser efectuado por terceiro, devendo o credor, que por esta forma vê realizado o seu interesse, aceitar esse cumprimento. Tudo isto significa, sobretudo no plano

funcional, que o que tem interesse para o credor não é a prestação, o comportamento ou a acção do devedor, mas o "bem" que esta proporciona.

Ponhamos, porém, esta crítica entre parêntesis e não a desenvolvamos especialmente, porque o que é certo é que a dogmática civilística continua a ver na prestação o objecto do direito de crédito ou, pelo menos, o seu objecto imediato, e não é fácil encontrar um elemento de substituição para ela.

Estruturalmente, o direito de crédito é o direito a uma prestação, não sendo assim despropositada a contraposição que a doutrina clássica faz entre obrigação e direito real, considerando aquela como um direito a uma prestação e este como direito sobre uma coisa. Não seria despropositada essa contraposição... se não interviessem considerações suplementares susceptíveis de revelar a insuficiência da doutrina clássica. Porém essas considerações existem e são de molde a fazer-nos repelir essa doutrina.

Em primeiro lugar porque, por um lado, esta concepção de direito real como um poder directo e imediato sobre uma coisa parece não fornecer um critério que esgote a análise da situação correspondente ao direito real.

Pergunta-se: porque é que se pode dizer que no direito real o titular activo tem um poder directo e imedia

to sobre uma coisa? porque é que o usufrutuário, tomando um exemplo clássico de direito real, tem um poder directo e imediato sobre uma coisa e já, por exemplo, o comodatário, titular de um direito de crédito, ou o arrendatário, segundo a doutrina predominante, já não têm esse poder directo e imediato sobre a coisa? Quando o que é certo é que, observadas exteriormente, numa abordagem fenomenológica, há em ambos os casos a mesma situação de contacto, uma inerência material entre uma pessoa e uma coisa.

Ora o poder directo e imediato sobre a coisa existe como corolário do direito que tem o seu titular de excluir todos os outros de uma intervenção na coisa. O poder directo e imediato sobre a coisa não é uma realidade originária ou primária, mas uma consequência jurídica do poder de impôr aos outros uma abstenção e uma não ingerência na coisa que é objecto do direito. É porque existe, do lado contrário àquele em que se situa o titular activo do direito real, um dever geral de abstenção, que fica reservado para aquele o monopólio do uso exclusivo da coisa e surge o tal poder directo e imediato sobre ela. Esta a primeira consideração.

Acresce que só poderia ter valor imagético ou alegórico o dizer-se que o direito real é uma relação entre uma pessoa e uma coisa. Pode pôr-se assim em relevo um elemento importante da situação — a coisa cujas utilidades serão fruídas, sendo esta fruição o interesse subjacente ao direito real. Mas é um absurdo falar-se de relações entre uma pessoa e uma coisa; é absurdo fazer desta o sujeito passivo.

Um dos terminais do direito real é o sujeito activo, o dono da coisa, o usufrutuário, por exemplo. E o outro ? Este só pode ser outro ou vários outros homens e isto porque o direito, como fenómeno social, regulamenta relações entre pessoas propondo-se resolver conflitos entre estas ou seja, no caso particular dos direitos reais, conflitos relativos ao domínio e à utilização das coisas, conflitos inter-subjectivos, entre homens.

O direito é um fenómeno social que existe porque existe sociedade, porque existe vida de relação. Não há direito subjectivo ou objectivo enquanto existe um Robinson Crusoe isolado numa ilha deserta; para que surja, é necessário, pelo menos, a chegada de "Sexta-Feira". Todo o direito supõe uma relação entre pessoas, entre sujeitos de direito. O direito real não pode, assim, bastar-se com a ligação entre o seu titular e a coisa, tem de exprimir-se necessàriamente num elo inter-subjectivo. Só este, aliás, é que explica a obrigação de indemnizar em que se constitui o infractor no caso de violação de um direito

real, v.g., no caso de destruição da coisa ou de qualquer prejuízo causado nela.

8 - Destas considerações arranca uma outra concepção, a concepção ou teoria personalista.

Esta doutrina, formulada,p. ex.,por Planiol, jurista francês, põe em questão a teoria clássica. O direito real é, para este autor, uma relação, não entre uma pessoa e uma coisa, mas entre um sujeito e todos os outros consociados. Aos poderes do titular activo contrapõe-se aqui uma obrigação passiva universal. O direito real é um poder de compelir os outros indivíduos a absterem-se de qualquer acto que possa prejudicar o titular do direito real. A obrigação passiva universal está pois presente na estrutura do direito real como obrigação geral e negativa, enquanto no direito de crédito o dever que recai sobre o titular passivo não é esta obrigação, mas sim um dever de prestação a cargo de pessoa determinada ou determinável . Este é o núcleo fundamental da doutrina personalista.

9 - Cabe agora fazer referência a uma doutrinaque é um desenvolvimento da doutrina personalista — concepção de DEMOGUE, outro jurista francês.

DEMOGUE reduz a uma unidade a dicotomia direitos reais-direitos de crédito, ao afirmar que nestes últimos também existe uma obrigação passiva universal.

Segundo este autor, também, nos direitos de crédito, envolvendo como uma espécie de casca exterior o poder que o credor tem de exigir a prestação do devedor, existe uma obrigação — a que todos os outros se encontram adstritos — de respeitar o direito de crédito,de tal forma quequalquer consociado pode ser responsável perante o credor por ter impedido o cumprimento da obrigação. A obrigação passiva universal não seria assim, para DEMOGUE, privativa dos direitos reais,mas estaria também presente nos direitos de crédito. A diferença entre direito real e direito de crédito não seria verdadeiramente qualitativa mas mais quantitativa, uma vez que, havendo em ambos essaobrigação passiva universal,esta é o elemento fundamental dos direitos reais,enquanto nos direitos de crédito consiste na imposição "erga omnes ", pelo credor, do seu direito à prestação do devedor.

Esta doutrina carece, porém, de fundamento material a partir do momento em que o sistema jurídico não admitao

chamado efeito externo das obrigações a que esta concepção conduz.

Ora, nem a doutrina nem os dados legais permitem afirmar este efeito externo das obrigações, ou seja, não atribuem ao credor um poder ou direito de exigir uma indemnização de terceiro que tenha impedido o cumprimento da obrigação. Esta solução encontra, desde logo, algum apoio no n.º2 do art.º 406º do C.C. e também, de alguma forma, nas normas integradas na regulamentação do contrato promessa e do pacto de preferência, respectivamente art.º 413º e 421º, que correspondem antes à doutrina dominante ou seja, à negação desse efeito externo das obrigações. E, sendo assim, negado esse apoio normativo, então carece de apoio a doutrina de DEMOGUE.

10 - Há, além desta concepção, uma outra que, embora por via diferente, opera idêntica redução, vindo também a conduzir os direitos reais e os direitos de crédito a uma unidade, mediante a identificação de ambas as relações, realizada através da ideia de que o direito de crédito se traduz, afinal, em um direito sobre o património de devedor. Esta doutrina, ofuscada pelo aspecto da execução patrimonial do direito de crédito, não é harmónica com

os dados normativos, uma vez que à posição do credor faltam notas típicas dos direitos reais, nomeadamente os direitos de sequela e de preferência. Um credor não tem, com efeito, pela simples razão de ser mais antigo, qualquer preferência sobre o titular de um crédito mais recente, nem pode perseguir os bens do devedor que vão saíndo do seu património, salvo nos termos da impugnação pauliana, caso em que esses bens voltam ao património inicial, mas para serem colocados numa posição que beneficia todos os credores e não apenas aquele que tomou a iniciativa de propor a acção.

11 - Expostas, assim, a doutrina clássica e a doutrina personalista dos direitos reais, urge proceder a uma opção no sentido de se saber qual a concepção preferível.

Cremos que se terá de partir da doutrina personalista. Só esta concepção, que vê o direito real como uma relação estabelecida entre o titular activo e todos os outros consociados, atende a uma nota fundamental do direito real que é a garantia, ou seja, a defesa contra as violações do direito. Esta defesa do titular activo contra as violações do direito real, só pode ser concebida se a

dmitirmosque faz parte da estrutura do direito real uma obrigação passiva universal a que todos os outros consociados se encontram adstritos em face do titular do direito.

Só admitindo este dever geral de abstenção, situado no contrapolo do titular activo, é que podemos compreender a responsabilidade civil resultante da destruição ou deterioração da coisa, as pretensões reais como, p. ex.,o direito de reivindicar a coisa, ou seja, o direito que tem o proprietário de a ir buscar ao património de quem abusivamente se apoderou dela, tudo soluções que só se compreendem à luz da preexistência de um dever de não perturbar o exercício dos poderes do proprietário. A própria tutela possessória, os poderes que tem o titular da posse de obter a sua restituição no caso de esbulho, só encontra guarida através da ideia de que havia uma relação por força da qual os outros se encontram obrigados a respeitar a posição do titular activo.

Assim, precisando o conceito de direito real, definir-lo-emos como o poder de exigir de todos os outros indivíduos uma atitude de respeito pelo exercício de determinados poderes sobre uma coisa ou, por outras palavras, o poder de exigir de todos os outros uma atitude de respeito pela utilização da coisa em certos termos por parte

do titular activo.

Quais os poderes ou quais esses termos de utilização que devem ser respeitados? Pois bem, são aqueles que correspondem ao conteúdo concreto do direito real em causa. Ora, como os direitos reais estão sujeitos ao princípio da tipicidade ou "numerus clausus" — só podem ser direitos reais as figuras restritas previstas na lei — são os poderes correspondentes ao conteúdo típico do direito real do qual se nos apresenta uma manifestação.

Poder, pois,de exigir de todos os outros uma atitude de respeito pelo exercício de determinados poderes sobre a coisa. Mas esta formulação leva-nos a pensar imediatamente no seguinte: é que não pudemos fugir nela à necessidade de delimitar a esfera de acção que deve ser respeitada — a esfera de acção do titular activo — com referência a uma coisa.

Afirmamos, acima, tratar-se de um poder do titular activo de exigir de todos os outros uma atitude de respeito pelo exercício de certos poderes sobre uma coisa ou pela utilização desta em certos termos. Na definição desta relação inter-subjectiva tivemos que nos reportar a uma coisa, aos poderes sobre esta, à sua utilização. Quando quisemos delimitar os poderes ou a esfera de acção do titular do direito, tivemos que referi-los a uma coisa. Quer di-

zer: parece que não podemos fugir a esta necessidade de fazer uma referência aos poderes que se podem exercer, dado o tipo de direito real, sobre a coisa.

Ora, é precisamente o exercício desses poderes que não pode ser perturbado e o seu conhecimento esclarece-nos, por um lado, sobre quando é que ocorre uma violação ou quando é que esta não existe. Por outro lado, o tipo desses poderes permite individualizar os vários tipos de direitos reais entre si. Não é, com efeito, pela ligação inter-subjectiva que distinguimos a propriedade do usufruto, da servidão ou do direito de superfície, p.ex., visto que em todos eles há este esquema formal — um poder ao qual se contrapõe uma obrigação passiva universal. O que distingue a propriedade do usufruto ou da hipoteca é precisamente o conteúdo específico de poderes que, num caso e no outro, se podem exercer sobre a coisa; o que conduz a que tenhamos que atender, para a definição do direito, ao conteúdo deste.

Há no direito real um lado externo: a ligação inter-subjectiva, o poder de exigir dos outros a obrigação passiva universal. Este lado externo deixa um espaço no qual agir o titular activo, e a forma pela qual esse vazio é preenchido tem que resultar da consideração do tipo de poderes que se está legitimado para exercer sobre a coisa.

Há aqui um lado interno, como que um núcleo, que não pode estar ausente na definição do direito real.

O defeito da teoria clássica era pura e simplesmente negar o aspecto inter-subjectivo e acentuar apenas o poder directo e imediato sobre a coisa. Uma posição personalista, porém, que procurasse ser completamente espiritualista, que procurasse não dar relevo à posição do titular sobre a coisa, que se reduzisse ao chamado lado externo, limitando a definição do direito real à obrigação passiva universal, também seria incorrecta ou insuficiente por não levar em conta o tipo de poderes exercitáveis sobre a coisa. Há aqui um lado interno que não pode ser descurado.

O direito real terá, pois, um lado externo e um lado interno, caracterizado este por poderes de certo tipo que podem ser exercidos sobre uma coisa. É esta consideração do lado interno que permite, como referimos, distinguir entre si os vários direitos reais - direitos reais de gozo e de garantia e, dentro daqueles, a propriedade dos *jura in re aliena*, dos direitos sobre propriedade alheia e, ainda aqui, o usufruto da servidão, de enfi-

teuse, do direito de superfície, etc. (7).

* * *

(7) - Cfr. na doutrina portuguesa uma outra construção do direito real, excluindo-o do esquema da relação jurídica, em OLIVEIRA ASCENSÃO, in As Relações Jurídicas Reais, Lisboa 1962, especialmente pág. 79 e ss., e in Lições de Direitos Reais, ao Curso do 4.º Ano Jurídico de 1966-67, edição da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, pág. 71 e ss. O Direito Real para este Autor é uma situação jurídica inerente a uma coisa (nesta medida a referida posição pode ser incluída ainda entre as que reconduzem o Direito Real a um poder directo sobre a coisa). A posição dos terceiros perante o titular do Direito Real, para este Autor, não é dada por uma relação entre eles e o titular activo, mas pelo dever jurídico de respeitar a esfera jurídica alheia, pelo dever jurídico de "neminem laedere".

CAPITULO II

CARACTERISTICAS DOS DIREITOS REAIS. CONFRONTO COM OS DIREITOS DE CRÉDITO

12 - Encontrado o conceito de direito real, tem lógica justificação apurarmos agora as suas principais características, para o que recorreremos, nessa análise, à perspectiva de um confronto dos direitos reais com os direitos de crédito. Quais são as notas distintivas que permitem diferenciar estes dois tipos de direitos?

a) EFICÁCIA ABSOLUTA

13 - Em primeiro lugar surge-nos como característi

ca específica dos Direitos Reais a eficácia absoluta de que estes gozam. Com efeito, são os Direitos Reais eficazes "erga omnes" o que se traduz, por um lado, na atribuição ao seu titular do poder de os exercer em face de todos os outros e, por outro, na imposição a estes de restrições, ou, melhor, da necessidade de respeitarem o direito que em face deles se apresenta. São, portanto, empregando uma outra fórmula latina, "jura excludendi omnes alios".

É, aliás, esta eficácia absoluta dos direitos reais uma das razões determinantes da sua sujeição ao princípio da tipicidade ou "numerus clausus", princípio referido no art.º 1306º C.C. e cujo significado será, adiante, objecto de uma precisão mais minuciosa.

Mas, para já, fique a idéia, aliás conhecida, de que este princípio resulta da impossibilidade em que se encontram os particulares de criar direitos reais de um tipo ou com um conteúdo que não correspondam aos tipos e conteúdos desenhados na lei; não há, assim, liberdade de conformação interna dos direitos reais diversamente do que sucede nos direitos de crédito.

Dissemos que a eficácia absoluta dos direitos reais, embora não constitua a única razão determinante do princípio da tipicidade, é, porém, uma das suas justificações, o que levanta lògicamente a questão de saber por que for-

ma ou em que termos esta eficácia absoluta caracterizadora dos direitos reais postula o princípio da tipicidade.

Pois bem, este princípio - o da tipicidade - surge-nos como um corolário, uma resposta, a uma exigência derivada daquela eficácia absoluta dos direitos reais que temos vindo a referir, e isto por duas razões:

- a primeira é a de que se os direitos reais gozam de uma eficácia absoluta, então, como vimos, devem ser respeitados por todos, o que implica, para que isso se verifique, a sua cognoscibilidade por todos os restantes membros da colectividade; ora isto só é possível se se proceder à tipicização desses direitos;

- a segunda exprime a idéia de que uma protecção absoluta ou seja, em face de todos, só deve ser garantida pelo ordenamento jurídico se se verificar a existência de uma real necessidade nesse sentido; é que a eficácia absoluta dos direitos reais implica a criação de restrições à liberdade de acção de todos que não o titular desses direitos; ora, esta limitação da liberdade, correlativa da atribuição de um direito real, só pode justificar-se em face de uma vantagem de carácter geral resultante dessa situação; daqui decorre que não possa permitir-se aos interessados a criação de direitos reais de um tipo ou conteúdo determinados pelo seu alvedrio.

Os tipos dos diferentes direitos reais e respectivos conteúdos devem, pelas considerações expostas, encontrar-se pré-determinados e descritos na lei.

Diversamente, os direitos de crédito, porque se traduzem no poder de exigir uma prestação do devedor -; pessoa certa e determinada pelo menos ao momento do cumprimento -, têm uma eficácia meramente relativa.

Resumindo, a primeira nota distintiva dos direitos reais em face dos direitos de crédito resulta da circunstância de aqueles gozarem de uma eficácia absoluta, enquanto que a destes é meramente relativa.

b) DIREITO DE SEQUELA OU DE SEGUIMENTO

14 - Segue referir-se na exposição das notas distintivas dos direitos reais o direito de sequela ou de seguimento que constitui, ele também, uma consequência da eficácia absoluta dos direitos reais. É, de facto, por força desta característica que as relações jurídicas reais, de que nos ocupamos, se encontram dotadas desta nota, tradicionalmente designada por direito de perseguição, direito de sequela ou, ainda, direito de seguimento.

Significa isto que o direito segue a coisa, persegue-a, acompanha-a, podendo fazer-se valer seja qual fora situação em que a coisa se encontre. Daí que o titular do direito real possa sempre exercer os poderes correspondentes ao conteúdo do seu direito, ainda que o objecto entre no domínio material ou na esfera jurídica de outrém.

A hipótese tìpicamente indicada para exemplificar o direito de sequela é a seguinte: o proprietário pode reivindicar a coisa de um terceiro que dela se tenha apoderado e isto, tanto no caso de essa apropriação ter resultado de um acto material, como no de provir de um acto de natureza jurídica. Assim, figure-se que um indivíduo comprou um prédio a A, mero locatário, julgando ser este o proprietário respectivo. O proprietário pode reivindicar a coisa da pessoa que a adquiriu por um título - compra e venda - normalmente idóneo para transferir a propriedade, mas que, não o é, no caso em apreço, por o transmitente não possuir legitimidade para alienar uma coisa que lhe não pertence. Não fica, por isso, o proprietário inibido de reivindicar a coisa, podendo fazê-lo, excepto se, como é óbvio, entretanto se tiverem verificado os pressupostos da usucapião a favor do terceiro adquirente. Pode, com efeito, muito bem suceder que a reivindicação da coisa seja paralizada por uma excepção - a da aquisição por usuca-

pião - oposta pelo seu possuidor desde que tenham já decorrido os pressupostos dessa forma de aquisição da propriedade.

Retomando agora a hipótese referente ao exemplo utilizado, poderá dizer-se que o proprietário exerce uma acção de reivindicação, constituindo esta o meio processual pelo qual a sequela se manifesta.

Note-se, porém, que não é a acção de reivindicação o único meio processual de manifestação da sequela, embora o facto de esta ser correntemente exemplificada com hipóteses do tipo daquela que assinalámos pudesse sugerir o contrário.

No exemplo citado a sequela revestirá efectivamente a veste processual correspondente à acção de reivindicação. Isso deve-se à circunstância de aí a coisa se encontrar numa situação material incompatível com o direito, uma vez que ela se situa, não na posse do seu proprietário ou de quem a detivesse com permissão deste, mas na de um terceiro que a adquiriu de quem, sem autorização do seu proprietário, não tinha legitimidade para a alienar. Ora, nestes casos em que a coisa se encontra numa situação material incompatível com o direito, a sequela vai manifestar-se precisamente através da acção de reivindicação.

15 - Nas hipóteses em que, não se verificando essa situação de incompatibilidade, mas apenas a existência de uma situação jurídica susceptível de perturbar o direito real, não havendo, por isso, lugar à acção de reivindicação, não deixa, porém, também aí, de se manifestar a sequela.

Assim, por exemplo, tanto ao usufrutuário como ao titular de um direito real de garantia (v.g. a hipoteca) assiste o direito de sequela, se a coisa for alienada a terceiro pelo seu proprietário; isto na medida em que esses direitos reais podem ser opostos ao terceiro adquirente para quem a coisa se transmitiu. Não há, todavia, nestes casos qualquer razão que justifique o exercício de uma acção de reivindicação, desde logo porque, por exemplo, na hipótese do usufruto, o usufrutuário até está na posse da coisa, não tendo assim nada a reivindicar.

Então, pergunta-se: em que se manifesta aqui esse direito de sequela?

Manifesta-se na circunstância referida ou seja nada o usufruto poder ser exercido em relação ao novo adquirente da nua propriedade ou propriedade de raiz. Só que, agora, o exercício da sequela não vai traduzir-se numa acção de reivindicação, mas no de uma acção de simples apreciação.

O usufrutuário está, como já dissemos, na posse da

coisa, não obstante esta ter sido transmitida do proprietário da raiz para um outro, podendo afirmar o seu direito de usufruto em face do novo proprietário. É nesta possibilidade que assiste ao usufrutuário de fazer valer o seu direito contra qualquer adquirente da propriedade, limitada pelo usufruto, que precisamente reside a sequela. Só que aqui este direito de sequela não vai manifestar-se através de uma acção de reivindicação, uma vez que - insistimos - nada há a reivindicar, mas mediante uma acção de simples apreciação intentada pelo usufrutuário, se surgirem dúvidas sobre a existência do seu direito, para que este venha a ser declarado.

Daqui resulta que a acção de mera apreciação constitui em hipóteses do tipo que prefiguramos - o usufruto - o meio processual idóneo para o direito de sequela se manifestar.

As coisas passam-se de forma idêntica em relação ao outro exemplo citado - a hipoteca. Também ao credor hipotecário, ao titular do direito real de garantia, assiste a possibilidade de continuar a dar à execução a coisa, objecto do seu direito, independentemente de esta pertencer ainda ao proprietário que constitui a hipoteca, ou já a um posterior adquirente. É precisamente nessa possibilidade que o titular da hipoteca tem de fazer valer o seu

direito, independentemente da transmissão da propriedade, que reside esse direito de sequela.

16 - Destas considerações arranca uma segunda nota específica dos direitos reais em face dos direitos de crédito. É que ao titular destes, diversamente do que vimos acontecer em relação ao titular daqueles, não assiste o direito de sequela. Este surge-nos, assim, como privativo dos direitos reais.

Figure-se, neste sentido, um exemplo extraído do contrato de comodato ou de um contrato-promessa de comodato. O credor desta promessa não pode opôr o seu direito ao novo proprietário da coisa sobre que este incide, se, entretanto, aquela for alienada. Concretizando: se A promete emprestar-nos o seu automóvel no próximo fim de semana é-nos lícito exigir-lhe, chegado esse momento, o cumprimento da obrigação a que se acha adstrito, facultando-nos o uso do veículo. Se, no momento do cumprimento, o devedor - A - tiver, porém, alienado o automóvel, não podemos exigir ao novo proprietário que nos faculte a utilização do veículo. A nossa posição de credor não aderiu, assim, à coisa, não a acompanhou na transmissão da sua propriedade para um terceiro adquirente; o que conduz necessàriamente à conclusão de não nos assistir aqui o direito

de sequela que permanece, assim, exclusivo dos direitos reais.

Aliás, já vimos, em momento anterior, ser a falta deste requisito que nos leva a repudiar aquela concepção que vê no direito de crédito um direito real sobre o património do devedor. O direito de crédito não proporciona, como então dissemos, um direito real sobre o património do devedor, uma vez que o seu titular, diferentemente do titular deste, não pode perseguir os bens que saem do património do devedor, excepto através da chamada impugnação pauliana, verificados os pressupostos deste instituto (p. ex. má fé nas alienações onerosas). Não se trata aqui — como se vê - do direito de sequela.

Na vigência do Código de Seabra a doutrina apontava, também, como argumento favorável à não identificação da acção pauliana com a sequela, o disposto no art.º 1044º do respectivo Código, ao estatuir que, exercida a impugnação pauliana, os bens voltavam ao património do devedor para aí serem executados no interesse de todos os credores. O Código de 1967 veio, porém, introduzir aqui uma alteração ao estatuir textualmente no seu art.º 616º n.º 4, que "os efeitos da impugnação pauliana aproveitam apenas ao credor que a tenha requerido".

Este esclarecimento, com alcance de "jure condito",

deve ser tomado em conta ao versarmos esta questão sobre a qual já tecemos, aliás, em momento anterior, considerações de carácter genérico. Aí fez-se referência, em termos gerais, a esta inexistência da sequela nos direitos de crédito e disse-se que, reentrando os bens no património do devedor, eles eram aí executados por todos os credores (8).

No nosso direito positivo actual, as coisas não se passam inteiramente desta forma. Não deixa, porém, de ser exacta a afirmação de que a sequela se não confunde com a impugnação pauliana, uma vez que esta implica, diferentemente do que resulta do exercício do direito de sequela, a anulação do acto de transmissão da coisa para um terceiro adquirente, exigindo ainda, para que possa ser exercida, a verificação de certos e determinados requisitos. Não é, portanto, a impugnação pauliana uma manifestação do direito de sequela.

Só se quer acrescentar, agora, a terminar o confronto entre estes dois institutos - direito de sequela-impugnação pauliana - não ser inteiramente exacta, em face dos termos do n.º4 do art.º616º referido, onde se consagra doutrina inovadora, a ideia de que os bens alienados, por força da impugnação pauliana regressados ao património do

(8) - Cfr. Supra, n.º 10, p. 37

devedor, são aí executados no interesse de todos os credores. Esses bens aproveitam apenas, nos termos dessa disposição legal, ao credor que tiver exercido essa impugnação. Não obstante, continua a ser válida, pelo exposto, a afirmação de que a impugnação pauliana não constitui uma manifestação do direito de sequela.

17 - Cumpre, agora, na continuação da análise desta segunda característica privativa dos direitos reais - e que vale para todos eles - versar uma outra questão.

Comportará o direito de sequela excepções? Haverá situações em que, pelo menos, substancialmente, se verifiquem resultados equivalentes a excepções ao direito de sequela?

Vejamos.

Não constitui excepção ao exercício do direito de sequela a boa fé do adquirente "a non domino" ou seja, do terceiro que recebeu a coisa de quem não era seu proprietário. Daí que apesar da boa fé do adquirente, o verdadeiro proprietário continue a poder reivindicar a coisa e a exercer o seu direito em face daquele terceiro adquirente.

18 - Não encontra, assim, expressão entre nós um princípio que - expresso na máxima francesa "en fait de meubles possession vaut titre" (em matéria de móveis a posse vale título) - é aceite por muitas legislações estrangeiras (9) em relação aos bens móveis.

Significa tal máxima que o adquirente de um móvel, estando de boa-fé por ignorar os vícios de legitimidade da pessoa que lho transmitiu, o adquire definitivamente, não podendo ser-lhe exigida a restituição do objecto. O seu direito sobre este surge, pois, como pleno e definitivo.

Assim acontece, como dissemos, na legislação inglesa que voltamos a referir por este princípio se encontrar aí consagrado com uma particular acuidade. Com efeito, de acordo com este sistema jurídico, toda a pessoa que adquira um bem móvel num comerciante, ou num mercado aberto, por exemplo, torna-se proprietário dela, desde que ignore não pertencer o objecto em causa ao transmitente, por v. g., ter sido encontrado, roubado ou furtado - desde que, portanto, se encontre de boa-fé.

Poderá perguntar-se, e com pleno cabimento, quais as razões justificativas deste regime, desta relevância atribuída assim a esse elemento de boa-fé.

Pois bem, sem nos alongarmos, poderá dizer-se, num apontamento sociológico, que este regime corresponde no

(9) - Princípio que exprime uma doutrina aceite nos direitos francês, italiano, alemão e inglês.

mais alto grau aos interesses do comércio, pretendendo satisfazer as necessidades do tráfego.

Já em França, onde esta máxima encontra igualmente expressão legal, o legislador entendeu introduzir-lhe, porém, algumas restrições. Assim, também este sistema jurídico considera o detentor de boa-fé da coisa móvel como seu verdadeiro proprietário, exceptuando apenas, e diversamente do sistema de "common law" referido, em que esse princípio encontra a sua máxima expressão, as hipóteses de o anterior proprietário ter sido dela desapossado por perda ou furto. Exceptuados estes dois casos, então, em todas as restantes hipóteses segundo o direito francês, o adquirente de boa-fé adquire validamente.

Entre nós, como dissemos, o princípio "posse vale título" não encontra apoio legal podendo sempre o proprietário reivindicar a coisa do terceiro que a tenha adquirido do mesmo de boa-fé - isto até na hipótese prevista no art.º 1301.º C.C. - coisa "... comprada, de boa-fé, a comerciante que negocie em coisa do mesmo ou semelhante género..." -, que é daquelas em que mais se faria sentir a necessidade de um regime idêntico ao inglês. Decorre do exposto que o proprietário reivindicante, o verdadeiro proprietário, pode exigir a restituição da coisa de terceiro, ainda que este a tenha adquirido a comerciante que negoceie no mesmo tipo de bens. Assim, exemplificando, se alguém compra numa loja de antiguidades uma estatueta, ignorando que o objecto adquirido pertence a um terceiro e foi perdido, furtado ou vendido ao comerciante por quem erròneamente julgava ter legitimidade para o fazer, ainda nestes casos, em cumprimento da disposição citada, corre o comprador do objecto o risco de este lhe ser exigido pelo verdadeiro proprietário.

A lei tenta, porém, temperar um pouco esta desprotecção da boa-fé ao atribuir no referido art.º 1301º, ao adquirente a possibilidade de exigir do reivindicante a restituição do preço, embora concedendo a este um direito de regresso contra quem é responsável pela colocação dessa coisa no comércio, contra a vontade do seu proprietário.

Portanto, retenha-se esta ideia, a boa-fé não constitui, pelo exposto, um obstáculo ao exercício do direito de sequela, mesmo naquele caso particular, de a coisa móvel, objecto da reivindicação ter sido adquirida a comerciante nos termos do art.º 1301º citado.

O único aspecto em que de alguma forma a nossa lei foi sensível a esta necessidade geral de conceder alguma protecção aos terceiros de boa fé que adquirem móveis "a non domino", surge-nos em matéria de preceitos sobre a usucapião.

É que este princípio - posse vale título - embora de consagração e amplitude discutíveis, corresponde a uma real necessidade geral de protecção a terceiros, adquirentes de boa-fé, uma vez que não existindo um sistema de publicidade tabular (registral) para os móveis, a sua apropriação é difìcilmente cognoscível, o que conduz, lògicamente, a que a propriedade dos móveis seja indiciada pela sua posse. Por esta infere-se que quem detém a coisa em seu poder é o proprietário.

Daí que países com maiores tradições e necessidades comerciais, como é o caso da Grã-Bretanha, consagrem esse princípio, ao contrário do que se verifica noutros; nomeadamente em Espanha ou mesmo entre nós.

Como dissemos, essa necessidade social não passou, porém, desapercebida ao nosso legislador que veio a dar-lhe alguma guarida na medida em que estabelece prazos muito curtos para a usucapião de coisas móveis. Neste sentido cite-se, por exemplo, o art.º 1299º C.C. nos termos do qual "a usucapião de coisas não sujeitas a registo dá-se quando a posse, de boa fé e fundada em justo título, tiver durado três anos,...". Assim, retomando o exemplo que há pouco indicámos, o indivíduo que comprou a coisa ao comerciante e verifica, posteriormente, que aquela não pertencia a este, encontrando-se, portanto, sujeito a ser

despojado dela pelo seu autêntico proprietário, (10) pode, no entanto, adquirir, por usucapião, a plena propriedade da coisa, decorridos que sejam três anos sobre a sua aquisição.

Portanto - e resumindo - pode afirmar-se que a boa-fé de terceiro adquirente de bens móveis não constitui obstáculo ao exercício do direito de sequela.

19 - E quanto aos imóveis?

Também aqui não há, em princípio, obstáculo à sequela. O titular de um imóvel, A, pode sempre reivindicar a coisa de um terceiro, C, para quem foi transmitida por intermédio de B. O verdadeiro proprietário pode reivindicar a coisa ainda que C se encontrasse de boa-fé ao adquiri-la a B .

Podem equacionar-se várias hipóteses a este respeito. Como se sabe, as alienações de imóveis só são eficazes em relação a terceiros feito o respectivo registo. Vejamos essas hipóteses:

---

(10) - Embora, nesta hipótese - a do art.º 1301º-isto só aconteça, se lhe for entregue a importância que dispendeu por ela.

A — B — C

I - a coisa está registada em nome de A, sendo vendida a C por B que carece de legitimidade para o fazer. A pode, neste caso, exercer o direito de sequela, mediante uma acção de reivindicação, indo buscar a coisa ao património de C sem que este possa, para se lhe opôr, invocar a sua boa-fé ;

II - a coisa estava registada em nome de B a quem tinha sido invàlidamente vendida por A. Declarado nulo ou anulado este acto, tudo se passa como se não tivesse havido transmissão. A continua a ser proprietário, podendo reaver a coisa de C para quem B entretanto a transmitira. Esta nulidade ou anulabilidade do acto entre a A e B só pode, porém, ser oposta a C, dentro dos limites do art.º 291.º e, nessa medida, pode ocorrer aqui uma excepção ao direito de sequela;

III - a coisa pertence a A por lhe ter sido vendida por B mas A não registou a aquisição, o que não acarreta a invalidade do negócio , dado que a falta de registo se traduz apenas na ineficácia do acto em relação a terceiros; posteriormente, B vende a coisa a C que a registou; nesta hipótese, A embora tendo aquirido a propriedade por força do primeiro acto, não pode reivindicar a coisa de C e isto porque não tendo registado a sua aquisição esta é inoponível a terceiros que tenham primeiro registado a sua compra.

Também aqui há uma situação que, de certo modo, equivale substancialmente a uma excepção à sequela. A adquire de B por acto válido, mas não registou: A é proprietário mas não pode invocar a sua propriedade em face de terceiro e, se assim é, então, não há sequela. E, nesta hipótese, acontecerá assim, ainda que C esteja de má fé, por saber da primeira venda de B a A. É que a lei, pretendendo dar uma eficácia absoluta ao registo, estabelece uma prevalência a favor da primeira venda registada, ainda que o posterior adquirente - C no nosso exemplo - tenha tido conhecimento de ter havido uma venda anterior à sua. O que decide aqui é, assim, a prioridade do registo.

c) DIREITO DE PREFERÊNCIA OU DE PREVALÊNCIA

20 - Outra característica dos direitos reais é o direito de preferência ou de prevalência. Esta traduz-se na circunstância de os direitos reais constituídos sobre uma coisa prevalecerem, quer sobre os direitos de crédito relativos a essa coisa, quer sobre os direitos reais posteriormente constituídos sobre a mesma coisa e que se revelam total ou parcialmente incompatíveis com o anterior.

É este um princípio que vale - ele também - para todos os direitos reais.

Dele resulta, pois que, verificando-se uma constituição sucessiva de direitos reais sobre a mesma coisa, incompatíveis entre si, o conflito resultante dessa situação é dirimido de acordo com a velha regra "prior in tempore, potior in jure". É a prioridade temporal de constituição do direito real que determina a prioridade jurídica.

Constitui, também, esta característica uma emanação da eficácia absoluta dos direitos reais. De facto, quem adquire um direito real pode opô-lo por força da sua eficácia absoluta, "erga omnes", a todas as pessoas, inclusivamente a quem tenha adquirido posteriormente um direito real sobre a mesma coisa, incompatível com o anterior. O direito de prevalência surge-nos, por isso, como um corolário da eficácia absoluta dos direitos reais, encontrando algum apoio no n.º 1 do art.º 408.º C.C. que estabelece a regra da transmissão dos direitos por mero efeito do contrato.

Dissemos que o direito de preferência ou de prevalência era uma característica de todos os direitos reais. Há, porém, quem não entenda assim as coisas.

Luís PINTO COELHO (11) e, hoje também, OLIVEIRA ASCENSÃO (12), defendem que a prevalência ou preferência é uma característica que se estende, não a todos os direitos reais, mas exclusivamente aos de garantia.

Compreende-se que se fale de preferência - dizem estes Autores - quando, por exemplo, se constituiram sucessivamente duas hipotecas sobre uma mesma coisa. Surgem então dois direitos reais de garantia conflituantes, tornando-se necessário estabelecer uma prioridade, uma ordem de exercício dos referidos direitos, o que se consegue fazendo prevalecer o direito primeiramente constituído ou, no caso da hipoteca, primeiramente registado. Daí que o titular da segunda hipoteca só possa vir a pagar-se depois de o titular da primeira ter obtido satisfação do seu crédito pelo valor da coisa. Isto é que seria autêntica e genuína preferência.

Nos direitos reais de gozo não haveria lugar ao direito de preferência; segundo esses Autores, a transmissão sucessiva da propriedade sobre a mesma coisa a dois sujeitos diferentes não cria nenhum direito de preferência. O que se verificaria então seria a existência de um direito e de um não-direito e isto porque, tendo-se o transmitente despojado do seu direito na primeira transfe

(11) - Cfr. ob. cit., p. 42 e segs.
(12) - Cfr. ob. cit., p. 89.

rência, não pode agora, na segunda, transmitir um direito que não possui. Daí que se não verifique uma situação de conflito entre dois direitos que necessite de ser resolvida mediante a intervenção do direito de preferência, mas uma colisão entre um direito e um não-direito.

Que dizer desta concepção?

Não se pode efectivamente ignorar a diferença que existe entre as duas situações em confronto ou seja, entre os termos em que a preferência se põe no domínio dos direitos reais de garantia e aqueles em que surge no dos de gozo e a esta doutrina cabe o mérito de o pôr a claro. Não parece, contudo, que se deva ir mais longe, a ponto de recusar a legitimidade da preferência nos direitos reais de gozo.

Com efeito, se, por exemplo, uma pessoa aliena duas vezes um direito de usufruto sobre a mesma coisa ficamos perante duas situações que, em si, são aptas em geral (que aspiram ambas), a gerarem um direito, cumprindo então decidir sobre qual dessas situações constitui o direito. Ora, é precisamente a resposta a esta questão que nos é dada pelo princípio da prioridade temporal, tradicionalmente expresso pela ideia de preferência ou prevalência. Há aqui dois pretensos direitos, duas situações reivindicando cada uma delas a legitimidade para constituir um direito. Onde esteja este, qual das transmissões - a primeira ou a segunda - tenha feito surgir o direito - isso depende de considerações de política legislativa. Mas quando o legislador determinou que prevalece o direito primeiramente constituído, ou primeiramente registado, nessa hipótese, diz-se que os direitos desse tipo estão dotados da característica de preferência ou prevalência. A prioridade temporal engendra, assim, a prioridade jurídica. Não se vê que esse regime, aliás não forçoso, pois até comporta excepções, possa ser expresso por outra forma que não a referida: a prevalência ou preferência.

Só que, como é óbvio, enquanto que o princípio da preferência estabelece, nos direitos reais de garantia uma prioridade de exercício do direito, aqui, nos direitos reais de gozo, esse direito de prevalência vai decidir da própria existência ou inexistência do direito.

Nestes termos é o direito de preferência ou prevalência, de que nos temos vindo a ocupar, uma característica que com toda a lógica se pode imputar aos direitos reais.

21 - Estes dois direitos sobre os quais nos debruçámos ùltimamente - o direito de preferência e o de sequela - emprestam ao direito real uma tutela particularmente for

te, o que justifica o interesse que certos credores manifestam dentro do mundo económico, do mundo do crédito, em reservar ou adquirir o direito de propriedade sobre certos bens até ao cumprimento dos contratos de onde emergem os créditos de que são titulares. Há mesmo, pode dizer-se, na vida económico-jurídica hodierna uma tendência muito nítida para o surgimento de figuras em que uma posição de credor é garantida através da reserva ou da aquisição de um direito real de gozo sobre uma determinada coisa.

Neste sentido basta lembrarmo-nos da chamada venda com reserva de propriedade, figura que se encontra regulada no art.º 409.º C.C. - um indivíduo, por hipótese comerciante, vende a outro, normalmente a prestações, um determinado objecto, reservando, porém, a propriedade deste até ao pagamento de última prestação. E o que se pretende com isto? Pretende-se que o credor do preço fique numa posição privilegiada. De facto, se não houvesse reserva de propriedade, no caso de não pagamento, o vendedor-credor poderia apenas executar o património do comprador, tendo de suportar, nessa execução, a concorrência de todos os outros credores, inclusivé no que toca à execução da própria coisa vendida.

Certo, poderia pensar-se então numa outra figura, v.

g., uma venda com garantia real. Mas a garantia real de um móvel, de um aparelho de televisão, por exemplo, teria que ser o penhor, em que se exige a entrega da coisa ao credor; ora o que as partes precisamente pretendem na venda de um aparelho cujo preço fica em débito é que o comprador se utilize imediatamente dele e não que este permaneça em poder do credor-vendedor.

Urgia, assim, encontrar uma fórmula que permitisse a realização desse interesse. Esta fórmula, excogitada pela vida para satisfação desta necessidade de garantia do vendedor-credor, é a venda com reserva de propriedade, cuja função é precisamente a de oferecer uma plena garantia de que o contrato vai ser cumprido, ligada como está ao carácter mais sólido, mais forte e mais eficaz de que se reveste a tutela dos direitos reais.

No fundo, é também esta idéia que se encontra por detrás de figuras como, por exemplo, a alienação fiduciária para um fim de garantia, (13) constituindo o que se designa por "fiducia cum creditore" e que se traduz v. g. no seguinte: um indivíduo pede uma determinada importância num mútuo, alienando ao seu credor, em contraparti-

(13) - Cfr. Sobre os negócios fiduciários M. de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, vol.II, p.175 e segs

da, uma coisa do seu património ficando convencionado que haverá uma repristinação da coisa, quando aquele entregar o preço; algo de semelhante ocorre na chamada venda a retro.

E o mesmo sucede em certas formas de financiamento do moderno crédito industrial, por exemplo no chamado "leasing", forma de financiamento em que tem lugar uma separação entre a propriedade dos bens e o seu uso nos seguintes termos: uma empresa, em vez de facultar ao financiado os fundos com que este vai adquirir os bens, vai ela própria fazê-lo, cedendo àquele o uso do material, com a cláusula de, pagas certas prestações, a propriedade se transferir para o utente, se este optar por essa solução. Reserva-se sempre, assim, a propriedade como forma de garantia do pagamento.

Tudo isto são manifestações que exprimem a mesma ideia geral, a de que se recorre muitas vezes na vida económico-jurídica de hoje a formas de reserva ou de constituição da propriedade a favor de um credor com o fim de conceder a este uma plena garantia de pagamento, garantia esta maior do que aquela que resultaria de uma simples posição creditícia.

22 - Por tudo isto o direito de preferência é, sem

dúvida, uma característica dos direitos reais. Podem, todavia, assinalar-se dois tipos de grupos ou de casos de excepção ao direito de preferência.

Um, já conhecido, consiste na situação que pode resultar do registo, no caso de venda de coisa a ele sujeita. Com efeito, como vimos, o primeiro adquirente se, embora tenha adquirido a propriedade, a não a registou, não goza do direito de prevalência em face de um segundo adquirente que registou a sua aquisição. Isto porque, como também referimos no lugar oportuno, os actos sujeitos a registo, mas não registados, são inoponíveis a terceiros.

O segundo grupo de excepções reside no regime dos privilégios creditórios imobiliários. É esta uma figura já conhecida: constituem os privilégios creditórios garantias reais das obrigações, direitos reais de garantia, definidos no art.º 733º C.C. traduzindo-se na faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos credores de serem pagos pelo valor de certos bens com preferência a outros e isto independentemente de registo.

Os privilégios creditórios não estão sujeitos a registo, produzindo a sua eficácia sem necessidade deste. É a lei que os atribui directamente, não resultando, assim, de uma convenção das partes. São privilégios legais concedidos em atenção à causa do crédito.

Ora, os privilégios imobiliários que são os regulados nos art.ºs 743ºe 744º- crédito por contribuição predial devida ao Estado ou às autarquias locais e créditos por despesas de justiça feitas directamente no interesse comum dos credores - beneficiam de um privilégio sobre os bens imóveis com os quais estão relacionados. Os titulares desses créditos são, assim, simultâneamente titulares de um direito real de garantia - um privilégio creditório imobiliário sobre esses bens.

Ora, nos termos do art.º 751.º C.C., estes privilégios imobiliários preferem à consignação de rendimentos, à hipoteca, ao direito de retenção, ainda que estas garantias tenham sido anteriormente constituídas. Quer isto dizer, portanto, que se um indivíduo dá um certo prédio em hipoteca, registando-a, mas, posteriormente assume uma dívida que é garantida por lei com um privilégio creditório imobiliário sobre esse prédio, o beneficiário deste privilégio, embora o crédito garantido seja posterior à hipoteca, tem preferência sobre o titular da hipoteca anteriormente constituída - isto, repetimos, apesar de o privilégio ser posterior e até de não se encontrar registado, dado que, segundo o regime dos privilégios, o registo não é exigido.

Aqui reside uma nítida excepção ao princípio da preferência ou da prevalência.

Já o mesmo não sucede em relação aos privilégios mobiliários especiais, uma vez que o art.º 750.º C.C. determina o acatamento do direito de preferência, ao estatuir que "no caso de conflito entre o privilégio mobiliário especial e um direito de terceiro, prevalece o que mais cedo se houver adquirido". Daqui decorre que havendo, nesta hipótese, um acatamento do direito de preferência, as excepções a este restringem-se, neste domínio, aos privilégios imobiliários especiais previstos nos art.ºs 743º e 744º referidos.

23 - Note-se agora que, não obstante o direito de preferência constituir uma nota característica dos direitos reais, não constitui, porém, uma nota exclusiva destas. Com efeito, pode também haver lugar ao direito de preferência em algumas hipóteses de direitos de crédito.

E quais são, então, essas hipóteses?

Há-as de dois tipos:

- Um é aquele a que se refere o art.º 407.ºC.C., donde resulta que, se por contratos sucessivos são constituídos sobre a mesma coisa, e a favor de pessoas diferentes, direitos pessoais de gozo incompatíveis entre si, prevalece o mais antigo em data. Exemplificando: - dois comodatá-

rios adquirem, por contratos sucessivos, o direito à entrega da coisa para o mesmo dia. Há aqui uma incompatibilidade, já que o devedor não pode cumprir simultâneamente os dois contratos, ou não pode, por exemplo, facultar a utilização do seu automóvel, no mesmo dia, a duas pessoas diferentes (14). O art.º 407.º resolve a questão fazendo prevalecer o direito mais antigo em data. Ora, é esta solução, uma consagração do direito de preferência.

A lei podia ter consagrado um outro regime, nomeadamente o que na falta de texto especial, vigorava anteriormente, segundo o qual o devedor cumpriria qual dos dois contratos quizesse, ficando em situação de inadimplemento em relação ao outro e constituindo-se, por isto, em responsabilidade civil em face do titular do contrato preterrido. Podia o devedor, dado que, no caso concreto, não lhe era possível emprestar o seu automóvel aos dois indivíduos, escolher aquele a quem facultaria o uso do veículo - o primeiro ou segundo credor, como preferisse - tendo lugar, depois, a indemnização ao outro.

(14) - Como é óbvio, este exemplo de comodato referido pressupõe que não consideramos o comodato como um contrato real quanto à constituição, como um contrato real "quoad constitutionem", para empregar uma expressão latina consagrada. É que, como se sabe, esta expressão - contratos reais - é susceptível de um duplo sentido. Com efeito

Hoje, segundo o art.º 407.º já não é este o regime consagrado na lei. O titular do direito primeiramente constituído pode, agora, exigir a satisfação específica do seu direito.

tanto pode surgir por oposição a contratos consensuais como para exprimir uma sinonímia com os contratos com eficácia real. Não é neste último sentido que utilizamos agora a expressão, mas sim no primeiro ou seja, no de contratos reais por oposição a consensuais.

Esta doutrina dos contratos reais sustenta que certos contratos - o comodato, o mútuo, o depósito - não existem pela simples circunstância de haver um acordo de vontades, mas só quando há um acto material de entrega.

É esta a doutrina tradicional. Era assim no direito romano, tendo-se esta ideia mantido até hoje.

Porém, actualmente, esta doutrina é algo criticada e nós também entendemos que estes contratos não são inderrogàvelmente reais.

Podem, se as partes estão de acordo, constituir-se por simples acordo. Não se vê razão para que assim não seja e acima de tudo não se vê uma razão para que só estes sejam tidos como contratos reais e não outros como, v.g., a locação, que nunca se entendeu ser um contrato real. Portanto, admitindo, embora, que as partes podem querer esses contratos em termos de contrato real, mas não havendo cláusula nítida nesse sentido, estes contratos devem ter-se, em princípio, por vinculativos logo que se verifique o acordo. Assim, segundo o nosso ponto de vista, há um mútuo desde que um indivíduo promete emprestar uma importância a outro, e esse outro se declara interessado, quer em receber, quer em restituir, quer ainda em pagar a importância correspondente aos juros. Desde este momento

Um outro exemplo susceptível de ser indicado, é o da locação. Figurem-se dois contratos de locação, incidindo sobre o mesmo prédio ou, dois alugueres do mesmo automóvel.

Nunca ninguém entendeu estes contratos como reais. Figure-se que um indivíduo aluga duas vezes o mesmo automóvel ou arrenda, também, duas vezes a mesma casa a pessoas diferentes mas para o mesmo período. Segundo a doutrina tradicional, mas discutível, o locatário detém, não um direito real, mas um direito de crédito o que nos leva, nesta hipótese, a entrar no campo de aplicação do artº 407.º. Assim, dos dois locatários sucessivos, o que detém

---

existe um mútuo sem necessidade, para que este surja, de se aguardar a entrega do dinheiro. Concebe-se, a não ser imperativa a ideia de que a entrega da coisa é constitucional do contrato, que isto aconteça. Pode, pois, então falar-se de um direito do comodatário a exigir a entrega da coisa.

Segundo a teoria dos contratos reais nunca existe este direito uma vez, que segundo esta doutrina, o contrato só surge quando a coisa é entregue. Até lá não haveria, assim, qualquer contrato, podendo por isso a pessoa que prometera emprestar retratar-se livremente. Ora, isto não parece aceitável. Claro que os defensores da teoria dos contratos reais dirão que enquanto não se verificar a entrega, há uma promessa de comodato, mas isto é já uma solução que assenta no reconhecimento dos resultados insustentáveis a que esta teoria nos leva. Não se vê nenhum motivo que obste a que as partes queiram fazer o contrato vinculativamente, desde logo, por acordo de vontades.

a preferência é aquele cujo contrato foi primeiramente celebrado. É a este que o senhorio tem de entregar a chave, podendo este locatário exigir que aquela lhe seja entregue e não, apenas, uma indemnização por não cumprimento.

Tudo isto é a consagração do direito de preferência para os direitos de crédito, relativos ao gozo de uma coisa.

Outra situação em que se verifica o direito de preferência nos direitos de crédito ocorre na hipótese correspondente aos chamados privilégios mobiliários gerais, privilégios creditórios que incidem sobre todos os bens móveis do devedor.

Estes privilégios, note-se em primeiro lugar, são sempre mobiliários uma vez que a nossa lei desconhece privilégios imobiliários gerais. Daqui que só possam existir privilégios gerais sobre móveis, sobre todos os móveis do devedor.

Os casos em que estes privilégios - os privilégios mobiliários gerais - podem surgir estão reguladoe nos

---

Vistas as coisas assim, visto o comodato como um contrato que pode ser consensual, se as partes quizerem, então o exemplo dado está perfeitamente adequado. Visto o comodato como um contrato que é sempre real, em relação ao qual o simples acordo não tem, portanto, ainda qualquer valor, surgindo apenas este quando a coisa é entregue, então, nessa hipótese porque ao comodatário não assiste o direito de exigir a coisa, o exemplo será impróprio.

• Cfr., sobre a figura dos contratos reais, vistos como um preconceito resultante duma aceitação passiva de

art.ºs 736.º e 737.º C.C.

Exemplificando:

Um crédito emergente do contrato de trabalho, o crédito a salários, é um crédito privilegiado uma vez que o trabalhador, credor neste caso, pode pagar-se pelos móveis do devedor com preferência sobre qualquer outro. Este crédito beneficia, assim, de um privilégio mobiliário geral nos termos da al. d) do art.º 737º.

Os privilégios mobiliários gerais dão, portanto, preferência em relação aos credores comuns. Ora, este privilégio mobiliário geral que concede uma preferência não constitui, porém, um direito real mas uma garantia especial das obrigações. Porque é que não é um direito real?

Pois bem, não o é pela razão de que o privilégio mobiliário geral incide sobre todos os bens do devedor e os direitos reais têm, necessàriamente, de incidir sobre coisas certas e determinadas. Aliás isto infere-se claramente do art.º 749.º ao estatuir que "o privilégio geral não vale contra terceiros...", que lhe recusa, portanto, eficácia absoluta.

Constata-se, pois, pelo exposto, que o privilégio geral garante uma preferência. O titular deste", o titular do privilégio geral, paga-se preferentemente aos credores comuns - e até na hipótese de o privilégio geral

ser um dos previstos no n.º 1 do art.º 736.º - crédito do Estado ou de autarquias locais - prevalece sobre os seus congéneres mobiliários especiais que - note-se - constituem direitos reais. Os créditos do Estado, a que se refere o n.º 1 do art.º 736.º indicado, garantidos por privilégio mobiliário geral, têm, assim, nos termos do art.º 747.º, preferência sobre outros créditos que se encontram garantidos por privilégio especial.

Portanto, e resumindo, pode dizer-se que os privilégios mobiliários gerais dão não só preferência sobre os credores comuns, mas também a dão em certos casos, - os do n.º 1 do art.º 736.º citado - sobre os privilégios mobiliários especiais que, repitamo-lo, constituem direitos reais.

d) PERMANÊNCIA DOS DIREITOS REAIS E TRANSITORIEDADE DOS DIREITOS DE CRÉDITO. REJEIÇÃO DESTA IDEIA.

24 - Outra característica assinalada aos direitos reais, em confronto com os direitos de crédito, traduz-se na ideia, muitas vezes afirmada, de que enquanto os direitos reais são permanentes, os de crédito, diversamente, ca-

racterizam-se pela sua transitoriedade. Esta ideia é de rejeitar.

De facto se, em primeiro lugar, se pretende afirmar que enquanto os direitos reais são perpétuos tal não acontece com os direitos de crédito, então a ideia é falsa. Isto porque há direitos reais que, por sua própria essência e segundo o regime que para eles a lei estabelece, são temporários. Assim, nomeadamente, o usufruto é por sua natureza temporário, como aliás resulta do art.º 1439.º ao defini-lo como "o direito de gozar temporária e plenamente uma coisa ou direito alheio, sem alterar a sua forma ou substância". Daqui resulta ser a própria lei a acentuar, neste particular direito real, a nota do seu carácter temporal.

Se, em segundo lugar, se pretende com esta oposição - carácter permanente dos direitos reais-carácter transitório dos direitos de crédito - exprimir a ideia de que os direitos reais, por se não extinguirem pelo seu exercício, apresentam um carácter permanente ou mais estável, enquanto que, por o exercício dos direitos de crédito acarretar a sua extinção, estes se revestiriam de um carácter mais fugaz, diga-se então que, não obstante, posta a questão nesses termos, a diferença estabelecida já gozar de alguma consistência, não exprime, mesmo assim, mais do que

uma nota tendencial ou predominante.

É que, por um lado há direito reais que não detém essa tal estabilidade extinguindo-se pelo seu exercício, criando-se, portanto, para se extinguirem por este. Assim todos os direitos reais de garantia - v.g., a hipoteca e o penhor, são direitos que são criados, não com o fito de prosseguirem uma possibilidade de fruição permanente de uma coisa, mas são-no antes para se extinguirem pelo seu exercício.

E, pelo outro, há obrigações que se não extinguem pelo seu exercício apresentando, assim, um carácter permanente. Neste caso, claramente as obrigações de prestação de facto negativo como, por exemplo, as obrigações emergentes de um pacto de não concorrência, traduzido na obrigação que o cedente assume num contrato de trespasse, cláusula, aliás, frequente no tráfego, de não abrir um estabelecimento de ramo idêntico no mesmo local. Daqui decorre que, se um indivíduo trespassa um estabelecimento comprometendo-se a, para não prejudicar a aquisição de clientela pelo adquirente, não abrir um outro do mesmo ramo na mesma localidade, esta obrigação é uma daquelas que se não extingue pelo seu exercício. Pelo contrário, esta omissão -a de não abrir esse estabelecimento -, até a vai mantendo e consolidando, diversamente do que sucede, por exem

plo, com a obrigação de pagar o preço que se extingue pelo seu exercício. Pago o credor, libera-se o devedor.

Mas a obrigação de prestação de facto negativo, essa, como vimos, não se extingue pelo seu exercício. E o mesmo sucede, em geral, com todas as restantes obrigações designadas por relações obrigacionais duradouras.

A obrigação emergente de uma cláusula de não concorrência é uma obrigação duradoura.

Não apenas as obrigações de prestação de facto negativo podem apresentar esta característica de permanência. Esta, pode, como vamos ver, resultar também de obrigações de prestação de facto positivo.

Figure-se, assim, por exemplo, uma empresa que se compromete a fornecer carvão a uma outra segundo as necessidades desta e por tempo indeterminado. Há, indubitàvelmente, aqui uma obrigação duradoura que apresenta, ela também, um carácter de estabilidade ou de permanência, uma vez que não nasceu para se extinguir. Diversamente, a obrigação de pagar o preço: esta, atinge o seu ponto culminante ao momento da extinção; a sua extinção é que constitui o meio adequado de ela desempenhar a sua função.

Já a relação duradoura é, pelo contrário, constituída para durar e para se manter, para existir numa palavra. Pode extinguir-se - é um facto -, mas a sua extinção cons-

titui sempre uma rotura em relação à consecução da sua função, uma vez que o interesse do credor só é satisfeito enquanto ela dura, enquanto existe e não quando se extingue. Assim, enquanto se pode dizer que, para o credor de uma obrigação de execução instantânea quanto menos aquela durar tanto maior realização obtém o seu interesse - para o credor do preço quanto mais ràpidamente este lhe for entregue melhor - já, diversamente, para o credor do carvão em prestações mensais quanto maior for a duração da obrigação melhor se realiza o seu interesse.

De tudo isto decorre que, adentro das obrigações, há que se estabelecer uma nítida fronteira entre aquelas que, nascendo para se extinguirem, apresentam, por isso um carácter temporário e aquelas outras que, diversamente, tendo sido constituídas para durarem se revestem de um carácter de estabilidade ou de permanência. E se assim é, se há, como vimos, obrigações duradouras, então aquela doutrina que pretende apresentar a permanência como característica específica dos direitos reais em oposição à transitoriedade inerente aos direitos de crédito, essa doutrina é então - repitamos - incontestàvelmente de rejeitar.

e) INERÊNCIA DA COISA AO SEU TITULAR

25 - Uma outra característica dos direitos reais é a que designaremos por inerência da coisa ao seu titular.

Formula-se mais correntemente esta ideia dizendo-se que os direitos reais conferem um domínio ou soberania sobre a coisa, seu objecto. Porém esta expressão - domínio ou soberania -, é de aplicação mais correcta aos direitos reais de gozo, não surgindo com tanta nitidez nos restantes. Daí que seja, talvez, preferível falar-se nesta relação de inerência da coisa ao seu titular, como propomos.

É a característica que se exprime ao falar-se do lado interno do direito real.

Em última análise, não é senão um corolário da eficácia absoluta do direito real, representando, como tal, uma síntese das ideias de sequela e de preferência. A coisa adere ao seu titular. É isto que no fundo se quer exprimir quando se fala nesta inerência ou desta aderência da coisa ao seu titular.

f) CARACTERISTICAS DO OBJECTO DOS DIREITOS REAIS

26 - O direito real apresenta também características específicas, distintivas do direito de crédito, no tocante ao seu objecto.

O objecto do direito real tem de incidir sobre coisa certa e determinada, o mesmo sucedendo com os negócios dotados de eficácia real cujo objecto tem de se revestir de idêntica característica: ser certo e determinado. É que só pode haver o direito de excluir todos em relação a uma coisa, se esta for certa e determinada, não podendo, por isso, constituir-se direitos reais sobre coisas não individualizadas ou indeterminadas.

Diversamente, nos direitos de crédito, a prestação pode ter por objecto uma coisa determinada apenas pela sua referência a um tipo ou a um género e por uma certa quantidade. Assim, por exemplo, a obrigação de entregar x pipas de vinho, sem que se saiba se será este ou aquele o que será entregue. Este só será determinado ao momento do cumprimento. O objecto da prestação não tem que se encontrar determinado ao momento da constituição da obrigação.

Ao invés, o objecto dos direitos reais tem de se encontrar individualizado, quando aqueles se constituem, dado que, doutra forma, não poderiam existir os direitos de sequela e de preferência. Para que estes existam é, por-

tanto, necessário que os direitos reais incidam sobre coisas certas e determinadas.

27 - Acentua-se, também, por vezes, que os direitos reais incidem sobre a totalidade das coisas que constituem o seu objecto. Esta ideia não é, porém, inteiramente válida. Ela só é, de facto, de aceitar sem rectificação no que se refere à propriedade e ao usufruto, mas já não é inteiramente exacta para a servidão, que não tem de incidir sobre a totalidade da coisa (15).

Tal ideia, no domínio em que é válido dizer-se que o direito real incide sobre a totalidade da coisa e assim acontece designadamente na propriedade, significa que as partes integrantes ou constitutivas da coisa não podem, enquanto se mantiverem como tal, ser objecto de direitos particulares, seguindo antes o destino jurídico da coisa que detém, por isso, um destino unitário.

Por partes constitutivas ou componentes designam-se, diga-se agora, aqueles elementos de uma coisa que a formam na sua totalidade, não podendo ser dela separados sem se destruirem ou, melhor, sem que algum deles fique destruido ou sem que à coisa no seu conjunto se torne incompleta ou imprópria para o uso a que se destina (16). Assim por exemplo, as salas de um edifício ou, mais constitucionalmente ainda, as pedras, as janelas, as portas, as telhas, as vigas, são partes constitutivas ou componentes desse edifício, seguindo, portanto, o destino da coisa. Há, assim, um destino unitário desta no que se refere à sua submissão a um direito real.

(15) - Cfr. Pires de Lima, na Rev.Leg. e Jur., ano 98, p. 174 e segs.

Partes integrantes, às quais também se aplica este princípio de unidade, são, por ser turno, as como tais consideradas pelo n.º 3 do art.º 204º; ou seja "todo a coisa móvel ligada materialmente ao prédio com carácter de permanência". Constituem, assim, esta categoria de coisas a instalação eléctrica ou de água, o aquecimento central, por exemplo, ou seja, aquelas que, como diz a lei, se encontram ligadas ao prédio com um carácter de permanência.

Todas estas coisas seguem o destino unitário da coisa pelo menos e nitidamente no que se refere às partes constitutivas ou componentes que referimos.

Por força desta ideia não podem, assim, constituir-se direitos de propriedade diversos sobre as várias salas ou as diferentes partes de um mesmo imóvel, excepto nos termos em que a lei permite a chamada propriedade horizontal,

(16) - Cfr. M. de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, vol. I, p. 237.

que - essa sim - é permitida se se encontrarem preenchidos os requisitos que para a sua constituição a lei estabelece, designadamente o de só poder incidir sobre unidades independentes (art.º 1414.º). Fora desta hipótese que se encontra, aliás, tipicizada na lei, não pode haver direitos particulares de propriedade sobre partes componentes de uma coisa. Não é, assim, possível um indivíduo ser proprietário de uma sala, enquanto outrem o é da sala contígua ou ser-se proprietário duma parede e não das restantes do mesmo compartimento. A coisa tem um destino unitário na sua totalidade.

Significa, ainda, este princípio de sujeição da totalidade da coisa a um direito real que, se uma coisa é unida ou incorporada com outra, por facto natural ou por indústria do homem, aquilo que assim acresceu passa a ser abrangido pelo direito real que incidia sobre a coisa antes do aditamento verificado.

É, aliás, esta ideia que subjaz a uma forma de aquisição da propriedade, designada por acessão, e que o Código regula nos art.ºs 1325º e segs., podendo revestir duas modalidades: natural, quando resulta exclusivamente de forças da natureza - um prédio que é acrescentado pelos materiais arrastados, por exemplo, por uma cheia - ou industrial, resultando, neste caso, a acessão da acção do

homem - um indivíduo que, por exemplo, constroi, de boa ou má fé, em terreno alheio.

Esta circunstância - a acessão - possibilita ao dono do prédio que assim foi aditado adquirir a propriedade sobre aquilo que lhe foi acrescentado, regime que representa um corolário da tal ideia que referimos: a de que o direito real alcança a totalidade da coisa (17).

Uma consequência prática deste princípio - sujeição da totalidade da coisa a um destino unitário -, traduz-se na nulidade de que enfermaria uma cláusula de reserva de propriedade relativa a coisas que se vão tornar partes constitutivas de outra coisa. Exemplificando: não poderá haver "pactum reservati dominii" na venda de materiais, v.g. elementos pré-fabricados, que se destinam a ser integrados na estrutura de um imóvel.(18) É que, se assim não fosse, ocorreriam situações nas quais o imóvel seria pertença de um indivíduo e os materiais pelos quais é constituído só-lo-iam de outrem (o vendedor que tinha aposto uma reserva de propriedade). Daí que seja nulo o "pactum re-

(17) - Cfr. uma aplicação à hipoteca da mesma ideia, num Parecer da Procuradoria - Geral da República e um acórdão publicados na Rev.Leg. a Jur., ano 101.º, p. 160.

(18) - Assinale-se, a propósito, que, segundo Acórdão do S.T.J., publicado no Bol.Min.Justiça, n.º192, as casas desmontáveis são coisas móveis.

servati dominii" na alienação de coisas que se vão tornar partes constitutivas de certa coisa. (19)

Esta ideia parece-nos certa, pelo menos no que se refere às partes componentes ou constitutivas de uma coisa, já podendo surgir dúvidas no tocante às partes integrantes.

Note-se, a terminar, que, como é óbvio, este princípio de unidade de destino da coisa não se aplica às chamadas coisas acessórias ou pertenças a que se refere o art.º 210º, coisas móveis que, não constituindo partes integrantes, não estão, por isso, ligadas materialmente à coisa, encontrando-se apenas afectadas, por forma duradoura, ao serviço ou ornamentação de outra.

Integram-se nesta categoria de coisas, por exemplo, as alfaias agrícolas, as máquinas agrícolas com que o prédio é explorado ou os objectos utilizados numa casa para comodidade dos seus utentes, v.g. os aquecedores não ligados materialmente à casa - excluindo-se, portanto, o aquecimento central -, os frigoríficos, etc.

Em relação a estas coisas acessórias pode ter lugar um "pactum reservati dominii", uma vez que elas se não vão

(19) Nestes termos Lent - Schwab, ob. cit., p. 6, seguido entre nós por H. Mesquita, ob. cit., p. 14.

tornar partes constitutivas da coisa, mas apenas acessórias, gozando, assim, de alguma autonomia, como, aliás, o revela desde logo o n.º 2 do art.º 210.º ao estatuir que "os negócios jurídicos, que têm por objecto a coisa principal não abrangem, salvo declaração em contrário, as coisas acessórias". Se assim é, se o negócio que incide sobre uma coisa não engloba, salvo cláusula em contrário, as coisas acessórias daquela, então isso só pode justificar-se por estas gozarem de autonomia em face daquela (a coisa principal).

g) - OUTRAS CARACTERÍSTICAS

28 - Finalmente, seguem-se ainda outras características dos direitos reais que iremos, apenas, enunciar rápida e sumàriamente. São elas duas.

A primeira traduz-se em que só os direitos reais podem ser adquiridos por usucapião. É esta, - a usucapião -, uma forma de aquisição restrita aos direitos reais, não existindo no domínio dos direitos de crédito qualquer possibilidade de usucapião.

Aliás, precise-se, nem todos os direitos reais são passíveis de essa forma de aquisição. São-no a propriedade e os direitos reais de gozo, nos termos do art. 1287.º

C.C., mas já a hipoteca, um direito real de garantia, é insusceptível de ser adquirido por usucapião. Assim, este instituto restringe-se às hipóteses de propriedade, usufruto, enfiteuse, servidão e direito de superfície, excluindo-se a sua aplicação no campo dos direitos reais de garantia (20).

29 - Outra diferença entre os direitos reais e os direitos de crédito será esta: a violação daqueles resulta de um comportamento positivo (de uma acção); nestes, diversamente, a violação, consequência do comportamento lesivo do devedor é, geralmente, um facto negativo (uma omissão), como, v.g. o inadimplemento ou a mora. E isto porque os direitos de crédito são normalmente de prestação de facto positivo ou de prestação de coisa.

O facto positivo que lesa um direito real dá ao seu titular, uma vez que este beneficia de garantia, determinados direitos, nomeadamente, o direito à indemnização com fundamento no art.º 483.º. O titular do direito real lesado pode, assim, pedir uma indemnização ou, sendo caso

(20) - Aliás, verificam-se também excepções à possibilidade de usucapião no domínio dos direitos reais de gozo: cfr. art.º 1293.º (uso e habitação e servidões não aparentes).

disso, exercer o seu direito à restituição da coisa mediante uma reivindicação. A esta, ou melhor, à acção de reivindicação se refere, desde logo, o art.º 1277.º e os art.ºs 1311.º e segs. C.C., estes últimos integrados na propriedade, mas aplicáveis aos restantes direitos reais por força do art.º 1315º

Também o usufrutuário pode reivindicar a coisa no caso de ter sido privado dela, ou pode ter o direito, não de reivindicar, mas de exigir que seja mantido na sua posse no caso de a lesão ou a perturbação não ter chegado ao ponto de o despojar da coisa, mas apenas de o perturbar na sua posse.

Estes direitos de crédito - o direito à indemnização e o direito a exigir a restituição da coisa -, que resultam da violação de um direito real, são designados pela doutrina alemã por pretensões reais (pretensões porque, em alemão, esta palavra é usada como sinónimo de direito de crédito, e reais para acentuar a origem destes direitos - destas pretensões - que reside precisamente, na violação do direito real). Surgem estas pretensões - direitos de crédito como todos os outros - quando há uma violação do direito real. Há direitos reais - é óbvio - em cuja vida nunca chega a surgir uma pretensão indemnizatória, por nunca terem sido violados.

A circunstância de estas pretensões reais se encontrarem ligadas aos direitos reais não deixa, todavia, de ter algum significado. É que o facto de eles serem, no fundo, uma manifestação da garantia dos direitos reais, leva, pelo menos em relação a alguns, a que tenham um regime diverso do comum dos direitos de crédito. Assim, por exemplo, o direito à indemnização resultante da violação do direito de propriedade de outrem, é um direito de crédito e, como tal, prescritível. Está sujeito a extinguir-se por prescrição extintiva nos termos gerais, se o proprietário lesado não pede a indemnização dentro de um determinado prazo. Este é o regime geral nos direitos de crédito.

Já, por exemplo, o direito à restituição da coisa, exercitável mediante uma acção de reivindicação, é imprescritível, ainda que se veja nele um direito de crédito, um direito que o proprietário tem de exigir a restituição da coisa de quem se apossou dela indevidamente. Este direito de reivindicar não é, repetimos, prescritível, não se encontrando, portanto, sujeito ao regime geral dos direitos de crédito - aliás o art.º 1313.º di-lo claramente. Isto porque, no fundo, este direito de reivindicar é uma manifestação da sequela, uma manifestação do conteúdo do direito real, e a propriedade, como aliás outros direitos reais, é imprescritível, não se extinguindo, portanto, por prescrição extintiva.

Podem sim - note-se - alguns direitos reais, que não o de propriedade, vir a extinguir-se por uma outra causa que se pode aparentar à prescrição extintiva. Trata-se do não uso, mas este goza de um regime diferente do de prescrição.

* * *

CAPITULO III

PRINCIPIOS REGULAMENTADORES DA CONSTITUIÇÃO
E
DA VIDA DOS DIREITOS REAIS

30 - Após termos focado as características dos direitos reais, e de termos procedido a essa análise em confronto com os direitos de crédito, cabe, agora, dizer algo sobre certas ideias básicas, certos princípios fundamentais que dominam a constituição e a vida dos direitos reais.

Os Direitos Reais são um domínio específico do ordenamento jurídico, uma zona do mundo jurídico.

Ora, todo o domínio específico do ordenamento jurídico assenta sobre determinados princípios fundamentais .

Há sempre determinados pensamentos, determinadas directrizes, determinadas ideias gerais que presidem a cada um dos vários compartimentos em que o mundo jurídico se divide. Esses princípios, essas ideias gerais podem ter determinantes as mais diversas. Podem estas, com efeito, apresentar-se como razões de carácter político-ideológico, histórico, económico, como considerações racionais, éticas ou outras, ou, ainda, razões de técnica jurídica. Estas as razões que se situam por detrás desses princípios e que se repercutem numa dada zona do ordenamento jurídico, inclusivé mesmo no campo do direito privado.

Ora, os direitos reais também estão, portanto, submetidos a certos princípios. As ideias gerais que a seguir exporemos não são necessàriamente infrangíveis, sem excepções. Algumas são de validade absoluta; outras limitam-se a exprimir tendências, sendo, mesmo assim, útil referi-las, pois são pontos de apoio para o intérprete na compreensão deste ramo do ordenamento jurídico e até na procura concreta de soluções.

Os direitos reais são, assim, como qualquer ramo do ordenamento jurídico, alimentados por determinados princípios. Destes cita-se, desde logo, o do reconhecimento da propriedade dos particulares, que, como uma trave-mestra, o nosso sistema de direitos reais tem subjacente a

si. O reconhecimento da propriedade privada é, de facto, um princípio básico do nosso ordenamento jurídico em matéria de direitos reais.

Dissemos poderem as causas determinantes de um certo ramo do Direito Privado revestir-se de uma natureza muito vária: histórica, económica, ética, racional, de técnica jurídica, sócio-económica, político-ideológica ou outra.

O reconhecimento da propriedade privada, a concessão aos particulares da propriedade, não só dos bens consumíveis como também dos de produção, é um princípio que assenta numa consideração de tipo ideológico-político. É, assim, uma decisão político-ideológica, uma opção correspondente a uma determinada concepção do mundo e da vida, no que toca à organização da sociedade, particularmente no referente à organização desta. É pois uma consideração de tipo político-ideológico que está na base do princípio referido: a apropriação individual dos bens.

Feita essa opção, em execução dela é lançada essa trave-mestra dum determinado sistema de direitos reais - o reconhecimento da propriedade particular - uma decisão situada no tempo e que não encontra tradução em todos os sistemas jurídicos.

Edificado, nesta base, todo o sistema de direitos reais, concorrem, na sua constituição e na sua vida, deter

minadas ideias gerais influenciadas pelas circunstâncias indicadas e que obedecem a princípios que vamos, agora, referir.

a) PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

31 - O primeiro desses princípios é o da especialidade.

Que significa isto?

Pois bem, com esta ideia - princípio da especialidade -, pretende significar-se que os direitos reais devem ter como objecto coisas individualizadas, coisas certas e determinadas, como já dissemos.

Dentro deste contexto também se acentua um outro aspecto que não constitui senão um outro lado - uma outra "nuance" da mesma realidade: o de que os direitos reais são únicos, no sentido de que o direito real que incide sobre uma coisa não é o mesmo direito real que incide sobre outra coisa, embora porventura igual. Isto é, afinal, um simples corolário da ideia que os direitos reais têm por objecto coisas certas e determinadas, coisas individualizadas.

Este princípio da especialidade não exclui, todavia,

a possibilidade de se constituirem direitos reais sobre coisas colectivas (coisas compostas ou universalidades). O facto de os direitos reais terem como objecto coisas certas e determinadas, coisas individualizadas, não é, com efeito, incompatível com a possibilidade de o seu objecto ser uma coisa composta ou uma universalidade.

Estas - coisas compostas e universalidades - encontram-se definidas no art.º 206.º C.C., onde essas expressões são, aliás, usadas em sinonímia. Aí se estatui que "é havida como coisa composta, ou universalidade de facto, a pluralidade de coisas móveis que, pertencendo à mesma pessoa, têm um destino unitário", o que significa que essas coisas, embora integradas por uma pluralidade de coisas simples, podem ser tratadas pelo direito como se fossem uma coisa única. É que, para certos efeitos, pode haver interesse em que assim aconteça, nomeadamente para efeito de usufruto ou de acção de reivindicação.

Figure-se, assim, por exemplo, um rebanho-universalidade de facto - sobre o qual vai essa acção - de reivindicação - ser exercida. Para se não estarem a exercer tantas acções de reivindicação quantas as coisas simples que integram a universalidade, para que o proprietário, no caso concreto, não venha exercer tantas reivindicações quantos os animais que constituem o rebanho, há vantagem em

considerar este como uma coisa única, permitindo-se, assim, a reivindicação da totalidade.

Está visto que as coisas colectivas, revistam elas a fisionomia de coisas compostas ou a de universalidade de facto, são compatíveis como objecto de direitos reais, com a ideia de que estes têm de ter como objecto uma coisa certa e determinada. Isto, porque a universalidade ou a coisa composta são – elas próprias – uma forma de determinação ou de individualização. A coisa não deixa, assim, de ser certa e determinada ou individualizada pelo facto de ser constituída por uma pluralidade de coisas simples. Continua a ser, na mesma, coisa determinada, cujos limites estão traçados em termos cognoscíveis.

Diga-se agora, e a título de parêntesis, que esta identificação, a que a lei procede entre coisas compostas e universalidades de facto, passa um pouco por alto certa diversidade existente adentro das coisas colectivas.

Pode-se empregar esta expressão – coisas colectivas – para designar, em conjunto, tanto as coisas compostas como as universalidades de facto, mas vê-se nitidamente que certas coisas colectivas – as universalidades de facto –, não apresentam características inteiramente idênticas às de outras coisas colectivas. Assim, tanto um rebanho como uma biblioteca constituem conjuntos ou pluralidades de coisas simples que se encontram no mesmo plano entre si ou seja, não estão numa relação do tipo coisa principal-coisa acessória. As ovelhas e os livros são coisas que se encontram todas no mesmo plano. Não há, entre elas, a mesma relação que se revela por exemplo entre uma casa e um aquecedor, não obstante constituirem estas, quando consideradas em conjunto, uma pluralidade de coisas. É que aqui constata-se a existência de uma relação do tipo coisa principal-coisa acessória, uma vez que um dos objectos referidos "in concreto" – o aquecedor – se acha adstrito à comodidade que a outra – a casa – proporciona.

Diversamente, entre as coisas simples que formam a universalidade não há essa relação de acessoriedade. Encontram-se, repitamo-lo, no mesmo plano. Assim, retomando o exemplo dado, os animais que formam o rebanho ou a manada são de valor homogéneo e, para certos efeitos, o direito tem interesse em os tratar como uma coisa única. Constituem uma universalidade de facto, cujo valor, como tal, reside no somatório dos valores das coisas simples que a integram.

Há outras coisas colectivas, porém, por exemplo, um estabelecimento comercial que, não sendo uma coisa simples mas colectiva, a lei trata, não obstante, como se

constituisse uma coisa única para muitos efeitos, nomeadamente para o de admitir uma transferência unitária do estabelecimento (o chamado trespasse).

Em matéria de reivindicação admite, igualmente, a lei que o estabelecimento seja objecto de uma única acção de reivindicação, o que implica ser ele aqui tomado globalmente. Daí que o proprietário reivindicante não tenha de intentar diversas acções incidindo, v.g., sobre as fazendas, os móveis, etc., mas uma única acção sobre a totalidade do estabelecimento.

Da mesma forma pode haver um usufruto de um estabelecimento globalmente considerado e não das várias coisas que o integram.

O estabelecimento comercial é, portanto, também uma coisa colectiva, unificada pelo direito - daí que nos refiramos a ele como uma coisa e não como várias coisas -, mas não, como dissemos, uma universalidade de facto. Seria, sim, um exemplo de coisa composta, unitária, uma só coisa unificada pelo direito, mas permanecendo, não obstante, como coisa composta em oposição a coisa simples.

Porque não é o estabelecimento uma universalidade?

É que o estabelecimento, além de ter uma composição heterogénea, tem um valor que excede o valor somado dos elementos singulares que, numa perspectiva analítica, o

compõem. É, assim, uma coisa composta, unificada pelo direito.

Alongámo-nos só para referir entre parêntesis, como dissemos de início, que esta sinonimia utilizada entre coisas compostas e universalidades não distingue entidades bastante diferentes como o são aquelas que exemplificamos.

Fique agora, como conclusão da ideia que estavamos a expôr, o seguinte: - não constitui obstáculo à possibilidade de direitos reais sobre universalidades ou sobre coisas compostas o facto de os direitos reais obedecerem ao princípio da especialidade, o facto de terem como objecto coisas certas e determinadas. A universalidade ou a coisa composta são uma forma de determinação ou de individualização do objecto.

b) PRINCIPIO DA TRANSMISSIBILIDADE

32 - Referimo-nos agora ao princípio da transmissibilidade, um dos princípios básicos, fundamentais que dominam o mundo dos direitos reais.

Estes direitos, à semelhança do que sucede com todos os direitos patrimoniais, podem mudar de titular, são transmissíveis inter-vivos ou mortis causa. Significa is-

so que a ligação entre os direitos reais e o seu titular é cindível, pode ser quebrada por vontade do titular ou por outra causa. Esta característica traduz no fundo a alienabilidade e a hereditabilidade dos direitos reais, mas não tem carácter absoluto; é sim uma nota tendencial na medida em que comporta excepções.

33 - Poderemos citar desde logo o exemplo do usufruto — conforme preceitua o artº. 1443º., este direito não pode exceder a vida do usufrutuário. Não pode por esse motivo ser hereditável.

Embora não hereditável, é, contudo, alienável inter-vivos, pois o artº. 1444º. permite o seu trespasse a terceiro, o que se traduz em o usufrutuário poder transferir para outrém o seu direito, definitiva ou temporàriamente. Só que esta transmissão produz os seus efeitos, transmitindo-se para o adquirente o usufruto, durante o prazo pelo qual foi constituído inicialmente ou, no caso de constituição inicial por tempo indeterminado, extingue-se quando falecer a pessoa a cuja vida o usufruto estava ligado; o adquirente, nêste caso, detém vàlidamente o direito, mas este extingue-se pela morte do transmitente. Isto mostra-nos que o usufruto não é totalmente incindível, pode ser alienado, mas não transmitido mortis-causa,

por força do artº. 1443º.

Idêntico regime vamos encontrar no chamado direito de uso e habitação, menos frequente na vida económico-jurídica, mas em todo o caso uma figura prevista e consagrada na nossa lei. A noção de uso e habitação é-nos dada pelo artº. 1484º., onde no nº.1 se diz que "o direito de uso consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos frutos, na medida das necessidades, quer do titular, quer da sua família. "Prima facie" poderemos ser levados a identificá-lo com o usufruto, mas devemos atentar na parte final do preceito, onde se revela a funcionalização do direito de uso, o seu âmbito, o seu conteúdo, é limitado pela medida das necessidades do titular ou da sua família; quanto ao usufruto, traduz-se no direito de fazer seus todos os frutos do prédio e não apenas na medida das necessidades do titular ou das da sua família.

O nº. 2 do mesmo artigo estabelece que "quando este direito se refere a casas de morada, chama-se direito de habitação"; também aqui se patenteia uma diferença importante, o titular do direito de habitação tem a faculdade de morar naquela casa;o usufrutuáriode uma casa pode arrendá-la e receber as respectivas rendas.

Em face da caracterização que dele foi traçada, con-

clui-se que este direito de uso e habitação é forçosamente intransmissível; sendo um direito ligado à satisfação das necessidades do seu titular ou da sua família, não pode transmitir-se para outrém, ideia expressa no artº. 1488º., mas que já se inferiria da noção legal respectiva.

34 - De algum modo há também uma excepção a este princípio da transmissibilidade no domínio das servidões, se bem que o significado desta excepção se processe em termos algo diferentes da considerada anteriormente. As servidões estão reguladas nos artºs. 1543º. e ss., e da sua definição, bem como da circunstância de em nenhuma outra parte do Código se regular outro tipo de servidões, constata-se que estas figuras são caracterizadas pela imposição de um encargo a um prédio em benefício de outro prédio.

As servidões só são admitidas em relação a prédios; não existem no nosso actual sistema jurídico servidões pessoais. Este tipo de direito real era muito frequente numa estrutura feudal da propriedade, mas a partir da superação dessa fase, sobretudo a partir da revolução francesa e dos movimentos de transformação político-económica por ela influenciados — do advento do liberalismo — ve-

rificou-se uma tendência muito marcada para reagir contra os encargos do mais diverso tipo que incidiam sobre a terra. Entre nós essa tendência atingiu o seu ponto mais importante com a legislação da revolução liberal de Mouzinho da Silveira, através da extinção das lutuosas e de uma série de outros encargos que incidiam sobre os bens.

No regime anterior, de estrutura feudal da propriedade, vigorava toda uma gama de encargos, do tipo da servidão pessoal, dos quais um exemplo poderá ser o direito de caçar em prédio alheio, que não é hoje admitido como direito real. Há um direito de caçar em prédio alheio que actualmente não é admitido como direito real, antes é uma faculdade geral integrada no regime da caça extensivo a todas as pessoas, mas aplicável sòmente em certas propriedades pois há muitas em que não se pode caçar, nomeadamente as propriedades muradas e todas aquelas que o respectivo diploma regulador exclui da liberdade de caça. Especificamente, mesmo em relação a uma propriedade em que não é admitida em geral a caça, pode um indivíduo fazer um contrato com o respectivo titular mediante o qual este autorize aquele a caçar ali, mas neste caso estamos perante uma pura obrigação, um puro direito de crédito, não um direito real que adira ao prédio e o siga em todas as suas transmissões — se o titular do prédio em consideração,

devedor da obrigação de deixar caçar, o vender a terceiro, este terceiro não fica vinculado a tolerar que o adquirente do direito, por um contrato em que ele não foi parte, continue a caçar no seu prédio. Se existissem as servidões pessoais, então sim, ele seria obrigado a tal, pois que estaria em face de um direito que teria inerência real, de um verdadeiro direito real.

Existiam pois direitos deste tipo na antiga estrutura feudal da propriedade. Hoje tal não se verifica, uma vez que o artº. 1543º. só admite encargos impostos num prédio, mas em benefício de outro prédio e não de uma pessoa; concebe-se uma servidão de passagem porque ela é necessária ou convencionada para se poder passar através de um prédio para outro prédio, mas não pode constituir-se um direito real mediante um contrato pelo qual um indivíduo A autoriza outro, B, a passear, quando lhe apetecer ou todos os dias a determinadas horas, num parque privado que A possui; B pode fazer esse contrato com A, pode ir para lá passear, mas esse direito tem um carácter puramente obrigacional, é um direito de crédito, e, se A não cumprir, B pode pedir-lhe uma indemnização; tal contrato não implica a constituição de um encargo sobre o prédio do tipo da servidão, pois que se A transmitir posteriormente o prédio para um terceiro C, este não é obrigado a respeitar o direito, que B tinha em face de A, de lá passear quando lhe apetecesse, uma vez que não foi C quem assumiu essa obrigação perante A, nem esse direito incide sobre o prédio. Não se pode dizer que o prédio está onerado com uma servidão constituída a favor de B cujo conteúdo é o de poder ele ali passear, porque tal hipótese foge ao esquema típico consagrado no artº. 1543º. e já veremos que nos direitos reais vigora o princípio da tipicidade.

O artº. 1543º. define servidão como "o encargo imposto num prédio em proveito exclusivo de outro prédio pertencente a dono diferente". Daí decorre que as servidões não são separáveis dos prédios a cujo proveito se destinam; o titular de uma servidão não a pode transmitir isoladamente e só o pode fazer conjuntamente com a transmissão do prédio a cujo proveito exclusivo ela está afectada.

O direito de servidão não tem uma ligação directa com o respectivo titular, entre este e o direito há um "quid" intermédio — a titularidade do direito real por força do qual se tem a servidão, a propriedade do prédio beneficiado com a servidão. Só se tem uma servidão pelo facto de se ser dono de certo prédio; por esse motivo não há uma transmissão separada das servidões. O artº. 1545º. formula este princípio do inseparabilidade das servidões

e, nessa medida, existe aqui uma restrição em certos ter-
mos ao princípio da transmissibilidade.

Algo de semelhante se passa com os direitos legais de preferência, que são direitos reais de aquisição.

Nos termos do artº. 1410º., o comproprietário goza do direito de preferência na alienação do quota ideal do outro comproprietário.

Outro exemplo será dado pelo artº. 1117º. — o arrendatário comercial goza de direito de preferência na venda do prédio onde está instalado o estabelecimento.

Também estes direitos de preferência não podem ser transmitidos isoladamente pois nem o comproprietário nem o dono do estabelecimento podem ceder o seu direito de preferência a uma terceira pessoa. Não podem ser separados das situações objectivas a que foram atribuídos. O direito de preferência, em suma, só pode transmitir-se quando acompanhe a transmissão do direito por força do qual ele era pertença de um determinado indivíduo. Nesta medida estamos perante um tipo de inseparabilidade semelhante ao das servidões pois, como estas, também o direito de preferência não tem uma ligação directa com o seu titular — entre ele e o seu titular há um "quid" intermédio, tem-se o direito legal de preferência porque se é comproprietário ou dono do estabelecimento e não fora dessas si-

tuações. Só se transmitem estes direitos — a servidão ou o direito legal de preferência — com o direito que constitui o tal "quid" intermédio entre a servidão ou a preferência e o seu titular. Não são direitos transmissíveis "ad libitum", não podem transferir-se livremente em quaisquer circunstâncias.

35 - Acerca deste princípio pode pôr-se um problema — será possível excluir-se por convenção das partes este regime de transmissibilidade dos direitos reais? Poderão as partes convencionar a intransmissibilidade da propriedade, p. ex., poderá um indivíduo vender a outro um prédio estabelecendo uma cláusula obrigando o adquirente a não poder vender o prédio comprado?

Significa isto pôr em discussão o valor das cláusulas de inalienabilidade.

Poderíamos pensar em recorrer aos artºs. 577º. e 588º. para solucionar a questão, dentro de uma aplicação analógica. Estes artigos regulam a cessão de créditos, preceituando o nº.2 do artº. 577º. sobre as cláusulas de inalienabilidade nas cessões de créditos e o artº. 588º. sobre a aplicação das regras da cessão de créditos às transmissões de outros direitos. Seria pensável aplicar aqui o mesmo regime: inoponibilidade a terceiros de cláusula

de inalienabilidade, a não ser que o terceiro adquirente a conhecesse. Mas parece não ser esta a solução apropriada, pois estas cláusulas, embora possam produzir efeitos obrigacionais, são insusceptíveis de produzir efeitos reais. De algum modo, podemos encontrar apoio legal para esta solução no artº. 1306º., que consagra o princípio da tipicidade — não é permitida a constituição, com carácter real, de restrições ao direito de propriedade senão nos casos previstos na lei. Ora a cláusula de inalienabilidade introduzia uma restrição ao direito de propriedade, que não está prevista em geral na lei; por isso não é possível inscrir na propriedade uma indisponibilidade resultante de o seu titular ter assumido "ex contractu" esse encargo, essa inibição. No caso de ser estipulada uma venda com cláusula de inalienabilidade, esta cláusula só pode ter efeitos obrigacionais, pode provocar efeitos relativos entre vendedor e comprador, mas não em relação a terceiros que posteriormente adquiram do tal comprador que se tinha obrigado a não vender.

Só poderá deixar de ser assim e portanto só de alguma forma a lei dará relevo à inalienabilidade na hipótese de substituições fideicomissárias, que em certos termos comportam uma inalienabilidade. O artº. 962º. refere-se a essa figura, admitindo-as apenas nas doações e nos testamentos, e só num grau.

É de algum modo também o artº. 959º. admite a possibilidade de, na doação, o doador se reservar, ele próprio, o direito de dispor da coisa, podendo este direito ser registado, sem o que a reserva não tem eficácia em relação a terceiros.

Fora das hipóteses dos artºs. 959º. e 962º., a cláusula de inalienabilidade não produz efeitos reais.

c) PRINCÍPIO DA ELASTICIDADE

36 - Que significa este princípio?

Entende-se que os direitos reais limitados, os tradicionalmente chamados "jura in re aliena" — o usufruto, a servidão, a enfiteuse, o direito de superfície, o direito de uso e habitação — oneram, restringem a propriedade. Sempre que estamos perante um direito real limitado, concorrem dois direitos sobre o mesmo objecto: o direito de propriedade e o direito real limitado a certas utilidades da coisa. É assim nìtidamente no usufruto — há um usufrutuário e há um proprietário da raíz; é assim na servidão — há um direito de servidão sobre aquele prédio e há a propriedade sobre o prédio. Patenteia-se-nos sem-

pre nestas situações uma concorrência de direitos.

Se o direito real limitado se extingue, imediatamente a plena propriedade se reconstitui — retoma a plenitude da sua compreensão e do seu conteúdo. Há como que uma força expansiva, como que uma elasticidade do direito de propriedade, desencadeada pela extinção dos direitos reais que a limitavam, surgindo-nos aí a figura da aquisição restitutiva, derivada ou originária.

d) PRINCÍPIO DA TIPICIDADE

37 - Opõe-se o princípio da tipicidade ou do "numerus clausus" ao princípio da atipicidade ou do "numerus apertus". Implica ele que não possam constituir-se direitos reais que se não enquadrem dentro de um daqueles tipos de que a lei faz expressa previsão e com um conteúdo que não seja aquele que a lei lhes atribui.

Mais concretamente: não há, no domínio da constituição, modificação ou extinção dos direitos reais, liberdade de conformação interna, ao contrário do que sucede com as obrigações, cujo conteúdo pode ser fixado pelas partes segundo o seu livre alvedrio, dentro dos limites da lei, nos termos do nº. 1 do artº. 398º..Nos direitos reais,

não podem as partes conformar o seu conteúdo, estão subordinadas a uma coerção legal - têm que acatar o tipo e o conteúdo dos direitos que a lei prevê e lhes impõe.

"De jure constituto" está este princípio consagrado no art.º 1306.º; "de jure constituendo", não há identidade de opiniões. Autores entendem, e até na nossa doutrina,p.ex.,OLIVEIRA ASCENSÃO(21),ser mais razoável o princípio d "numerus apertus" dos direitos reais, e esta era também a opinião de Philip HECK (22), civilista alemão. Argumentam, no fundo, com o interesse da espontaneidade social, uma vez que o princípio da tipicidade pode conduzir a um desfasamento entre os esquemas legais e a vida prática; a vida é sempre mais célere, mais ágil, tem mais iniciativa do que um legislador, e haveria vantagem geral em respeitar os produtos dessa espontaneidade social no tocante à exploração dos bens.

A opinião mais consolidada, e que nos parece a mais razoável, postula a vigência do princípio da tipicidade ou do "numerus clausus" neste domínio.

As razões em que se baseia são já conhecidas. Acentua-se,e parece que com alguma razão, o facto de estes

(21) - Cfr., "A Tipicidade dos Direitos Reais", Lisboa, 1968,pp. 76 e segs. bem como as Lições de Direitos Reais cits.

(22) - Cfr. Grundriss des Sachenrechts, § 23, 10.

direitos serem absolutos e, como tal, importarem restrições de liberdade para todas as outras pessoas. Por essa razão não se compreende que quaisquer particulares, por acordo entre si, possam criar um agravamento das situações de liberdade para os restantes membros da comunidade; isso só deve ser possível, onde e quando a lei entenda ir corresponder a interesses públicos.

Além disso trata-se de uma matéria ligada a interesses superiores de ordem pública, que, por tal, se compreende seja regulada imperativamente pela lei.

Finalmente acentua-se a possibilidade de o princípio do "numerus apertus" conduzir a uma proliferação de direitos reais; desde logo ressuscitariam com muita probabilidade alguns dos direitos reais característicos de uma estrutura feudal da propriedade, como atrás foi dito. E tal proliferação seria econòmicamente desvantajosa, pois que os bens onde conflituam muitos direitos reais nunca podem ser explorados tão intensiva e eficazmente como aqueles que se encontrem numa situação de exploração exclusiva ou de apropriação por uma só pessoa. Normalmente, e em princípio, as pessoas não estão dispostas a ter os mesmos incómodos e as mesmas despesas com uma coisa que não é só delas ou de cujas utilidades partilham outros e não chegam fàcilmente a acordo entre si, quando se trata de deci-

cidir sobre uma coisa àcerca de cuja gestão eles não podem dispôr exclusivamente.

Por outro lado, também ocorre aqui a ideia - que os antigos exprimiam proverbialmente - de que a comunhão é fonte de discórdias, a confluência de direitos sobre a mesma coisa é fonte de atritos, é raiz potencial de quezilias; como tal também por aí haveria interesse em limitar a possibilidade de surgimento de novos direitos, novos "jura in re aliena", como necessàriamente teriam de ser os novos direitos reais, pois que o direito pleno sobre coisa própria é apenas a propriedade; todos os novos direitos teriam de ser "jura in re aliena", partilha de utilidades de coisas alheias.

Estas as razões apontadas. Parece, pois, que com razoabilidade se opta, num sector maioritário da doutrina, pelo princípio da tipicidade ou do "numerus clausus". De todo o modo, "de jure condito", é este o princípio consagrado irrecusàvelmente no art. 1306.º do Código Civil.

Segundo este preceito, os particulares não podem constituir direitos reais que não caibam num dos tipos previstos na lei e não podem atribuir-lhes um conteúdo diverso daquele que corresponde ao desenho legal.

38 - Afirma-se por vezes vigorar entre nós um prin-

cípio da tipicidade para os negócios com eficácia real, mas tal ideia não nos parece inteiramente exacta pois os direitos reais podem constituir-se por negócios atípicos ou inominados: uma pessoa pode, p. ex., criar ou transferir a propriedade por um negócio inominado.

A que nos parece ser exacta é a ideia de haver uma tipicidade dos modos de constituição dos direitos reais. Concretamente: se a lei prevê a possibilidade de um direito real se transferir por contrato, isso poderá realizar-se mesmo através de um contrato atípico ou inominado; usando o mesmo exemplo, pode a propriedade transferir-se mediante um contrato em que se troque a transferência de um bem contra um serviço - estaremos aqui perante um negócio atípico ou inominado.

Não pode é constituir-se por contrato um direito real, se a lei não indicar o contrato entre os modos de constituição desse direito real; não se poderá, igualmente, criar um direito real por usucapião, se a lei não enuncia esta figura como um dos modos de constituição desse tipo de direitos reais.

Esta questão da tipicidade dos modos de constituição dos direitos reais, por vezes incorrectamente designada por tipicidade dos negócios com eficácia real, assumia relativa importância antes do actual Código Civil no respeitante à constituição dos direitos de preferência convencionais.

Discutia-se então se o direito real de preferência só existiria nos casos expressamente previstos na lei, ou se poderia também constituir-se por acordo das partes. Parece-nos que no domínio dessa legislação anterior devia entender-se como mais correcta a solução de não poder surgir um direito convencional de preferência com eficácia real. Hoje não é inteiramente assim, em virtude de o art. 421.º expressamente prever a possibilidade de as partes pactuarem com eficácia real uma preferência, mas devendo sujeitá-la a registo para que revista essa eficácia "erga omnes".

e) PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

39 - Entendido também como um dos princípios constitucionais dos direitos reais, implica este princípio dever a constituição ou a transferência de qualquer direito real revestir notoriedade, ser acessível ao conhecimento geral.

Por detrás desta nota teremos de colocar o interesse da comunidade; o tráfico jurídico tem de ser fluente, não

pode sofrer demoras excessivas no seu processamento e, sobretudo, tem de ser seguro, certo, as pessoas não podem estar à mercê de surpresas. Não é conveniente que os actos mediante os quais adquiriram direitos possam vir a ser destruídos por ilegitimidade de quem lhes fez a alienação - para tal devem esses actos ser públicos, fornecer a possibilidade de um conhecimento geral, para que seja conhecida a situação jurídica das coisas.

Este princípio tem uma validade tendencial no campo dos direitos reais, não é um princípio absoluto, que vigore para todos. Assume aqui importância a distinção entre bens móveis e bens imóveis.

Quanto às coisas imóveis, existe o instituto do registo predial, precisamente com a finalidade de dar publicidade à situação jurídica dos bens deste tipo.

De alguma maneira, também o formalismo a que a lei sujeita os actos sobre imóveis tem um efeito de dar publicidade a esses actos, embora não seja esse o seu desiderato principal; as suas finalidades específicas são as de defender as partes contra a sua leviandade e contra a falibilidade da prova testemunhal, distinguir as negociações dos termos definitivos do negócio, por vezes razões fiscais, etc. Embora contribuindo para, como se disse, haver uma certa publicidade do acto, não é este o instituto es-

pecífico para a realização desse fim; para tal existe "ex professo" o registo predial. Traduz-se este, como se sabe, num serviço público realizado em repartições próprias onde existem livros que contêm a história dos imóveis, não a história física mas a jurídica; mediante este instituto introduz-se uma dose mais elevada de segurança na contratação. Não uma segurança absoluta, pois o registo não dá direitos - pode perfeitamente suceder vir a verificar-se não pertencer um determinado imóvel à pessoa em cujo nome estava registado. Todavia o registo garante pelo menos que, se o imóvel alguma vez pertenceu à pessoa em cujo nome está registado, então ainda continua a pertencer-lhe. É esta a dose de segurança que o registo oferece, não mais que isso.

Esta exigência de publicidade, consistente no registo, foi também transplantada para alguns móveis. Alguns destes, pelo seu valor, mercê da possibilidade de individualização que oferecem, foram sujeitos a registo - é o caso dos automóveis, dos navios e dos aviões.

Quanto aos outros móveis - uma jóia, um aparelho electrodoméstico, etc. - não vigora qualquer necessidade de registo.

Nalguns sistemas jurídicos, já o sabemos, há regimes que procuram alcançar esta mesma finalidade de certe-

za sobre a situação dos bens móveis mediante princípios diferentes. É, por exemplo, o caso dos sistemas em que a transferência da propriedade dos móveis exige a tradição, ou o caso dos sistemas em que vigora o princípio de "posse vale título", nos termos do qual o adquirente de boa-fé de uma coisa ao seu possuidor, vê a sua situação jurídica de adquirente protegida em termos definitivos; nalguns países, isso vai mesmo ao ponto de se considerar válida à aquisição daquele que de boa-fé adquiriu um objecto furtado ou achado.

Entre nós não vigora nenhum destes princípios; nem sequer na hipótese do art. 1301.º isso se verifica. Podemos dizer que, quanto aos móveis em geral, não só falha uma sujeição ao registo, como até esse papel sucedâneo que a posse pode representar em relação ao registo não é valorizado nos mesmos termos de outros sistemas.

Há apenas um direito real em que a lei atribui à posse, à transferência da coisa, um papel fundamental, de tal maneira que o direito real não surge sem a tradição - referimo-nos ao penhor que, nos termos do art. 669.º, exige o desapossamento da coisa, efectivo ou simbólico - simbólico por vezes, na medida em que pode não ser necessário entregar a própria coisa, bastando a entrega dos documentos que confiram a disponibilidade dela.

f) PRINCÍPIO DA CONSENSUALIDADE

40 - Referiremos, para finalizar, o princípio em epígrafe, empregando aqui a expressão consensualidade no sentido correspondente ao disposto no art. 408.º - os contratos de constituição ou de alienação de direitos reais sobre coisa certa e determinada produzem esse efeito "ex contractu", por mero efeito do contrato. Significa isto que, inversamente ao exigido noutros sistemas, não se torna necessária a tradição da coisa para a transferência de um direito real sobre móveis, nem se exige para os imóveis outro acto, bastando o contrato - o contrato constitutivo ou translativo de direitos reais - para que estes se constituam ou se transfiram. Basta, para esse efeito, o consenso no contrato.

Como se disse, nalguns sistemas, p.ex., o alemão, as coisas passam-se de maneira diversa; aí, um contrato de compra e venda só tem uma eficácia obrigacional, mas não transfere logo a propriedade; por força dele, o comprador tem apenas direito a exigir a entrega da coisa (móveis) ou que se pratique um acto de inscrição do negócio num livro adequado (imóveis) para se produzir o efeito real.

Entre nós não é assim; o direito real está ligado ao

próprio contrato, mesmo que a coisa continue na posse do vendedor, e, quanto aos imóveis, independentemente de registo; só que, quanto a estes, o registo é condição de eficácia em relação a terceiros.

Estes os termos em que entendemos o princípio da consensualidade. Como dizíamos acima, pode a expressão ter um outro sentido - dizem-se consensuais os negócios que não carecem, para a sua eficácia, de formalismo especial; aqueles negócios que podem realizar-se por qualquer das formas que as declarações de vontade possam revestir.

Neste sentido, aos negócios consensuais opõem-se os negócios formais; nesta especial perspectiva, não se poderia dizer que vigorasse no domínio dos direitos reais o princípio da consensualidade, pois, pelo menos para os negócios sobre imóveis, é exigido um formalismo especial (a lei exige escritura pública para este tipo de negócios).

Não é, assim, esta acepção que tomamos em conta ao falar em princípio da consensualidade; o sentido com que aqui utilizamos esta expressão visa pôr em relevo que se podem constituir ou transferir direitos reais sobre coisa certa e determinada por mero efeito de contrato, sem necessidade de um acto posterior que venha acrescer ao negócio jurídico.

* * *

CAPITULO IV

CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS REAIS

41 - Dentro da sistematização adoptada cumpre traçar, agora, um quadro classificatório dos direitos reais, visto que, seguidamente, iremos estudar alguns direitos reais em especial.

Neste contexto usa fazer-se uma clássica distinção entre direitos reais de gozo e direitos reais de garantia.

Esta distinção não é, porém, uma "summa divisio" ou seja, uma distinção que cubra toda a universalidade dos direitos reais. Trata-se, de facto, de uma distinção incompleta, dado haver direitos reais que não cabem nos quadros desta classificação, nomeadamente os direitos reais de aquisição como, v.g., o direito de preferência. Esses -

os direitos reais de aquisição - não podem rigorosamente dizer-se nem direitos reais de gozo nem direitos reais de garantia.

Daí que optemos por uma outra classificação. Vamos distinguir entre a posse, a propriedade e os direitos reais limitados, subdividindo estes últimos em direitos reais de gozo, direitos reais de garantia e direitos reais de aquisição.

a) POSSE

42 - Começando pelo primeiro dos direitos referidos (a posse) diremos que esta é definida no art. 1251.º C.C. como "...o poder que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real". Assim, consideremos um indivíduo que exerce, em nome próprio, sobre uma coisa, poderes correspondentes ao conteúdo do direito de propriedade, porque achou a coisa, porque a furtou, porque se apropriou dela ou - figure-se - porque ela lhe foi transferida por negócio nulo; em qualquer desses casos o indivíduo apresenta-se-nos numa situação de posse.

Perguntar-se-á.

Mas a posse é um direito? A posse não será antes um mero facto, uma pura e simples situação de facto?

Caracterizamo-la como um direito real provisório e, na verdade, parece ser mais do que um mero facto.

Porquê? Porque é que a posse é um direito?

Pois bem, é um direito por constituir uma situação jurídica subjectiva que confere um poder sobre uma coisa e que é tutelada pelo direito objectivo, desde logo na medida em que é hereditável, alienável e registável e na medida em que ele confere ao seu titular uma garantia jurídica. Um titular da posse pode, com efeito, pedir uma indemnização no caso de ser violada a sua situação e há toda uma série de meios de defesa da posse, enunciados no art. 1276.º e segs. - acção de prevenção, acção de manutenção da posse, acção de restituição da posse. Tudo isto são meios jurídicos que a lei confere ao possuidor, unicamente por ele ser possuidor e sem averiguar se, por detrás da posse, existe ou não um outro direito real. Para conseguir uma finalidade de mais fácil ordenação da vida e porque, normalmente o possuidor é proprietário, a lei confere-lhe meios de defesa da posse sem averiguar mais nada.

Poderá parecer chocante que tal aconteça, isto é, que um indivíduo, que achou uma coisa ou a furtou, possa, não obstante, invocar a tutela possessória. Porquê este re-

gime? - pergunta-se com pleno cabimento.

É que, no comum dos casos, não é isto que se verifica. No comum dos casos quem está de posse da coisa tem realmente um direito e a lei não quer obrigar as pessoas que pretendem defender a sua detenção e fruição dos bens a produzir, desde logo, a actividade probatória dirigida à demonstração de quem detém o direito de propriedade sobre eles. Contenta-se com a prova da posse; provada esta, a pessoa pode logo obter uma acção de prevenção contra a turbação da posse ou exigir a manutenção desta ou ainda, conseguir a restituição da coisa no caso de ter sido esbulhado dela.

Tudo isto mostra, pois, que a posse é um direito e, dentro das várias categorias destes, um direito real.

É-o - um direito real - e não um direito relativo, porque é um direito absoluto, com eficácia "erga omnes", o que confere um poder sobre a coisa - tem, portanto, as notas específicas dos direitos reais. O possuidor persegue a coisa mediante as acções atrás referidas.

Por outro lado, acrescentando uma nota que põe as coisas nos seus devidos lugares, é um direito real provisório. Provisório, porquê?

Porque os seus efeitos são independentes da circunstância de se saber quem é o titular do direito real sobre

a coisa que está na esfera do possuidor. A protecção possessória é provisória, porque só actua, enquanto não for definitivamente apurado quem é o autêntico titular do direito real sobre a coisa.

Quer isto dizer, portanto, que à pessoa que detém ou frui uma coisa basta provar a posse e se ela fôr uma posse de ano e dia, logo superior a um ano, como diz o nº 2 do art. 1278.º, não tem que se averiguar mesmo mais nada. Basta, assim, a simples prova desta posse para que o indivíduo possa exigir a restituição da coisa.

Só depois é que se irá, então, discutir se a posse é ou não legítima, se o possuidor detém ou não um direito real definitivo sobre a coisa. Há, assim, portanto uma tutela apenas provisória; daí que autonomizemos esse direito - a posse - de todos os outros.

O exposto mostrou porém, que na posse há algo mais do que um simples facto: há um direito real, embora provisório.

b) PROPRIEDADE

43 - Indicamos a seguir, na distinção dos diversos direitos reais proposta, a propriedade. O direito de pro-

priedade é o direito real pleno e o direito real mais importante.

Define-o o art.º 1305 C.C. como sendo o poder que o proprietário detém de gozar "... de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela impostas." Aliás, uma definição que caberia com toda a legitimidade num código inspirado por uma orientação individualista estreme. Isto porque não há sequer, aqui, uma acentuação dos aspectos limitativos da propriedade, ligados à sua função social ou outros aspectos superadores do individualismo extremo. A lei acentua aqui a propriedade em termos praticamente iguais à classificação romana do "jus utendi, jus fruendi e jus abutendi"

Esta propriedade pode ainda revestir várias formas.

Há, com efeito, várias espécies que, para efeitos de regulamentação, merecem ser autonomizadas - e a lei autonomiza com efeito algumas. Assim, por exemplo, a lei indica e regulamenta separadamente a propriedade de imóveis. Concebe-se que assim seja, pois há toda uma série de problemas que só se põem para os imóveis; o que constitui, mais uma manifestação da ideia, já conhecida, de a vida, pela sua variedade e pelo seu polimorfismo, nem sempre se coa-

dunar com a pretensão de se formularem teorias gerais, estética ou lògicamente perfeitas, mas que podem falsear a vida na medida em que a sua generalidade pode não corresponder à diversificação vital.

Uma manifestação desta ideia reside, desde logo, no facto de a propriedade de imóveis desencadear uma problemática muito diferente da da propriedade de móveis. Já o vimos atrás, a propósito de alguns princípios constitucionais dos direitos reais, - muitos daqueles princípios valiam para os imóveis (a publicidade, por exemplo) e já não para os móveis e compreende-se que assim seja pela própria natureza das coisas.

Acrescente-se, a título incidental, ser a distinção entre móveis e imóveis tão significativa que um ou outro autor, (23) ao estudar os direitos reais, faz logo uma grande divisão - direitos reais sobre imóveis-direitos reais sobre móveis-estudando-os separadamente.

Podemos estudá-los globalmente, mas estaremos obrigados à medida que defrontarmos os problemas, a salientar diferenças que necessàriamente surgem a respeito de uma e de outra categoria de coisas.

A propriedade de imóveis põe problemas especiais. Assim, só se põe o problema do direito de demarcação para

(23) - Cfr. Baur, ob. cit.

os imóveis - os móveis estão demarcados por natureza. Só se põe o problema do direito de tapagem, do direito de edificar valas, muros ou sebes para os imóveis. Só para estes se põe o problema de construção, como só para eles se põe o problema do direito de plantação de árvores ou de arbustos. Só se põem problemas acerca de paredes e muros de meação para os imóveis; só se põem problemas de fraccionamento e de emparcelamento para imóveis — para imóveis rústicos.

Depois foca a lei em especial a propriedade das águas. Também esta põe alguns problemas específicos pela natureza do seu objecto; há, com efeito, problemas especiais ligados à propriedade das águas. v.g., os direitos dos proprietários dos prédios inferiores (art. 1391.º), o aproveitamento e captação de águas subterrâneas (art. 1394.º), etc.

Por último, distingue a lei, também por desencadearem uma problemática própria, a compropriedade e a propriedade horizontal.

Tudo isto são formas do direito de propriedade.

c) DIREITOS REAIS LIMITADOS

44 - Cabe referir, agora, dentro do quadro classificatório proposto, a terceira categoria de direitos reais - a dos direitos reais limitados.

Estes são direitos que não conferem a plenitude dos poderes sobre uma coisa. Conferem apenas a possibilidade de exercer certos poderes sobre uma coisa, mas não a plenitude dos poderes correspondentes à clássica tripartição - "jus utendi, jus fruendi e jus abutendi". São, portanto, direitos sobre coisas que em propriedade pertencem a outrém. São direitos que pressupõem, assim, uma concorrência de direitos. Quando eles existem, incide também sobre a mesma a coisa uma propriedade que é restringida por este direito real limitado (o limitador). São, portanto "jura in re aliena "(direitos sobre coisa alheia) ou, pelo menos, sobre coisa não própria.

Dentro deles - os direitos reais limitados - distinguimos os direitos reais de gozo, os direitos reais de garantia e os direitos reais de aquisição. Vejamos em que consiste cada um destes tipos:

I - Direitos reais de gozo.

45 - Os direitos reais de gozo são aqueles que conferem um poder de utilizar, total ou parcialmente, uma coisa e, por vezes, também o de apropriação dos frutos que a coisa produza.

No nosso direito são o usufruto, o uso e habitação, a enfiteuse, o direito de superfície e as servidões prediais. Esta enumeração é exaustiva, uma vez que, como já referimos, estamos num domínio onde vigora o princípio da tipicidade ou do "numerus clausus".

Desapareceram, designadamente, no actual sistema, alguns direitos reais de gozo que o Código antigo conhecia como, por exemplo, o quinhão e o compáscuo. Estes eram direitos reais admitidos e regulados pelo Código de Seabra e que desapareceram na nova legislação.

Definimo-los - os direitos reais de gozo - como poderes de utilizar, total ou parcialmente, uma coisa e, por vezes, além disso, o poder de apropriação dos frutos da coisa. Estamos concretamente a pensar no usufruto em que não há só o poder de utilizar a coisa, mas também o poder de apropriação dos seus frutos, enquanto, por exemplo, no direito de uso e habitação há apenas o direito de usar a coisa. Cremos que esta definição cobre todas as hipóteses

de direitos reais de gozo.

II - Direitos reais de garantia

46 - Os direitos reais de garantia são direitos que conferem o poder de, pelo valor de uma coisa ou pelo valor dos seus rendimentos, um indivíduo obter, com preferência sobre todos os outros credores, o pagamento de uma dívida de que é titular activo.

Esta distinção entre direitos de gozo e de garantia e, mesmo, o seu terceiro termo - direitos reais de aquisição - tem como critério a função económica do direito real.

Os direitos reais de garantia são o penhor; a hipoteca; os privilégios creditórios especiais - que são, como já referimos, todos os privilégios imobiliários e certos mobiliários excluindo-se, os privilégios mobiliários gerais que não constituem, como então, também dissemos, direitos reais - o direito de retenção e a consignação de rendimentos - esta última designada, no nosso antigo direito e também em alguns sistemas jurídicos estrangeiros de países de língua latina, por antícrese.

Os direitos reais de garantia são, indubitàvelmente, autênticos direitos reais.

Já se sustentou, porém, entre nós que esses direitos não constituiam verdadeiros direitos reais, mas meros acessórios dos direitos de crédito. Daí que eles - os direitos reais de garantia - sejam muitas vezes estudados, para efeitos didácticos ou para efeitos expositivos da problemática jurídica, em conexão com as obrigações e na cadeira de direito das obrigações.

Que dizer de tudo isto?

Há, de facto, funcionalmente, uma conexão entre os direitos reais de garantia e os direitos de crédito. Os direitos REAIS DE GARANTIA [redacted] estão ao serviço do pagamento ou da satisfação do interesse do credor. Podem integrar-se num domínio institucional que podemos designar por garantias das obrigações onde entram, também, outras figuras que não são direitos reais, como, v.g. a fiança. Há, de facto, uma identidade de função entre a hipoteca e a fiança ou a prestação de caução ou a abonação - tudo isso, são garantias das obrigações. São, portanto, os direitos reais de garantia, sem dúvida, acessórios dos direitos de crédito, designadamente no que se refere à sua extinção - extinguindo-se o direito de crédito, extingue-se o direito real que garante o respectivo crédito.

O facto de os direitos reais de garantia serem acessórios, dos direitos de crédito não quer dizer porém, que

não tenham uma natureza jurídica própria e que nós não a devamos investigar.

Ora, a natureza jurídica destas figuras parece ser a dos direitos reais dado que apresentam as notas características destes, designadamente o direito de sequela e o direito de preferência.

Vejamos a hipoteca (caso típico): há aí, o direito de sequela e o direito de preferência.

III - Direitos reais de aquisição

47 - Segue-se referir, por último, dentro do esquema que fornecemos, os direitos reais de aquisição.

Estes são direitos reais que conferem a um determinado indivíduo a possibilidade de se apropriar de uma coisa, de adquirir uma coisa.

Note-se, porém, que estas situações não se identificam com a faculdade geral - mera emanação da capacidade jurídica - de adquirir. Não é esta faculdade geral que temos aqui em vista, mas antes aquelas situações especiais em que certas pessoas podem exercer uma especial faculdade de, em determinadas circunstâncias, adquirir uma coisa.

α) Direito de preferência

48 - Exemplo de direito real de aquisição é, desde logo, o direito real de preferência.

O direito real de preferência confere a pessoas em certas situações a possibilidade de adquirirem uma coisa, no caso de o proprietário dela a pretender alienar e o preferente estar disposto a pagar por ela a mesma importância que o terceiro adquirente se propõe pagar. É, portanto, o direito de fazer suas certas coisas, dando tanto por tanto, dando o valor pelo qual se projecta negociar a coisa.

Vamos dar, agora, uma exemplificação, o mais possível completa, das situações em que existe este direito real de preferência.

Assim, por exemplo, este direito real de preferência pode ser legal - é, por vezes a lei que o confere para certas situações -, ou pode ser convencional. A possibilidade de um direito convencional de preferência está referida no art. 421.º C.C., sendo possível atribuir eficácia real aos pactos de preferência celebrados entre pessoas em quaisquer circunstâncias.

O direito de preferência legal existe, por sua vez, por exemplo:

- Na hipótese dos arts. 1117.º e 1119.º C.C. (direito de preferência do arrendatário comercial e do arrendatário para exercício de profissão liberal, quanto à alienação do prédio por eles arrendado);

- também no art. 1380.º (proprietários de prédios confinantes de área inferior à unidade de cultura) a lei, para facilitar a reunião das pequenas parcelas em prédios rústicos, confere um direito de preferência ao proprietário confinante, se o prédio cujo proprietário tem direito de preferência tiver uma área inferior à da unidade de cultura; e quer isto dizer que este artigo supõe que sejam definidas as unidades de cultura por região;

- por sua vez, o art. 1409.º atribui um direito de preferência ao comproprietário; o comproprietário tem, nos termos dessa disposição, preferência na alienação da quota ideal do seu comproprietário; já não tem lugar idêntico direito no domínio da propriedade horizontal; nesta não há, com efeito, por força do art. 1423.º, direito de preferência. Assim ao proprietário de uma unidade independente num prédio por andares - regime da propriedade horizontal - não assiste um direito de preferência na venda de qualquer outra unidade do mesmo prédio;

- os arts. 1499.º e 1501.º estabelecem uma preferên

cia atribuída aos titulares do domínio directo e do domínio útil na enfiteuse, e igual regime nos surge no sub-enfiteuse por força do art.1523.º;

- o art. 1535.º atribui - ele também - um direito de preferência ao proprietário do solo no direito de superfície; aqui - no direito de superfície - há um desdobramento, uma vez que o prédio e o solo em que aquele se encontra implantado pertencem a proprietários diferentes; pois bem, o proprietário do solo tem preferência na venda do prédio nele implantado;

- o art. 1555.º atribui, por sua vez, um direito de preferência ao titular do prédio serviente na servidão de passagem; assim, ao indivíduo que está onerado com uma servidão de passagem sobre o seu prédio, assiste um direito de preferência na venda do prédio dominante;

- o art. 2130.º atribui aos co-herdeiros um direito de preferência na alienação do quinhão hereditário, estando indivisa a herança, por não terem ainda sido realizadas as partilhas; ao titular de uma fracção da herança assiste, assim, nos termos dessa disposição, um direito de preferência na alienação dos outros quinhões hereditários.

São estas, - os casos dos arts. 1117.º, . 1119.º; 1380.º; 1409.º; 1499.º; 1501.º; 1523.º; 1535.º; 1555.º; e 2130.º C.C. referidos -, numa indicação exaustiva, as

hipóteses de direito legal de preferência. Fora delas não se pode verificar o direito real de preferência, a não ser que haja um pacto de preferencia com eficácia real.

β) CONTRATO-PROMESSA COM EFICÁCIA REAL

49 - Um outro exemplo de direito real de aquisição é, a nosso ver, o direito do promissário no contrato-promessa de compra e venda a que foi atribuída eficácia real, "rectius", o direito do promissário num contrato-promessa de alienação onerosa de bens imóveis ou de móveis sujeitos a registo, se as partes atribuirem eficácia real ao contrato.

As partes podem fazer um contrato-promessa de compra e venda e não lhe atribuir eficácia real. Quais são, então, nestes casos os direitos do promissário?

Pois bem, são o de pedir a devolução do sinal em dobro ou, no caso de não ter havido sinal, o de pedir a execução específica do contrato.

É este - a possibilidade de execução específica do contrato-promessa - uma inovação do novo Código que, porém, só actua, nos termos do artº. 830º C.C., no caso de não ter havido sinal. Se este tiver sido prestado, en-

tão, como dissemos, já aquela providência não pode ser utilizada, sendo apenas exigível uma quantia equivalente ao dobro da que, como sinal, foi prestada pelo promissário. Porquê esta relevância dada ao sinal?

É que a lei presume que, quando houve sinal, as partes sancionaram como garantia do negócio a restituição do sinal em dobro; se não houve sinal, nos termos do artº. 830º, o promitente comprador pode exigir,pode provocar uma sentença que faz as vezes de escritura,ou seja, uma execução específica. É isto, como dissemos, uma solução inovadora do Código de 1966.

É claro que a possibilidade de execução específica não significa, porém, eficácia real, pois não tem lugar, se entretanto o promitente vendedor já vendeu o prédio para terceiro. Então - se essa transferência se tiver verificado - não se pode, por sentença judicial,provocar a aquisição da coisa, a não ser que, no contrato-promessa, se tenha convencionado que ele tinha eficácia real e que essa cláusula atributiva de eficácia real ao contrato-promessa tenha sido registada. Em apoio legal desta idéia,desta solução, podem citar-se os artºs. 410º e ss., máxime o artº. 413º C.C..

No contrato-promessa podem, assim, pôr-se várias hipóteses práticas que vamos referir, partindo do pressuposto de que o contrato-promessa não é cumprido.

Assim, figure-se que um indivíduo promete vender a outro certo prédio e, depois, se recusa a fazer a escritura.

Quid juris? Vejamos:

- houve sinal passado? Então, neste caso, o promitente-comprador pode exigir a devolução do sinal em dobro;

- não houve sinal passado? Então, nos termos do artº. 830º referido, o promitente-comprador pode vir a juízo, e requerer a execução específica do contrato-promessa. É proferida sentença que faz as vezes de escritura, passando, assim, por esse efeito, o prédio para a propriedade do comprador;

- se, para além de tudo isto, foi estipulada eficácia real, então o adquirente (promissário) pode ir buscar o prédio a terceiro que o tenha adquirido do promitente-vendedor; isto, desde que, como já referimos, essa eficácia real do contrato-promessa tenha sido registada.

Ora, esta posição do promissário, na hipótese do artº 413º - contrato-promessa com eficácia real registado - constitui, também, um direito real de aquisição(24).

---

(24) - É corrente classificar o direito real de

preferência entre os direitos reais de aquisição, dentro, portanto, da categoria dos direitos reais; já quanto ao direito do promissário no contrato-promessa isso não se verifica, porque se trata de uma inovação do Código Civil.

Esta atribuição de eficácia real ao contrato-promessa de alienação de imóveis ou móveis sujeitos a registo é, pois, uma inovação do Código Civil. Já é, porém, corrente encontrar-se a qualificação do direito de preferência como direito real de aquisição, logo, como um direito real.

Também, porém, uma vez que outra, se encontram referências a este direito como direito potestativo.

Neste sentido - o direito de preferência como direito potestativo - refira-se MANUEL DE ANDRADE que, no seu livro Teoria Geral da Relação Jurídica (cfr. vol. I, pág.14), ao exemplificar os direitos potestativos constitutivos, inclui, entre os exemplos aí referidos, o direito de preferência.

Pode então perguntar-se: o direito de preferência é um direito real ou um direito potestativo?

Parece que as duas coisas não são inteiramente conciliáveis, uma vez que o direito real é um direito subjectivo pròpriamente dito, enquanto o direito potestativo não o é, por nele, como sabemos, à atribuição do direito não corresponder, pelo lado passivo, a imposição de um dever jurídico, mas antes a de um mero estado de sujeição.

A qualificação corrente é a de direito real.

Talvez, porém, que bem vistas as coisas - isto é uma simples proposta feita com carácter algo dubitativo, aliás o problema é de natureza puramente conceitual e, portanto, um problema relativamente menos importante — não haja, aqui, um direito real e haja, antes, uma relação obrigacional complexa de origem legal ou contratual, integrada por um crédito do preferente em relação ao proprietário da coisa a respeito de cuja alienação a preferência pode funcionar, e um direito potestativo de provocar ine-

xoràvelmente a aquisição da coisa, no caso de ela ter sido alienada sem que fosse feita a oferta ao preferente. Há, portanto, aqui, um direito de crédito a exigir do proprietário que ofereça a coisa ao preferente para este a comprar, se o quizer fazer, mediante a entrega do respectivo preço e um direito potestativo constitutivo, que, evidentemente, se é direito de aquisição de uma coisa, é oponível a terceiros.

Ora, é precisamente esta oponibilidade a terceiros que leva a afirmar haver aqui um direito real.

Pode duvidar-se, contudo, que seja legítimo falar aqui de um direito real, pois não existe o poder directo e imediato sobre uma coisa. O preferente não tem um poder directo e imediato sobre a coisa, como parece ser típico dos direitos reais.

Por outro lado, não se vê muito claramente a eficácia absoluta - característica decisiva dos direitos reais, como referimos - do direito de preferência. No caso de a coisa não ter sido oferecida ao preferente e este ter que a ir adquirir mediante o exercício do seu direito em face do terceiro adquirente da coisa, o preferente, a poder exigir uma indemnização a alguém, só o pode fazer ao alienante e não ao adquirente.

Ora, parece que um enquadramento possível para esta situação - talvez, até, mais adequado -, será o que prescinde de falar, aqui, de um direito real e vê a situação do preferente como titular de uma relação obrigacional complexa, integrada por um direito de crédito em relação ao proprietário e por um direito potestativo de aquisição ou de constituição de uma relação de proprietário sobre a coisa.

É, porém, - repetimos - corrente enunciar-se o direito de preferência entre os direitos reais.

Vê-se afirmar, algumas vezes também, e talvez nem sempre com inteira consciência da contradição, que o direito de preferência constitui um direito potestativo; ora,

se há direito potestativo não há, lògicamente, direito real. Isto, porque os direitos reais são sub-espécies dos direitos subjectivos pròpriamente ditos, enquanto assim não acontece com os direitos potestativos, por - repetimos - não corresponder pelo lado passivo nenhum dever, nem sequer um dever geral, mas antes um estado de sujeição.

Mas - afirmamo-lo de novo - este problema da qualificação do direito de preferência como um direito real, como um direito potestativo, ou como uma relação obrigacional complexa, é uma questão de menor importância; ponto é que se conheça o regime jurídico da figura.

* * *

CAPITULO V

HIPOTESES DE QUALIFICAÇÃO REAL DUVIDOSA OU CONTROVERTIDA

50 - Há certas situações acerca das quais se discute se têm ou não a natureza de direitos reais. Nalgumas delas, no termo da discussão, não se chega a uma conclusão segura e continua assim a sua qualificação a ser duvidosa.

a) DIREITO DO LOCATÁRIO

51 - Uma dessas situações em que o debate tem mais tradições, e é mais vivo, é a do direito do arrendatário; mais genèricamente, e em face do actual Código, o problema pode alargar-se em geral ao locatário.

O direito do locatário será um direito real ou um direito de crédito? É esta a forma por que se pode equacionar o problema.

Há uma solução que qualifica o direito do locatário como um direito de crédito - o locatário não tem um poder directo e imediato sobre a coisa, as suas possibilidades de gozo da coisa passam pela mediação de um outro sujeito - o locador. Tem o direito de exigir do locador que lhe proporcione o gozo da coisa, e não um direito sobre a coisa em face de todos os outros.

Para um outro ponto de vista, estaremos em face de um direito real; o direito do locatário seria um direito real.

Outros há que propendem, dentro do problema, para soluções intermédias, salientando existirem aqui notas típicas dos dois grandes grupos de relações jurídicas, e afirmando a prevalência de uma ou de outra dessas categorias.

52 - Em face destes tópicos do problema, tentaremos agora fazer uma apreciação mais desenvolvida da questão.

Para que se possa tratar de um direito real, terá a posição do arrendatário de possuir as notas próprias desse grupo de relações. Uma das notas típicas dos direitos

reais - dela exclusiva - é o chamado direito de sequela - a possibilidade que o titular do direito real tem de exercer os poderes correspondentes ao conteúdo do seu direito, onde quer que a coisa se encontre, mesmo que esta entre na esfera jurídica ou material de outrem.

Ora, o direito de sequela existe no arrendamento; o direito do arrendatário está dotado dessa característica dos direitos reais, como claramente o revela o artº 1057º do actual Código Civil - "o adquirente do direito com base no qual foi celebrado o contrato sucede nos direitos e obrigações do locador...". Quer isto dizer que o locatário pode continuar a exercer os seus poderes sobre a coisa; pode continuar a utilizar a coisa apesar de ela ter sido vendida ou por qualquer forma alienada pelo locador a terceiro. O seu direito, a sua posição jurídica, tem eficácia em relação ao novo adquirente da coisa.

Isto é nitidamente o direito de sequela. Não se pode pretender, como já se pretendeu, não ter esta solução nada a ver com o direito de sequela, por ser uma manifestação de cessão da posição contratual - a transmissão da posição do locador verificava-se, do alienante para o adquirente do prédio arrendado, porque acompanhando a alienação do prédio havia a cessão da posição do locador.

Esta solução não é de forma alguma aceitável por-

que este efeito é imperativo. Este efeito, por força do qual o adquirente subentra na posição do locador, impõe-se "volens nolens", sem a sua vontade ou mesmo até contra ela.

Se se tratasse de uma cessão da posição contratual teria de ser pactuado entre o alienante e o adquirente que este adquiria a posição de locador e teria que haver consentimento da outra parte, isto é, do locatário. Aqui não se torna necessário o consentimento de ninguém; estamos perante um efeito que a lei liga automàticamente à transmissão do prédio, algo que poderemos apodar de subrogação "ex lege" do contrato. O adquirente do prédio fica subrogado legalmente na posição do locador.

Em conclusão: esta solução imperativa é genuìnamente uma expressão do direito de sequela.

Sob este ponto de vista, idêntica situação é aquela em que se encontra o usufrutuário, para a manutenção do direito do qual é perfeitamente irrelevante a alienação da propriedade.

53 - O direito de preferência faz, também, parte das notas indicadas correntemente como características dos direitos reais e existe na situação do arrendatário, mais genèricamente, na do locatário. Só que esta nota não

é aqui decisiva, pois o artº. 407º mostra-nos a sua existência mesmo nos direitos de crédito, que confiram o gozo de uma coisa. Nessa medida, o facto de existir aqui a preferência não seria decisivo para qualificar a posição do arrendatário como direito real.

54 - Os adversários da qualificação real do direito do arrendatário aceitam estas soluções e têm de reconhecer a existência da sequela. São, pelo menos, obrigados a reconhecer aqui a existência de fortíssimas notas típicas da situação de realidade, da situação do direito real. Excluem, contudo, a qualificação desse direito como real por não existir um poder directo e imediato sobre a coisa; para eles o locatário não teria uma ligação directa e imediata com a coisa, mas apenas mediata - as suas possibilidades de gozo da coisa passariam pela cooperação do senhorio. Teria sòmente o poder de exigir deste que lhe proporcionasse o gozo da coisa. O que no fundo se traduz em negar a inerência da coisa ao seu titular (uma característica dos direitos reais); este não teria o poder directo e imediato, a ligação directa com a coisa; tê-la-ia por intermédio do locador.

Esta afirmação - de outro modo seria uma pura proposta de expressão gráfica das coisas - era concretiza-

da através da enunciação de certas obrigações que cabem ao senhorio. Este tem certas obrigações especiais - ele não seria apenas um dentre os restantes consociados obrigado a acatar a obrigação passiva universal contraposta ao direito real - o que tornaria o direito do locatário um puro direito de crédito.

Não nos parece decisiva esta maneira de ver as coisas. Sem dúvida que, p. ex., o artº. 1031º impõe obrigações ao senhorio (a obrigação de entregar a coisa ao locatário, de lhe assegurar o gozo desta para os fins a que se destina) e daqui se pode desentranhar toda uma série de obrigações, v.g., ter de fazer obras de conservação da coisa; o artº. 1037º prescreve-lhe a abstenção de prática de actos que diminuam ou impeçam o gozo da coisa pelo locatário.

Não cremos, porém, que o facto de poder haver deveres especiais do senhorio para com o locatário seja incompatível com a qualificação como direito real da posição deste.

Situações deste tipo parece surgirem também noutras hipóteses ou em hipóteses nítidas de direitos reais. Assim, p. ex., no usufruto podem estar a cargo do proprietário da raiz obrigações para com o usufrutuário, como a decorrente do artº. 1473º; no direito de superfície

os artºs. 1532º e 1533º podem originar obrigações a cargo do proprietário do solo; na servidão, em geral, o artº 1567º revela que podem existir obrigações a cargo do proprietário do prédio serviente.

Sempre que exista uma concorrência de direitos reais sobre a mesma coisa - propriedade e um direito real limitado - podem surgir deveres especiais a cargo de um dos titulares desses direitos reais limitados. Isto parece não excluir decisivamente a qualificação do direito do locatário como real. Há toda uma série de hipóteses de direitos reais, em que também existe esta possibilidade de vínculos especiais. Não é forçoso concluir, a partir desses deveres especiais, a não existência de uma inerência da coisa ao seu titular; onde a inerência encontra expressão é na circunstância de o titular do direito poder perseguir a coisa, acompanhá-la em todas as suas deslocações - será um sintoma nítido de aderência do direito à coisa, de inerência - e isto acontece no direito do arrendatário, nos termos do artº. 1057º.

É certo que podem existir direitos de crédito que conferem o contacto com a coisa, o que acontece com o direito do comodatário, do depositário ou o direito do indivíduo que, por contrato, adquira a possibilidade de passear no parque de outra pessoa ou de caçar em proprieda-

de alheia.São contratos que geram direitos de crédito,por força dos quais o credor tem um contacto com a coisa e até pode exercer certos poderes sobre ela. Certo, isto só de per si não qualifica essas situações como direitos reais. Simplesmente nestas situações não há inerência, porque as pessoas que nelas ocupam a posição de credor não têm a possibilidade de acompanhar a coisa nas suas movimentações jurídicas, não podem impôr o seu direito ao novo proprietário; o comodatário, a quem foi emprestado um automóvel, não pode manter o direito de o usar em face do novo adquirente da propriedade desse automóvel.

Isso não acontece no arrendamento,aí existe a possibilidade de sequela, que necessàriamente gera a inerência.

55 - Não pode,também,invocar-se, como argumento decisivo a favor da qualificação creditícia do direito do locatário, o facto de este ter de pagar uma renda ou aluguer, pois isso também acontece em muitas hipóteses nítidas de direito real. Este facto nada tem a ver com a natureza do direito. Assim, nitidamente na enfiteuse,tem de se pagar o foro; e no direito de superfície pode ter-se convencionado que o superficiário pague uma importância periódica ao proprietário do solo, em vez de pagar uma importância global. E isto não exclui a classificação real do direito do enfiteuta ou do superficiário.

56 - Acontece, por vezes, e agora isto com a finalidade de fazer apelo às intenções do legislador, que se utiliza um argumento extraído do artº 1037º - se o legislador considerasse o direito do locatário como um direito real, não teria facultado a este expressamente os meios de tutela possessória, que lhe confere no nº 2 desse artigo. Segundo ele, "o locatário que for privado da coisa ou perturbado no exercício dos seus direitos pode usar, mesmo contra o locador, dos meios facultados ao possuidor nos artigos 1276º e seguintes". E isso porque, como titular do direito real, ele já teria a posse e genèricamente nela incluídos estes poderes.

Este argumento está longe de ser decisivo. Poderemos dizer que o legislador fez isso por ser duvidoso que se tratasse de um direito real ou de um direito de crédito. Não implica uma tomada de posição decisiva por parte dele. Se ele sabia que era um ponto duvidoso, uma questão não resolvida com argumentos definitivos em nenhum sentido, pode ter querido conferir ao locatário, por esse motivo, expressamente, esses poderes. Teremos de passar além desta pesquisa de intenções do legislador, até porque

este não vai decidir uma questão científica. Isto porque pode este entender cientìficamente que uma dada questão reveste determinada natureza e termos nós depois que concluir outra coisa, à face do regime que o Código, na totalidade da regulamentação do instituto em que ela se integra, confere a essa situação jurídica.

O que se pode concluir é que o locatário tem esses poderes, e que tais poderes são, em princípio, privativos do titular de um direito real.

57 - Chegados a este ponto, e rememorando o que até aqui foi dito, que conclusão poderemos efectivamente tirar?

Investigámos algumas soluções, vimos que elas trazem fortes ingredientes de realidade - poderiam apontar, sem possibilidade de crítica fundada, a qualificação do direito do arrendatário como um direito real.

Poderá parecer, assim, que a questão não tem interesse, que, chegados a este ponto, se reduz a um enquadramento indiferente numa ou noutra categoria. Na verdade, quanto às soluções indicadas, todos os autores as conhecem e aceitam; uns, porém, extraem delas a conclusão de que se trata de um direito real; outros dizem ter fortes características de realidade, mas ser ainda, predominantemente, um direito de crédito.

Parece, pois, um puro nominalismo, uma questão de pura opção por um "nomen" para uma situação que é caracterizada claramente nas suas particularidades (25).

58 - Talvez não seja, contudo, inteiramente assim. Há, sobretudo, um outro problema de regulamentação ainda não focado e que tem conexão com esta classificação do direito do arrendatário como direito real ou como um direito de crédito - a questão de saber se o direito, a posição jurídica do arrendatário pode ser adquirida por usucapião.

---

(25) - Poderia pensar-se que uma irrefutável confirmação da natureza real do direito do locatário se encontra na circunstância de este ter direito a ser indemnizado pelo autor dum facto danoso que, danificando o objecto locado, impossibilite a sua utilização, solução que parece não poder oferecer dúvidas. Se A arrenda uma casa ou aluga um automóvel e B destrói o objecto locado, parece que B terá de indemnizar, não só C, locador, mas também A, locatário. Ora, rejeitando-se o chamado efeito externo das obrigações, qual o direito absoluto de A que foi violado por B ? Seria o direito de locatário, concebido assim como direito "erga omnes", como direito real.

Este argumento não colhe. Desde logo idêntico direito de indemnização teria A, se fosse um mero comodatário e o comodato não atribui um direito real, faltando ao comodatário a sequela. O direito real de A violado por B, naquela hipótese, pode descortinar-se na sua posse, mesmo quando se trate de uma posse precária ou em nome alheio ou ainda, mera detenção, como é o caso vertente.

É uma questão frequentemente posta na doutrina e ainda recentemente um Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (26) concluiu no sentido de que o direito do arrendatário se não pode adquirir por prescrição aquisitiva ou usucapião. Esta posição tem anotação favorável de VAZ SERRA na Revista de Legislação e Jurisprudência (27).

Este problema assume especial importância numa situação de grande relevo prático - a hipótese dos arrendamentos para fins comerciais ou para profissões liberais, que não foram reduzidos a escritura pública.

Nos outros arrendamentos - os arrendamentos para habitação - o problema não reveste tanta importância, porque o negócio não é formal e pode provar-se mediante a apresentação dos recibos da renda.

Nos arrendamentos para fins comerciais, mesmo que haja recibos de renda, o contrato é nulo se não tiver sido reduzido a escritura pública.

Pode perguntar-se: se o arrendatário está há vinte anos nessa situação e exibe recibos comprovativos de que paga renda há mais de vinte anos, deve ou não entender-se que adquiriu por usucapião a posição de arrendatário? O problema é importante, como se disse, nos arrendamentos para fins comerciais ou para exercício de profissões liberais.

(26) - Acórdão do S.T.J. de 2/XI/66, publicado na Rev. de Legislação e Jurisprudência, ano 100, p. 197 e ss.

(27) - Cfr. Rev. cit., ano 100, p. 202.

Em face do problema, a corrente maioritária da doutrina portuguesa entende que a resposta deve ser negativa (não pode o arrendatário adquirir por usucapião a sua posição) e aquele Acórdão enfileira pacìficamente nessa orientação.

Há, no entanto, um ou outro autor que afirma poder adquirir-se este direito por usucapião - em DIAS MARQUES (28) essa posição é expressamente afirmada; outros autores não a afirmam, mas aqueles que, como OLIVEIRA ASCENSÃO (29), consideram o direito do arrendatário um direito real, certamente que consideram a referida solução virtualmente contida nessa asserção.

Quer, porém, a posição largamente maioritária (negadora dessa possibilidade), quer a posição minoritária (que a admite), resolvem a questão como um corolário da classificação já feita prèviamente. Uns autores já concluíram que se trata de um direito de crédito - logo, não pode

(28) - Cfr. "Prescrição Aquisitiva", Lisboa, 1960, vol. I, p. 220.

(29) - Cfr. ob. cit., p. 374.

ser adquirido por usucapião; outros, que é um direito real - logo, pode.

59 - Cremos não serem fundamentalmente esses os termos em que a questão pode ou deve ser posta.

Através da indagação até agora feita, percorrendo todos os marcos em que a questão pode ter alguma expressão, não chegámos a um resultado inconcusso sobre a natureza jurídica do direito do arrendatário; conseguiu, sim, apurar-se a existência de fortíssimas notas de realidade. Parece, pois, que não se pode optar, no fim do itinerário percorrido, por uma ou outra natureza, em termos tão definitivos, que a questão da usucapibilidade se venha a resolver depois a partir dessa premissa.

Parece-nos dever ser outro o caminho a percorrer.

O art. 1287.º diz que "a posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação: é o que se chama usucapião." Vemos, pois, que a usucapião é reservada para a aquisição da propriedade ou de outros direitos reais de gozo. Não está, contudo, claramente definido se o direito do arrendatário é ou não um direito real de gozo - no plano formal-sistemático, nenhum argumento é decisivo, pois não há nenhum capítulo com a epígrafe "direitos reais de gozo"

Certo, o arrendamento está regulado, não no livro do direito das coisas, mas no dedicado ao direito das obrigações (contratos em especial). Nessa parte do direito das obrigações também estão, no entanto, muitos direitos reais - os direitos reais de garantia estão lá todos e o pacto de preferência com eficácia real ou o contrato-promessa com idêntica eficácia também lá se encontram. O arrendamento está fora da parte do direito das coisas, mas isso também sucede com outros direitos reais.

Do ponto de vista formal-sistemático, nada se colhe. Do ponto de vista das soluções que decorrem dos vários problemas significantes para efeito de qualificação - haver ou não direito de sequela, haver ou não direito de preferência, problema das obrigações do locador, etc. - não nos parece possível chegar a uma conclusão assaz líquida que deva justificar uma pura dedução, donde resulte agora se há ou não usucapião. Aliás, a termos que, em face daqueles problemas e pondo agora de parte este da usucapião, chegar a uma conclusão, inclinar-nos-íamos para a ideia de que se trata de um direito real, sobretudo pela nota da sequela, típica dos direitos reais e exclusiva deles.

Parece-nos que o problema da usucapião deve ser mais um dos problemas a resolver, e de cuja solução nós podemos partir para qualificar o direito do arrendatário como direito real ou não. Mais concretamente: o problema da usucapião não deve ser uma questão a resolver por dedução de uma qualificação prévia como direito real ou como direito obrigacional, mas um ponto que vamos resolver, e de cuja solução iremos depois tirar mais uma achega para o qualificar como direito real ou como direito de crédito.

Isso leva-nos a ter de perguntar qual a justificação, quais as finalidades da usucapião. Porque permite a lei a usucapião como modo de aquisição de certos direitos: os direitos reais de gozo e a propriedade?

Pode indicar-se, desde logo, como fundamentos desta figura a sua função de servir um interesse social na clarificação das situações e na sua estabilização; a usucapião destina-se a pôr o direito de acordo com o facto; há um interesse social em que, ao fim de uma certa permanência de uma situação de facto correspondente a um direito, o facto gere o direito - em que o direito se ponha de harmonia com o facto.

Para além disso, a usucapião serve também o interesse individual da pessoa que adquire. O titular de um direito tem interesse em dispor de uma forma de justificação do seu direito que o dispense de ter, sempre e necessàriamente, de invocar os títulos constitutivos desse direito. A possibilidade de invocar a usucapião dispensará muitas vezes da necessidade de mostrar uma cadeia de transferências e de títulos que conferem a certo indivíduo um determinado direito ou de apresentar um título já antigo que não se encontra. Esta necessidade de demonstração da legitimidade da posição jurídica poderia ser uma "probatio diabolica" e a usucapião vem precisamente resolver esse problema. Se um indivíduo está há mais de vinte anos - ou mesmo menos tempo - na posse de uma coisa, bastar-lhe-á invocar a posse prolongada para justificar o seu direito.

Postas as coisas neste plano, não vemos razão para a usucapião não poder aproveitar ao arrendatário que esteja há mais de vinte anos (cfr. artº. 1296º) na posição correspondente, tal como aproveita ao enfiteuta e ao usufrutuário. Se um indivíduo está há mais de vinte anos na posição de usufrutuário, é pacífico que pode adquirir por usucapião - porque não sucederá o mesmo com o arrendatário?

A solução que sugerimos não traduz uma decidida tomada de posição em sentido afirmativo; a nossa ideia é antes a de equacionar o problema e manifestar uma preferência, uma inclinação, em que não há ainda uma reflexão de-

finitiva sobre a questão. Não repugna,parece-nos, aceitar que o arrendatário possa invocar a situação de posse - da posse da qualidade de arrendatário - para que adquira a posição correspondente. Será algo chocante poder o locador, que durante vinte anos ou mais recebeu as rendas correspondentes ao arrendamento para fins comerciais ou para exercício de profissões liberais,vir invocar a nulidade do contrato para obter a recuperação da coisa e, consequentemente, o despejo do arrendatário.

Enquanto não decorrer esse lapso de tempo,este resultado tem de aceitar-se por uma exigência de forma - o formalismo negocial é imperativo,e o modo de ele ser acatado é, evidentemente, quando não fôr observado, impôr a consequência da nulidade.

Porque não, pois, aceitar efectivamente a ideia de usucapião?

Os argumentos em que se abona a doutrina dominante para excluir a possibilidade de usucapião são frágeis - é, basicamente, a ideia de que o direito do arrendatário é um direito de crédito;mas esta ideia não tem um fundamento convincente, decisivo, antes é esse o "quod est demonstrandum".

E nós já vimos que todas aquelas notas, que seriam aqui decisivas, não conseguem mostrar-nos com muita clareza tratar-se de um direito de crédito.

Na verdade, partindo-se dessa ideia vaga de que não há uma inerência, porque o senhorio tem obrigações, esquece-se a sequela e as outras notas de realidade para se dizer predominantemente ser um direito de crédito.

No comum dos casos a questão acaba por não ser resolvida e faz-se apelo então à intenção do legislador.

A intenção do legislador, porém, tem de ser reconstituída através da unidade do sistema, e essa unidade leva-nos antes a dar relevo à sequela. Não nos interessa a intenção do legislador como pura opção científica; interessa, sim, é o regime jurídico na medida em que ele se pode reconstituir a partir de uma série de soluções várias, e essas levam-nos a admitir que se trata de um direito real, ou, pelo menos,não tornam legítimo o partir-se de uma qualificação diversa para resolver este problema da usucapião. Cremos que este problema deve ser antes significante para a qualificação,sendo esta posterior - isto em boa metodologia.

É a essa luz que equacionamos a questão da usucapião. Não propomos uma solução definitiva, antes pretendemos suscitar uma reflexão. Não nos repugna aceitar a possibilidade de aquisição do direito do arrendatário por usucapião,tal como pode adquirir por esse título o enfi

teuta ou o usufrutuário.

O problema é de grande importância prática - repetimos - nos arrendamentos para fins comerciais ou exercício de profissões liberais, sem escritura pública, que durem há mais de vinte anos (30).

b) DIREITO DE RETENÇÃO

60 - Há uma polémica tradicional acerca da qualificação desta figura como direito real de garantia.

Actualmente a resposta a èsta questão tem de ser afirmativa. Nos termos dos artºs. 758º e 759º, o direito de retenção tem natureza real, é um direito rèal de garantia.

Além de ser uma excepção, uma causa legítima de não cumprimento, atribui ao seu titular um direito real de garantia - a possibilidade de o seu titular se pagar com preferência aos outros credores sobre o valor da coisa retida.

(30) - Numa situação análoga decidiu recentemente a nossa jurisprudência, com fundamento no princípio do abuso do direito, por na espécie concorrerem os seus pressupostos, no sentido de o senhorio não poder reaver o prédio; no caso concreto não tinha, porém, o prazo necessário à invocação da usucapião. Cfr. a sentença do Juiz de Direito do 4º Juízo Cível da Comarca de Lisboa, Dr. Jerónimo Martins e o acordão da Relação de Lisboa que a confirma, in Revista dos Tribunais, ano 88º (1970), pp. 85 e 228 respectivamente.

c) O DIREITO DO DESTINATARIO DE UMA PROPOSTA IRREVOGÁVEL DE ALIENAÇÃO DE UMA COISA.

61 - Focamos aqui o direito do destinatário de uma proposta irrevogável de alienação de um objecto, p. ex., o destinatário de uma carta-proposta ao qual é dada a opção de aceitar ou não a venda de um objecto. É enviada uma proposta irrevogável; o destinatário fica na posição de optar pela aceitação do contrato ou não e, consequentemente, tornar-se o titular do objecto cuja venda lhe é proposta.

Esta posição do destinatário de uma proposta irrevogável de alienação de um objecto será a de titular de um direito real, algo como um direito real de aquisição?

Parece que a resposta tem de ser negativa.

Por um lado, esta posição do destinatário da proposta não outorga um poder direito e imediato sobre a coisa. Por outro lado, o que é mais relevante, esta posição do destinatário - aceitante de uma proposta irrevo

gável de alienação de um objecto não pode efectivar-se face a terceiro que "medio tempore" tenha adquirido a coisa.

A propõe a B vender-lhe um objecto, e a proposta é irrevogável; se, "medio tempore", enquanto o destinatário não manifesta a sua vontade de comprar, o vendedor transfere o objecto para um terceiro, o comprador, ao efectuar a compra, não pode reivindicar o objecto daquele terceiro; esta posição do destinatário da proposta não pode efectivar-se face a terceiro.

Esta posição não consta, aliás, dos direitos sujeitos a registo no Código do Registo Predial.

d) ÓNUS REAIS

62 - Traduz-se esta figura numa situação jurídica cuja manifestação fundamental é o direito de obter uma prestação periódica, geralmente pecuniária, que grava de forma especial e directa um bem imóvel, em termos de o seu titular ser responsável por essa prestação.

A obrigação de efectuar a prestação periódica transfere-se, pois, com as deslocações do imóvel. O titular do imóvel em cada momento é responsável por essa prestação, que destarte adere ao imóvel, o acompanha, grava

sobre ele. Há aqui, assim, uma verdadeira sequela - a transferência do bem importa a transferência da obrigação.

Estas situações conhecidas por ónus reais têm uma certa afinidade com outro tipo de situações já conhecidas, as chamadas obrigações reais ou obrigações "propter rem" ou, ainda, "ob rem".

A distinção entre estas figuras é tradicionalmente feitas nestes termos:

Em ambos os casos, quer nos ónus reais, quer nas obrigações "propter rem", a necessidade de efectuar uma prestação incumbe ao titular de um certo direito real; há em ambos os casos uma ligação indirecta duma obrigação ao seu sujeito passivo, que é determinado através da titularidade de um direito real.

Simplesmente, nas obrigações "propter rem" - p. ex., os deveres que cabem ao proprietário serviente para com o titular do prédio dominante, os deveres entre os vários comproprietários - o adquirente do direito real por inerência do qual surge a obrigação, só é responsável pelas obrigações surgidas para futuro.

Nos ónus reais o titular do prédio gravado com o ónus responde mesmo pelas obrigações já vencidas antes da sua aquisição.

Esta distinção parece que legitimaria a qualificação real dos ónus reais; enquanto as obrigações reais serão claramente direitos de crédito, os ónus reais seriam verdadeiros direitos reais, pois as próprias obrigações já vencidas acompanham o prédio e são exigíveis do novo titular deste.

O que se pode perguntar é se, no fundo, estes direitos reais em que os ónus se traduzem não serão simples direitos reais de garantia, do tipo dos privilégios creditórios imobiliários, ou se serão algo de autónomo.

Parece que não se trata de uma figura autónoma, isto porque o adquirente do prédio sobre o qual grava o ónus responde pelas obrigações anteriores à sua aquisição e também pelas posteriores.

Só que esta responsabilidade processa-se em termos diferentes.

Pelas obrigações anteriores só responde com o prédio, enquanto que pelas obrigações posteriores responde com todos os seus bens, mas o credor das prestações tem um direito de garantia sobre o prédio especialmente onerado.

Afigura-se-nos, pois, não ser isto diferente do que sucede nos privilégios creditórios imobiliários.

Acrescente-se, também, que no ónus real aquilo

que é susceptível de qualificação real não é o dever de efectuar cada uma das prestações - isso são direitos de crédito. O ónus real é a situação global que gera essas várias prestações com o decurso do tempo.

Em conclusão, os ónus reais são direitos reais, mas não parece revestirem autonomia em face dos direitos reais de garantia, dos privilégios creditórios imobiliários.

Cremos que só haveria uma autêntica autonomia para os ónus reais, se o titular do prédio gravado com o ónus respondesse com todos os seus bens e não apenas com o prédio, mesmo pelas dívidas anteriores à aquisição deste. Nessa altura haveria claramente aqui algo de autómomo em relação ao direito real de garantia.

Não sendo assil - como é o regime da maior parte das figuras avulsas da nossa legislação em relação às quais se discute sobre a legitimidade da atribuição da natureza de ónus real -, parece que o ónus real, sendo um direito real, aderindo ao objecto "ut lepra cuti", para empregar uma expressão drástica dos glosadores, apesar de tudo isso, dizíamos, não é um direito real autónomo (31).

---

(31) - Como exemplos de ónus reais, refere a doutrina, v.g., os casos dos artºs. 2018º e 959º, nº 1 "in fine" do Código Civil, da alínea X) do nº 1 do artº. 2º do Código do Registo Predial, etc.

TITULO II

DIREITOS REAIS EM ESPECIAL

CAPÍTULO I

INDICAÇÃO DE SEQUÊNCIA

63 - Após termos exposto sob a epígrafe - Noções Gerais - o conceito de direito real e as características deste - confrontando-as com as dos direitos de crédito, os princípios regulamentadores da sua constituição e vida, a classificação dos direitos reais e termos, por último, referido hipóteses de qualificação real controvertida ou duvidosa, tudo isto visando fornecer algumas noções gerais sobre o objecto da nossa disciplina - os direitos reais - cumpre, agora, ocuparmo-nos dos direitos reais em especial.

Dada a exiguidade de tempo dedicada ao nosso curso, não poderemos ir muito além do estudo das generalidades, mas procuraremos dar uma visão tanto quanto possível completa da posse, do direito de propriedade e suas formas e dos vários direitos reais de gozo: o usufruto

e o uso a habitação, o direito de superfície e as servidões (32).

Começaremos, assim, segundo o esquema traçado, pela posse.

* * *

(32) - Não cuidaremos, portanto, da anfiteuse.

CAPÍTULO II

A POSSE

A - NOÇÃO.

64 - A noção de posse (33) é dada, no nosso sistema jurídico, pelo artº. 1251º C.C. que a define como "... o poder que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real".

65 - Na linguagem corrente a palavra posse é empregada muitas vezes como sinónimo de propriedade. Fala-se assim do possuidor para designar o proprietário, dos "beati possidentes" (os felizes proprietários) empregando uma expressão latina, etc.

Juridicamente, contudo, as duas noções - posse e

(33) - Sobre a posse é clássica na doutrina portuguesa um livro de MANUEL RODRIGUES ("A Posse", 2ª ed., Coimbra, 1940).

propriedade -, diferenciam-se e de tal maneira que a posse pode ou não coincidir com a propriedade.

A posse é admissível em relação a qualquer outro direito real que não a propriedade: pode haver uma posse traduzida na prática de actos correspondentes ao conteúdo, não da propriedade, mas de um outro direito real. Pode, assim, haver uma posse de uma servidão, de um usufruto, etc.

Mesmo, porém, quando nos referimos à posse traduzida na prática de actos correspondentes ao direito de propriedade, o que constitui, aliás, o caso mais comum, ainda aqui posse e propriedade se diferenciam.

Muitas vezes - é certo - a posse coincide com a titularidade do direito de propriedade ou do direito de outro tipo (servidão, usufruto, etc.) a que corresponde. Assim, se, v.g., um proprietário habita o seu prédio é simultâneamente proprietário e possuidor, não tendo, aqui, a posse, por força dessa coincidência, autonomia em relação ao outro direito real (a propriedade).

Da mesma forma, se o proprietário tem o prédio arrendado, e recebe as rendas é, também, o seu possuidor, uma vez que está a fruir ás vantagens económicas da coisa, na espécie, do seu prédio. É certo,que o prédio é habitado pelo locatário, mas este é um possuidor em nome

alheio, pois está pagando as rendas ao proprietário. O que ocorre, aqui, é um exercício de posse mediante um intermediário. O proprietário é, assim, nesta hipótese, um possuidor por intermediário.

Existe, portanto, nestes casos, a reúnião, na mesma pessoa, das qualidades de proprietário e possuidor.

Pode, contudo, não acontecer assim.

Figure-se neste sentido um lavrador, um agricultor, que começa a cultivar para além das estremas do seu terreno, começando, portanto, a cultivar o terreno vizinho e fazendo-o de forma reiterada, sem que, para isso, tenha sido autorizado, afirmando, ainda, o seu intento de se comportar como proprietário, recolhando os frutos,etc. Pois, em hipótese deste tipo, o agricultor referido torna-se possuidor daquele terreno; tem a posse respectiva, mas não a sua propriedade. O proprietário é o dono do prédio, que, por sua vez, não tem a posse correspondente.

Da mesma forma, se alguém acha uma coisa perdida, ou se furta um objecto e o guarda, passando a frui-lo, surge, aí também, uma dissociação entre a qualidade de possuidor e de proprietário. O proprietário é o lesado; este continua a ser proprietário da coisa, mas não seu possuidor.

Se, numa outra hipótese, um indivíduo compra um

objecto a quem não era o seu proprietário, isto porque o alienante não proprietário vende conscientemente uma coisa alheia, ou porque ele próprio - o alienante - a tinha, por sua vez, adquirido por acto nulo. O adquirente não se torna proprietário, dado o princípio segundo o qual "nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet".

Este princípio implica a consequência de o comprador nada adquirir, visto o alienante não possuir nenhum direito.

Não obstante, se a coisa lhe foi entregue, o adquirente, torna-se possuidor dela. Não é, todavia, seu proprietário. Proprietário é o indivíduo cuja coisa foi vendida por outrém; esse, sim, continua a ser o proprietário. Quanto ao adquirente, este, uma vez que a coisa lhe foi entregue, é, apenas, o seu possuidor.

Em todos estes casos, portanto, estamos perante situações de posse que não coincidem com a titularidade do direito real correspondente, uma vez que, neles, há um indivíduo que detém a coisa em seu poder e que, embora se comporte como proprietário em relação á ela, não tem essa qualidade.

B - ELEMENTOS DA POSSE

66 - Na análise de uma situação de posse distinguem-se dois momentos:

I - um elemento material - "corpus" - que se identifica com os actos materiais praticados sobre a coisa com o exercício de certos poderes sobre a coisa;

II - um elemento psicológico - "animus" - que se traduz na intenção de se comportar como titular do direito real correspondente aos actos praticados.

I - Elemento material ("corpus")

67 - O "corpus" pode traduzir-se no exercício de poderes de detenção, ou seja, em guardar a coisa em seu poder, em conservá-la, guardando-a, se é um móvel, ocupando-a, se é um imóvel.

Aliás, note-se a este respeito, costuma acentuar-se que não é necessário um permanente contacto físico com a coisa. Basta que a coisa esteja virtualmente dentro do âmbito do poder de facto do possuidor.

Assim, por exemplo, não deixa de ser possuidor de um automóvel o indivíduo que o deixa estacionado numa rua e se afasta por umas horas ou por um dia. É que, neste caso, embora ele não esteja a ocupar o veículo, este não deixa, por essa circunstância, de estar dentro do poder de facto do seu possuidor.

Pode, também, o "corpus" traduzir-se em actos de fruição ou, até, dos dois tipos - detenção e fruição - conjuntamente.

Pode, assim, não haver pròpriamente uma detenção da coisa - esse contacto físico, real ou virtual, que indicámos -, mas haver uma fruição da coisa mediante a recolha das vantagens económicas desta. Neste caso - por exemplo, o de um indivíduo que recolhe os frutos (vinho, azeitona, etc.) de um prédio rústico ou que recebe as rendas de um prédio -, está o indivíduo que frui o prédio, a possuí-lo.

Nas últimas hipóteses não tem de haver contacto físico com a coisa em nenhuma circunstância, diversamente do que acontece com os actos de detenção que referimos. Nestes - actos de detenção - não tem que haver um contacto com a coisa (o automóvel, no exemplo então, indicado) em todos os momentos, enquanto naqueles - actos de fruição -, esse contacto não tem que se verificar em nenhum momento. Assim, o indivíduo que está a receber as rendas (retomando o exemplo) não tem em nenhum momento contacto com a coisa, estando, porém, na posse desta.

Aliás, a própria lei no artº. 1252º C.C. sugere esta possibilidade, ao falar na posse por intermédio de outrem. É de facto o que se depreende sem esforço do nº 1

do artº citado - o 1252º - ao estatuir que "... a posse tanto pode ser exercida pessoalmente como por intermédio de outrem".

É, assim, uma aplicação deste princípio, o exemplo referido, de se estar a receber as rendas do locatário, que é quem se encontra em contacto físico com a coisa.

Este - o locatário - não é possuidor por se encontrar a possuir em nome de outrém, não se comportando, por isso, em relação à coisa como um proprietário (34).

Da mesma forma possui uma coisa o indivíduo que a faz cultivar por assalariados. Esse indivíduo possui-a, embora através de intermediários (os assalariados por ele contratados).

II - Elemento psicológico ("animus")

68 - O outro elemento da posse é o "animus", que se traduz num elemento de natureza psicológica.

É necessário para haver posse, além desta situação material de exercício de um poder de facto sobre a coisa, a vontade de se comportar como titular do direito correspondente aos actos realizados.

---

(34) - Falta-lhe o "animus", como se verá.

Não basta, assim, esse contacto físico com a coisa - o praticar em relação a ela actos idênticos aos do proprietário, aos do titular de servidão, etc.;é necessário, também, que haja a intenção de se comportar em relação à coisa como titular do direito correspondente.

Não necessàriamente - note-se - um "animus domini", visto que pode haver posse fora da propriedade.Fala-se assim de um "animus possidendi". É que, por exemplo, pode haver posse de um direito de usufruto ou de um direito de servidão, sem que o indivíduo que está na posse destes direitos - usufruto ou servidão - queira comportar-se como proprietário, mas antes, no caso de usufruto, como usufrutuário.

Não tem, portanto, que existir um"animus domini" - este seria só para a posse correspondente à propriedade -, mas apenas um "animus possidendi", ou seja, o intuito de se comportar como o titular do direito correspondente aos actos que se praticam.

Assim, é por falta deste "animus" que, por exemplo, uma pessoa que se senta numa cadeira em casa de outrem, não a possui, pois não tem a intenção de se comportar como proprietário.

Da mesma forma, para indicar um outro exemplo, uma pessoa que em casa de outrem é convidado por esta, bebe uma chávena de café, não é possuidor de chávena que segura, precisamente por falta desse elemento psicológico. O elemento material existe, como se vê, mas falta o elemento psicológico ou seja a intenção de, ao praticar aquele acto, se comportar como proprietário.

É, aliás, uma situação idêntica a que se verifica nas situações de locatário ou de comodatário. Estes não são possuidores por lhes faltar o "animus" correspondente à propriedade, embora pratiquem em relação à coisa actos equivalentes ao conteúdo da propriedade ou,pelo menos,do usufruto. O locatário e o comodatário têm um contacto físico com a coisa, mas por força de um título (o contrato) que é um permanente reconhecimento de que não são proprietários.

Não há, portanto, nos exemplos que acabámos de referir, posse.

III - Necessidade de coexistência do "corpus" e do "animus".

69 - Ora, é necessário para existir a posse que concorram estes dois elementos?

Há duas concepções da posse: uma objectiva e outra subjectiva.

α) Concepção objectiva

70 - Para a concepção objectiva da posse, à qual anda ligado o nome de IHERING - jurista alemão já conhecido -, bastaria para haver posse o elemento objectivo, o "corpus", o elemento material. Existindo este - o elemento material -, existe posse. Assim, no nosso exemplo, tanto o locatário como o comodatário, são possuidores.

β) Concepção subjectiva

71 - Para uma concepção subjectiva à qual anda ligado o nome de SAVIGNI são necessários os dois elementos, uma reunião permanente destes, só existindo, assim, posse, quando existem "animus" e "corpus" conjuntamente.

Daqui resulta - desta concepção subjectivista - que a posse se adquire quando se reunem os dois requisitos - "corpus" e "animus" -, e se perde se se perdem os dois elementos (por exemplo, um indivíduo que vende um objecto e o entrega perde o "corpus" e perde o "animus", logo perde a posse) mas igualmente quando se perde algum deles. É que pode, com efeito, acontecer que se perca só o elemento psicológico ou só o elemento material.

Assim, por exemplo, pode perder-se o elemento material, quando se perde a coisa, ou quando esta é furtada ou ainda usurpada por um terceiro, v.g., quando o

prédio rústico de um indivíduo começa a ser cultivado por outrem, que se arroga a propriedade do prédio. Aqui, o antigo possuidor perdeu a posse, não porque tenha perdido o "animus", uma vez que continua a considerar-se proprietário, mas porque perdeu o "corpus", deixando, portanto, de ter contacto com a coisa.

Pode, também, acontecer que o que se perde seja o elemento psicológico (o "animus"), o que é, aliás, vulgar verificar-se nas situações em que tem lugar o chamado constituto possessório. Nessas situações o proprietário de um prédio vende-o a outrem, mas convencionam simultâneamente, que continua no prédio como locatário. Assim esse indivíduo permanece no prédio, já não como proprietário, uma vez que o vendeu, mas como locatário por força do contrato de arrendamento. Aqui, o ex-proprietário, ora locatário, perdeu o "animus" e, embora continue a manter um contacto físico com a casa ("corpus"), deixa de ser possuidor, porque deixa de a possuir em nome próprio, deixa de se comportar em relação a ela com a convicção ou com a intenção de exercer o direito correspondente aos actos que pratica.

γ) Posição legal

72 - Ora estas duas concepções de posse - a objec

tiva de IHERING e a subjectiva de SAVIGNY -, explicam-se porque cada uma delas parte de uma acentuação prevalente de uma determinada justificação da posse.

Para SAVIGNY o fim e a causa, ou seja, a justificação de uma protecção jurídica da posse era a defesa da paz pública. A posse é protegida porque, se o não fosse, gerar-se-ia a desordem: os possuidores teriam que recorrer à auto-tutela dos seus direitos. Se um possuidor não pudesse, sem mais, recorrer ao tribunal, quando é perturbado ou quando é esbulhado da coisa, se esta situação de facto - a posse - não pudesse ser protegida logo em si, o indivíduo então faria justiça por suas mãos, o que implica a desordem. O indivíduo cuja posse não é protegida, sendo difícil ou pelo menos demorado ir provar que é proprietário, se para defender a posse tivesse sempre que provar aquela qualidade, então defendia-a por suas mãos. Ora não pode aceitar-se a auto-tutela dos direitos, senão em termos limitados.

Para IHERING a razão pela qual todos os sistemas protegem a posse não seria a da protecção da paz pública. É que a posse, para este autor, é o sinal visível ou exterior do direito real correspondente - normalmente a propriedade.

A posse é, digamos, uma guarda-avançada, uma sombra da

propriedade. Compreende-se, portanto, que ela seja protegida desde logo. É certo que assim se protegem alguns não-proprietários (o indivíduo que furta ou que usurpa, por exemplo) mas protegem-se apenas provisòriamente (35). Simplesmente, a maioria estatística dos possuidores é mesmo formada por proprietários das coisas possuídas. Se não se protegesse a simples posse as pessoas teriam que provar o seu direito, o que exigiria, muitas vezes, a prova de uma cadeia ininterrupta de transmissões, e seria, assim, uma prova dificílima ou mesmo impossível - uma "probatio diabolica".

Portanto, à custa de algumas vezes se proteger provisòriamente o usurpador, ou, de qualquer maneira, o indivíduo que não está legìtimamente na posse da coisa, consegue-se um rendimento geral, porque se facilita aos autênticos proprietários, que constituem a maioria dos possuidores, defenderem o seu contacto com a coisa ràpidamente só com base na prova da posse, sem que tenham, portanto, de provar com títulos a propriedade.

Entre nós está acolhida a posição subjectiva.

Dos artºs. 1251º e 1253º C.C. verifica-se que a posse exige o "corpus" e o "animus". Se falta o "animus pos-

(35) - Depois irá discutir-se a propriedade, mas, imediatamente, tem protecção como possuidor.

sidendi", estamos perante uma mera detenção ou posse precária.

A nossa lei, todavia, embora defina a posse e a caracterize em termos correspondentes à concepção subjectiva, acaba por, no fundo, consagrar resultados, ao menos parcialmente, coincidentes com a doutrina objectiva. Por disposições "ad hoc" a nossa lei concedeu a tutela possessória - os chamados meios de defesa da posse - a meros detentores ou possuidores precários. Por exemplo, ao locatário - artº. 1037º, nº 2; ao parceiro pensador - artº. 1125º, nº 2; ao comodatário - art. 1133.º, nº 2; ao depositário - artº. 1188º, nº 2. Embora estes não sejam autênticos possuidores, a lei, por norma avulsa, vem dizer que eles podem valer-se dos meios de defesa da posse que adiante especificaremos.

Não estão, porém, equiparados aos possuidores para todos os efeitos, nomeadamente para efeitos de usucapião. O locatário ou o comodatário, por exemplo, não podem adquirir por usucapião, salvo se houve inversão do título.

Portanto, na nossa legislação, para que exista posse, é necessário que existam simultâneamente o "corpus" e o "animus", embora, como acabámos de ver, a lei acabe por não se afastar muito dos resultados da concepção objectiva - isto, na medida em que, por normas "ad hoc", vai conceder a tutela da posse a vários detentores precários.

O facto de a lei exigir o "corpus" e o "animus" para efeito de haver posse implica que o possuidor tenha de provar a existência dos dois elementos - um material, outro psicológico - para poder, por exemplo, adquirir por usucapião ou lançar mão das acções possessórias.

Ora, esta prova poderá ser muito difícil. Como é que o possuidor prova o "animus"? Pois bem, para lhe facilitar as coisas, a lei estabelece uma presunção. A lei diz que, em caso de dúvida, se presume a posse naquele que exerce o poder de facto.

Daqui decorre que, sendo necessário o "corpus" e o "animus", o exercício daquele faz presumir a existência deste.

C - FUNDAMENTO DA TUTELA JURÍDICA DA POSSE

73 - Ora, pergunta-se seguidamente, qual é o fundamento da tutela jurídica da posse, e a resposta já foi algo avançada nas considerações anteriores.

Na verdade, poderá parecer estranho que o possuidor seja protegido, que a lei proteja, às vezes, contra o autêntico proprietário, o usurpador, ou o indivíduo que

adquiriu sem se ter verificado sequer a transferência da propriedade, por a coisa lhe ter sido vendida por quem não era seu proprietário, ou até proteja quem furtou. A tutela da posse pode, com efeito, conduzir a que este indivíduo seja protegido. É claro que é sempre uma tutela provisória, visto que os meios de tutela da posse- o chamado contencioso possessório - resolvem só de imediato, mas não definitivamente.

I - Defesa da paz pública

74 - Uma das justificações é a defesa da paz pública. A tutela da posse, a tutela desta situação de facto resultante de um indivíduo estar em contacto com as coisas - a detê-las, a explorá-las e a fruí-las -, tem a vantagem de evitar a desordem, de garantir a paz pública por não forçar as pessoas à auto-tutela dos direitos. Se o possuidor de um automóvel não pudesse recorrer aos tribunais para a restituição do veículo no caso de alguém o ter furtado e tivesse que ir demonstrar a propriedade para uma acção destinada a recuperar o objecto, então ele iria buscá-lo por suas mãos.

Assim, a tutela da posse destina-se, desde logo, a impedir a desordem e a anarquia no que toca ao domínio

dos bens.

II - Dificuldade de prova do direito definitivo

75 - Há também essoutra justificação avançada por IHERING para justificar a sua concepção objectiva.

A protecção de posse permite facilitar aos autênticos titulares dos direitos a continuação do exercício dos poderes de facto correspondentes, sem necessidade de estarem a invocar e a provar a existência do seu direito sobre eles. A aparência, a visibilidade exterior, que é o facto de as pessoas estarem a ocupar o prédio ou a comportar-se em face dele como proprietário, leva a que, provisòriamente, sejam tratados como proprietários e, estatìsticamente, são-no na maior parte dos casos. Facilita, assim, a defesa dos titulares dos direitos reais que não têm sempre de os invocar ou de os provar para conseguir que a coisa lhes seja entregue ou sejam mantidos na sua posse. Basta, para isso, provar essa situação de facto, embora, como dissémos, seja uma protecção provisória.

Na verdade, se um indivíduo vem procurar reaver uma coisa, alegando que esta, p. exemplo, lhe foi furtada, o possuidor - até mesmo o autor do furto - pode imediatamente obter uma acção de manutenção da posse, desde

que prove que está na posse dela. Se estiver na posse dela há mais de um ano, basta provar esse facto para que se não discuta mais e ele continue de posse da coisa. O proprietário pode depois ir para o contencioso petitório, isto é, para a acção de reivindicação, demonstrar que a sua propriedade lhe foi furtada e, provado isso, então torna a reaver a coisa. Isto implica, porém, uma indagação mais demorada. Mediante a simples prova da posse, o indivíduo que tinha a coisa em seu poder, obtém que ela seja mantida em seu poder, até contra o verdadeiro proprietário.

Estas hipóteses de protecção possessória do autor de um furto ou de um usurpador são, porém, pouco numerosas. O caso normal é o de o possuidor ser o proprietário. Aqueles casos são, assim, um preço que se paga para que, no comum dos casos, em que as pessoas que estão na posse são os autênticos proprietários, estes possam, mais fàcilmente, e sem serem obrigados a provas difíceis ou mesmo impossíveis de conseguir, defender os seus poderes de facto sobre a coisa.

III - Valor económico da posse

76 - Para além disso, ainda há uma outra razão:

é que a posse, e hoje compreende-se isso melhor do que no passado, é um elemento com importância do ponto de vista da produção e da economia em geral. A posse, a exploração das coisas tem em si um valor económico e repercute aqui a ideia de que interessa mais à economia geral a exploração da coisa do que a propriedade inerte, passiva ou a inacção. A posse só de per si, o facto de uma coisa ser explorada por alguém, é um valor económico, é algo que não só deve ser respeitado em geral pelos outros, como é algo que tem interesse económico.

O interesse económico da posse é, assim, mais uma razão para a posse dever ter alguma protecção, designadamente a protecção traduzida em atribuir-se ao possuidor de boa fé os frutos, etc. Independentemente de tudo o mais, há no interesse económico da posse, uma razão autónoma para a sua protecção.

D- OBJECTO DA POSSE

77 - O que é que pode ser objecto de posse?

Podem ser objecto de posse as coisas que podem ser objecto de propriedade.

Assim, estão excluídas da posse as coisas que estão fora do comércio, v.g., as coisas integradas no do-

mínio público.

O artº. 1267º, nº 1, al. b) sugere-o claramente.

"De jure constituto" parece que estão excluídos os direitos reais de garantia. Pelo menos é o que"a contrario" pode inferir-se do artº. 670º, al. a).

Já, "de jure condendo" não seria impossível admitir a posse nos direitos reais de garantia, pelo menos naqueles que conferem um poder de facto sobre uma coisa, como é o caso do penhor e do direito de retenção.

Já quanto à hipoteca, que não confere um poder de facto sobre a coisa, ou quanto aos privilégios creditórios, não se vê que pudesse haver uma posse.

Mas, "de jure constituto", parece que entre nós os direitos reais de garantia estão excluídos da posse.

Os direitos reais de aquisição estão, também, excluídos da posse. Isto compreende-se pois que estes direitos, v.g., o direito de preferência, são direitos não duradouros. O seu exercício traduz-se num só acto, exercem-se "de um só golpe". Não há aquela situação duradoura que a posse exige. Não se concebe, assim, a posse num direito de preferência. É que este - o direito de preferência - é um direito cujo exercício se não traduz em actos reiterados sobre uma coisa, mas é antes um direito que se exerce de uma só vez, "de um só golpe" se assim

se pode dizer.

Os direitos reais de gozo - esses sim - são susceptíveis de posse. É no seu domínio que se verifica a posse e isto - já o dissémos - não só na propriedade. Também, por exemplo, a servidão ou o usufruto podem ser objecto do direito de posse.

O que significa isto, a posse numa servidão ou num usufruto?

Significa praticarem-se reiteradamente os actos correspondentes ao conteúdo da servidão ou do usufruto. Assim, por exemplo, no caso do usufruto,é fazer seus os frutos.

Quanto ao "corpus",a posse do usufruto não se distinguirá da posse da propriedade; simplesmente, o "animus" é diferente. O indivíduo que está na posse como usufrutuário não se arrogou, não actua com o intento de exercer o direito de propriedade. Como tal ela não o levará, por exemplo, a adquirir a propriedade por usucapião. Pode a posse de um usufruto levar a adquirir um usufruto levar a adquirir um usufruto por usucapião, mas nunca a propriedade, salvo havendo inversão do título (artº. 1265º).

Não pode, todavia, haver posse nas chamadas servidões não aparentes que, adiante, veremos o que signifi-

com.

Di-lo o artº. 1380º C.C. embora com uma excepção, consagrada na segunda parte dessa disposição ao estatuir que não pode haver posse nas servidões aparentes"...salvo quando a posse se funda em título proveniente do proprietário do prédio serviente ou de quem lho transmitiu".

Qual a justificação desta regime de impossibilidade de posse nas servidões aparentes?

É que os actos correspondentes ao conteúdo das servidões não aparentes são normalmente actos de tolerância do proprietário da coisa.

E - CARACTERES DA POSSE

78 - A posse pode apresentar características diversas, características estas relevantes para vários efeitos. Vejamos algumas espécies de posse.

I - Posse titulada e não titulada

79 - Assim, pode, em primeiro lugar, ser titulada ou não titulada, distinção que tem importância para efeitos de usucapião. No verdade a usucapião obedece a prazos diversos, consoante a posse que a fundamenta é titulada ou não titulada.

O que é a posse titulada? - pergunta-se.

Dá resposta a esta pergunta o artº. 1259º C.C., de cujos termos se infere que a posse titulada é a que se funda num modo legítimo de adquirir, ou seja, se funda num modo que segundo o seu tipo geral é idóneo para provocar uma aquisição, independentemente de, no caso concreto, o transmitente ter ou não o direito a transmitir e independentemente da validade substancial do negócio jurídico.

Quer dizer: um negócio, que, por seu tipo geral, é idóneo para transmitir um direito, titula a posse, mesmo que haja um motivo substancial de invalidade, como acontece, por exemplo, no caso de uma venda anulável por incapacidade, por erro, por dolo ou por coacção, ou mesmo que a coisa vendida pertencesse a outrem.

Já - é importante notá-lo -, se faltar no título, no negócio realizado, um requisito formal de validade, a posse é não titulada. Por exemplo, uma venda verbal ou por escrito particular não transfere a propriedade, por ser nula.

Pergunta-se: E a posse do adquirente, se a coisa lhe foi entregue? É titulada ou não titulada?

Pois bem, nos termos do nº 1 do artº. 1259º citado, é não titulada, ou seja, só provoca a usucapião ao fim

de vinte anos, enquanto que, se fosse posse titulada, vigorariam prazos mais curtos.

II - Posse pacífica e posse violenta

80 - O artº. 1261º C.C. fala de posse pacífica, ou seja, aquela que foi adquirida sem violência, a que se contrapõe, como é óbvio, a posse violenta.

Esta distinção - posse violenta - posse não violenta ou pacífica - tem importância para vários fins, nomeadamente para os efeitos do artº. 1297º.

III - Posse pública e posse oculta

81 - Também o artº. 1262º C.C. fala de uma posse pública, ou seja, aquela que se exerce de modo a ser conhecida pelos interessados.

A esta - posse pública - contrapõe-se lògicamente uma posse clandestina ou oculta.

Também esta distinção a que a lei procede, entre posse pública e posse oculta, reveste interesse para efeitos do artº. 1297º.

É que, se a posse foi constituída ocultamente, os prazos para a usucapião só começam a contar-se, nos termos dessa disposição, desde que a posse se torne pública. Assim, por exemplo, um indivíduo furta um objecto e guarda-o. Trata-se de uma posse clandestina, que não conta para a usucapião, enquanto se não tornar pública. O indivíduo furtou o objecto e escondeu-o durante vinte anos - - pois, não o adquire por usucapião, e isto porque a usucapião exige, como dissémos, que a posse se torne pública, se torne conhecida dos interessados.

IV - Posse de boa fé e posse de má fé

82 - Outra distinção é a que se faz entre posse de boa fé e posse de má fé.

São estas - boa fé e má fé - noções já demasiado conhecidas para que seja necessário explicitá-las. Cite-se, porém, a definição de posse de boa fé contida no nº 1 do artº. 1260º C.C.: "A posse diz-se de boa fé, quando o possuidor ignorava, ao adquiri-la, que lesava o direito de outrem" - donde se infere "a contrario sensu" a noção de má fé.

A distinção entre estas duas ideias - a de boa fé e a de má fé - tem importância, v.g., para efeito dos artºs. 1295º e 1296º, sempre, como se constata da leitura dessas disposições, em matéria de prazos de usucapião

- o prazo é mais curto, quando a posse é de boa fé; e mais longo, quando é de má fé. Não só, porém, neste domínio dos prazos: assim, também os direitos do possuidor de boa fé, quanto a frutos e benfeitorias, são diversos dos do possuidor de má fé (cfr. artºs.1270º, 1271º e 1275º).

F - EFEITOS DA POSSE

83 - Segue-se referir os efeitos da posse.

A posse confere ao seu titular uma série de efeitos favoráveis. Pode falar-se, também, aqui de "beati possidentes", embora esta expressão seja normalmente usada para designar as vantagens ou as possibilidades que a propriedade dá aos titulares de muitos bens.

Quais são esses efeitos?

Vamos referi-los de seguida, mas antes cumpre relembrar a justificação ou as razões que explicam certos efeitos favoráveis da posse (36).

Porque é que uma situação de facto, ou seja, a prática reiterada de actos materiais exercida sobre uma coisa com o "animus" de se exercer um direito, é protegida pela lei?

Pois bem, as razões desta solução legal são três,

(36) - V. supra nºs. 74-76

como já referimos. São elas, repitamo-las:

- primo: as vantagens desta tutela possessória aproveitam sobretudo aos titulares autênticos dos direitos reais, visto que, estatìsticamente, quem possui são normalmente os titulares de direitos definitivos sobre as coisas possuídas - as situações em que há um desfasamento entre a posse e a propriedade são minoritárias.

- secundo: esta solução - a de conferir logo certos efeitos favoráveis à posse - é preferível a cairmos na desordem e na auto-tutela de direitos, dado que se não houvesse certa protecção possessória judicial, o indivíduo cuja posse fosse ameaçada, recorreria à auto-defesa; a lei, por isso, para evitar a anarquia que resultaria da auto-tutela dos direitos, liga logo à posse - vista como sinal exterior, visível do direito - certos efeitos favoráveis.

- tertio: há também um interesse geral em que se estabilizem certas situações correspondentes à posse, em que, concretizando, quem esteja, durante muito tempo, a comportar-se em relação à coisa como titular de um direito sobre ela, se torne titular desse direito sobre a coisa; no fundo isto é uma justificação que logo nos faz pensar na usucapião, que é - ela também - um dos efeitos da posse.

Vejamos, então, agora quais são os efeitos da posse (37).

I - Valor probatório da posse

84 - Refere-se a este efeito da posse - o seu valor probatório - o artº 1268º,o qual estatui que a posse confere a presunção da titularidade do direito.

Significa isto presumir-se que, quem está na posse de uma coisa, é titular do direito correspondente aos actos que se praticam sobre ela.

É esta uma presunção - a do artº. 1268º citado - que assenta na experiência - "o quod plerumque accidit" legitima esta opção, esta decisão do legislador que apresenta um grande valor prático.

É que, de facto, pode ser difícil ou impossível provar directamente por uma cadeia ininterrupta de transmissões a titularidade do direito.

Esta presunção significa, portanto, que numa acção de reivindicação - uma acção em que, como já foi dito, se pretende obter a declaração da propriedade e a restituição da coisa ao proprietário -, acção posta pelo proprietário contra o possuidor, este não tem o ónus da prova,cabendo, assim, ao reivindicante esse encargo.

(37) - Além dos efeitos indicados de seguida, pode ter lugar uma indemnização por violação da posse,mesmo se se trata duma mera detenção (cfr. supra, p.190).

Figurando um exemplo: se A está na posse de um bem e B vem a juízo requerer que lhe seja entregue esse bem, porque é seu proprietário, A, pelo facto de estar na posse, não tem o encargo de provar que está legìtimamente na posse ou seja, que é proprietário. Alega, porventura "sou proprietário", mas não tem de o provar, uma vez que beneficia dos critérios de repartição do ónus da prova,que vai caber à outra parte.

Ora, isto - esta presunção legal estabelecida no artº. 1268º - pode ser muito importante, porque pode ser atribuída a propriedade ao possuidor (no nosso exemplo,A) não pròpriamente porque o possuidor conseguiu provar que era proprietário, mas antes porque não foi provado que ele o não era.

Decorre daqui que, numa situação de dúvida, o impasse que esta suscita é superado em termos favoráveis ao possuidor.

É, aliás, esta doutrina que se exprime na velha máxima latina "in pari causa melior est condictio possidentis" (em igualdade de circunstâncias é melhor a posição de possuidor).

II - Direitos do possuidor em relação aos frutos.

85 - Outro efeito da posse é o referente aos direitos do possuidor em relação aos frutos da coisa.

Referem-se a estes direitos os artºs. 1270º a 1272º, tendo relevo aqui a destrinça entre possuidor de boa fé e possuidor de má fé. É que o possuidor de boa fé faz seus os frutos, enquanto que o de má fé deve restituir não só os frutos que a coisa produziu, como tem mesmo de responder pelo valor daqueles que um proprietário diligente poderia ter obtido.

III - Direitos do possuidor relativamente a benfeitorias.

86 - Outro efeito da posse refere-se aos direitos do possuidor relativamente às benfeitorias(38) que haja feito.

Tem relevo, aqui também, a destrinça entre posse de boa fé e de má fé. Ambos os possuidores, quer o de má fé,

(38) - Sobre o conceito legal de benfeitorias e as espécies respectivas (necessárias, úteis e voluptuárias), cfr. o artº. 216º do Código Civil.

quer o de boa fé, estão colocados numa situação de paridade, quanto às benfeitorias necessárias ou úteis. Têm ambos o direito de ser indemnizados das benfeitorias necessárias ou úteis; nestas últimas, a indemnização, segundo as regras do enriquecimento sem causa, só tem lugar se não puderem ser levantadas, sem detrimento da coisa (artº. 1273º).

Já as benfeitorias voluptuárias(não necessárias nem úteis) isto é,as que apenas servem para recreio do benfeitorizante,não aumentando o valor da coisa,estão sujeitas a regime especial. Enquanto o possuidor de boa fé tem direito a levantá-las ou, no caso de isso não ser possível, ao seu valor, o possuidor de má fé perde o valor das benfeitorias voluptuárias que tenha feito (artº 1275º).

IV - Contencioso possessório

87 - Outro efeito relevante da posse é o que se traduz nos respectivos meios de defesa - as chamadas acções possessórias.

A posse confere a possibilidade de vir a juízo requerer determinadas providências, mediante as chamadas acções possessórias. Podemos, assim, falar de um contencioso possessório para designar o conjunto dessas acções,por oposição ao contencioso petitório, representado fundamental-

mente pelas acções destinadas a defender a propriedade e não a posse.

O que são as acções possessórias?

São, genèricamente, acções destinadas a defender a posse contra actos que a ameacem ou que a lesem.

Quais são essas acções?

São a acção de prevenção, a acção de manutenção, as acções de restituição da posse e os embargos de terceiro.

α) Acção de prevenção

88 - A primeira das acções de defesa da posse é a acção de prevenção, referida no artº. 1276º.

A acção de prevenção é uma acção dirigida contra uma ameaça geradora de um justo receio de se ser perturbado ou esbulhado da coisa. A acção de prevenção destina-se, assim, a afastar o perigo de perturbação da posse. Por exemplo: fazem-se obras no terreno vizinho e delas advém o grave receio de vir a ser perturbada a posse sobre o terreno contíguo. Pois bem, numa hipótese deste tipo, o ameaçado pode requerer que o autor da ameaça seja intimado para se abster de lhe fazer agravo, sob pena de multa e responsabilidade pelo prejuízo causado.

É, portanto, uma acção preventiva.

β) Acção de manutenção da posse

89 - Refere-se a este meio de defesa da posse - a acção de manutenção - o artº. 1278º C.C.

É uma acção dirigida contra actos de perturbação ou de agressão à posse, actos determinados por uma pretensão possessória de outrem.

É o que se verifica quando um indivíduo está na posse de uma coisa e alguém vem perturbar essa posse, porque se considera a si próprio legitimado para ter a posse da coisa.

É claro que esta acção de manutenção da posse supõe que o requerente conserva a posse da coisa - só se pode manter algo que se conserva; se já se foi esbulhado, não há lugar a uma acção de manutenção, mas de restituição.

γ) Acção de restituição da posse

90 - O artº. 1278º citado refere-se, também, a este meio de defesa da posse.

A acção de restituição é uma acção que se destina a obter a recuperação da posse, de que se foi privado por esbulho.

Assim, por exemplo, se um indivíduo foi privado da posse da coisa, v.g., um automóvel ou mesmo um imóvel (v. g., um cultivador começa a cultivar o terreno contíguo), o

possuidor, por essa forma privado da posse sobre a coisa, pode recuperá-la mediante a acção da restituição da posse.

Ambas as acções últimamente referidas - a acção de manutenção e a acção de restituição - têm, tanto uma como outra, uma linhagem romana.

Assim, a primeira - acção de manutenção da posse - filia-se num interdito, no "interdictum retinendae possessionis"; a segunda - acção de restituição - no "interdictum re integrandae ou recuperandae possessionis".

Em relação a ambas estas acções - diga-se agora - há uma nota importante a frisar.

É que só é plenamente protegido por essas acções - a de manutenção e a de restituição da posse - o possuidor cuja posse é superior a um ano, ou seja, que detenha a posse chamada de ano e dia. Tal possuidor pode sempre, provada que seja a posse de ano e dia, obter a manutenção da restituição da posse, não sendo admitida a contraparte a provar que tem melhor posse.

A posse de ano e dia confere, por isso, plenamente o direito a essas acções.

Já, se a posse actual durar há menos de um ano, então ela pode soçobrar perante a prova de melhor posse aduzida pela outra parte.

Em que consiste esta prova de melhor posse?

Melhor posse, diz o nº 3 do artº.1278º referido, é "...a que for titulada; na falta de título, a mais antiga; e, se tiverem igual antiguidade, a posse actual".

δ) Acção de restituição no caso de esbulho violento.

91 - Ainda outro meio de defesa da posse é o referido no artº. 1279º, ou seja, a acção de restituição no caso de esbulho violento.

Protege-se aqui o possuidor contra uma privação violenta da posse - um esbulho violento - e esta acção de restituição tem lugar sem audiência do esbulhador. É, assim, concedida sem audiência sequer do esbulhador violento; trata-se de um procedimento cautelar que, como todos os procedimentos cautelares, só se mantém ou seja, não caduca, se a respectiva acção for intentada dentro de um certo prazo ou, mais concretamente, dentro de um prazo de trinta dias, nos termos do artº. 382º do C.Processo Civil.

ε) Embargos de terceiro

92 - Outra acção possessória, outro meio, portanto, de defesa da posse, é a constituída pelos chamados embargos de terceiro, a que se refere o artº. 1285º.

É este um meio de defesa contra uma diligência judi-

cial, por exemplo, a penhora, ordenada pelo tribunal a requerimento de terceiro.

São penhorados bens possuídos por uma pessoa numa execução movida contra outra. O credor A vem executar B (seu devedor) e nomeia à penhora, sendo apreendido, v.g., um aparelho de televisão, que está na posse de outra pessoa (C), mas que o credor entende pertencer a B. Pois o possuidor - C - pode opôr-se à penhora com embargos de terceiro. Não tem, assim, de provar a sua propriedade; basta-lhe provar a posse para fazer cair essa diligência judicial.

Há neste caso uma simples manifestação do valor indiciário ou probatório da posse. A lei confere à posse a qualidade de fundamento suficiente da oposição por embargos de terceiro a uma diligência judicial lesiva da posse(39).

---

(39) - Note-se que, embora o nome possa sugerir o contrário, o facto é que o processo especial regulado no artº. 1044º e segs. do C.P.C., denominado posse ou entrega judicial, e tradicionalmente designado por posse judicial avulsa, não é um meio de defessa da posse.

Apesar de sugerir uma conexão com a tutela possessória, a entrega ou posse judicial nada tem a ver com ela.

A posse ou entrega judicial do artº 1044º do C.P.C. - posse judicial avulsa, na designação tradicional do nosso direito - é um processo especial pelo qual o adquirente de um bem, por força de um acto translativo, pode requerer que ele lhe seja entregue. Assim, por exemplo, o comprador

93 - Ainda dentro desta matéria - meios de defesa da posse - cabe frisar que as acções que enunciámos - acção de prevenção; acção de manutenção; acção de restituição; acção de restituição no caso de esbulho violento e embargos de terceiro - são meios de defesa judicial da posse.

Há também meios de defesa da posse de carácter extra-judicial, como o são, genèricamente, a acção directa e a legítima defesa, meios regulados nos artºs. 336º e 337º.

V - A posse como criadora de direitos

94 - Finalmente, o último efeito da posse é o efeito criador de direitos. A posse gera a aquisição da propriedade por usucapião. Faz adquirir o direito, desde que se mantenha durante certo período de tempo.

Esse período de tempo necessário para a verificação

---

a quem não foi entregue a coisa, exibindo o título, pode requerer a entrega do objecto comprado.

É este - a posse judicial avulsa - um processo especial destinado a permitir com mais facilidade conseguir esse resultado do que se tivesse que se recorrer ao processo comum.

De tudo isto se vê que a entrega judicial não é um meio de defesa da posse, mas, pelo contrário, um meio destinado a obter a posse por parte de alguém que a devia ter, mas não a tem.

da usucapião varia, como já referimos, consoante a posse exercida sobre o objecto, que se pretende adquirir por essa forma de aquisição, tenha sido titulada ou não titulada, de boa ou de má fé, começando o prazo exigido a ser contado apenas a partir do momento em que a posse se tornou pacífica e pública (cfr. artº. 1297º).

Isto porque nem todas as categorias de posse merecem a mesma protecção ou apresentam a estabilidade suficiente para que se lhe possa atribuir, nos mesmos termos, o efeito criador ligado à usucapião(40).

G - NATUREZA JURÍDICA DA POSSE

95 - Cabe referir, agora, o problema da natureza jurídica da posse, problema já conhecido.

Pois pode dizer-se que a posse não é um mero facto - tem mais relevo do que um facto; o seu regime revela ser a posse um verdadeiro direito - um direito real provisório, como já dissemos.

É um direito, porque a posse é uma situação jurídica

(40) - A posse de má fé conduz à aquisição por usucapião de imóveis ao fim de vinte anos, não havendo registo de título nem de mera posse; ao fim de quinze anos, havendo título de aquisição e registo deste e ao fim de dez anos, se houver apenas registo da mera posse.

No caso de boa fé os prazos são mais curtos, o mesmo sucedendo quanto aos móveis, haja ou não boa fé.

subjectiva que confere um poder sobre uma coisa em face de todos os outros - daí que seja um direito real -, situação negociável, hereditável, susceptível de registo e que pode ser defendida, como vimos, por meios jurídicos. Está, portanto, dotada de garantia jurídica.

É um direito real provisório, porque esta protecção só se mantém, ou melhor, cessa, não havendo anteriormente usucapião, perante a acção de reivindicação.

É, assim, a posse um direito real provisório, designação mais rigorosa do que a afirmação de estarmos perante uma simples aparência de direito, perante um "fumus boni juris".

Parece - sim - que haverá um direito, mas um direito especial: um direito real provisório.

* * *

CAPÍTULO III

A PROPRIEDADE

SUBCAPÍTULO I

A PROPRIEDADE EM GERAL

A - CONTROVÉRSIA ENTRE A PROPRIEDADE INDIVIDUAL E A PROPRIEDADE COMUNITÁRIA

96 - O direito de propriedade é o molde jurídico onde se vaza o poder humano de usar, de gozar, ou de dispôr dos bens de forma plena.

Conferindo, portanto, poderes plenos e, em princípio, ilimitados sobre as riquezas, constituindo o instrumento, por excelência, da realização de poderes sobre os bens, concebe-se que, a seu respeito, se tenham desenvolvido, ao longo da história, as mais veementes controvérsias, quantas vezes apaixonadas.

Está no centro desses debates, pelo menos no momento actual, o problema da sua titularidade, do princípio da sua titularidade - individual ou comunitária (colectiva).

Mas a polémica também se manifesta noutros pontos. Dentro das mesmas coordenadas de opção, a controvérsia abrange os poderes do titular - seja a propriedade colectiva ou individual, quais devem ser os seus poderes? - a questão de saber quais são os objectos que devem estar apropriados por uma ou outra forma, etc.

O problema, posto nestes termos, é um problema que transcende o quadro puramente jurídico. É vivificado por considerações de carácter político-ideológico, económico, social, cultural etc.

Toda esta controvérsia é conhecida.

Nas hostes desfavoráveis à apropriação privada das coisas ou, pelo menos, à sua transmissão hereditária, divisamos uma longa coorte de pensadores, filósofos, sociólogos, economistas, etc.

Assim, exprimiram, por exemplo, as suas críticas severas à propriedade privada, manifestando-se a favor de formas comunitárias ou colectivas de apropriação, pensadores da Antiguidade, como PLATÃO ou os ESSÉNIOS; moralistas políticos do Renascimento, como o THOMAS MORUS de "Utopia"ou o CAMPANELLA de "A Cidade do Sol", revolucionários de 89,

como BABEUF ou um SAINT-JUST do célebre moto "Il ne faut ni riches ni pauvres"; os chamados socialistas utópicos, como o PROUDHON do célebre ensaio "Qu'est-ce que la propriété" e da não menos célebre resposta "La propriété, c'est le vol" ou, entre nós, e dentro da mesma linha dos socialistas utópicos, o OLIVEIRA MARTINS ou o ANTERO DE QUENTAL, do período das conferências do Casino, os chamados socialistas científicos como MARX, ENGELS e seus seguidores.

A lista dos defensores da propriedade privada,aliás com grandes divergências acerca do conceito,é balizada no curso da história, por filósofos como ARISTÓTELES,S.TOMÁS DE AQUINO, por economistas liberais, a quem os juristas ou, melhor, os políticos, muitas vezes pedem argumentos a favor da propriedade individual, como, por exemplo, JEAN-BAPTISTE SAY, pondo em relevo, predominantemente, o papel da propriedade privada como estimulante económico contra o desperdício e contra a preguiça, ou um STUART MILL, mais "nuancé", não acentuando tanto o aspecto do estímulo económico, mas antes as vantagens morais da propriedade (seria uma fonte de aperfeiçoamento moral, uma garantia moral), a Igreja Católica através, nomeadamente, das figuras de LEÃO XIII, PIO XI ou PIO XII, para referir alguns papas que em suas encíclicas e mensagens tocaram o

ponto, pronunciando-se a favor do princípio da propriedade privada mesmo dos meios de produção – a propriedade capitalista –, embora acentuando e pondo em relevo as exigências e as limitações derivadas do bem comum.

São também conhecidos os argumentos que se produzem de um lado e do outro.

Assim, por um lado, como méritos da propriedade individual, argumenta-se com o estímulo económico por ela representado e o seu valor como garantia de liberdade individual ou familiar.

Contestam-se, no lado oposto, estes argumentos, ligando-se à supressão ou à limitação da propriedade uma autêntica liberdade, e pondo-se em evidência – como resultados funestos e lamentáveis da propriedade privada – a anarquia económica(a que se deveria opôr a planificação) a exploração do homem pelo homem, as desigualdades artificiais, etc.

Limitamo-nos a mencionar em termos gerais e sumários as posições sobejamente conhecidas, e as mais diversas, que entraram nesta controvérsia; cremos susceptível de uma abordagem mais objectiva, não a controvérsia, mas sim a fenoménica da realidade tal como ela se nos vem apresentando nos sistemas existentes ao longo da história, e, mesmo no nosso actual momento histórico, entre sistemas

orientados por coordenadas diversas.

B – FENOMENOLOGIA DA PROPRIEDADE AO LONGO DA HISTÓRIA E NO MOMENTO ACTUAL (41)

97 – Quanto às formas primitivas de apropriação, sobretudo da terra, bem jurídico fundamental numa sociedade primitiva, os historiadores e sociólogos referem frequentemente a tese da anterioridade da propriedade colectiva sobre a propriedade individual.

Podemos referir a este propósito LAVELEYE(42) que, na sua obra de investigação histórica, nos traça um esquema, segundo o qual se passou da comunidade de clã para a comunidade de aldeia(acompanhando a transição do nomadismo do homem para a vida sedentária), da propriedade de aldeia para a propriedade familiar e desta para a propriedade individual.

Embora dentro de uma perspectiva diversa, mas aproximadamente no sentido desta tese, é o ponto de vista de

---

(41) – Para um maior desenvolvimento deste ponto e das suas inserções sociológicas, culturais e económicas, cfr., p. ex., ORLANDO DE CARVALHO, ob. cit., pp. 11-60 e CARBONNIER, ob. cit., nºs. 27 e 28.

(42) – Cfr. LAVELEYE, "De la Propriété Privée et de ses Formes Primitives", 1891, 4ª ed..

ENGELS - "A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado" - e poderemos citar, também, já no séc. XVIII, SAINT-SIMON e sua escola.

Entre nós este fenómeno da propriedade colectiva originária tem ainda actualmente certas reminiscências(43); através delas conseguiu chegar até aos nossos dias uma forma de apropriação colectiva dos bens fundamentais para aquele tipo de economia - a terra, o gado, os utensílios agrícolas.

Esta tese e este esquema de evolução suscitam opositores. Poderemos referir FUSTEL DE COULANGES, autor da "Cidade Antiga", que se limita a partir da comunidade doméstica, não da propriedade de clã nem da de aldeia. Considera como originária a comunidade doméstica, e daí passa para a propriedade individual.

A informação sobre esta matéria é sempre fragmentária e algo conjectural, sobretudo se pretendermos uma solução geral. Duas coisas parecem, porém, inegáveis - nas sociedades arcaicas, se é possível falar em termos gerais, há um menor sentido do "tenho" (a distinção entre "o meu" e "o teu") do que nas sociedades posteriores; e, em relação com isto, há um âmbito mais amplo de apropriação colectiva dos diversos bens nessas sociedades - a terra, os utensílios, as armas, os próprios frutos do trabalho.

(43) - Referimo-nos às comunidades agro-pastoris de Vilarinho das Furnas, Rio de Onor e Tourém.

98 - Passando para períodos posteriores, vamos encontrar na Roma clássica a norma-tipo da propriedade individual, mas há vestígios que permitem indiciar, também, a existência de uma propriedade colectiva da "gens", não talvez do estado romano (não existente na altura), e uma propriedade familiar. De qualquer forma, a propriedade individual aparece em dada altura (período clássico) em Roma atribuída ao chefe da família na qualidade de "pater familias", que sobre ela tem um poder absoluto.

Já tal não sucede nos povos germânicos, onde se encontra a propriedade dentro de uma manifestação de colectivismo até muito mais tarde, acentuada esta nota pelo carácter nómada destes povos (44).

A propriedade romana aparece-nos, pois, no período clássico como o "dominium ex jure quiritium", uma "plena in re potestas", mais tarde definida na célebre qualificação tripartida de poderes - "ius utendi, ius fruendi, ius

(44) - Para muitos autores que traçavam a evolução da comunidade de clã para a de aldeia e desta para a propriedade de aldeia, a primeira dessas etapas é normalmente indiciária da passagem do nomadismo à vida sedentária.

abutendi" -, e esse é o modelo; todas as outras formas de propriedade existentes nessa altura (a propriedade pretória, a propriedade provincial, a propriedade dos peregrinos) vão desembocando no esquema da propriedade individual.

99 - Com o feudalismo medieval operou-se como que um fraccionamento do domínio. A "plena in re potestas" fracciona-se num "dominium directum" que pertence ao senhor e num "dominium utile" que pertence ao vassalo. É a época da grande difusão do modelo enfitêutico, do tipo da enfitause. Por um lado, o "dominium directum" do proprietário, melhor dizendo, do senhor; e dizemos senhor e não proprietário, porque o titular do domínio directo está quase desprovido dos poderes do proprietário - tem é o poder de exigir prestações, tem certos privilégios, pode exigir serviços ao vassalo, recebe prestações periódicas ou não periódicas, geralmente onerosas, numerosas e muito variadas (rendas, lutuosas, laudémios, foros, prestações de serviços), não tem contacto directo com a coisa, não a cultiva, não tem uma actuação produtiva com ela, como que se limita a receber tributos sobre ela. Por outro, o vassalo, que é a quem de facto cabe uma utilização real da terra.

100 - Com o desenvolvimento do comércio surgiu a classe burguesa, inicialmente ambulante (os "colporteurs"),

que cresceu e se tornou poderosa; e durante todo o séc. XVIII vai multiplicando os seus ataques ao regime feudal de propriedade, que não era um molde adequado aos interesses que essa classe de comerciantes burgueses segregara no plano social.

Em 14 de Julho de 1789 o povo de Paris ataca e destrói uma velha fortaleza, conhecida pela Bastilha e esse episódio passou a ser desde então um símbolo da superação do absolutismo real e da estrutura feudal da propriedade. Com efeito, na sequência dos acontecimentos revolucionários na noite de 4 de Agosto de 1789, foi votado o princípio "L'Assemblée Nationale détruit entièrement la féodalité" e posteriormente executado.

As concepções e o regime feudal da propriedade são destruídos apesar de a vitória de todos esses movimentos revolucionários subsequentes a 1789 ter pertencido aos moderados (os girondinos) e não aos radicais (os jacobinos). Apesar disso, dizíamos, houve uma verdadeira superação da estrutura feudal da propriedade e o que vem a resultar desse processo é a superação de todos os encargos, prestações e privilégios do senhor sobre a terra, donde vai sair uma terra livre e alodial, sem encargos, conferida a um proprietário com plenos e absolutos poderes.

Vem a reconstituir-se, assim, por coincidência, o

"dominium" quiritário, a "plena in re potestas" do direito romano clássico, por ser essa a forma correspondente aos interesses do grupo social que é o motor dessas transformações (a burguesia), sobretudo depois de se ter instalado na posição de domínio social, encarnando a vitória dos elementos moderados. Na verdade, a propriedade privada, eliminados os elementos mais avançados, vem a ser definida como um direito absoluto, "inviolável e sagrado".

Este movimento verificou-se também entre nós, logo, mas sem seguimento, em 1820 na primeira revolução liberal e posteriormente, numa forma definitiva, com a legislação de MOUZINHO DA SILVEIRA em 1834 - a extinção dos dízimos, das rendas feudais, a apropriação dos bens das ordens eclesiásticas que depois são vendidos livres e alodiais, desamortizados, sobre os quais se vai constituir uma propriedade plena; a própria extinção dos morgadios é uma desvinculação da terra.

Todo este movimento se dirige à implantação da propriedade livre e individual, coincidente com a clássica "plena in re potestas" romana, cujas fórmulas servem aos interesses do grupo social dominante e o princípio da plena propriedade privada mantém-se até hoje. Os países de sistema económico capitalista têm na sua base, toda a sua estrutura assenta sobre a propriedade privada. É claro que

se multiplicaram as restrições de direito público ao direito de propriedade individual.

Num sistema caracterizado pela apropriação individual dos meios de produção os poderes do proprietário pleno não são os mesmos que existiam no séc. XIX; há toda uma série de limitações inspiradas por razões de interesse público. Mas, em princípio, é este o esquema que vigora.

Sobretudo no domínio das ideias filosóficas e político-sociais acentua-se cada vez mais a função social e os interesses do bem comum, à luz dos quais se perspectiva o direito de propriedade individual. Em princípio, porém, é a propriedade individualista que constitui a pedra angular dos Direitos Reais num sistema de tipo capitalista, sem que aquelas limitações ultrapassem muitas vezes o plano de meros tópicos vagos e genéricos.

101 - Uma superação deste princípio é constituída pelos sistemas de tipo socialista, em que os moldes e o conteúdo correspondente são totalmente diferentes.

Genèricamente, não há um monolitismo do sistema; há desvios de interpretação da teoria económica marxista, diferenças de evolução em relação aos objectivos programados, características locais e experiências próprias que levam à existência de diferenças entre esses sistemas.

Como nota comum a todos eles, a base da organização económica, após a nacionalização do solo e das empresas, é a propriedade sobre os bens por parte do Estado ou das cooperativas.

Esquemàticamente, pode dizer-se haver três categorias de propriedade no seio das sociedades socialistas.

- Há, desde logo, uma propriedade estadual, mais desenvolvida nalguns países socialistas do que noutros (mais na U.R.S.S. do que nos outros, sobretudo mais do que na Jugoslávia, onde aliás é vista mais como propriedade do povo, da sociedade do que do Estado). A propriedade socialista de Estado ou propriedade estadual tende a abranger o solo, o sub-solo, as minas, os transportes, as empresas agrícolas, industriais, comerciais e o crédito.

- Ao lado desta propriedade estadual existe um outro tipo de propriedade: a propriedade cooperativa. Esta abrange propriedades e empresas agrícolas, industriais ou comerciais, mas manifesta-se sobretudo no sector agrícola.

A extensão da propriedade cooperativa é variável. Há países, como a Jugoslávia, em que é ela o elemento básico do sistema. Na verdade, o sistema económico jugoslavo caracteriza-se por assentar na propriedade de comunidades menores (cooperativas, ou mesmo autarquias locais), enquanto noutros sistemas se dá prevalência à propriedade estadual. A propriedade das cooperativas na União Soviética é designada por "kolkhozes", por oposição às explorações agrícolas do Estado "sovkhozes" (45).

- Há ainda uma propriedade pessoal, pertença dos particulares. Só que esta propriedade não é designada, na linguagem jurídica, por propriedade privada, mas sim - como dissemos - pessoal, tendo na verdade fundamentos filosóficos e económicos e um regime jurídico diverso do da propriedade privada capitalista.

Trata-se de uma propriedade destinada a satisfazer as necessidades materiais ou culturais da pessoa e que não pode originar proventos que não resultem do trabalho. Não é uma propriedade geradora de lucros sem trabalho, instrumento de rendimentos, mas uma propriedade que se pretende à medida das necessidades da pessoa. Está vinculada ao escopo sócio-económico para que foi constituída e perde pro-

---

(45) - Esta propriedade das cooperativas populares constitui, conjuntamente com a propriedade estadual e, eventualmente, com a de outras organizações sociais (sindicatos, organizações de juventude, Cruz Vermelha, etc.), a categoria da chamada propriedade socialista, à qual acrescem, no seio dos países socialistas europeus, a propriedade pessoal e até - como fenómeno transitório e residual - uma propriedade privada de índole capitalista.

tecção jurídica, se, em concreto, vai contra o seu destino sócio-económico.

A propriedade pessoal tem igualmente uma extensão variável conforme os países. Num esquema genérico, que se arriscará a não coincidir em todos os países, abrangerá os produtos do trabalho (salários ou remuneração em espécie), os produtos da poupança, os objectos de consumo instantâneo ou mesmo duradouro (electro-domésticos, automóvel, objectos de uso e comodidade doméstica), a casa de habitação e terreno respectivo, bem como a possibilidade de uma residência de férias (46).

A propriedade é, pois, de âmbito variável, na medida em que o próprio progresso económico levará ao alargamento dos tipos de bens que ela possa abranger.

O crescimento da produção social acarreta um aumento da propriedade pessoal pois esta resulta das deduções para fins de investimento operadas no produto total do trabalho colectivo. É que o produto total do trabalho, em re-

---

(46) - Na Hungria - e damos este exemplo para mostrar o âmbito variável da propriedade pessoal - não há limite fixo para a propriedade pessoal de casas de habitação. Estas, porém, de acordo com o escopo sócio-económico a que estão vinculadas, têm de ser habitadas pelo próprio, têm de satisfazer necessidades pessoais do proprietário, não podendo ser lançadas num mercado de habitação.

gime socialista, é um produto social.

Deste produto social, uma parte é destinada a substituir os meios de produção, assim como ao desenvolvimento da produção e ainda à criação de um fundo de reserva.

Feitas estas deduções, a parte restante do produto total é destinada ao consumo.

Este produto destinado aos consumidores, antes de lhes ser entregue, é ainda objecto de reduções destinadas às despesas de administração, às necessidades comuns, às pessoas incapazes de trabalhar; só o remanescente é então distribuído aos indivíduos para ocorrerem às suas despesas pessoais, repartição feita segundo o princípio socialista: a cada um segundo a quantidade e a qualidade do seu trabalho.

É sobre esta parte que lhe é distribuída, que o trabalhador adquire um direito de propriedade pessoal que surge, por esta construção, como uma consequência natural da propriedade socialista de Estado ou Cooperativa, que constituem tanto a fonte material de propriedade pessoal como a sua garantia.

Decorre dessa interligação de causa e efeito entre essas duas categorias da propriedade - a pessoal e a socialista - que um desenvolvimento da produção social acarreta um aumento da propriedade pessoal.

*

Em alguns dos Estados socialistas existe também uma propriedade privada do tipo capitalista, perfeitamente igual à dos países com sistema económico capitalista. Estamos em presença de um fenómeno contraditório com o sistema socialista, apresentado sempre como transitório e residual, como algo que, abrangendo sectores de escasso significado económico, se mantem ou pode manter por razões de oportunidade. Nalguns países socialistas quase nem existirá já, noutros existirá ainda correspondendo a uma dada etapa da evolução do sistema. Mesmo onde exista, nunca diz respeito senão a sectores menos importantes, a sectores marginais da vida económica, e sempre revestindo, por princípio, natureza transitória; será algo para desaparecer, logo que atingidos os objectivos de determinada fase(47)-(48).

---

(47) - A inclusão de um bem numa determinada categoria ou forma de propriedade não resulta das suas características intrínsecas, mas da relação social no seio da qual se encontra. Por exemplo, uma máquina de costura pode ser objecto da propriedade estadual, cooperativa, pessoal ou privada, consoante a relação de que é objecto. Já, por exemplo, bem se compreenderá que uma locomotiva, dada a sua natureza e a regulamentação jurídica dos transportes, não pode senão ser objecto da propriedade estadual.

(48) - Cfr. para concretas precisões sobre as diferentes categorias da propriedade em sistema socialista os textos copiografados das sessões de estudos da "Faculté International pour l'Enseignement du Droit Comparé", de Estrasburgo, da autoria, por exemplo, de KNAPP, JONASCO, etc.

Passámos assim em relvo o espectro, necessàriamente genérico, da propriedade tal como ela se revela na ordem dos fenómenos, quer ao longo da história, quer na contemporaneidade em sistemas inspirados por princípios divergentes e que neste problema têm uma das suas linhas divisórias fundamentais.

C - CARACTERÍSTICAS DO DIREITO DE PROPRIEDADE NO NOSSO SISTEMA

102 - O Código Civil português não define o direito de propriedade, mas o artº. 1305º caracteriza-o, dizendo que "o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela impostas".

Esta definição parece transferida de um código inspirado por princípios individualistas extremos. Não repercute aqui, directamente, nenhuma ideia ligada à função social da propriedade, nem lá se contém uma cláusula geral, embora vaga, donde pudesse derivar uma limitação; o que não implica que, no conjunto do sistema, não haja possibilidade de nos socorrermos de cláusulas limi-

tativas. Aparece-nos, logo, o abuso de direito no artº. 334º, que, de alguma forma, pode repercutir-se aqui. Visto isoladamente, o artigo correspondente no Código de Seabra (artº. 2167º) parece menos secamente absoluto do que este, definindo o direito de propriedade como "... a faculdade, que o homem tem, de aplicar à conservação da sua existência, e ao melhoramento da sua condição, tudo quanto para esse fim legìtimamente adquiriu, e de que, portanto, pode dispor livremente" - uma definição nimbada de certo espírito humanista e filosófico, demonstrando embora um certo individualismo, mas humanista, uma certa funcionalização humanista correspondente à perspectiva do autor do Código.

Estruturalmente, à face do actual Código, o proprietário detém os poderes correspondentes ao seu direito de um modo pleno e exclusivo, gozando de plenos poderes, apenas com os limites da lei. Não implica isto, no entanto, que o sistema não contenha globalmente cláusulas de limitação a esses poderes, como dissemos.

103 - Como notas que dessa definição se possam inferir para caracterizar a propriedade, diremos em primeiro lugar que o proprietário tem poderes indeterminados. Em face disso é legítimo dizer-se que a base é o "ius uten-

di, fruendi e abutendi"; é o direito de propriedade em termos individualistas; não se limitam os poderes do proprietário senão através das concretas restrições pela lei impostas. Há uma indeterminação na delimitação dos poderes, ao contrário dos de um usufrutuário ou dos do titular de um outro direito real limitado que são apenas aqueles especificamente atribuídos na lei. No direito de propriedade, o titular tem, em princípio, todos os poderes.

104 - Como segunda nota, poderemos dizer que o direito de propriedade é elástico, é dotado de uma certa elasticidade, de uma força expansiva - extinto um direito real que limite a coisa (a propriedade da coisa), reconstitui-se a plenitude da propriedade sobre ela; não fica vago o somatório dos poderes que se extinguiram, correspondentes ao direito que findou. O proprietário limitado recupera a plenitude do seu direito de propriedade.

105 - A terceira característica a referir será a sua qualificação como um direito perpétuo, o que imediatamente implica não poder extinguir-se pelo não uso. Costuma dizer-se a este respeito que, não usar a propriedade, é ainda uma forma de a usar; o proprietário tem tais poderes que pode querer estar inactivo, e esta possibilidade

cabe dentro do conteúdo do seu direito.

Embora na nossa legislação ordinária esta faculdade de estar inactivo não sofra restrições, constata-se, à face de cláusulas gerais contidas na Constituição (cfr. artº 35º), que este regime não é forçoso para certas categorias de bens, atenta a sua produtividade potencial. À luz da função social da propriedade compreende-se mal esta possibilidade de inactividade na exploração da coisa.

Além deste significado, o princípio da perpetuidade implica também a não existência de propriedade temporária, nos termos do nº 2 do artº. 1307º, a não ser "nos casos especialmente previstos na lei". Exemplos destas excepções encontramo-los no caso do fiduciário nos fideicomissos, no caso da propriedade do superficiário - fiduciário, isto é, do titular do direito de superfície, quando se tenha estipulado no título constitutivo que, ao fim de algum tempo, a propriedade reverte para o dono do solo; também há propriedade temporária na propriedade resolúvel (de alguma forma na venda a retro ou num negócio translativo da propriedade sob condição resolutiva) e, também, na venda com reserva de propriedade.

106 - A propriedade pode abranger bens incorpóreos ou imateriais.

Do artº. 1303º infere-se que a chamada propriedade intelectual - pelo menos a propriedade industrial, ressalvada a diferença do objecto, substancialmente é tratada como autêntica propriedade.

107 - Os modos de aquisição da propriedade estão referidos nos artºs. 1316º e ss. - contrato, sucessão por morte, usucapião; e merecem aqui uma referência especial duas formas de aquisição originária que são a ocupação, e a acessão.

A ocupação é regulada nos artºs. 1318º e ss. Certas categorias de bens referidos na lei, e em certas circunstâncias que variam consoante o tipo de bens de que se trata - os animais bravios no caso da caça e da pesca, os animais ferozes fugidos, os enxames de abelhas, os animais e as coisas móveis perdidas, os tesouros - são passíveis de ocupação, mas variando as condições da sua efectivação, conforme o preceituado nos artigos correspondentes a cada uma das categorias de objectos.

A acessão é regulada nos artºs. 1325º e ss.; tem lugar "...quando com a coisa que é propriedade de alguém se une e incorpora outra coisa que lhe não pertencia". Pode ser uma acessão natural, por exemplo, por aluvião (os proprietários dos prédios confinantes com uma corrente de

água adquirem aquilo que neles foi depositado);e pode ser uma acessão industrial, mobiliária ou imobiliária, quando se dá por acto do homem; já anteriormente referimos este ponto (49).

108 - A propriedade, como direito que é, está dotada de garantia jurídica. A sua violação dá direito a indemnização. Está, também, dotada de uma defesa específica.

Essa defesa pode ser extrajudicial - por acção directa ou legítima defesa - actuando como em qualquer outro direito (não há aqui nenhum regime especial), tal como se pode defender a vida ou a integridade física através desses meios extrajudiciais.

Dentro dos meios judiciais, avulta como manifestação por excelência de defesa da propriedade a acção de reivindicação. Esta acção é exercida pelo proprietário não possuidor contra o detentor ou possuidor não proprietário da coisa - só pode utilizá-la o proprietário que não está na posse contra o possuidor não proprietário. Estamos aqui em face da acção petitória ou de reivindicação.

Mas pode exitir também uma acção negatória - o proprietário que está na posse da coisa exerce essa acção para que seja repelida a pretensão de outrém como proprietário dessa coisa. Destina-se, portanto, a fazer negar um

(49) - Cfr. supra nº 27, pág. 86.

outro direito real sobre a coisa, arrogado por outrem, exercido ou não em termos de perturbar o gozo da coisa.

109 - A lei regula seguidamente em capítulos subsequentes várias formas de propriedade - a propriedade de imóveis, a propriedade das águas, a compropriedade e a propriedade horizontal.

* * *

SUBCAPÍTULO II

PROPRIEDADE DE IMÓVEIS

A - CONTEÚDO

110 - A propriedade de imóveis é regulada nos arts. 1344º e ss.

Esta figura abrange o imóvel, rústico ou urbano, o espaço aéreo correspondente à sua superfície, bem como o subsolo ou tudo o que nele se contém e não esteja desintegrado do domínio por lei ou negócio jurídico. Esta ressalva entende-se porque há, na Constituição, normas (50) que integram no domínio público certas riquezas subterrâneas (jazigos minerais, águas minero-medicinais, etc.). Esses bens não pertencem ao proprietário do terreno, porque in-

---

(50) - Constituição Política da República Portuguesa - artº. 49º.

tegrados no domínio público; embora o proprietário tenha uma posição especial relativamente a esses bens - preferência na concessão, se tiver capacidade económica para isso, ou um direito a receber uma prestação - não é proprietário directo deles. Outras coisas que não estejam expressamente integradas no domínio público, por exemplo, um tesouro, são já pertença do proprietário do subsolo ou do espaço aéreo (dentro das limitações legais).

O nº 2 do artº. 1344º limita em certos termos os poderes do proprietário - "o proprietário não pode, todavia, proibir os actos de terceiro que, pela altura ou profundidade a que têm lugar, não haja interesse em impedir". Todos os dias as companhias de navegação aérea violam os limites dos prédios, mas é um acto que o proprietário não tem interesse em impedir.

111 - Como nota importante, refira-se que a propriedade dos imóveis é uma propriedade que existe sempre, não há "res nullius" imóveis. Se um móvel pode ser uma "res nullius", pode perder-se a propriedade sobre ele por abandono, um imóvel não fica vacante por se ter abandonado o direito sobre ele; uma vez que o artº. 1345º preceitua que "as coisas imóveis sem dono conhecido consideram-se património do Estado", não pode haver ocupação de "res nullius"

imóveis.

112 - A propriedade de imóveis confere certos direitos específicos gerados pela natureza desses bens - o direito de demarcação, de tapagem, de construção, de plantação de arbustos, etc. Estes poderes indeterminados obtidos pelo proprietário têm limitações, que indicaremos seguidamente.

B - LIMITAÇÕES AOS PODERES DO PROPRIETÁRIO

I - Restrições de direito público

113 - Consta este tipo de restrições de legislação avulsa e numerosa. Exemplificativamente: não se pode impedir que sejam colocados postes para passagem de linhas eléctricas de alta tensão, de linhas telegráficas, telefónicas, etc; há restrições quanto ao direito de construção, por motivos de defesa militar nas zonas de servidão militar, por motivos de higiene e salubridade, por razões históricas e artísticas, etc; a possibilidade de expropriação e de requisição referidas na Constituição (51) e no Código Civil (artºs. 1308º e 1309º), etc.

---

(51) - Constituição Política, artº. 49º, nº 8, § 1º in fine.

II - Restrições de interesse particular (52)

114 - Estão, fundamentalmente, reguladas no Código Civil, e normalmente derivam das relações de vizinhança. Por haver proximidade ou contiguidade entre prédios, o proprietário não é livre de fazer tudo aquilo que se compreenderia num ilimitado" "ius utendi , abutendi e fruendi"; têm de estabelecer-se restrições derivadas da necessidade de coexistência.

Vejamos algumas destas restrições de interesse particular.

- O artº. 1346º proibe a emissão de fumos, fuligem, vapores, cheiros, calor, ruídos, trepidações que importem prejuízo substancial para uso do imóvel ou que não resultem de uma utilização normal do prédio donde emanam (53)(54)

---

(52) - Cfr., sobre este ponto, os desenvolvimentos de H.MESQUITA, ob. cit., pp. 141-176.

(53) - Este preceito parece aplicar-se a quaisquer vizinhos e não apenas ao vizinho contíguo; caso contrário cairíamos num literalismo excessivo. Literalmente, aliás, vizinho tanto é o prédio contíguo como qualquer prédio próximo; parece-nos que a "ratio" do preceito leva a estendê-lo mesmo aos proprietários não contíguos.

(54) - Ainda dentro dos últimos anos de vigência do Código de Seabra discutiu-se entre nós uma questão curiosa. O proprietário de uma clínica pretendia que se declarasse que um vizinho era obrigado a não ter uma capoeira onde existiam numerosas aves, cujos ruídos prejudicavam a clínica. O S.T.J. entendeu, porém, que não havia o direito de impedir o proprietário de ter ali instaladas as aves que quizesse. Hoje, com fundamento no C.C., poder-se-ia impedir tal facto, especialmente neste caso de uma clínica - - "...ruídos que importem um prejuízo substancial para o uso do imóvel..."; isto partindo do princípio que a existência da clínica é anterior à do aviário no prédio vizinho.

- O artº. 1347º proscreve as instalações prejudiciais; o artº. 1348º refere-se às escavações, preceituando que não se pode escavar no próprio terreno em termos de provocar riscos de desmoronamento do terreno contíguo.

- O artº. 1349º impõe uma restrição importante - a obrigação de dar passagem forçada momentânea. O proprietário de um terreno é obrigado a conceder passagem momentanea, se um vizinho precisar, por exemplo, para reparar um edifício, de colocar um andaime ou uma escada para reparar uma parede; tem de tolerar a passagem momentânea para esse fim, ou, como se diz no nº 2, para que alguém possa ir buscar uma coisa sua que acidentalmente nele se encontre, por exemplo, um animal que para lá foge, uma coisa que lá caiu.

Note-se que não se está aqui em face de qualquer servidão; não é uma servidão que se constitui, mas sòmente uma passagem momentânea, embora forçada.

- O artº. 1351º preceitua que "os prédios inferiores estão sujeitos a receber as águas que, naturalmente e sem obra do homem, decorrem dos prédios superiores, assim como a terra e entulhos que elas arrastam na sua corrente". Quando exista um terreno inclinado, o proprietário da parte inferior não pode instalar um dique contra o qual a água de torrente natural ou da chuva, fique retida; isso prejudicaria o proprietário do terreno superior e constitui assim uma limitação ao direito daquele.

- Os artºs. 1357º e 1359º tratam do direito de tapagem. No caso de se tapar com valas ou regueiras é necessário deixar uma "...mota externa de largura igual à profundidade da vala...", para que as águas não inundem.

Para a tapagem com sebes vivas também são formuladas restrições.

- O artº. 1360º, nºs. 1 e 2 impõe restrições importantes na prática, quer sobre a abertura de janelas, portas ou obras semelhantes (é necessário deixar um intervalo de metro e meio em relação ao prédio vizinho), quer para as varandas, terraços e eirados, (em princípio têm de estar a mais de um metro e meio quando sejam servidos de parapeitos de altura inferior a metro e meio, mas já podem estar na própria linha divisória se tiverem um parapeito superior a essa altura).

Já não se aplicam estas restrições nos prédios que estejam dentro da situação prevista pelo artº. 1361º (prédios separados por estrada, caminho, rua ou travessa).

Estas restrições não se aplicam às frestas, seteiras ou óculos para luz e ar ou janelas gradadas, nos termos do artº. 1363º.

Focámos o regime geral; não se exclui que se possa constituir uma servidão de vistas por acordo ou por usucapião (constrói-se uma janela, o proprietário vizinho não se opõe, ao fim de determinado número de anos - artºs. 1293º e ss. - pode constituir-se uma servidão de vistas e a pessoa não pode ser obrigada a tapar a janela).

- O artº. 1365º - "o proprietário deve edificar de modo que a beira do telhado ou outra cobertura não goteje sobre o prédio vizinho ..." - refere o problema dos beirais. Deve deixar-se, na construção, um intervalo mínimo de cinco decímetros entre o prédio e a beira se de outro modo não puder evitá-lo.

Pode também constituir-se aqui uma servidão - de estilicídio - por usucapião ou por acordo.

- O artº. 1366º permite a plantação de árvores e arbustos até à linha divisória dos prédios, sendo no entanto lícito ao dono do prédio vizinho cortar ou arrancar as raízes, os troncos e os ramos que se introduzam no seu

terreno, se o dono do prédio, rogado judicial ou extrajudicialmente, o não fizer dentro de três dias.

- Uma restrição importante na prática é a prevista nos artºs. 1370º e ss. relativa às paredes e muros de meação - a concessão do direito de comunhão forçada no muro ou parede.

Estas construções podem ser feitas por acordo, pagando cada um dos proprietários metade do muro e do terreno. Ou pode suceder que, no exercício do direito de tapagem, o proprietário mure o seu terreno sem acordo do vizinho, mas fá-lo no seu terreno, e inteiramente à sua custa; nesta hipótese, o proprietário confinante, se quizer, pode adquirir metade do muro, pagando metade do terreno e metade da construção. Há sempre a possibilidade de tornar comuns os muros ou paredes feitos na divisória. É um direito potestativo - o proprietário construtor como que é expropriado, há aqui uma expropriação forçada de metade do muro no interesse do proprietário confinante.

115 - Estas são as limitações gerais à propriedade derivadas das relações de vizinhança que em princípio existem, mas que podem extinguir-se por negócio jurídico - - as partes podem constituir uma servidão (de estilicídio, de vistas, uma servidão inominada, etc.).

Como exemplo de servidão inominada pode citar-se o caso de ramadas inclinadas sobre um terreno vizinho; em princípio não podem estar assim, mas pode constituir-se "ex contractu" uma servidão e então o dono do prédio adquire o direito de essas árvores, ou todas as do seu prédio, poderem invadir o prédio vizinho com as suas raízes ou os seus ramos, desaparecendo estas limitações pelo acordo constitutivo de uma servidão.

116 - Segue-se no Código a matéria da propriedade das águas, que tem um regime especial em função das características do seu objecto - artºs. 1385º e ss.

Há logo uma distinção fundamental entre águas públicas e privadas. Ao direito civil caberia apenas estudar o regime das águas particulares e dos direitos adquiridos por particulares sobre águas públicas.

Dadas as limitações de tempo que ao presente Curso necessàriamente se impõem, e por que consideramos esta matéria de menos importância geral em relação às restantes, apenas referiremos elementos de informação sobre esta matéria (55).

---

(55) - Cfr., anteriormente ao Código Civil, PIRES DE LIMA - Lições de Direitos Reais, cits.; e, posteriormente, H. MESQUITA - ob. cit.

SUBCAPÍTULO III

COMPROPRIEDADE

A - NOÇÃO

117 - A lei regula a compropriedade como um Capítulo dentro do título referente ao estudo da propriedade.

A figura da compropriedade ou propriedade em comum apresenta-se-nos "...quando duas ou mais pessoas são simultâneamente titulares do direito de propriedade sobre a mesma coisa", noção que consta do artº. 1403º.

As disposições legais que contém o regime da compropriedade são aplicáveis, com as necessárias adaptações, à comunhão de quaisquer outros direitos, segundo o artº 1404º. Efectivamente, a compropriedade como um direito de propriedade não é mais do que uma manifestação particular de um fenómeno que pode ter lugar em relação a outros di-

reitos - pode haver uma comunhão numa servidão ou num usufruto, como pode até haver uma situação de comunhão em relação a um direito de crédito (a comunhão numa parte social - por exemplo, por herança, os dois ou três descendentes de um indivíduo subentram na titularidade da sua quota social numa sociedade por quotas e ficam numa situação de comunhão).

Esta aplicação das regras da compropriedade à comunhão de quaisquer outros direitos tem importância, designadamente para efeitos de direito de preferência. Também se verifica em relação à situação de comunhão, por exemplo, de uma quota social, aquele mesmo direito de preferência que tem lugar na compropriedade, ou seja, na comunhão na titularidade de um direito de propriedade; qualquer dos contitulares de uma quota social tem preferência na alienação que o outro faça da sua parte ideal nessa quota.

B - DISTINÇÃO DA SOCIEDADE

118 - Pode haver, por vezes, uma certa dificuldade em distinguir a situação de comunhão ou de compropriedade da situação correspondente à sociedade, e o problema põe-se fundamentalmente em relação à sociedade civil, porque

esta, segundo o entendimento divulgado não tem personalidade jurídica. Se estamos perante uma sociedade personalizada, não há dificuldades, estamos face a uma pessoa jurídica autónoma; mas quando não estamos perante uma sociedade personalizada, v.g., mera sociedade civil, a situação distingue-se da comunhão ou da compropriedade ou identifica-se com ela?

O problema é importante, porque há certas diferenças entre o regime da compropriedade e o regime da sociedade.

Assim, em matéria de uso da coisa comum, a norma constante do artº. 1406º, diverge da norma sobre o uso das coisas sociais contida no artº. 989º.

A sociedade tem, nos termos do artº. 1007º, certas causas de dissolução que não se confundem com o direito de exigir a divisão (forma de pôr termo à compropriedade, segundo o artº. 1412º).

Tem cabimento perguntar-se como poderemos saber se estamos perante uma compropriedade ou uma sociedade.

Parece que o critério preferível é o resultante da definição da sociedade, dada no artº. 980º - a sociedade supõe uma actividade económica que não seja de mera fruição, a sociedade pressupõe uma actividade dirigida a potenciar os rendimentos da coisa, dirigida não apenas a

fruir os rendimentos que a coisa dá, mas também a actuar sobre ela potenciando a sua produtividade ou rentabilidade.

Esta distinção torna-se por vezes difícil na prática, e há que recorrer aos usos e à maneira normal de fruir uma coisa ou de a explorar em ordem a aumentar os seus lucros; saber quando estamos perante uma situação ou perante outra depende da vida.

Parece, no entanto, ser este o critério que nos leva a distinguir entre a compropriedade e a sociedade não personalizada, como é a civil, ou outro tipo de sociedade não personalizada em que haja um fundo comum.

Por vezes há certas formas de sociedade em que nao há um fundo patrimonial comum, põem-se em comum apenas serviços, mas o que normalmente acontece é as pessoas porem em comum um património e serviços.

Nessas situações em que há um fundo comum de bens é que tem cabimento a pergunta - sociedade ou compropriedade? E o critério parece ser este: compropriedade, se é uma actividade de mera fruição; sociedade, se se trata de uma actividade económica que não seja apenas de mera fruição.

C - NATUREZA JURÍDICA

119 - O problema da natureza jurídica da compropriedade é, esquemàticamente, passível de três soluções:

a) uma doutrina tradicional, perfilhada entre outros por MANUEL RODRIGUES, segundo a qual a compropriedade resulta da coexistência dos direitos de cada um dos consócios sobre uma quota ideal ou intelectual do objecto da compropriedade; cada um dos comproprietários tem direito a uma fracção, uma quota ideal não especificada do objecto;

b) segundo um outro ponto de vista, não se trataria da coexistência de direitos incidindo cada um deles sobre uma quota ideal, mas tratar-se-ia da coexistência de vários direitos de propriedade sobre todo o objecto, direitos esses que se limitavam recìprocamente; a compropriedade seria um feixe de direitos de propriedade verdadeiros e absolutos sobre todo um objecto mas que, como têm em comum o mesmo objecto, se autolimitam na mesma medida em que também há limitações de propriedade por outros direitos reais; aqui haveria várias propriedades sobre o mesmo objecto, limitadas por outras propriedades com idêntico objecto;

c) uma terceira posição entende que estamos perante um só direito, um único direito com vários titulares (56).

(56) - Cfr. H.MESQUITA, ob.cit., p. 246.

Para a primeira posição haveria vários direitos sobre fracções ideais do objecto, na segunda teríamos vários direitos sobre todo o objecto, para a última tratar-se-ia de um só direito com vários sujeitos.

120 - A construção que nos parece traduzir com mais exactidão a realidade correspondente, embora não isenta de dificuldades, será a ideia tradicional - cada um dos comproprietários tem direito a uma quota ideal ou intelectual do objecto da compropriedade.

Por um lado, parece-nos ser essa a construção que fornece o melhor enquadramento para a possibilidade que cada um dos consortes tem de alienar a sua quota ideal e para a possibilidade que também cada um tem de requerer a divisão da coisa comum, quando o quiser.

Tudo isto supõe que cada um dos comproprietários tem um direito autónomo, que não há apenas um direito para todos, mas cada um deles tem um direito próprio sobre uma quota ideal.

Por outro, há também pontos de apoio literais ou formais, no teor dos preceitos reguladores deste instituto, que nos permitem perfilhá-la. Além de ser ela o enquadramento mais harmónico para as soluções indicadas - - artºs. 1408º e 1412º que referem a possibilidade de cada consorte alienar a sua quota e pedir a divisão da coisa comum -, tem pontos de apoio literais e formais no nº 2 do artº. 1403º, no nº 1 do artº. 1406º, no artº. 1405º, etc.

O facto de cada um dos consortes ter certos poderes de uso e de administração sobre toda a coisa no seu conjunto não parece contrariar esta concepção; ela não encontra um obstáculo lógico e insuperável no facto de cada um dos consortes ter um poder de uso sobre toda a coisa, pois, embora sendo um direito de propriedade sobre uma quota ideal, é um direito de propriedade que não incide sobre parte especificada, potencialmente abrange toda a coisa.

As outras posições não podem com coerência exprimir certos aspectos do regime da compropriedade.

121 - A segunda posição, defendida por LUIS PINTO COELHO, choca com a ideia de não se poder conceber mais de um direito de propriedade sobre a mesma coisa; a propriedade, por definição, é um direito absoluto que opõe o seu titular a todos os outros. Há um ilogismo na ideia da possibilidade de vários direitos de propriedade plena sobre o mesmo objecto na sua totalidade.

122 - A outra posição, que a concebe como um só direito com vários titulares, não dá expressão às diferen -

ças do regime entre a compropriedade e a chamada comunhão de mão comum ou património colectivo - aqui, sim, há um só direito com vários titulares porque não se pode pedir a indivisão dada a afectação especial do património a um fim específico, nem pode cada um dos contitulares alienar uma quota do objecto (por exemplo, na comunhão conjugal, nenhum dos cônjuges pode alienar uma quota do património conjugal ou pedir a divisão deste, enquanto durar a vida conjugal).

No património colectivo há, pois, um só direito com vários titulares, não podendo nenhum deles isoladamente fazer nada; na compropriedade não se passam assim as coisas - cada um dos contitulares tem certa liberdade para agir isoladamente, quanto à sua fracção do objecto - porque estamos em face de vários direitos, cada um pertencente ao seu titular, que incidirão sobre toda a coisa, mas sobre parte não especificada dela, sobre uma quota ideal, uma fracção da coisa.

123 - Parece-nos, em resumo, que a doutrina tradicional fornece um enquadramento mais harmonioso do que as posições ulteriores para as soluções que se apresentam insertas no regime da compropriedade, não se produzindo contra ela nenhum argumento decisivo.

Nem cremos que seja decisivo contra ela dizer-se que o direito a uma quota ideal contradiz qualquer princípio constitucional dos direitos reais.

Sabemos que um desses princípios é o de que os direitos reais têm de incidir sobre coisa determinada; mas ali a coisa está determinada, é uma quota ideal daquele objecto, que, potencialmente, incide sobre todo ele, mas que não é exactamente um direito sobre todo o objecto - - é um direito sobre uma fracção daquele objecto.

Isto parece oferecer um grau de suficiente determinação para os fins em que ela - a necessidade de determinação - tem relevo no domínio dos direitos reais, designadamente para determinar quando é que há uma lesão do direito ou para resolver o problema do risco. É uma quota ideal de todo o objecto, daquele que está determinado. Não surge, assim, o obstáculo que se ergue quanto a um eventual direito de propriedade sobre coisas genéricas, direito que seria absurdo. Um direito sobre uma quota ideal de um objecto determinado parece, porém, corresponder às exigências suficientes de determinação do objecto dos direitos reais.

D - REGIME JURÍDICO

124 - Pode perguntar-se de seguida qual seja o re-

gime jurídico da compropriedade.

O problema principal que aqui se põe é o de saber quais são as possibilidades de ser praticado um acto sobre a coisa comum, isoladamente, por um comproprietário ou por um grupo de consortes que não represente a totalidade destes.

Quanto à possibilidade que todos têm de, por unanimidade, praticar quaisquer actos sobre a coisa, ela é evidente - não constitui problema. Todos em conjunto, exercem os poderes que correspondem aos do proprietário singular - di-lo o artº. 1405º.

Mas, separadamente, ou por grupos parcelares, quais são os poderes dos comproprietários?

Há actos que podem ser praticados isoladamente por um comproprietário; outros há que exigem o acordo da maioria dos comproprietários; e outros implicam a unanimidade dos consortes.

Concretizemos.

125 - I - Actos que podem ser praticados isoladamente por um dos consortes - cada consorte pode, nos termos do artº. 1406º, usar a coisa comum na falta de acordo sobre o seu uso, "...contanto que a não empregue para fim diferente daquele a que a coisa se destina e não prive os outros consortes do uso a que igualmente têm direito" Não havendo, portanto, acordo entre os consortes quanto ao uso da coisa, cada um deles a pode usar dentro dos limites legais.

E pode também cada um deles, nos termos do artº. 1408º, dispor de toda a sua quota na comunhão, ou de parte dela (por venda, doação, dação em pagamento, etc.). E, podendo dispor, pode também onerar a sua quota, v.g., dá-la em hipoteca, o que está, aliás, previsto na lei(artº. 689º nº 1: "é também susceptível de hipoteca a quota de coisa ou direito comum"). Isoladamente, pode dispor ou onerar, pelo menos nos termos da hipoteca, a coisa comum. Já no penhor teria de haver uma entrega ao credor pignoratício.

Não pode isoladamente alienar ou onerar uma parte especificada da coisa comum, visto que não tem direito a uma parte concreta, individualizada, enquanto não se proceder à divisão, mas apenas a uma parte ideal. Se o fizer, o nº 2 do artº. 1408º manda aplicar ao acto as normas sobre a disposição ou oneração de coisa alheia(artº. 892º e ss.); o seu acto é equiparado à disposição de coisa alheia porque a coisa não é inteiramente sua.

A forma de alienação da sua quota ideal é a forma exigida para a disposição da coisa, segundo o nº 3 do artº

1408º; a venda pelo comproprietário, por exemplo, de meta de de um imóvel exige escritura pública, tal como se exige para a venda do imóvel.

Pode ainda isoladamente, nos termos do nº 2 do artº 1405º, cada um dos consortes reivindicar de terceiro a coisa comum sem que se lhe possa opor que ela lhe não pertence por inteiro. Cada comproprietário pode exercer a acção de reivindicação da coisa comum em relação a terceiro que a possua indevidamente.

Um ponto que tem conexão com esta matéria é o seguinte: quando há uma disposição da quota ideal por um dos comproprietários a um estranho - não a outro comproprietário - têm lugar os pressupostos do exercício do direito de preferência. Nos termos dos artºs. 1409º e 1410º os outros comproprietários têm preferência e têm o primeiro lugar entre os preferentes legais no caso de venda ou dação em cumprimento a estranhos da quota de qualquer dos seus consortes.

Entende-se que já não há preferência no caso de troca, pois aqui, como não há um preço, mas sim um outro objecto que se recebe, não se poderia saber bem qual o valor em causa. Na venda, representa a mesma coisa para o vendedor receber o preço do terceiro ou do comproprietário; no caso da troca ele quer receber por aquele objecto, como correspectivo, um outro objecto, e o comproprietário não lhe poderá dar um objecto precisamente igual ao que lhe daria terceiro.

E também não há preferência em relação à doação; e isto muitas vezes origina simulações para através delas se frustrarem direitos de preferência que poderiam ser exercidos no caso de venda.

126 - II - Actos que podem e devem ser praticados pela maioria - nos termos do artº. 1407º, que remete para o artº. 985º , é esse o regime a que está submetida a administração da coisa - prática de actos de conservação e de normal frutificação -, não já o seu uso. Este artigo, integrado no regime do contrato de sociedade, prescreve que, pertencendo a administração a todos os sócios ou apenas a alguns deles, não havendo convenção, todos podem administrar, tendo portanto poderes iguais. Pode, contudo, haver convenção no sentido de que só alguns deles possam administrar.

Quando a administração pertença a todos ou a alguns, qualquer dos administradores tem o direito de se opor ao acto que outro pretenda realizar; cabe depois à maioria decidir sobre o valor da oposição; isto acaba por significar que é a maioria que decide, quando há contestação sobre um

acto de administração. Para os efeitos do artº. 1407º, a maioria tem de ser, não numérica ou pessoal, mas do valor das quotas, é necessário que ela represente pelo menos metade do valor total das quotas. Parece que tem de ser a maioria do artº. 985º (maioria pessoal), mais a maioria do valor total das quotas.

Em conexão com este ponto da administração da coisa está o problema dos encargos que têm de suportar-se com as benfeitorias necessárias feitas para conservar o objecto. Esses encargos impendem sobre todos os comproprietários da coisa na proporção das respectivas quotas; é uma obrigação "ob rem", inerente ao seu direito.

Cada um dos comproprietários só pode eximir-se deste encargo se renunciar ao seu direito, nos termos do artº. 1411º. No caso de alienar para terceiro, continua responsável pelos encargos. Se renunciar, quem adquire a quota são os outros comproprietários; a lei vê, no fundo, nesta aquisição da quota pelos outros, uma espécie de compensação para o encargo acrescido que eles têm nas despesas de conservação ou nas benfeitorias necessárias.

127 - III - Actos que exigem, para serem praticados, a unanimidade dos comproprietários - nos termos do artº. 1408º, a disposição de toda a coisa ou de parte especificada da coisa exige o consentimento de todos os consortes ou comproprietários.

Não se pode vender, doar, trocar, toda a coisa ou parte especificada dela sem o consentimento de todos os consortes; aqui não basta, pois, a maioria.

E o mesmo se aplica, nos termos do artº. 1024º nº 2, ao arrendamento de prédio indiviso. O arrendamento de uma coisa comum exige o consentimento de todos os comproprietários. Só que a lei, neste caso, se contenta com uma manifestação posterior do seu assentimento. Pode suceder que, no momento do acto, algum dos comproprietários não possa dar o seu acordo, mas pode vir a dá-lo posteriormente e o acto considera-se válido.

Se a lei exige escritura pública para o arrendamento, v.g., o arrendamento para fins comerciais ou para profissão liberal, é necessário que o consentimento de todos, consentimento simultâneo ou posterior, conste da forma exigida pela lei, sem o que o acto não é válido.

E - EXTINÇÃO DA COMPROPRIEDADE

128 - Como se extingue a compropriedade?

Pode extinguir-se por via negocial - cada um dos

comproprietários pode adquirir as quotas de quaisquer dos outros ou de todos.

Como forma de extinção especial pode citar-se a referida nos artºs. 1412º e 1413º - extinção por força da divisão da coisa comum. Qualquer dos consortes pode, a todo o tempo, requerer a divisão da coisa comum; ninguém é obrigado a permanecer na indivisão.

Pode, às vezes, haver interesse em clausular-se que, durante certo número de anos, nenhum dos proprietários possa pedir a divisão. A lei admite essas cláusulas de indivisão, mas limita a sua validade a cinco anos; é lícito pactuar-se a renúncia por cinco anos ao direito de pedir a divisão. Isto, dado o princípio da aplicação das regras da compropriedade à comunhão dos outros direitos, também se aplica, v.g., a uma quota social - os contitulares de uma quota social ou de um lote de acções podem pô-los em comunhão e pactuar que, durante cinco anos, ninguém pede a divisão.

Estamos aqui perante uma excepção ao princípio geral consagrado no nº 1 do artº. 1412º de que ninguém é obrigado a permanecer na indivisão, mas uma excepção prevista na lei e derivada de um acto de vontade dos próprios que autolimitaram este seu poder.

Se for pactuada uma indivisão por mais de cinco a-

nos, teremos uma cláusula que vai contra a lei e é nula. O problema que pode surgir aqui é o da redução dos negócios jurídicos, que se resolve nos termos gerais da teoria geral do negócio jurídico.

Para valer em relação a terceiros, esta cláusula de indivisão tem de estar registada, nos termos do nº 3 do artº. 1412º. Se estipulam a cláusula de indivisão, não a registam, e um dos comproprietários vende a sua quota, o terceiro adquire-a vàlidamente.

A divisão amigável da coisa comum, que não é feita em processo judicial, equivalente portanto à partilha extra-judicial, tem de ser feita obedecendo aos requisitos de forma que a lei exige para a alienação onerosa da coisa. Quer dizer, só se pode dividir, por exemplo, um prédio rústico, por escritura pública, tal como ela seria exigida para a alienação do prédio.

* * *

SUBCAPÍTULO IV

PROPRIEDADE HORIZONTAL

A - REFERENCIA HISTORICA E DETERMINANTES DO INSTITUTO.

129 - A propriedade horizontal é um instituto que, ao contrário do que talvez corresponda à primeira impressão das pessoas, está longe de ser uma figura moderna, de ser um fenómeno do nosso tempo.

Há manifestações de que ela existiu já em períodos mais recuados, embora parecesse ter caído em declínio a partir do último século e mesmo durante o actual, correspondendo esse declínio, talvez, à pujança que revestiu o direito de propriedade plena e absoluta sobre as coisas no seu conjunto e ao facto de não se verificarem com acuidade as necessidades determinantes da sua existência.

Sobretudo, foi depois da II Guerra Mundial, nos paí-

sos que conheceram esse flagelo com intensidade e noutros que o não conheceram, mas onde se registaram carências semelhantes na construção, que ela teve grande incremento.

Entre nós as Ordenações Filipinas contêm manifestações de um fenómeno deste tipo - referenciavam a hipótese de a um indivíduo pertencer o sobrado e a outro o sótão.

Passou a ser regulamentada, entre nós, pela primeira vez, de uma forma sistemática pelo Dec.-Lei 40.333 de 14/10/1955, e agora encontra-se regulada no Código Civil - artº. 1414º e ss.

130 - As causas do incremento desta figura são bem conhecidas. Corresponde a necessidades actuais, sobretudo nas grandes cidades. Facilita o acesso à propriedade de poupanças que não teriam essa possibilidade a não ser nestes termos e permite solucionar problemas de necessidade de construção e alojamento.

O legislador quis criar uma fórmula tendente a potenciar a construção, através da colocação em comum das pequenas economias, e resolver simultâneamente problemas de espaço que levam a dar preferência ao crescimento vertical dos meios populacionais, mas que importam um aumento do custo da construção e, consequentemente, uma maior dificuldade de um só indivíduo ser titular de toda a obra; surge, assim, a conveniência de os edifícios serem seccionados em parcelas determinadas e especificadas pertencentes a várias pessoas.

B - NOÇÃO E DOMÍNIO DE APLICAÇÃO

131 - A propriedade horizontal é, destarte, a propriedade que incide sobre as várias fracções componentes de um edifício, fracções essas que devem estar em condições de constituirem unidades independentes.

É um regime de propriedade, não sobre um edifício na sua estrutura unitária, mas sobre fracções do mesmo edifício que constituam unidades independentes.

A noção é dada no artº. 1414º e o seu objecto é caracterizado no artº. 1415º - "só podem ser objecto de propriedade horizontal as fracções autónomas que, além de constituírem unidades independentes, sejam distintas e isoladas entre si, com saída própria para uma parte comum do prédio ou para a via pública".

É necessário portanto que se trate de fracções privativas, mas existindo instalações comuns ou serviços de utilização comum.

132 - A lei chama-lhe propriedade horizontal. Não diz nada sobre este ponto, mas é claro que pode ser uma propriedade vertical em vez de ser horizontal. Isto é, o seccionamento pode ser segundo uma linha vertical e não segundo uma linha horizontal.

Ao falar de propriedade horizontal, a lei tem em vista o caso comum em que um indivíduo é proprietário de um andar. Fala-se, umas vezes, em propriedade por andares, outras vezes por apartamentos, mas a expressão propriedade por andares pode não ser rigorosa, se existe mais que uma unidade no mesmo andar atribuído a proprietários diversos.

Pode, no entanto, haver um seccionamento em sentido vertical, de tal maneira que pertença um lado a um proprietário e outro a proprietário diferente. Figuremos um prédio de um só piso, em que pode verificar-se uma hipótese deste tipo. Pode, também, ser um prédio com mais de um andar sujeito a este regime de seccionamento vertical, e o lado esquerdo pertencer a um indivíduo e o lado direito a outro, cada um dos lados constituíndo uma só unidade.

O que é necessário para podermos falar da figura da propriedade horizontal, é que as unidades obtidas por seccionamento vertical, tendo autonomia, todavia não sejam tão autónomas que deixem de ser interdependentes.

A propriedade horizontal supõe que não há autonomia estrutural das várias fracções, na medida em que fazem parte do mesmo objecto unitário, e que funcionalmente haja utilização de coisas comuns - escadas, ascensores, canalizações, etc.

Se, segundo o seccionamento vertical, cada uma das partes é absolutamente autónoma, se não há coisas comuns, então, não há propriedade horizontal, o que existe são duas propriedades contíguas.

O problema do seccionamento vertical, em termos de continuar a ser aplicável o regime da propriedade horizontal, só tem lugar quando continuam a existir partes comuns; se esse seccionamento se faz, mas cada uma das partes obtidas tem absoluta autonomia, sem existência de partes comuns, então não há propriedade horizontal. Estaremos perante coisas totalmente independentes sem aquela interdependência que, apesar da necessária autonomia, tem de existir na propriedade horizontal.

C - NATUREZA JURÍDICA

133 - Focamos o problema da determinação da natureza jurídica da propriedade horizontal.

Parece que nos encontramos, no concernente a esta

figura, perante uma situação de natureza dualista. A propriedade horizontal é integrada por um concurso de dois direitos. Há um direito de plena propriedade sobre partes privativas (cada condómino é pleno proprietário de cada uma das fracções independentes de que se compõe o prédio sujeito ao regime da propriedade horizontal), e este direito é uma "plena in re potestas" conferindo os poderes do proprietário. Coexiste, com esta plena propriedade, uma compropriedade nas partes comuns (cada um dos condóminos é, além de proprietário pleno da sua parte privativa, comproprietário das partes comuns), que está ligada à propriedade plena da parte privativa, de tal forma que na alienação do direito de propriedade horizontal vão coenvolvidos a propriedade sobre a parte privativa e o direito de compropriedade sobre as partes comuns.

Esta compropriedade é uma compropriedade forçada, não é possível sair da indivisão, ao contrário do que sucede na compropriedade normal, em que é sempre lícito requerer a divisão da coisa comum. A compropriedade das partes comuns dum edifício em propriedade horizontal é forçosa, enquanto durar a propriedade horizontal. Nesta medida, é forçosa e perpétua.

Em suma, a figura em epígrafe reveste uma natureza dualista, resultante do concurso destes dois direitos.

D - MODOS DE CONSTITUIÇÃO

134 - Como se poderá constituir a situação de propriedade horizontal?

A sua constituição pode fazer-se por negócio jurídico, por usucapião ou decisão judicial.

I - Por negócio jurídico - Podem apresentar-se várias modalidades negociais, susceptíveis de constituir a propriedade horizontal "ex negotio".

É necessário, em primeiro lugar, que seja lavrado um título constitutivo de propriedade horizontal por escritura pública; este título será um requisito prévio da propriedade horizontal.

A atribuição de cada uma das unidades a vários proprietários é que poderá ter lugar por vias negociais diversas.

a) Pode um indivíduo, proprietário pleno e exclusivo de um bloco habitacional, recém construído ou mesmo construído já há muito tempo, constituir o regime de propriedade horizontal sobre esse bloco, para depois alienar separadamente as várias unidades a outros sujeitos.

b) Pode suceder, e será o caso mais vulgar, que uma entidade (normalmente, uma empresa de construção) tome a iniciativa de reunir os fundos de várias proveniências -

que lhe sejam entregues por determinadas pessoas interessadas em adquirir uma fracção a título de propriedade horizontal - e com esses fundos, e eventualmente outros que obtenha por recurso ao crédito, iniciar a construção. Vai recebendo prestações, à medida que se vão alcançando certas fases de adiantamento da construção, e esta é assim feita, sendo atribuídas as fracções a cada um dos indivíduos que foram adiantando importâncias para a construção do edifício.

Essa entidade tem as funções do elemento polarizador das aspirações dos outros e detentor da iniciativa(57); é uma pessoa que incorpora os interesses e a posição de todas as outras, tornando possível a situação desejada colectivamente.

A via jurídico-negocial normalmente utilizada para esta modalidade de constituição da propriedade horizontal é o contrato-promessa de venda. O incorporador recebe determinadas importâncias e promete vender à pessoa que lhe entregou a importância uma fracção do prédio em construção ou que vai ser construído, com certas caracterís-

(57) - No Brasil a pessoa que assume tais funções é designada por incorporador e esta modalidade de actuação tem o nome de incorporação.

cas.

A promessa de venda é o meio mais corrente na nossa vida jurídico-negocial e tem o efeito de mais tarde ser necessário efectuar-se uma escritura definitiva de transmissão da fracção; se o prédio não vier a ser construído, ou se não for construído dentro do prazo fixado, como foi entregue uma importância a título de sinal, o promitente comprador pode exigir a sua restituição em dobro, no caso de se querer desligar do negócio.

Nada impede, porém, que se possa seguir outra via; seria, v.g., possível fazer uma escritura de venda de coisa futura e simultâneamente de venda do direito de propriedade sobre o solo que já existe.

Este meio dispensaria o ter de se fazer mais tarde uma outra escritura, mas por outro lado a promessa dá ao promitente vendedor uma maior liberdade de acção, podendo ele em determinado momento deixar de construir, embora suportando a necessidade de restituição do sinal em dobro.

Já não seria assim inteiramente no caso de se fazer logo a escritura de venda de coisa futura, em que qualquer indemnização não seria pautada pelo sinal, mas pelos prejuízos efectivamente causados ao comprador.

c) Sobre um edifício já existente, e pertencente a um só indivíduo, ou mesmo a vários em regime de propriedade

de horizontal, podem vir a construir-se novos andares; pode alguém adquirir o direito de construir sobre edifício já existente.

Este direito de construir sobre edifício já existente, a que se refere o artº. 1526º, é uma situação que deve ser enquadrada dentro do chamado direito de superfície.

Simplesmente, nos termos da mesma norma, levantado o edifício - feita esta construção do novo andar -, são aplicáveis à ampliação efectuada as regras da propriedade horizontal.

d) Pode, também, acontecer que sem haver um elemento que tenha a iniciativa de reunir todos os outros, sejam os vários interessados que se põem em comum, constituindo eles próprios uma sociedade para efeitos de construirem um prédio em regime de propriedade horizontal.

Tudo isto são modalidades "ex negotio" de constituição da propriedade horizontal.

II - Por usucapião - Pode também adquirir-se a propriedade horizontal por usucapião, nos termos gerais deste instituto.

III - Por decisão judicial - É outro meio de aquisição desta forma da propriedade, através de decisão judicial proferida em processo de divisão de coisa comum.

Figure-se que dois indivíduos são coherdeiros de um proprietário dum prédio, cada um deles tendo direito a uma quota ideal; em vez de um deles ficar com o prédio e o outro receber tornas, decidem fazer a divisão submetendo o prédio ao regime da propriedade horizontal, porque se verificam os requisitos respectivos e cada um deles fica com um certo número de unidades equivalentes às do outro; fazem a divisão criando o regime da propriedade horizontal.

Pode, portanto, haver uma decisão judicial, a requerimento de qualquer consorte, em acção de divisão de coisa comum, e constituir-se por divisão a propriedade horizontal.

E - DIREITOS E OBRIGAÇÕES OU ENCARGOS DOS CONDÓMINOS.

135 - A propriedade horizontal supõe uma contiguidade e uma interpenetração de esferas de vida, de esferas patrimoniais dos vários condóminos; cria um grupo que vai ter interesses contíguos e solidários por força da interdependência que há entre as unidades que integram o prédio sujeito ao regime da propriedade horizontal. É, pois, natural que haja direitos e deveres recíprocos e, por esse motivo, surja a necessidade de determinar com rigor a posi-

ção jurídica de cada um dos condóminos.

Da natureza jurídica do instituto, atrás referida, já podemos inferir as linhas de orientação para este aspecto, independentemente da concretização mais minuciosa que se vai traçar.

136 - Cada condómino é pleno proprietário da sua parte privativa - e a sua parte privativa não é apenas, como já se tem escrito, um cubo de ar em que as paredes são comuns e ele é sòmente proprietário do conteúdo. Trata-se, sim, de uma unidade habitacional fechada e tapada pelas partes comuns, que lhe pertence para os usos próprios a que um prédio sob este regime se destina e vêm enunciados no título constitutivo - esse espaço de que é proprietário é uma fracção independente, a sua fracção autónoma e privativa.

Em relação a ela, tem o titular os poderes normais de um proprietário - pode usá-la, fruí-la, arrendá-la e receber as rendas, dispor dela com plena liberdade sem necessidade de submeter a sua decisão a qualquer aprovação da assembleia de condóminos ou de outra qualquer entidade.

Tem em relação a ela o "ius utendi, fruendi e abutendi" como qualquer normal proprietário, e mais, nem sequer aqui tem lugar, ao contrário do que sucede na compropriedade, o direito de preferência. Não há direito de preferência na propriedade horizontal, nos termos do artº 1423º - "os condóminos não gozam do direito de preferência na alienação de fracções nem do direito de pedir a divisão das partes comuns". Esta última parte revela precisamente aquele aspecto de comunhão forçada atrás focado.

137 - Como estamos numa situação algo especial, com particularidades, há aqui limitações que não se verificam na propriedade em geral.

Verificam-se todas aquelas limitações derivadas da situação de vizinhança, já focadas, que impendem sobre os proprietários em geral (omissão de fumos, produção de ruídos, etc.), e, além dessas, existem aqui também certas limitações especiais.

Não se pode prejudicar, quer com obras novas, quer com obras de reparação, a segurança, a linha arquitectónica ou o arranjo estético do edifício. O proprietário pleno e normal pode modificar, segundo o seu alvedrio, a linha estética do seu edifício, mas isso não pode acontecer por parte de cada condómino.

Não pode destinar a sua fracção a uso ofensivo dos bons costumes; não pode dar-lhe um fim diverso do uso a que é destinada nem para quaisquer outras actividades que

tenham sido proibidas no título constitutivo ou posteriormente por acordo de todos os condóminos.

Há, como se vê, algumas limitações que não existem na propriedade em geral, e que têm a sua fundamentação na especial interdependência que há entre os direitos dos condóminos.

138 - Quanto às partes comuns, cada um dos condóminos tem um direito de compropriedade, está sujeito ao regime da compropriedade. Por força desta compropriedade das partes comuns há determinadas obrigações que impendem sobre os condóminos - têm encargos de conservação e fruição do imóvel.

São obrigados a pagar as despesas relativas à conservação e à fruição das partes comuns do edifício; a suportar as despesas correspondentes ao pagamento de serviços de interesse comum - a energia eléctrica do ascensor, os serviços de porteiro, se este é remunerado, a energia eléctrica da iluminação das escadas, etc.

A participação de cada um nestas despesas é estabelecida em função do valor relativo das respectivas fracções; esse valor relativo não é determinado por avaliação "ad hoc", mas está prefixadp no título constitutivo da propriedade horizontal, em percentagem ou permilagem. Estabelece-se o valor que tem cada fracção no valor global do edifício e a repartição dos encargos faz-se segundo este critério, quando não houver especial critério de repartição desses encargos.

Também em matéria de inovações existe a obrigação de pagar as que forem introduzidas, desde que elas sejam aprovadas pela maioria dos condóminos, e aqui exige-se uma maioria qualificada de dois terços.

Este ponto está, porém, sujeito a limites. A assembleia dos condóminos não pode aprover inovações nas partes comuns, que prejudiquem a utilização por parte de algum dos condóminos, tanto das suas coisas próprias, como das coisas comuns.

As despesas com as inovações são repartidas pelos condóminos nos termos do artº. 1424º, mas os condóminos que não tenham aprovado as deliberações - a minoria - que não aprovou a inovação - podem recusar-se a contribuir para as despesas, a não ser que seja judicialmente declarada infundada a sua recusa. A recusa será sempre fundada - - pode sempre um condómino recusar-se a contribuir para qualquer inovação que foi aprovada, mesmo pelos dois terços, desde que se trate de uma inovação de carácter voluptuário (cfr. artº. 216º, nº 3), ou que não seja proporcionada à importância do edifício. Isto di-lo o nº 3 do

artº. 1426º.

Uma outra obrigação importante que a lei impõe aos condóminos é a obrigação de segurar o edifício contra o risco de incêndio, e, portanto, pagar na respectiva proporção o prémio do seguro.

F - ADMINISTRAÇÃO DAS PARTES COMUNS DO EDIFÍCIO.

139 - Já sabemos que existe na propriedade horizontal um direito de propriedade sobre as partes privativas, que são administradas pelo próprio titular.

E quanto às partes comuns?

É necessária a existência de uma estrutura adequada à prática dos actos de administração dessas partes comuns. Essa estrutura está prevista na lei, e é integrada exclusivamente por dois órgãos - a assembleia de condóminos e o administrador.

A assembleia de condóminos é um órgão colegial constituído por todos os condóminos, com carácter deliberativo, que tem poderes de controlo, de aprovação e decisão final sobre todos os actos de administração.

O administrador é o órgão executivo. É um órgão de execução, nomeado e exonerado pela assembleia de condóminos, a quem tem de prestar contas da sua actividade. Procede, portanto, à execução das decisões daquela e à adopção das medidas necessárias à conservação e vida do edifício.

140 - Sendo um órgão deliberativo, a assembleia dos condóminos não vê, contudo, o seu campo de acção exaustivamente determinado na lei. Fundamentalmente, cabe-lhe superintender na administração das partes comuns do edifício.

Dentro destes poderes de administração, podemos concretizar que ela não pode interferir com a administração das partes privativas de qualquer dos condóminos; só pode exercer esses seus poderes em relação às partes comuns.

Excepcionalmente, por maioria qualificada pode decidir das inovações, mas essas inovações nunca podem ser tais que prejudiquem a utilização, por parte de cada um dos condóminos, da sua coisa própria, como das coisas comuns.

Ela só pode tomar decisões em matéria de administração, não pode praticar actos de alienação em relação ao imóvel ou às partes comuns do imóvel - não pode praticar actos de disposição em relação às partes comuns.

Os actos de disposição de partes comuns só podem ser decididos por unanimidade, mesmo em relação às partes comuns enunciadas pela lei no artº. 1421º - o solo, o te-

lhado, os terraços de cobertura (58), entradas, vestíbulos, escadas, corredores de uso, instalações gerais de água, electricidade, aquecimento, os pátios e jardins anexos, os ascensores, as garagens, etc. -, e não por maioria, mesmo qualificada.

Não pode também tomar deliberações administrativas que privem qualquer dos condóminos de direitos que lhes foram conferidos pelos títulos, por força dos quais eles adquiriram a sua propriedade. Por exemplo, se algum dos condóminos, por força do título de aquisição e do título constitutivo da propriedade horizontal, adquiriu direito ao aquecimento (adquiriu uma fracção com aquecimento central), a assembleia de condóminos não pode, por deliberação, privá-lo desse direito; só o pode fazer com acordo dele. Não pode impôr-se-lhe uma deliberação que o prive dum direito que ele adquiriu por força de um título donde promanou o direito de propriedade sobre a sua parte privativa.

141 - Quanto ao administrador, foram traçados os as-

(58) - O terraço na propriedade horizontal, mesmo quando destinado ao uso do último morador - mesmo quando este o pode utilizar para recreio ou para usos vários - é propriedade dos condóminos. E, por exemplo, um direito de construir sobre ele é um direito de que dispõe a comunidade, e não apenas o proprietário do último andar.

pectos essenciais da sua função - é um órgão executivo, nomeado e exonerado pela assembleia, tem as funções constantes dos artºs. 1436º e 1437º.

Entre elas, reveste especial importância a legitimidade que o artº. 1437º lhe confere para estar em juízo em representação dos condóminos, quer como autor, quer como demandado.

* * *

CAPITULO IV

DIREITO DE SUPERFICIE

A - NOÇÃO LEGAL

142 - O direito de superfície é regulado no artº. 1524º e ss., e a noção que a nossa lei dá desta figura é a seguinte - "...consiste na faculdade de construir ou manter, perpétua ou temporàriamente, uma obra em terreno alheio, ou de nele fazer ou manter plantações".

Esta definição sugere-nos algumas observações.

Faz-se referência ao direito de "fazer ou manter plantações"; não abrange só a possibilidade de construir, mas também o direito de fazer plantações; pode-se, assim, adquirir por direito de superfície o direito de plantar um pomar num terreno de outrem, por exemplo.

Esta possibilidade não se verifica em todos os ordenamentos jurídicos; no direito italiano, por exemplo, não

se admita que a propriedade de árvores ou de plantações seja separada da propriedade do solo.

O nosso ordenamento admite, não só o direito de construir um prédio em terreno alheio, como também o de aí fazer plantações de árvores.

143 - Uma outra observação nos parece ter cabimento.

Embora a noção legal de direito de superfície se refira apenas ao direito de construir ou manter obra em terreno alheio (art. 1524.º), parece poder reconduzir-se-lhe uma outra situação. Da leitura das disposições integradas no título respectivo, supomos poder, também, entender-se por direito de superfície algo que é, em certa medida, diferente deste direito de construir.

Na verdade, o art. 1528.º diz que o direito de superfície "pode resultar da alienação de obra ou árvores já existentes, separadamente da propriedade do solo". Em face disto, parece-nos estarem abrangidas nesta figura duas situações de tipo diferente, que, algo equivocamente, nos parece não estarem bem destacadas.

A distinção resulta clara do regime respectivo. Por um lado tanto é direito de superfície o direito de construir, efectuar a construção, como o direito sobre a construção existente em terreno alheio.

As situações são de natureza diferente, porque o direito de construir ou de plantar em terreno alheio é uma concessão "ad aedificandum" ou "ad plantandum", feita pelo proprietário do solo - uma autorização que se dá a outrem para construir.

O direito sobre construção já existente não é uma concessão para edificar, é um direito sobre uma construção já feita, do tipo do direito de propriedade.

São, pois, dois direitos de natureza diferente. O primeiro - a concessão "ad plantandum" ou "ad aedificandum" - é um direito real autónomo "in re aliena", sobre coisa de outrem. O segundo - a propriedade da obra separada do solo - é um direito de propriedade.

Parece que o legislador, embora na noção legal só faça referência à concessão "ad aedificandum" (ao direito de construir), todavia, considera, também, direito de superfície o direito de propriedade sobre a construção ou as árvores, separadas do solo - isto, desde logo, sugere-o art. 1528.º.

E tanto a natureza jurídica é diferente, que o art. 1526.º diz que "o direito de construir sobre edifício alheio está sujeito às disposições deste título..."

Isto diz-nos que o direito de construir sobre prédio alheio é um direito de superfície. Mas, na parte final

do mesmo preceito diz-se "levantado o edifício, são aplicáveis as regras da propriedade horizontal. Concretamente, uma vez feita a construção, estamos já perante um direito diferente: a propriedade horizontal. E o mesmo se diga quando se trata, não de construir sobre edifício alheio, mas de construir sobre o solo.

O direito de construir é, no fundo, um direito de superfície, e a construção é uma propriedade que não abrange o solo - são dois direitos de natureza diferente.

O legislador integra-os, ambos, dentro da noção do direito de superfície.

Poderiam pôr-se algumas dúvidas quando se diz, no art. 1535.º que o proprietário do solo goza de direito de preferência na venda ou dação em cumprimento do direito de superfície. Tratar-se-á de direito de preferência, quanto à alienação do direito a construir, ou quanto à alienação do prédio construído? Parece-nos que o será em relação a ambos, pois embora a noção legal de direito de superfície se refira só à construção "ad aedificandum", poderemos concluir que também se refere assim o direito sobre a construção separada da propriedade do solo.

Há preferência quando se vende não só a propriedade do solo, como também quando se vende o direito a construir.

O direito de superfície pode, portanto, apresentar-se em duas situações - ou existir só o direito de construir ou existir o direito sobre prédio já construído, separado da propriedade do solo. Em ambos os casos a propriedade do solo pertence a outrem.

B - A PROPRIEDADE DO SOLO

144 - Pode perguntar-se qual o sentido desta propriedade do solo. Um indivíduo autoriza outro à construir e fica com a propriedade do solo; ou, mesmo mais do que isso, vende a construção e fica apenas com a propriedade do solo. O solo parece uma propriedade morta; parece não ter, em princípio, qualquer significado o ser-se proprietário do solo.

Não é inteiramente assim, e o direito de superfície com este desdobramento é mais uma fórmula, dentro dum espírito de racionalização, que a lei excogitou e pôs à disposição dos particulares, para eventualmente darem uma mais adequada satisfação aos seus interesses, se assim o entenderem.

E quais serão os interesses que possa ter o titular da propriedade sobre o solo em permanecer com este e vender só a construção ou em autorizar outrem a construir, mas

ficando com a propriedade do solo para si?

145 - Poderá ter interesse antes da construção quando faz a concessão "ad aedificandum" continua a ter interesse no solo antes da construção, visto que o art. 1532.º diz que "enquanto não se iniciar a construção da obra ou não se fizer a plantação das árvores, o uso e a fruição da superfície pertencem ao proprietário do solo..."; portanto, enquanto se não iniciam as obras ele continua a fruir o solo.

"...Todavia, não pode impedir nem tornar mais onerosa a construção ou a plantação", quer dizer, continua a poder fruir e usar, mas não pode fazer modificações tais que depois torne mais onerosa a construção. Quanto a esse aspecto é obrigado a uma abstenção: pode fruir, pode usar, mas não pode tornar mais onerosa nem impedir a construção. Não é obrigado, porém, a facilitar a construção, isto é, se vendeu um terreno que exige despesas de terraplanagens, nivelamento, etc., não é ele quem tem de as fazer, mas sim o superficiário, quando iniciar a construção. É-lhe apenas imposto um "pati", uma abstenção, um ter de suportar a construção que o outro faz.

146 - Pode, também, ter interesse durante a construção, porque a terra que é escavada e separada do solo lhe pertence. Pode dar-lhe o uso que quiser, pois ela não pertence ao superficiário, mas sim ao proprietário do solo.

E, eventualmente, quaisquer coisas valiosas, quaisquer achados que sejam encontrados no solo durante a construção, são dele e não do superficiário.

147 - Mesmo depois de feita a construção ainda continua a ter algum interesse, v.g., o resultante de a lei, no art. 1533.º, reservar para o proprietário do solo a fruição do subsolo, embora não possa causar prejuízo ao superficiário. Quer dizer: pode fazer no subsolo obras que não prejudiquem o superficiário, e isto pode ter um interesse económico, pois pode aproveitar o subsolo e explorá-lo - exploração de materiais, garagens, parques de estacionamento, cinemas, toda a espécie de utilizações que o subsolo possa oferecer - e continua a pertencer ao proprietário do solo a fruição do subsolo, embora limitado a fazê-lo em termos de não prejudicar o superficiário.

Além disso, o direito de superfície pode caducar, ou porque o indivíduo não construiu ou porque, construindo, a coisa é destruída e então o superficiário tem o poder de, nos termos da al. b) do n.º 1 do art. 1536.º, reconstruir a obra ou renovar a plantação; mas, se o não fizer dentro

do prazo estabelecido no contrato constitutivo da superfície ou, no máximo, dentro de dez anos, reconstitui-se a plena propriedade do proprietário do solo.

O proprietário do solo tem, pois, sempre uma expectativa de lhe vir a pertencer a plena propriedade.

C - OBJECTO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE

148 - Algumas regras sobre o objecto do direito de superfície estão contidas no art. 1525.º.

Se consiste num direito sobre obra ou árvores já existentes, tem como objecto estas coisas.

Se tem por objecto a construção de uma obra, estatui o art. 1525.º que pode abranger uma parte do solo não necessária à sua implantação, desde que tenha utilidade para o uso da obra.

Pode, também, tratar-se de um direito de construir sobre edifício alheio, alteando-o ou sobreelevando-o: uma vez feita a construção, tudo se resolve numa situação de propriedade horizontal.

Quanto ao subsolo: preceitua o n.º 2 do mesmo artigo que o direito de superfície não pode ter como objecto a construção de uma obra no subsolo, a não ser que se trate de parte inerente à obra superficiária; o subsolo continua sempre a pertencer ao proprietário do solo.

D - CONSTITUIÇÃO

149 - Nos termos do art. 1528.º, o direito de superfície pode constituir-se por contrato, testamento ou usucapião.

a) Por acto negocial "inter-vivos", gratuito ou oneroso, o dono do solo confere a outro indivíduo o direito de construir sobre ele; quando esse negócio seja oneroso, há uma contraprestação, que pode ser efectuada de uma só vez ou uma certa prestação anual, temporária ou perpétua. Tudo dependerá da livre modelação que as partes fizeram dos seus interesses.

b) Por negócio "mortis causa" pode este direito constituir-se sob a forma de legado. O testador pode, v.g., deixar o seu terreno em termos de ficar a pertencer o solo a um legatário e o direito de construir nele a outro legatário.

c) Pode também constituir-se por usucapião, e temos aqui um ponto em que reveste grande importância aquela distinção que há a fazer, e a lei não fez claramente, entre direito de construir sobre prédio alheio e direito sobre o prédio construído separado do solo.

Uma usucapião do direito de superfície, visto como direito sobre uma construção já existente separada do solo, compreende-se claramente; pode perfeitamente um indivíduo exercer actos de posse sobre uma casa que está construída, e exercê-los com um "animus", não de pleno proprietário, mas de superficiário porque, p. ex., lhe foi vendida por acto nulo a casa separada do solo. Foi constituído por escritura um direito de superfície sobre a casa separada do solo, mas o título constitutivo é nulo; ele não adquiriu a superfície, mas passou a possuir a casa nesses termos e com o respectivo "animus"; ao fim de um determinado número de anos adquire por usucapião o direito de superfície, adquiriu um direito sobre aquela casa separada da propriedade do solo.

Como é que, porém, se pode adquirir por usucapião o direito de construir? O que é a posse do direito de construir?

A posse sobre a casa separada do solo compreende-se imediatamente.

Para adquirir por usucapião o direito de construir, porém, seria necessária a posse - e como se possui o direito de construir? Parece que só se pode possuir ... construindo. Figuremos, porém, uma hipótese paralela à anterior - um indivíduo, por acto nulo por falta de forma, v. g.,

contrato verbal, confere a outrem o direito de construir. Este outrém não adquire o direito por falta de forma, mas ao fim de um determinado tempo pode adquiri-lo por usucapião porque este acto, nulo por aquele fundamento, se não lhe transferiu um verdadeiro direito, é todavia um título que mostra ter-se transferido a posse desse direito.

Numa situação deste tipo adquire-se por usucapião o direito de superfície.

d) O direito de superfície pode também constituir-se por alienação de obra ou árvore já existente, separada da propriedade do solo.

E - DIREITOS E DEVERES DO SUPERFICIÁRIO E DO PROPRIETÁRIO DO SOLO

150 - Quanto aos direitos e encargos do superficiário e do proprietário, já vimos que pode haver um contrato constitutivo do direito de superfície, no qual se convencione a obrigação, a cargo do superficiário, de pagar uma prestação.

O proprietário do solo - pode chamar-se-lhe, também, fundeiro - tem a fruição do solo antes de começar a obra(59),

(59) - Cfr. sobre o conteúdo deste direito, supra, n.º 145.

tem sempre a fruição do subsolo (60), o direito de receber a contraprestação estipulada (no caso de ela não ser paga pontualmente pode exigir o seu pagamento em triplo, conforme o art. 1531.º), e o direito de preferência na alienação do direito de superfície. Estes são, no fundo, os seus direitos mais importantes.

151 - Assinale-se ainda o seguinte. O direito de superfície é, no fundo, uma excepção àquele princípio geral da propriedade que é a acessão. Esta significa que o proprietário de uma coisa, como sabemos, adquire o direito sobre aquilo que nessa coisa se veio a incorporar.

O direito de superfície acaba por implicar uma excepção a esse princípio - um indivíduo tem o direito de construir, e por força do uso desta concessão "ad aedificandum" ou "ad plantandum", aquilo que ele constrói não se incorpora na propriedade do proprietário do solo - pertence-lhe a ele.

Isto tem uma consequência importante - se um terceiro vem, por exemplo, construir num terreno sobre o qual já há um direito de superfície, a construção do terceiro pode ser impedida, não apenas pelo proprietário do solo, como também pelo superficiário. Feita a construção por terceiro, e a aplicar as regras sobre a acessão - na medi

(60) - Cfr., sobre o conteúdo deste direito, supra, n.º 147.

da em que, segundo elas (cfr. arts. 1340.º e segs.) alguém pode fazer sua a coisa, mediante uma certa indemnização - a pessoa que tem o direito de as invocar para esse efeito não é o proprietário do solo, mas o superficiário. É este que tem o direito conferido, v.g., nos arts. 1340.º n.º 3 e 1341.º.

A pessoa que tinha direito de construir sobre aquele prédio é que pode invocar a acessão para fazer sua, mediante indemnização - se for caso disso -, a coisa construída por terceiro no solo relativamente ao qual só ele poderia construir.

A acessão aqui pode funcionar, não a favor do proprietário do solo, mas a favor do superficiário, para adquirir a coisa construída por terceiro.

F - EXTINÇÃO

152 - O direito de superfície extingue-se, nos termos do art. 1536.º.

a) Há certos casos de caducidade. São as hipóteses das alíneas a), b) e c) do n.º 1 do art.º 1536.º:

- se o superficiário não concluir a obra ou não fizer a plantação dentro do prazo fixado ou, na falta de fixação, no prazo de dez anos, caduca o seu direito;

- se destruída a obra ou as árvores, o superficiário não reconstruir a obra ou não renovar a plantação dentro dos mesmos prazos a contar da destruição;

- pelo decurso do prazo, sendo constituído por certo tempo; quando há uma constituição de um direito de superfície temporário, passado esse tempo ele caduca é a consequência da caducidade é a reaquisição da plenitude da propriedade pelo proprietário do solo (uma aquisição restitutiva por força da elasticidade do direito de propriedade).

Pode extinguir-se, nos termos da al. d), pela reunião na mesma pessoa do direito de superfície e do direito de propriedade. Essa reunião pode dar-se por força de contrato (venderam um ao outro o seu direito) ou por confusão (um é herdeiro do outro).

Nos termos da al. e) pode extinguir-se por desaparecimento ou inutilização do solo ou, nos termos da al. f), por expropriação por utilidade pública.

Estes os modos como se extingue o direito de superfície.

Um outro ponto importante a focar é a possibilidade de o superficiário, obrigado a pagar prestações anuais, ficar liberto desse encargo, se durante vinte anos deixou

de as pagar. A falta de pagamento durante esse tempo, perante a inércia do proprietário do solo, liberta-o de obrigação de pagar, o que não quer dizer, acentue-se, ficar ele proprietário do solo; fica apenas liberto de pagar as prestações. Continua a ter apenas um direito de superfície, mas sem a obrigação de pagar contraprestação.

Não se torna proprietário do solo; tanto que, embora já não tenha a obrigação de pagar, se, p.ex., a casa é demolida ou destruída, o proprietário do solo, que já não recebia nenhuma prestação, pode readquirir a plena propriedade, se o superficiário não faz a reconstrução nos termos do al. b) do n.º 1 do art. 1536.º

A libertação do encargo de pagar as prestações anuais não significa que o superficiário fique a ter mais que o direito de superfície e fique a ter o direito de propriedade sobre o solo.

* * *

CAPÍTULO V

SERVIDÕES PREDIAIS (*)

A - NOÇÃO

153 - Segue-se referir agora as servidões prediais, que constituem um outro direito real de gozo.

Pergunta-se liminarmente: o que é uma servidão predial? O que é um direito de servidão?

Pois bem, podemos defini-la como um direito real com o conteúdo de possibilitar o gozo de certas utilidades de um prédio em benefício de outro prédio.

Quer isto dizer que as utilidades, cujo gozo o direito de servidão propicia, devem ser utilidades susceptíveis de serem gozadas por intermédio de outro prédio - o prédio dominante.

(*) - Cfr., sobre este Capítulo, o respectivo anteprojecto do Código Civil e correspondentes notas, da autoria de PIRES DE LIMA, in Bol. Min. Jus., N.º 64.

Não basta, assim, a mera existência de uma vantagem, de um benefício, ou de uma utilidade para o titular da servidão individualmente determinado. É necessário que haja um proveito objectivamente ligado a outro prédio.

O titular da servidão não tem o poder de colher utilidades, vantagens ou benefícios, individualmente considerado, mas na qualidade de sujeito de outro prédio e na medida do objectivamente postulado para o proveito do prédio.

Isto porque o nosso direito não acolhe as servidões pessoais.

A definição do direito de servidão predial, coincidente com este conceito ou fornecendo apoio às notas focadas nele, consta do art. 1543.º ao estatuir: "servidão predial é o encargo imposto num prédio em proveito exclusivo de outro prédio pertencente a dono diferente; diz-se serviente o prédio sujeito à servidão e dominante o que dela beneficia".

Dos termos desta definição pode inferir-se - a disposição sugere-o - que tanto o sujeito activo como o passivo da relação jurídico-real de servidão são os prédios - o dominante e o serviente, respectivamente -, o que seria obviamente absurdo. Sujeitos são, sim, as pessoas.

Desta ideia, porém, do dizer-se que há um encargo imposto a um prédio em benefício de um outro - resulta vincar-se melhor a nota de as utilidades serem proporcionadas por um prédio (o serviente) em proveito objectivo de outro prédio (o dominante).

Daí, também, que no próprio preceito citado se tenha utilizado a expressão "servidões prediais" que designa o Título VI, do Livro III C.C. - isto precisamente para vincar a não existência de servidões pessoais.

Assim, exemplificando, a um indivíduo é vedado adquirir, com carácter de servidão, o direito de passear no prédio de outrem.

Pode, porém, haver, com a natureza de servidão, um direito de passar por um prédio para outro ou até mesmo de passear num dado prédio, v.g., no caso do direito dos hóspedes de um hotel ou de os internados numa clínica passearem num prédio ou num parque contíguo.

Note-se, todavia, que não ocorre aqui - nas hipóteses descritas - uma servidão pessoal. Existe, sim, um encargo imposto no prédio serviente em benefício do prédio dominante - o hotel ou a clínica no nosso exemplo -, uma vez que o facto de os hóspedes ou os internados, consoante a hipótese tomada, poderem passear no parque - prédio serviente - se traduz numa vantagem atribuída ao prédio dominante, numa ligação objectiva de proveito.

Esta ideia que temos vindo a expor é, também, reforçada pelo art. 1544.º ao estatuir, referindo-se ao conteú do deste instituto, - a servidão predial - que "podem ser objecto da servidão quaisquer utilidades, ainda que futuras ou eventuais, susceptíveis de serem gozadas por intermédio do prédio dominante,..."

Daí que não se trate de vantagens ou utilidades atribuídas ao titular individualmente considerado; é, antes, necessário um proveito objectivamente ligado ao prédio dominante.

De acordo com a noção referida, a servidão é um direito real sobre coisa alheia a que acresce, ainda, o ser autónoma, "sui generis" e não resultar de um parcelamento da propriedade. É um direito real sobre coisa alheia, sobre o prédio de outrem.

O titular da servidão não pode, por isso, ser considerado como parcialmente proprietário do prédio serviente, mas, sendo este de outrem, como detendo, apenas, um direito real sobre coisa alheia.

B - CARACTERÍSTICAS

154 - Exposta assim a noção de servidão predial, é oportuno procedermos agora à sua caracterização, que já foi, aliás, algo avançada na noção que demos desse instituto.

Quais são as características da servidão? - pergunta-se.

I - **INSEPARABILIDADE** →

155 - Pode, desde logo, citar-se a característica da inseparabilidade, referida no art. 1545.º, ao estatuir, no seu n.º 1, que "salvas as excepções previstas na lei, as servidões não podem ser separadas dos prédios a que pertençam, activa ou passivamente" e, no seu n.º 2, que "a afectação das utilidades próprias da servidão a outros prédios importa sempre a constituição de uma servidão nova e a extinção da antiga".

Desta disposição decorre explìcitamente que a servidão está ligada ao prédio dominante.

Assim, por exemplo, se se afecta uma servidão de passagem a um novo prédio, desaparecendo a anterior, não quer isto dizer que a servidão se transferiu. Não; o que

ocorreu foi a extinção da antiga servidão e a constituição de uma nova.

O facto de as servidões serem inseparáveis dos prédios a que dizem respeito, reforça, aliás, mais uma vez, o art. 1543.º referido, que já afirma esta ideia de inseparabilidade, ao definir a servidão como o encargo imposto num prédio em proveito exclusivo de outro prédio.

A inseparabilidade surge assim como um corolário do princípio de que as utilidades do prédio serviente devem ser gozadas através do prédio dominante.

156 - O facto de as servidões não poderem ser separadas dos prédios a que respeitam não implica que as utilidades que formam o objecto da servidão sejam insusceptíveis de separação. É que pode, de facto, ocorrer uma servidão que tenha como objecto utilidades que, em geral, são susceptíveis de separação. Simplesmente só surge a servidão se, na hipótese concreta, essas utilidades estiverem ligadas ao prédio dominante.

Concretizando: GUILHERME MOREIRA negava a possibilidade de se constituirem servidões que conferissem poderes de fruição de um prédio.

Assim, por exemplo, não poderia haver uma servidão traduzida no direito a pastos de um prédio alheio ou no

direito de extrair madeira, barro ou ainda, v.g., de aproveitar água de nascente ou fonte sita em prédio alheio, ou mesmo de passear neste - isto porque, segundo este autor, ocorrem aqui verdadeiros poderes de fruição, susceptíveis de serem separados do prédio dominante.

São poderes de fruição que não estão necessàriamente ligados à exploração do prédio dominante.

De facto, v.g., o direito de extrair barro é um direito que não está ligado à fruição de um prédio dominante.

Daí que GUILHERME MOREIRA excluisse a possibilidade de se constituirem servidões com esse conteúdo.

Parece-nos, porém, que esta solução não é aceitável, isto porque, desde que "in concreto" o direito a essas utilidades esteja ligado a um prédio dominante, encontramo-nos perante autênticas servidões.

Assim, por exemplo, o direito de utilizar os pastos sitos em prédio alheio é normalmente um daqueles que satisfazem uma vantagem individual do seu titular. Mas admitamos que o prédio cortíguo é destinado à exploração pecuária. O direito de fazer pastar os animais que fazem parte da exploração montada neste prédio é um direito que se resolve numa vantagem para o prédio contiguo, podendo constituir, nessa medida, uma servidão. Não se verificará

uma situação de servidão, v.g., no caso de um indivíduo ter o direito de fazer pastar quaisquer animais seus em prédio alheio. Trata-se, antes, de uma situação meramente obrigacional entre esse indivíduo e o titular daquele prédio.

Se esse indivíduo, porém, tem uma exploração pecuária no prédio contíguo e tem o direito a que os animais dessa exploração pastem em prédio alheio então, aqui, ocorre uma verdadeira servidão - importa ao prédio onde se encontram os pastos - constituída a favor do prédio onde se procede a essa exploração pecuária.

Daí que o conteúdo deste tipo de servidão surja perfeitamente delimitado - isto porque não são quaisquer animais que podem pastar, no exemplo indicado, no prédio serviente, mas exclusivamente os que são objecto desse género de exploração, sendo, por isso, vedado ao dono desta levar a pastar aí - no prédio serviente - quaisquer outros animais que, embora de sua pertença, não estão, porém, afectados a esse fim de exploração.

O mesmo pode dizer-se no tocante ao direito de colher madeira ou barro em prédio alheio, para utilizar as hipóteses que referimos.

Em geral poderia haver aqui um direito de fruição que atribuisse vantagens individuais - donde o não poder

considerar-se essa situação como uma servidão ou sequer como de usufruto. Não há aqui, em suma, um direito real, mas antes uma relação obrigacional.

De facto, não pode verificar-se uma servidão, porque o direito de alguém ir buscar madeira a prédio alheio, sempre que o deseje, não é um direito que se encontre ligado a um prédio dominante; nem ocorre uma situação de usufruto, porque este é o direito de fruir um prédio, total ou globalmente, não se restringindo, assim, apenas ao direito de lá ir buscar madeira.

Este direito - o de ir buscar madeira - que estamos a referir é um direito atípico, donde o não poder ser considerado como um direito real. Poderá quando muito revestir uma natureza obrigacional - um direito de crédito - não acompanhando, por isso, o prédio nas suas transmissões.

Figure-se agora que esse direito de ir buscar madeira ou barro a prédio alheio não é um direito de se ir buscar tanto quanto o seu titular deseje, mas é, antes, restrito às quantidades de matéria prima necessárias para a edificação de construções que se ergam no prédio dominante.

Aqui, como se vê, já ocorre uma situação de servidão de um prédio a favor de outro prédio.

De tudo isto decorre que é possível conceber-se uma servidão que tenha como objecto poderes de fruição, desde que esses poderes sejam limitados ao gozo de outro prédio.

Vejamos, agora, a hipótese, também referida, de um direito incidindo sobre água sita em prédio alheio. Pode esse direito ser de propriedade, no caso de ser um direito sobre a água.

Já se for um direito de usar a água de prédio alheio para fins de irrigação do prédio contíguo aqui surge, com essa extensão, uma servidão imposta a um prédio em benefício de outro.

Refira-se, também, o direito de passear em prédio alheio.

Se for este um direito individual da pessoa, a sua qualificação só é possível como direito de crédito, visto que não há aqui uma situação correspondente ao direito real, quer de servidão, quer de usufruto.

Se for, todavia, o direito de v.g. os alunos de um colégio, os doentes de uma clínica, os hóspedes de um hotel, etc., usarem um parque contíguo ou estabelecímento em que se encontram para passearem, nesta hipótese, ocorre uma verdadeira servidão a favor do colégio, clínica, hotel ou outros, conforme o caso.

Tudo isto para dizermos que, contràriamente à tese

de GUILHERME MOREIRA, podem ser objecto de servidão quaisquer utilidades, desde que, na espécie concreta, só possam ser gozadas na medida e por intermédio de prédio dominante, ainda que, em abstracto, essas utilidades sejam susceptíveis de separação.

Não constitui, assim, obstáculo à constituição de servidão o facto de esta vir a incidir sobre utilidades susceptíveis de separação. O elemento verdadeiramente relevante é, repetimos, a circunstância de a utilidade, embora separável, que vai ser gozada, o vir a ser, na espécie concreta, por intermédio do prédio dominante, e na medida das necessidades deste. Tanto basta para que surja a servidão.

É que, com efeito, ocorre aí um encargo imposto a um prédio em benefício, não de uma pessoa, mas de outro prédio.

II - INDIVISIBILIDADE

157 - Outra característica das servidões é a de indivisibilidade.

Refere-se-lhe o art. 1546.º C.C. ao estatuir que "as servidões são indivisíveis: se o prédio serviente for di-

vidido entre vários donos, cada porção fica sujeita à parte da servidão que lhe cabia; se for dividido o prédio dominante, tem cada consorte o direito de usar da servidão sem alteração nem mudança".

Decorre desta disposição legal que a divisão de um prédio não importa a multiplicação de servidões.

Assim, por exemplo, se há um prédio que beneficia de uma servidão de passagem através de um outro prédio e este é fraccionado, v.g., em duas metades, só a que é objecto da passagem permananece onerada com a servidão. Não há portanto, multiplicação da servidão ou seja, o facto de a outra metade fazer parte do prédio globalmente onerado não implica que, após o fraccionamento deste, surjam duas servidões. Isto porque cada fracção fica apenas sujeita à parte da servidão que lhe cabia. Logo, a metade que não era objecto de passagem deixa, pela divisão do prédio, de ficar onerada.

Isto é, também, como fàcilmente se vê, uma expressão da aderência da servidão ao prédio.

III - ATIPICIDADE DO CONTEÚDO

158 - Outra característica das servidões é a que se traduz na circunstância de poderem delas ser objecto quaisquer utilidades, ainda que futuras ou eventuais.

Há, portanto, aqui uma certa atipicidade, uma vez que, dentro do desenho típico, os encargos impostos num prédio, que possam ser gozados por intermédio de outro prédio (o que exclui, desde logo, como já vimos, as servidões pessoais), podem ser objecto da servidão.

Aliás, já vimos mesmo que, contràriamente a opinião de GUILHERME MOREIRA, podem ser utilidades do tipo poderes de fruição, v.g., o direito à água, aos pastos, à madeira, ao barro, a passear, etc.; tudo isto se pode traduzir em autênticos direitos de servidão (61).

---

(61) - O direito à madeira, ao barro, ou o de passear em prédio alheio, se não constituirem direitos reais, só podem qualificar-se como direitos de crédito. Já o direito à água, se não for uma servidão, poderá ser um direito de propriedade, sobre água existente em prédio alheio.

Este direito de propriedade sobre a água, surge quando um indivíduo tem o direito a toda a água existente nesse prédio alheio, ou seja, o direito sobre toda a água que considere necessária para quaisquer usos. Porém, como já vimos, se esse direito à água se restringir à hipótese de aproveitamento na medida das necessidades de irrigação do prédio contíguo ou das necessidades de um edifício industrial, então esse direito constitui uma servidão.

Diga-se agora não ser necessário, para surgir uma servidão, que esta venha atribuir vantagens económicas ao prédio dominante. Pode tratar-se de vantagens de mera comodidade.

Será o caso, por exemplo, de uma servidão de vistas, ou de não edificação, contratada com o fim exclusivo de tornar mais ameno, mais aprazível o prédio dominante. A pessoa pode, com efeito, ter interesse numa vista para o mar ou para uma outra paisagem, sem que isso corresponda a um valor económico e sem que a ausência desta obste à constituição da servidão.

IV - LIGAÇÃO OBJECTIVA DA SERVIDÃO

159 - Como última característica das servidões diga-se, como já várias vezes referimos, mas agora, especificamente, que não há servidões pessoais. As servidões têm sempre que incidir sobre um prédio em benefício de outro.

A importância fundamental desta distinção reside na circunstância de a servidão se extinguir ao fim de certo tempo pelo não uso, contràriamente ao que se verifica com o direito de propriedade.

Daí, desde logo, a relevância de saber-se quando estamos perante uma servidão - o que acontecerá sempre que a medida da utilização estiver ligada à utilização do prédio dominante - ou perante um direito de propriedade - quando não haja essa ligação, quando seja uma "plena in re potestas" não limitada pelas necessidades do prédio dominante.

Assim, como já dissemos, se se estipular a constituição da fruição de utilidades em benefício pessoal, e não por intermédio de um prédio dominante, isto só pode ter sentido obrigacional, como será o caso, em geral, de um direito de passear em prédio alheio. Este não tem, pelo que foi dito, sentido real mas, apenas, relevância obrigacional.

Daí decorre que, se o indivíduo sobre cujo prédio se constitui o direito de passear o alienar, o novo proprietário não se encontra adstrito à obrigação de tolerar sobre este seu prédio os passeios do credor do direito de passear, visto que se trata de um direito de crédito. Isto sem prejuizo de este (o credor) poder exigir ao alienante (devedor) uma indemnização pela não realização integral do seu crédito, no caso de o prédio em questão ter sido alienado antes do termo do prazo pelo qual a obrigação de passear se constituira.

C - CONSTITUIÇÃO

160 - Cabe, agora, referir a constituição das servidões.

Como se constituem as servidões? - pergunta-se.

As servidões podem ser constituídas por contrato, testamento, usucapião, ou destinação do pai de família,

nos termos do art. 1547.º n.º 1.

I - CONTRATO

161 - As servidões podem, em primeiro lugar, constituir-se por acordo voluntário das partes.

É este um ponto que não suscita especiais dificuldades, dispensando-nos, assim, de desenvolvimentos.

II - TESTAMENTO

162 - As servidões podem, também, constituir-se por testamento. Será o caso de um indivíduo legar um prédio a alguém, mas onerando o imóvel com uma servidão a favor de outrem.

É este um ponto que não suscita, igualmente, dificuldades.

III - USUCAPIÃO

163 - As servidões podem, também, constituir-se por

usucapião, embora só sejam susceptíveis deste modo de aquisição as chamadas servidões aparentes.

As servidões não aparentes, não podem ser constituídas por usucapião; nos termos do n.º 1 do art. 1548.º, que as define, no seu n.º 2, ao estatuir que "consideram-se não aparentes as servidões que não se revelam por sinais visíveis e permanentes."

Compreende-se este regime.

É que as servidões não aparentes, não se revelando por sinais visíveis, confundem-se, por isso, muitas vezes com actos de mera tolerância do proprietário do prédio serviente.

Por outro lado, na medida em que não há sinais visíveis ou permanentes, podem as servidões estar a ser exercidas na ignorância do dono do prédio serviente.

Daí que a lei só admita a usucapião de servidões naquelas que se revelem por sinais visíveis e permanentes.

Será o caso, v.g., de uma servidão de vistas. Abriu-se uma janela numa parede que está no limite de um prédio. Aqui há um sinal visível e permanente - a janela - podendo, portanto, adquirir-se uma servidão por usucapião.

IV - DESTINAÇÃO DO PAI DE FAMÍLIA

164 - Por último, como derradeira forma de constituição de uma servidão, refere a lei - no n.º 1 do art.1547º citado - a destinação do pai de família.

Em que consiste?

Estatui o art. 1549.º a este propósito que "se em dois prédios do mesmo dono, ou em duas fracções de um só prédio, houver sinal ou sinais visíveis e permanentes, postos em um ou em ambos, que revelem serventia de um para o outro, serão esses sinais havidos como prova da servidão quando, em relação ao domínio, os dois prédios, ou as duas fracções do mesmo prédio, vierem a separar-se, salvo se ao tempo da separação outra coisa se houver declarado no respectivo documento".

Prevê-se, nesta disposição legal, a hipótese de um indivíduo ser proprietário de um só prédio ou de dois prédios e aí haver marcas visíveis de que um deles fornecia serventia para o outro.

Ora, se esses dois prédios forem vendidos a donos diferentes e, no momento da transmissão se constatar a existência desses sinais, p. ex., de passagem, sem que o contrário tenha sido declarado no documento de transmissão, entende-se que se constituiu uma servidão por destinação do pai de família.

Na base desta figura ou deste modo de constituição de uma servidão, encontra-se uma presunção de acordo tácito - uma presunção de intenções imputáveis tanto ao alienante como ao adquirente.

Para ocorrer a constituição de uma servidão por destinação do pai de família é, assim, necessária a existência de sinais visíveis e permanentes, não apresentando relevância o facto de estes terem sido produzidos no prédio pelo proprietário antecedente ou por outro ainda anterior a este, ou ainda por um usufrutuário ou locatário.

Releva, assim, a existência, no momento da transmissão, desses sinais, nada tendo sido dito em contrário no documento de transmissão. Tanto basta para a lei presumir que tanto a pessoa que comprou como a que alienou quiseram constituir uma servidão.

V - SENTENÇA JUDICIAL

165 - Para além das quatro formas referidas de constituição de servidões - contratual, testamentária, usucapião e destinação do pai de família - referidas no n.º1 do art. 1547.º citado, podem estas também constituir-se ,

nos termos do n.º 2 da mesma disposição, por sentença judicial.

As servidões de que nos ocupámos até agora são servidões do mais diverso tipo, podendo ter diversos conteúdos.

Há, porém, certas hipóteses em que a lei prevê a possibilidade de um indivíduo, mediante o exercício de um direito potestativo, criar uma servidão, falando-se, então, em servidão legal.

Em que consiste esta?

Poderá dizer-se que servidão legal é o direito potestativo de constituir coercivamente uma servidão sobre prédio alheio mediante o pagamento de uma indemnização.

Há, de facto, hipóteses tipificadas na lei, em que um indivíduo exercendo um direito potestativo pode constituir uma servidão sobre prédio alheio pagando uma indemnização.

166 - Ora, quando é que é atribuído pela lei, este poder legal, que, uma vez exercido, importa a constituição efectiva de uma servidão?

A lei prevê várias hipóteses deste tipo de servidão:

a) Em primeiro lugar regulamenta as chamadas servidões legais de passagem.

Refira-se, em primeiro lugar, a servidão legal de passagem a favor de prédio encravado.

Pode - é certo - constituir-se, como aliás já vimos, uma servidão de passagem de carácter voluntário, ou seja, resultante de acordo entre as partes. Mas, na hipótese de um prédio encravado, a lei concede ao titular deste o poder de constituir coercivamente a servidão.

A esta servidão referem-se os arts. 1550.º e segs., estatuindo a primeira disposição no seu n.º 1 que "os proprietários de prédios que não tenham comunicação com a via pública... têm a faculdade de exigir a constituição de servidões de passagem sobre os prédios rústicos vizinhos", acrescentando o n.º 2 do mesmo preceito que "de igual faculdade goza o proprietário que tenha comunicação insuficiente com a via pública, por terreno seu ou alheio".

A lei também prevê a hipótese de servidão de passagem para o aproveitamento de águas.

Refere-se-lhe o art. 1556.º ao estatuir no seu n.º 1 que "quando para seus gastos domésticos os proprietários não tenham acesso às fontes, poços e reservatórios públicos destinados a esse uso, bem como às correntes do domínio público, podem ser constituídas servidões de passagem nos termos aplicáveis dos artigos anteriores".

b) Regula a lei seguidamente outras servidões - as

chamadas servidões legais de águas.

- Assim, no tocante ao aproveitamento de águas para gastos domésticos, estatui o n.º 1 do art. 1557.º que "quando não seja possível ao proprietário, sem excessivo incómodo ou dispêndio, obter água para seus gastos domésticos... os proprietários vizinhos podem ser compelidos a permitir ... o aproveitamento das águas sobrantes das suas nascentes ou reservatórios, na medida do indispensável para aqueles gastos."

- Também o art. 1558.º prevê uma hipótese de aproveitamento de águas - para fins agrícolas - ao estatuir no seu n.º 1 que "o proprietário que não tiver nem puder obter ... água suficiente para a irrigação do seu prédio, tem a faculdade de aproveitar as águas dos prédios vizinhos, que estejam sem utilização, pagando o seu justo valor".

- Por sua vez o art. 1559.º refere-se a uma possível servidão de águas designada "servidão legal de presa", ao estatuir que "os proprietários e os donos de estabelecimentos industriais, que tenham direito ao uso de águas particulares existentes em prédio alheio, podem fazer neste prédio as obras necessárias ao represamento e derivação da respectiva água..."

Decorre desta disposição que os indivíduos que preencham as condições previstas nesta disposição legal podem represar, estancar as águas, podendo impôr ao prédio alheio que se encontra do outro lado da corrente, por essa forma aproveitada, que nele se possam fazer as obras necessárias à construção de uma represa.

- O art. 1560.º refere-se também a uma servidão legal de presa no caso particular do aproveitamento de águas públicas.

- Por seu turno o art. 1561.º prevê uma outra hipótese de servidão de águas - servidão legal de aqueduto - ao estatuir no seu n.º 1 que "em proveito da agricultura ou da indústria, ou para gastos domésticos, a todos é permitido encanar, subterrâneamente ou a descoberto, as águas particulares a que tenham direito, através de prédios rústicos alheios,..."

- O art. 1562.º refere-se, também, a uma hipótese de servidão legal de aqueduto no caso específico de aproveitamento de águas públicas.

- Por último a lei refere-se, no art. 1563.º C.C. à servidão legal de escoamento. Traduz-se esta no direito que a lei atribui a um indivíduo de, em certas circunstâncias, obter que, através de prédio alheio se possa fazer o escoamento das águas que sobejam do aproveitamento do seu prédio.

São estes os casos - os dos arts. 1550.º a 1563.º referidos - de servidões legais, ou seja, aqueles em que a lei atribui a um indivíduo o direito potestativo de impôr a constituição de uma servidão.

167 - Acrescente-se, agora, numa precisão terminológica, que a expressão "servidão legal" é utilizada, não só para designar este direito potestativo de se constituirem servidões, mas também em referência à própria servidão já constituída.

A estas servidões legais opõem-se as servidões voluntárias. São aquelas que não correspondem às hipóteses onde a lei atribui o poder de produzir unilateralmente a sua constituição.

São, pois, as servidões referidas inicialmente, como resultando da vontade das partes, quer por efeito de contrato, quer de testamento, quer ainda por usucapião ou destinação do pai de família, sem existir preceito legal que as imponha.

Estas servidões de que nos estamos a ocupar - as legais - podem constituir-se, como dissemos, por sentença judicial.

Assim, por exemplo, um indivíduo que pretenda adquirir a titularidade, v.g., de uma servidão de aqueduto, das

referidas no art. 1561.º citado, pode chegar a acordo com o dono do prédio sobre o qual aquela virá a incidir. Mas, se esta solução, preferível por evitar demandas, se não vier a verificar, então, pode esse indivíduo obter sentença judicial que venha a constituir a servidão pretendida.

Alguns casos - note-se - de servidões legais de águas, ligadas a concessões de águas públicas, em vez de sentença judicial, podem ser constituídas por decisão administrativa. Neste caso a servidão é constituída, não por força de uma sentença proferida pelos tribunais, mas por uma decisão dos órgãos administrativos competentes.

D)-MODALIDADES

168 - Cabe analisar, agora, as diversas modalidades que as servidões podem revestir. Enunciaremos duas classificações.

I - VOLUNTÁRIAS E LEGAIS

169 - Os termos desta distinção já foram referidos. Repita-se, porém, que as servidões legais se tradu-

zem no poder de constituir coercivamente uma servidão, mediante o pagamento de uma indemnização, estendendo-se esta designação, como também referimos, à própria servidão constituída. Servidão voluntária é a que resulta do acordo das partes, sem haver preceito legal que a imponha.

II - POSITIVAS, NEGATIVAS E DESVINCULATIVAS

170 - Quanto ao conteúdo, as servidões são tradicionalmente classificadas em positivas e negativas.

As servidões qualificam-se como positivas, na medida em que se traduzem na permissão da prática de actos sobre o prédio serviente.

Assim, será, v.g., o caso de uma servidão de passagem. Aqui o titular da servidão pode praticar actos sobre o prédio serviente.

As servidões negativas são-no na medida em que impõem uma abstenção ao dono do prédio serviente.

Será o caso, v.g., de uma servidão de vistas ou de não edificar - "altius non tollendi".

Pode, com efeito, celebrar-se um acordo pelo qual o dono de um prédio se compromete a não edificar, constituindo-se, assim, a servidão designada por essa expressão

latina - "altius non tollendi" - diversa, portanto, da servidão de vistas.

Esta divisão dicotómica das servidões em positivas e negativas não cobre, porém, todas as hipóteses.

É que, com efeito, pode haver uma terceira categoria de servidões, não abrangida nessa distinção, servidões essas que poderemos designar por desvinculativas, segundo a proposta de OLIVEIRA ASCENSÃO (63).

O conteúdo destas servidões desvinculativas é o de libertarem o prédio dominante de uma restrição legal.

Já referimos a existência de certas restrições à propriedade, derivadas de relações de vizinhança como é o caso, v.g., da proibição de emissão de fumos sobre prédio alheio.

Figure-se agora que, por acordo, o dono de um prédio onde se vai proceder a uma determinada instalação, convenciona que o prédio vizinho tolera a emissão de fumos para este, fumos provenientes do primeiro prédio.

Estamos aqui em face de uma servidão desvinculativa, isto porque o prédio dominante é, nesta hipótese, desvinculado de certas restrições legais a que estava sujeito.

---

(63) - Ob. cit., p. 343.

E) EXERCÍCIO

171 - Segue-se tratar, agora, um outro ponto versando sobre o exercício das servidões, exercício este a que se referem os arts. 1564.º e segs.

A regra geral sobre esta matéria pode enunciar-se dizendo que as servidões têm a actuação e o modo de exercício definido no título constitutivo.

É, portanto, o título constitutivo que determinará a extensão e o exercício da servidão respectiva.

Pode, todavia, esse título não ser claro, aplicando-se, nessa altura, os arts. 1565.º e segs.

No fundo, verificando-se esta circunstância da falta de clareza de título, há uma ideia de realizar o equilíbrio de interesses entre o dono do prédio dominante e do prédio serviente.

Exemplificando:

Estatui o n.º 1 do art. 1565º que "o direito de servidão compreende tudo o que é necessário para o seu uso e conservação".

Figure-se, agora, a hipótese de constituição de uma servidão de passagem, cujo título não é suficientemente claro.

Pois bem, a lei entende que este direito de servidão engloba tudo o que é necessário para o seu uso e conservação, mas, não se encontrando a extensão e o modo de exercício deste direito real claramente definido no título constitutivo, vem a lei regulá-los, por forma a prosseguir a satisfação do duplo interesse em causa - o do dono do prédio dominante e o do dono do prédio serviente.

Nem outra justificação sugere a redacção do n.º2 da disposição citada - o art. 1565.º - ao estatuir que "no caso de dúvida quanto à extensão ou modo de exercício, entender-se-á constituída a servidão por forma a satisfazer as necessidades normais e previsíveis do prédio dominante com o menor prejuízo para o prédio serviente".

Daí decorre que, por exemplo, sendo necessário fazerem-se obras no prédio serviente, para possibilitar a passagem para o prédio dominante, essas possam realizar-se, nos termos do art. 1565.º, mas limitadas pelo agravamento da onerosidade da servidão - as obras não podem tornar a servidão mais gravosa.

Além disso, essas obras deverão ser realizadas no tempo e pela forma mais conveniente para o prédio onerado.

Estas soluções traduzem, sem dúvida, essa preocupação de equilíbrio de interesses que a lei pretende prosseguir nestas disposições legais.

Pode perguntar-se, agora: sobre quem recai o encar-

go das obras realizadas?

Se nada resulta do título constitutivo - por exemplo, do contrato, se foi este o título - ou se a servidão de passagem foi constituída pelo exercício de um direito potestativo, v.g., na hipótese do art. 1550.º referido, então o encargo das obras realizadas recai sobre o beneficiado, ou seja, o titular do prédio dominante.

Sendo vários os prédios dominantes, os encargos serão repartidos por todos, podendo, porém, qualquer deles eximir-se, caso o deseje, mediante a renúncia à servidão.

É esta uma solução justa, pois que a recusa de um dos titulares de um dos prédios dominantes em comparticipar nas despesas necessárias à constituição da passagem vai repercutir-se nos restantes titulares, onerando os seus encargos. Então é admissível a aquisição por estes da parte da servidão que competia àquele titular, sem que isto, como se vê, agrave a posição do prédio serviente.

Acrescente-se que, se o titular do prédio serviente auferir benefícios com a servidão, também ele terá de contribuir para as despesas realizadas com as obras (cfr. art. 1567.º, n.º 3 e 4).

F) MUDANÇA

172 - Pode, também, ocorrer uma mudança de servidão. Refere-se-lhe o art. 1568.º, que estatui no seu n.º 1 que "o proprietário do prédio serviente não pode estorvar o uso da servidão, mas pode, a todo o tempo, exigir a mudança dela para sítio diferente do primitivamente assinado, ou para outro prédio, se a mudança lhe for conveniente e não prejudicar os interesses do proprietário do prédio dominante, contanto que o faça à sua custa".

Há aqui a mesma ideia de conciliação de interesses, pois que, se o proprietário de um prédio serviente tem conveniência em mudar uma servidão, v.g., de passagem, sem isso prejudicar os interesses do proprietário do prédio dominante, é-lhe lícito fazê-lo, desde que o faça à sua custa.

Em obediência a esta mesma ideia de realização de ambos os interesses, a lei permite igualmente ao proprietário do prédio dominante que faça a mudança da servidão, se tal lhe for conveniente e não prejudicar o proprietário do prédio serviente.

G) EXTINÇÃO

173 - Por último, para terminar esta exposição de princípios genéricos sobre as servidões, cumpre ocuparmo-nos da sua extinção.

Como se extinguem as servidões?

Pois, refere-se a este ponto o art. 1569.º em diversas alíneas, que iremos analisar de seguida.

I - CONFUSÃO

174 - Como primeira hipótese de extinção das servidões, refere a al. a) do n.º 1 da disposição citada que estas se extinguem "pela reunião dos dois prédios, dominante e serviente, no domínio da mesma pessoa".

É este um caso de confusão, pois ambos os prédios - dominante e serviente - passam a pertencer ao mesmo proprietário - tal reunião implica, necessàriamente, a extinção da servidão. Isto porque não pode haver servidão fora da sua imposição a um prédio a favor de outro, pertença de proprietário diferente. Já os romanos exprimiam esta ideia pela máxima "nemine res sua servit".

Uma coisa própria não pode, com efeito - seria incoerente - estar onerada a favor de outra coisa própria.

II - NÃO USO

175 - A seguir refere a lei, com forma de extinção das servidões, o não uso.

Estatui, com efeito, a al. b) do n.º 1 do art. 1569.º, de que nos ocupamos, que estas se extinguem "pelo não uso durante vinte anos, qualquer que seja o motivo".

Na base desta eficácia extintiva do não uso durante vinte anos, encontra-se uma atitude hostil contra os direitos reais limitados, que não estejam a desempenhar uma função socialmente útil.

É esta uma expressão da ideia de que só devem ser impostos encargos, se existirem necessidades que os justifiquem.

Ora, o não uso vem precisamente mostrar que a coisa, no fundo, não está a ser necessária, daí que seja mais conveniente pôr termo à servidão. Não interessa manter um encargo num prédio, quando esse encargo não está a ser gozado por outro.

A servidão extingue-se, pois, pelo não uso, nos termos da lei, qualquer que seja o motivo deste.

176 - Por outro lado - é importante notá-lo -, esta não uso não coincide com a prescrição extintiva; conserva a sua autonomia em face desta.

Sabe-se que a não exigência de um crédito por um certo lapso de tempo acarreta a extinção deste.

Aqui - na extinção das servidões por não uso - passe-se algo de semelhante, mas com uma nota a salientar: este fundamento de extinção não está sujeito ao regime da prescrição extintiva.

Esta nota revela a sua importância, desde logo, na circunstância de à extinção por não uso se não aplicarem as causas de suspensão e interrupção que a lei consagra, nos arts. 318.º a 327.º, para a prescrição.

Assim, a prescrição extintiva pela não exigência de um crédito pode ser suspensa no caso de, por exemplo, o credor ser incapaz ou de se manter um vínculo conjugal entre o credor e o devedor, etc.

Ora, isto - estas causas de suspensão da prescrição extintiva - não se aplica ao não uso, como resulta claramente da parte final da disposição citada.

O que interessa, em face da al. b) do n.º 1 do art. o 1569.º, é o facto objectivo de não haver exercício da servidão durante vinte anos, enquanto, como vimos, se se tratasse de prescrição extintiva, esta bem poderia ocorrer

apenas após um prazo superior, bastando, para tanto, que se tivesse verificado a suspensão ou interrupção da prescrição.

177 - Um outro ponto que apresenta atinência com o que estamos a focar, é o referido no art. 1572.º.

Estatui esta disposição que "a servidão não deixa de considerar-se exercida por inteiro, quando o proprietário do prédio dominante aproveite apenas uma parte das utilidades que lhe são inerentes".

Significa isto que, se a servidão é exercida parcialmente, não deixa, apesar de o exercício ser apenas parcial, de se considerar exercida.

Esta solução vem dar resposta a um tipo de questões que se punha frequentemente no nosso direito, questão essa que era a da chamada "servidão de pé e carro".

Será o caso de um indivíduo deter o direito de passar por prédio alheio tanto a pé como com o carro.

Figura-se, agora, que, pelo período de vinte anos, ele exerceu essa servidão, mas passando só a pé - não levando carro, portanto.

Importará esse facto a extinção parcial da servidão, após o decurso desse tempo, ou seja, deixará ela de ser

uma servidão de pé e carro, para se restringir à uma servidão de passagem a pé?

A questão punha-se no domínio da legislação anterior, propendendo a doutrina dominante para a solução afirmativa. Haveria, assim, uma alteração, uma espécie de prescrição do modo de exercício da servidão. Não tendo a servidão sido totalmente exercida durante esse prazo, passaria a só o poder ser do modo correspondente aos actos que não deixaram de se praticar.

Actualmente já não acontece assim.

Nos termos do art. 1572.º citado, não pode verificar-se uma extinção parcial da servidão, derivada do seu não uso parcial.

O exercício parcial da servidão obsta, assim, à extinção desta.

III - "USUCAPIO LIBERTATIS"

178 - As servidões podem extinguir-se, também, "pela aquisição, por usucapião, da liberdade do prédio", segundo o estatuído na al. c) do n.º 1 do art. 1569.º.

É esta a hipótese que a doutrina designa por "usucapio libertatis"; a ela se refere, igualmente o art. 1574.º

o prédio serviente adquire a liberdade se o seu proprietário se opuser à servidão (se

ao estatuir, no seu nº. 1, que "a aquisição, por usucapião, da liberdade do prédio só pode dar-se quando haja, por parte do proprietário do prédio serviente, oposição ao exercício da servidão".

Assim, se o dono do prédio serviente se opôs ao exercício da servidão, v.g., impedindo, em dado momento, uma servidão de passagem, colocando, por exemplo, uma cancela que obste à passagem, e se o dono do prédio dominante durante vinte anos não força a passagem ou não a vem reclamar judicialmente, a servidão extingue-se por "usucapio libertatis".

Trata-se, "grosso modo" de uma aquisição, por usucapião, por parte do proprietário das faculdades, ou melhor, da parte do conteúdo do seu direito, de que estava privado pelo facto da existência da servidão. Como consequência desta aquisição - aquisição restitutiva - extingue-se a servidão.

IV - RENÚNCIA E DECURSO DO PRAZO

179 - São estas - a renúncia e o decurso do prazo - duas formas de extinção das servidões, referidas respectivamente nas als. d) e e) do n.º 1 do art. 1569.º, que não

necessitam de especial desenvolvimento.

V - DESNECESSIDADE

180 - Algumas servidões podem ainda extinguir-se por desnecessidade. Podem, com efeito, extinguir-se por essa causa autónoma, as servidões constituídas por usucapião - n.º 2 do art. 1569.º.

Assim, figure-se que se constituiu por usucapião uma servidão de passagem. A requerimento do proprietário do prédio serviente pode extinguir-se, desde que se mostre desnecessária ao prédio dominante.

Será o caso - exemplificando - de, v.g., o dono do prédio dominante passar a dispor de uma ligação com a via pública, sem lhe ser necessário utilizar aquela servidão de passagem.

As servidões constituídas por usucapião extinguem-se, portanto, desde que sejam desnecessárias, a requerimento do onerado com elas, aplicando-se idêntico regime, nos termos do n.º 3 do art.1569.º, às servidões legais.

Assim, por exemplo, pode extinguir-se uma servidão de passagem constituída a favor do prédio encravado, logo que esta se mostre desnecessária.

Tudo isto poderia sugerir que a extinção da servidão por desnecessidade derivaria, no fundo, da mesma ideia - a de que não deve haver encargos sobre um prédio a favor de outro, a não ser quando sejam necessárias. E, a ser assim, poderia então dizer-se que se deveriam extinguir por desnecessidade quaisquer servidões e não só as legais ou as constituídas por usucapião. Deveriam, portanto, extinguir-se por idêntica causa as servidões voluntárias, nomeadamente as constituídas por contrato.

As situações não são, porém, análogas.

Existe uma diferença fundamental entre, de um lado, as servidões legais, ou seja, as que, segundo a lei, se podem constituir coercivamente, e as servidões constituídas por usucapião e, do outro lado, as servidões voluntárias.

Resultando estas últimas de um acordo, este deve ser respeitado, acrescendo ainda que será difícil determinar-se quais as necessidades exactas que se pretenderam satisfazer por essa forma. Por outro lado, estas não são tão fortes que tenham compelido a lei a impôr a necessidade de as constituir.

Ora se a lei permite que por acordo se possam criar quaisquer servidões, seja qual for a sua necessidade, não se compreende que elas - as constituídas por acordo - se extingam, por se tornarem desnecessárias; de outro modo,

uma servidão que não fosse necessária, não se poderia constituir, mesmo por acordo, pois poderia terminar logo no momento seguinte.

Ora, a lei - repetimos - permite que se criem por acordo servidões que não são estritamente necessárias, de modo que elas não podem extinguir-se por desnecessidade.

Daí que as servidões voluntárias não possam estar sujeitas a esse regime de extinção; este só se compreende para as servidões legais em que a lei sancionou a possibilidade de se constituirem por haver uma necessidade nesse sentido e para as servidões adquiridas por usucapião, porque, também aí, não se verificou um facto voluntário na sua constituição.

Já aquelas servidões que têm na base um facto voluntário, permitindo a lei que se constituam mesmo quando não são estritamente necessárias, não podem extinguir-se por desnecessárias, porque, então, nem se poderiam constituir.

O facto, portanto, de existir um acordo na base das servidões voluntárias torna a situação diferente da que se verifica no domínio das servidões legais ou no das constituídas por usucapião.

VI - REMIÇÃO

181 - Finalmente, para terminarmos esta matéria falta-nos referir a extinção por remição judicial de certas servidões de águas, referida no n.º 4 do art. 1569.º. Esta disposição regula os termos em que certas servidões - as de aproveitamento de água para gastos domésticos, e do aproveitamento de águas para fins agrícolas, respectivamente nos arts. 1557.º e 1558.º oportunamente citadas - se podem extinguir por remição judicial, desde que o dono da água prove que quer fazer dela um uso justificado.

O art. 1558.º permite que um indivíduo, necessitado de água para fins agrícolas, possa aproveitar nessa medida a água de prédio vizinho não utilizada pelo dono desse prédio.

Este artigo veio consagrar uma solução com carácter algo inovador, embora não tão revolucionário como a solução paralela de outros direitos.

Em Itália, por exemplo, é possível o dono de um prédio, carecido de água para fins agrícolas, requerer e obter o direito à água, desde que, v.g., o dono do prédio, em que a água se encontre, não faça dela um uso tão justificado como o uso que aquele pretende fazer.

Assim, um indivíduo, que precisa de água para irri-

gação, pode requerer e obter a constituição do direito à água existente em prédio alheio, e cujo dono a utiliza, p. ex., para um repuxo ou quaisquer fins ornamentais.

Entre nós não acontece assim.

A solução do nosso sistema, embora traduzindo uma inovação, é menos audaciosa sob o ponto de vista do direito de propriedade, do que a solução da lei transalpina; esta possibilita uma comparação, um confronto da utilidade extraída da água pelo proprietário desta com a utilidade que dela pretende extrair o vizinho (irrigação).

Entre nós, se o dono do prédio utiliza a água, sejam quais forem os fins para que o faça (uma piscina ou um repuxo, por exemplo), o proprietário vizinho não tem direito a ela, mesmo tendo necessidades de irrigação.

Só se o proprietário da água a deixa sem utilização pode o vizinho adquirir esta servidão de aproveitamento de águas para fins agrícolas.

Ora, esta servidão do art. 1558.º, bem como a do art. 1557.º, podem extinguir-se por remição judicial, desde que o dono do prédio, onde existe a água, prove querer fazer, doravante, um aproveitamento justificado dessa água.

Pode fazer esse aproveitamento, tendo, porém, de restituir, no todo ou em parte, a indemnização recebida

(art. 1569.º, n.º 4, com remissão para o n.º 3).

A remição não pode, todavia, ser exigida antes de decorridos dez anos sobre a constituição da servidão (art. 1569.º, n.º 4).

* * *

CAPÍTULO - VI

O U S U F R U T O

A - INDICAÇÃO DE SEQUÊNCIA

182 - Para completarmos o estudo da galeria dos direitos reais de gozo mais importantes, vamos estudar agora o usufruto e essas duas figuras menores, essas duas espécies de diminutivos do usufruto que são o direito de uso e o direito de habitação.

Começaremos a nossa exposição pela noção do usufruto.

B - NOÇÃO

183 - O usufruto é o direito de gozar - de usar e de fruir - uma coisa ou um direito de outrem, sem, todavia, afectar a substância do objecto usufruído.

No termo do usufruto - o usufruto não é uma figura perpétua, tendo, como tal, um termo - o usufrutuário deve restituir a coisa ao proprietário, tornado então proprietário pleno, sem a sua substância estar alterada.

Esta definição reflecte, espelha uma definição clássica desta instituição que já vem das fontes romanas. É, assim, clássica a definição de PAULUS, jurista romano - "usufructus est jus alienis rebus utendi, fruendi salva rerum substantia".

Assim estão acentuados os poderes de uso e fruição, com ressalva da substância da coisa.

Reportando-nos, agora à clássica tripartição dos poderes do proprietário também inspirada nas obras romanistas - "jus utendi", "jus fruendi" e "jus abutendi" - constatamos que o proprietário tem o "usus", o "fructus" e o "abusus", enquanto o usufrutuário detém apenas os dois poderes primeiramente referidos - o "jus utendi" e o "jus fruendi". O usufrutuário não detém, assim, o "jus abutendi", o poder de dispor da coisa.

Toda a situação de usufruto supõe, implica um concurso de direitos reais. Onde existe um usufruto, coexiste uma propriedade esvaziada do "usus" e do "fructus".

Por esse motivo é esta propriedade clàssicamente designada por "nua propriedade" ou propriedade de raiz.

Não se infira, porém, do que dissemos - do facto de termos seccionado a propriedade em três tipos de poderes e termos dito que o usufruto abrange os dois primeiros - que o usufrutuário ou o proprietário de raiz detêm todos e quaisquer poderes que competem ao proprietário, isto é, que os poderes do usufrutuário, somados com os poderes do nu- proprietário, prefaçam os poderes do pleno proprietário.

Não é inteiramente assim, sobretudo quanto ao "abusus" - à faculdade de dispor da coisa.

O usufrutuário tem integralmente o poder de uso e de fruição, mas aqui, no concurso da nua propriedade e do usufruto, ninguém possui plenamente o "abusus", a possibilidade de dispor da coisa.

Na verdade, esse "jus abutendi" não abrange, só a possibilidade de alienar a coisa.

Isso ambos o podem fazer na medida dos seus direitos - tanto o nu-proprietário pode alienar a nua propriedade, como o usufrutuário o pode fazer no tocante ao seu

reito de usufruto.

Nenhum deles, porém, pode destruir a coisa, embora o poder de destruição seja um dos poderes contidos no "jus abutendi". Aqui, na situação de concurso entre propriedade de raiz e usufruto, ninguém tem o poder de destruir a coisa. Com efeito, nem o pode fazer o usufrutuário, porque tem que ressalvar aquele limite da substância da coisa, nem o pode fazer o nu-proprietário, porque assim violava o usufruto.

Tudo isto visa demonstrar a afirmação proferida no sentido de que o somatório dos poderes do nu-proprietário e do usufrutuário não integra os poderes da propriedade plena.

Pode ser dito é que, se o nu-proprietário e o usufrutuário se encontrarem de acordo, podem, os dois, exercitar todos e quaisquer poderes que caibam na propriedade plena.

O nu-proprietário não detém, assim, o conjunto dos poderes decorrentes do "jus abutendi", uma vez que não pode designadamente, destruir a coisa.

184 - De tudo o que dissemos resulta que o usufruto é um "jus in re aliena", um direito real sobre coisa alheia, um direito real integrado pelas faculdades de uso e

fruição sobre uma coisa que, em propriedade, pertence a outrem - o nu-proprietário -, um direito real que segundo a velha concepção de raiz romanista era classificado como uma servidão pessoal.

Esta expressão, ressuma um pouco o feudalismo à concepção feudal, mas, de facto, expressam-se assim as coisas com um certo poder de sugestão. O usufruto é uma servidão pessoal, sendo, aliás, a única existente no quadro dos direitos reais típicos do nosso sistema. É a única situação em que se dá a um indivíduo um direito sobre utilidades de um prédio alheio, direito esse que não tem de ser utilizado por intermédio de um prédio dominante, mas é, antes, individualmente usado.

Para além deste direito real - o usufruto - não há quaisquer outras servidões pessoais.

No seu âmbito estão globalmente incluídos todos os poderes de uso e fruição.

Já referimos anteriormente a não existência de servidões pessoais pelas quais um indivíduo pudesse adquirir o direito de fruição das utilidades avulsas de uma coisa, como, por exemplo, um direito de caçar.

Poderia sim surgir uma servidão predial com esse conteúdo, mas na medida em que isso se encontrasse objectivamente ligado a um direito sobre outro prédio.

Efectivamente não há servidões pessoais, com carácter de direitos reais. Podem apenas verificar-se com natureza creditícia.

Podemos dizer, agora, que o conceito explicitado corresponde claramente à noção dada no art. 1439.º ao estatuir que "o usufruto é o direito de gozar temporária e plenamente uma coisa ou direito alheio, sem alterar a sua forma ou substância.

C - CARACTERISTICAS

185 - A partir deste preceito - o art. 1439.º referido - onde nos é fornecida a noção do usufruto, bem como das normas seguintes que o regulamentam, podemos alinhar algumas características do usufruto.

Quais são essas características? - pergunta-se.

I - TEMPORARIEDADE

186 - O usufruto apresenta como primeira característica a sua temporariedade. O usufruto é um direito temporário e, no comum dos casos, vitalício.

Este carácter resulta da circunstância de o usufruto se extinguir pelo decurso do prazo, quando no título constitutivo foi estabelecido um prazo, e da de o usufruto se extinguir igualmente pela morte do usufrutuário (art. 1476.º).

Assim, desde que não haja prazo estipulado para duração do usufruto, este extingue-se pela morte do titular desse direito.

Havendo prazo estipulado, o usufruto extingue-se no termo deste, como já dissemos, excepto se, antes de decorrido o lapso de tempo pelo qual foi constituído, se verificar a morte do usufrutuário. Neste caso o usufruto extingue-se antes do decurso do prazo.

É este o regime aplicável às pessoas físicas - regime em que se encontra bem vincado o "intuitus personae".

É que, efectivamente, o usufruto é concedido a alguém durante um determinado prazo, mas nunca para além da vida do beneficiário.

"De jure condendo" poderia pensar-se no estabelecimento de um prazo máximo para o usufruto, v.g., trinta ou quarenta anos, subsistindo o direito ainda que o seu titular falecesse antes de esgotado esse lapso de tempo.

Não é, porém, essa a solução da lei. A lei não seguiu este sistema, por considerar que a única justifica-

ção suficientemente forte para superar os inconvenientes do usufruto é o seu carácter " intuitu personae".

Aceita como legítimo o interesse de um indivíduo em prover às necessidades de outrem, embora dentro de certos limites, desenhados em atenção aos inconvenientes graves do usufruto.

No tocante às pessoas físicas, o usufruto extingue-se, portanto, ou pelo decurso do prazo ou pela morte do titular, nos termos referidos.

No que se refere às pessoas colectivas, quer de direito público quer de direito privado, o art. 1443.º estabelece que a duração máxima do usufruto é de trinta anos. Traduz-se, também aqui, a preocupação do legislador em limitar o usufruto.

É que, de facto, se a lei utilizasse para a delimitação do prazo do usufruto das pessoas colectivas o mesmo critério que vimos presidir no domínio das pessoas físicas, ou seja, o de a medida do usufruto ser talhada sobre a vida do beneficiário, poderiam surgir usufrutos perpétuos a favor de pessoas colectivas, dada a sua duração normalmente indeterminada ou natureza perpétua.

187 - Poderá perguntar-se, agora, quais as determi-

nantes que levaram a lei a negar ao usufruto um carácter perpétuo, consagrando antes uma solução de transitoriedade, enquanto no tocante à propriedade admite a perpetuidade desta.

As razões dessa diferente regulamentação dos regimes do usufruto e da propriedade neste ponto são visíveis.

a) Em primeiro lugar o usufruto, na medida em que importa um desmembramento dos poderes atribuídos sobre a mesma coisa, apresenta, por isso, graves inconvenientes de ordem económica geral.

Os bens não são, com efeito, convenientemente explorados ou, pelo menos, não o são do mesmo modo que os bens em regime de propriedade plena. Não há nenhum estímulo para o melhoramento dos bens, pois o proprietário de raiz não se interessa em fazer reparações, em gastar dinheiro com a coisa usufruída, uma vez que não está a colher os seus rendimentos.

O usufrutuário, por seu lado, não deixará de ter sempre presente que o usufruto se extingue, quando ele morrer ou pelo decurso do prazo, se este tiver sido estabelecido. Essa circunstância levá-lo-á a agir segundo o critério de tirar o máximo de rendimento com um mínimo de despesas de investimento destinadas a aumentar a produtividade ou a rentabilidade da coisa fruída.

Daí que o desmembramento referido conduza a que os bens se não encontrem numa situação óptima de exploração.

b) Seguidamente, essa situação conduz a prejuízos na própria circulação dos bens, pois, a não ser que o hipotético adquirente compre o usufruto e a plena propriedade, não será fácil encontrar adquirentes para uma coisa que não é transmitida plenamente.

É que a não se realizar o acordo dos dois titulares, quanto à transmissão dos respectivos direitos, o adquirente obterá apenas um deles - o de usufruto ou o de nua-propriedade - o que não será, no comum dos casos, tão conveniente como adquirir um bem em plena propriedade.

O usufruto, como aliás todos os "jura in re aliena", apresenta esta consequência negativa, sendo esta uma das razões que determinam o princípio da tipicidade e, por outro lado, um dos motivos pelos quais os regimes sócio-políticos, que superaram o feudalismo, se orientaram decididamente para uma posição de hostilidade aos direitos reais limitados e às servidões pessoais - se orientaram contra a possibilidade de surgir uma partilha de utilidades de uma coisa entre várias pessoas.

188 - Não se conclua, porém, de todo o exposto que o usufruto só apresenta inconvenientes. Não é assim, pois o

usufruto tem, também, vantagens. No quadro dos interesses objectivos, que os homens individualmente ou em grupo prosseguem, o usufruto tem também um papel a desempenhar e presta serviços.

a) Assim, por exemplo, o usufruto permite a uma pessoa realizar algum capital, vendendo a nua-propriedade e continuando a auferir os rendimentos da coisa.

É evidente que o montante realizado será necessàriamente inferior ao que seria conseguido mediante a venda da propriedade plena. Interessa, porém, frizar que, mediante o usufruto, a pessoa pode compatibilizar a sua necessidade de realizar capital com a continuação da fruição dos rendimentos.

b) Uma outra vantagem do usufruto - e que se encontra na base da maior parte das situações respectivas - é de possibilitar a certas pessoas o proverem à situação de necessidade de outrem, mas conseguindo simultâneamente que os bens não saiam da família do disponente.

Será, v.g., o caso de um indivíduo deixar os seus bens aos seus parentes, mas, porque pretende prover à subsistência de outra pessoa, onera esses bens com um usufruto constituído a favor desta, enquanto for viva.

Por esta forma esse indivíduo consegue, por um lado, que os bens continuem dentro da sua família, como é natu-

ção corrente das pessoas e, por outro, acudir a uma situação de necessidade de outrem.

Surge novamente aqui, como é óbvio, o "intuitus personae" a justificar o usufruto.

A lei, em face das vantagens e inconvenientes do usufruto - como resultante das forças de sentido oposto que aqui actuam - consagrou a figura do usufruto com uma certa regulamentação em ordem ao melhor aproveitamento das suas vantagens e redução a um mínimo dos seus inconvenientes.

Daí que o carácter temporário do usufruto seja uma nota, onde, com muita nitidez, se constata a existência de uma síntese, resultante de uma tese, que aponta para a consagração do usufruto, e de uma artítese cujas solicitações conduziriam a resultado oposto.

II - PLENITUDE DO GOZO DO OBJECTO

189 - Outra característica do usufruto é a que se traduz no direito de gozar plenamente a coisa, como resulta, aliás, dos termos do próprio art. 1439.º referido.

Que significa esta ideia de se gozar plenamente a coisa sem alterar a sua forma e substância?

Pois bem, com esta formulação, pretende a lei explicitar que a posição do usufrutuário é mais sólida que a de outras pessoas, não obstante deterem estas igualmente certos poderes de gozo sobre uma coisa, como é o caso do locatário ou do arrendatário.

Quais são - pergunta-se agora - as manifestações deste direito de gozo pleno sobre uma coisa?

∝) ALIENABILIDADE DO USUFRUTO

190 - Desde logo o usufrutuário pode alienar "inter vivos" o seu direito, tal como resulta do n.º 1 do art. 1444.º ao estatuir que "o usufrutuário pode trespassar a outrem o seu direito ..."

Ora, é esta uma possibilidade que não assiste ao locatário. Com efeito, num arrendamento não pode haver alienação do direito sem autorização do senhorio, salvo aquele especial caso de trespasse de estabelecimento comercial ou industrial e de cessão do arrendamento para exercício de profissões liberais (cfr. arts. 1118.º e 1120.º).

O locatário não pode, assim, transmitir o seu direito, nem sublocar a coisa, sem autorização do senhorio.

Diversamente, o usufrutuário pode trespassar a terceiro o seu direito, possibilidade que se traduz numa ma-

nifestação do carácter pleno deste.

191 - Além de poder trespassar o seu direito, o usufrutuário pode também, nos termos da disposição citada, "... onerá-lo salvas as restrições impostas pelo título constitutivo ou pela lei".

Note-se que a lei, ao utilizar a expressão trespassar o direito, em vez de ceder o seu direito a outrem, fê-lo por pretender abranger aí quaisquer formas típicas ou atípicas de transferência do direito de usufruto sem se confinar à venda ou doação.

Daí que o usufrutuário passa, por exemplo, emprestar ou arrendar o seu direito.

Poderá parecer que esta possibilidade de trespasse do direito de usufruto, assim como o de o onerar, v.g., mediante hipoteca, é incompatível com o "intuitus personae".

É que, como já referimos, a lei consagrou o usufruto na medida em que este existe para satisfação das necessidades do usufrutuário. É para satisfazer este desiderato que a lei o torna legítimo.

Não há, porém, qualquer incompatibilidade entre este poder de trespasse ou de oneração do usufruto e o "intuitus personae" que o justifica. Isto porque o usufruto não exige a fruição em espécie da coisa usufruída.

Esta possibilidade confere, aliás, ao usufrutuário uma maior maleabilidade, uma maior autonomia, ao permitir-lhe tomar as medidas mais adequadas à satisfação do seu interesse.

Daí a compatibilidade do "intuitus personae", v.g., com um arrendamento do usufruto, pelo qual o seu titular recebe uma contra - prestação. Em vez de fruir a coisa em espécie, recebe uma renda paga pelo trespassário e este, com uma legitimidade transferida pelo usufrutuário, passa a dater os poderes contidos no usufruto.

Não há, portanto, - repitamos - incompatibilidade entre o "intuitus personae" e a cessão do usufruto, até porque o usufruto, uma vez transferido ou trespassado para outrem, não deixa de continuar a estar talhado à medida da vida do usufrutuário.

O facto de o usufruto ter sido transferido para outrem não significa, com efeito, que o seu prazo passe a ser contado pela medida da vida de pessoa que o adquiriu.

Este, não obstante a sua transferência, extingue-se com a morte do usufrutuário que o transmitiu.

Continua, por isso, a manifestar-se o "intuitus personae", uma vez que, exemplificado, o usufruto constituído a favor de A, e transferido por este para B, extingue-se ou à morte do transmitente, A, ou decorrido que for o pra-

zo pelo qual o usufruto foi constituído. Continua, repetindo, a duração do usufruto a pautar-se pela vida do usufrutuário, ou, no caso de ter sido o usufruto constituído a prazo, por este mesmo prazo.

Daí que algumas legislações, atendendo a esta circunstância. em vez de falarem em transferência do usufruto, falem antes em transferência do exercício do usufruto.

192 - Esta possibilidade de transferência do usufruto não é, porém, ilimitada, comportando, antes, restrições, quer de natureza voluntária, quer de carácter legal.

Podem, de facto, surgir restrições a essa possibilidade de disposição do usufruto, resultantes, desde logo, do seu título constitutivo. Será, v.g., o caso de um usufruto constituído por testamento, tendo o testador aí estipulado que o usufrutuário não poderá alienar o seu direito.

Não se esgotam, porém, aqui as restrições impostas à alienabilidade do usufruto. Estas podem surgir "ex vi legis".

Será o caso, v.g., do usufruto que os pais detém em relação aos bens dos filhos menores.

Estatui, com efeito o art. 1896.º que "o usufruto le-

gal é inalienável e impenhorável, não podendo os pais renunciar a ele em benefício do filho". O seu carácter legal é, por sua vez, expressamente afirmado no n.º 1 do art. 1893.º ao dizer que "os pais têm o usufruto dos bens do filho menor..."

Os pais não podem, por isso, alienar para terceiro o seu usufruto sobre os bens dos filhos.

193 - A transmissão do seu direito feita pelo usufrutuário, não o isenta de responsabilidade pela coisa usufruida. O n.º 2 do art. 1444.º impõe lògicamente ao usufrutuário a obrigação de responder pelos danos que a coisa sofrer por culpa da pessoa que o substitui.

Certo, o usufrutuário pode transferir o seu direito, emprestá-lo, arrendar a coisa, vender o seu direito, trocá-lo, doá-lo; em suma, transferi-lo para terceiro, embora, como já dissemos, o direito se extinga ou pela morte do usufrutuário ou pelo decurso do prazo nos termos expostos.

Se o adquirente, porém, causar danos na coisa, objecto do direito, por esses danos responde o usufrutuário perante o titular da nua propriedade.

Uma consequência importante, daí decorrente, é a verificada na hipótese de haver sido prestada caução, (como

adiante veremos, ao constituir o usufruto pode exigir-se que seja prestada caução pelo usufrutuário, como garantia de que, no termo do usufruto, a coisa, objecto do correspondente direito, se não encontra alterada. Havendo danos causados por terceiro, surge, desde logo, um fundamento para, com plena legitimidade, se não restituir ao usufrutuário a caução prestada, embora não fosse este o autor dos danos, mas o terceiro para quem o usufrutuário transmitiu o seu direito.

A lei responsabiliza, assim, o usufrutuário, directamente perante o proprietário da raiz, pelos danos causados pelo terceiro para quem a coisa foi transferida.

Daí que a existência desses danos seja considerada pela lei como causa legítima de impedimento do levantamento da caução pelo usufrutuário ou pelos herdeiros deste, no caso de o termo do usufruto se ter verificado por morte.

β) AUSÊNCIA DE ESPECIAL LIMITAÇÃO PELO FIM

194 - Uma outra manifestação do carácter pleno do usufruto é a que se traduz na circunstância de o usufrutuário não sofrer as mesmas limitações que sofre o locatário, no tocante ao fim a que a coisa se destina.

O usufrutuário pode, com efeito, usá-la e fruí-la sem afectação teleológica, enquanto o locatário tem de usar a coisa para certos fins sob pena de fundar com a sua actuação a resolução do contrato, como sucederá, v.g., na hipótese de o locatário afectar a fins comerciais uma casa que arrendou para sua habitação.

III - PRINCIPIO DA CONSERVAÇÃO DA FORMA E SUBSTÂNCIA

195 - Outra característica do usufruto, já aludida, é a que se traduz na circunstância de o usufrutuário poder gozar temporária e plenamente a coisa fruída, mas sem alterar a sua forma e substância.

Diversamente do que acontece, v.g., no código espanhol, este princípio tem natureza imperativa. Não pode estipular-se uma derrogação deste princípio de conservação da forma e substância da coisa usufruída.

Não é, portanto, possível que o usufrutuário, nomeadamente por contrato ou testamento, seja habilitado, legitimado para alterar a forma ou a substância da coisa usufruída, mediante, v.g., alienação desta, ainda que disso tenha necessidade.

196 - Diga-se que esta impossibilidade de alterar a forma ou a substância da coisa tem de ser entendida em termos hábeis.

É que há, pelo menos, uma hipótese expressamente prevista, em que as coisas podem ser alienadas ou destruídas - o caso de usufruto de coisas consumíveis. Aqui, pela própria natureza das coisas, o seu uso identifica-se com o "abusus". O uso de coisa consumível implica necessàriamente, como é óbvio, o seu desaparecimento.

Em relação a estas coisas a lei admite no art. 1451º que o usufrutuário se sirva delas ou as aliene, ficando, porém, adstrito à restituição do seu valor, findo o usufruto, no caso de as coisas terem sido estimadas. Caso contrário, caso não tenham sido estimadas, então, essa restituição será feita pela entrega de outras do mesmo género ou da mesma quantidade ou ainda do valor destas na conjuntura em que terminar o usufruto.

Na hipótese de usufruto, incidente sobre coisas consumíveis, a afirmação, segundo a qual o exercício do direito de usufruto não pode acarretar alteração da forma ou substância da coisa sobre que se processa, tem, portanto, de ser entendida em termos hábeis.

IV - USUFRUTO SOBRE DIREITOS

197 - Finalmente, como última característica do usufruto, cumpre referir que este pode incidir, nos termos do art. 1439.º, não só sobre coisas, mas também sobre direitos alheios, como seja o caso de incidir sobre créditos, sobre participações sociais, sobre direitos de autor, etc.

O usufruto pode ter como objecto, portanto, direitos e não necessàriamente coisas corpóreas.

D - CONSTITUIÇÃO

198 - Cabe ocuparmo-nos, agora, da constituição do usufruto. Como surge este? - pergunta-se.

Pois bem, o usufruto pode constituir-se por uma das quatro formas referidas no art. 1440.º

"O usufruto "estatui ésta disposição" pode ser constituído por contrato, testamento, usucapião ou disposição da lei".

Vejamos em que consiste cada uma dessas formas.

I - CONTRATO

199 - A constituição do usufruto por contrato pode operar-se de duas formas distintas:

a) Uma será a constituição "per translationem", que ocorre quando o proprietário cria directamente ao terceiro o usufruto, detendo ele a nua propriedade. Será o caso de A, pleno proprietário, passar para B o usufruto, ficando com a nua propriedade. Aqui, dá-se a constituição do usufruto "per translationem".

b) Outra será a constituição do usufruto "per deductionem", que ocorre quando o proprietário aliena a nua propriedade, ficando com o usufruto. Assim, na hipótese de A, pleno proprietário, alienar a nua propriedade a B, ficando com o usufruto, verifica-se esta forma contratual de constituição do usufruto "per deductionem".

Poderá parecer que esta distinção é um puro geometrismo sem interesse prático. Não é, porém, assim.

A importância desta dupla possibilidade de constituição do usufruto - "per translationem" ou "per deductionem" - revela-se, desde logo, no domínio da prestação de caução pelo usufrutuário. É que, nos termos do n.º 1 do art. 1469.º, o usufrutuário está dispensado de prestar caução no caso de o seu direito ter sido constituído mediante alienação com reserva de usufruto, ou seja, no caso típico de constituição "per deductionem".

Daí que o proprietário, se continuar a usufruir a coisa, limitando-se a transferir a nua propriedade, não tenha de prestar caução.

Esta só é, assim, exigida na constituição do usufruto "per translationem", ou seja, quando o proprietário cria um usufruto a favor de terceiro.

Estes contratos constitutivos de usufruto podem ser utilizados como sucedâneos do arrendamento.

Admitindo, com efeito, a lei que o usufruto se possa constituir por contrato, poderá o proprietário do prédio, em vez de o arrendar, constituir antes um usufruto.

Esta solução daria, por um lado, uma posição algo mais sólida ao adquirente e, por outro, sendo o usufruto necessàriamente de natureza temporária, apresenta vantagens de carácter pessoal para o proprietário, na medida em que lhe permitiria fugir à aplicação das normas especiais que protegem o arrendatário.

Por toda a parte, as legislações modernas manifestam-se no sentido da protecção do arrendatário, protecção que se manifesta, entre nós, por exemplo, naquela norma que impõe a renovação obrigatória do contrato de arrendamento.

A pessoa, que arrenda um prédio,corre o risco de durante décadas ter como inquilino o mesmo indivíduo, uma vez que o contrato se renova obrigatòriamente.

Ora os senhorios,zelosos na proteção do seu interesse, poderiam, em vez de arrendar, constituir um usufruto,v.g., durante cinco anos, no intuito de,decorrido esse lapso de tempo,readquirirem a propriedade plena,conseguindo por este estratagema, fugir à renovação obrigatória do contrato de arrendamento.

Diga-se, antes de continuarmos, que esta situação é paradoxal. Não deixa, de facto, de ser curioso que um direito, tido pela doutrina como um direito de crédito , como o é o arrendamento, goze de uma protecção maior do que um direito real típico, como é o de usufruto.

De facto é mesmo assim. O arrendatário tem uma muito maior possibilidade de permanecer no prédio do que o usufrutuário. Isto porque, enquanto o direito de usufruto caduca ao fim do prazo por que foi constituído, o arrendamento pode ser renovado por vontade unilateral do arrendatário.

Ora, esta fraude à lei que resultaria da constituição de um usufruto, em vez da celebração de um contrato de arrendamento, não pode ser admitida.

Daí que, para prevenir hipóteses desse tipo, se devam sujeitar obrigatòriamente ao regime do arrendamento todos os contratos que conferem o uso e fruição de uma coisa, mediante uma contraprestação que afastará de todo aquele possibilidade.

Assim, se o senhorio A cede o usufruto de um prédio a B, pretendendo por esta forma fugir às normas vinculativas que estruturam o regime do arrendamento, este contrato vale como arrendamento, dado que o négócio celebrado com fraude á lei é nulo, como resulta desde logo dos princípios gerais.

Tudo isto resulta - repitamo-lo - desta situação curiosa de o titular de um direito real - o usufrutuário - deter uma posição menos sólida, quanto à continuação do uso da coisa, do que um titular de um direito de crédito - o arrendatário, - para a doutrina dominante.

II - TESTAMENTO

200-- Outra forma de constituição do usufruto,referida no art. 1440.º,é a constituição por testamento.

Pode um indivíduo por testamento - é isto o que, aliás, se verifica estar na base da maior parte das situações de usufruto - constituir um usufruto a favor de ou-

trem, como já. noutra altura dissemos.

É este um ponto que não suscita particulares dificuldades, dispensando-nos, por isso, de especiais desenvolvimentos.

III - USUCAPIÃO

201 - Como terceira forma de constituição do usufruto, a lei refere na disposição citada a usucapião. O usufruto pode adquirir-se por usucapião.

Já se entendeu na vossa doutrina que o usufruto não podia ser adquirido por esta via.

É que a posse do usufruto é equívoca - dizia-se - uma vez que a posse do usufrutuário se analisa em termos idênticos à do proprietário. Tanto a posse de um como a do outro se traduz afinal no uso da coisa e na recolha dos seus frutos.

Daí que, não sendo possível estabelecer-se a destrinça entre essas duas situações de posse - a do usufrutuário e a do proprietário - se optasse pela impossibilidade da aquisição do usufruto por usucapião.

Esta posição negativa é, porém, dificilmente defensável em face da existência de um elemento que, com toda

a clareza, permite diferenciar a posse do usufrutuário de do proprietário. Esse é precisamente o elemento psicológico, o "animus possidendi".

À luz deste elemento psicológico distinguem-se claramente as duas situações.

Assim, figure-se um usufruto resultante de um contrato nulo por falta de forma, ou seja, um usufruto constituído por mero escrito particular, passando o usufrutuário a gozar a coisa.

Como, porém, para a constituição de direitos reais sobre imóveis é exigida escritura pública, o usufrutuário não adquiriu validamente o direito de usufruto, mas apenas a posse correspondente.

Neste caso, a sua intenção é nitidamente de usufrutuário, não podendo por isso adquirir a propriedade.

Pode, porém, adquirir o usufruto, uma vez que, estando psicològicamente na posição do usufrutuário, passou a fruir a coisa como tal. Isto não ocorrendo inversão do título.

Enquanto não se verificar uma eventual inversão do título, há apenas uma posse de um usufruto.

IV - DISPOSIÇÃO DA LEI

202 - Por último, o usufruto pode também constituir-se por disposição da lei.

São casos deste tipo de constituição o usufruto legal dos pais sobre os bens dos filhos, referido no art. 1893.º já citado, e, também, o do art. 2146.º que atribui um usufruto legal sobre parte da herança ao cônjuge sobrevivo, quando os bens do falecido são repartidos pela terceira classe de sucessíveis, nos termos das regras próprias da sucessão legítima.

É esta, aliás, a grande massa dos usufrutuários legais. Estatìsticamente, a maior parte dos usufrutos, são-no nos termos do art. 2146.º, ou seja, usufrutos do cônjuge sobrevivo sobre parte da herança.

E - USUFRUTOS SUCESSIVOS OU SIMULTÂNEOS

203 - Ainda em conexão com este ponto da constituição do usufruto cabe referir a possibilidade de se constituirem usufrutos simultâneos ou sucessivamente, nos termos do art. 1441.º.

Estatui, com efeito, esta disposição que "o usufruto pode ser constituído em favor de uma ou mais pessoas, simultânea ou sucessivamente, contanto que existam ao tempo em que o direito do primeiro usufrutuário se torne efectivo".

Decorre deste preceito que a um indivíduo é legítimo constituir um usufruto, quer simultâneamente a favor de duas pessoas, quer sucessivamente, ou seja, a favor de uma e, por morte desta ou decurso do prazo, a favor de outrem.

Poderá parecer que esta possibilidade de se constituirem usufrutos sucessivos é contrastante com o carácter temporário do usufruto.

Não é, porém, assim se se atentar no estatuído na parte final do art. 1441.º. Para se constituir o usufruto, é necessário que o segundo usufrutuário já exista no momento em que esse direito se torna efectivo.

O usufruto, ainda que sucessivo, não pode, pois, nunca ter uma duração maior do que aquele que teria, se tivesse sido directamente constituído a favor do último beneficiário.

Qualquer dos instituídos tem, portanto, de estar, ao momento da efectivação do usufruto, numa situação segundo a qual pudessem ser imediatamente nomeados.

O usufruto simultâneo tem, por isso, uma duração talha

da pela vida do último usufrutuário, excepto, como é óbvio, se, antes da morte deste, decorrer o prazo pelo qual foi constituído, no caso de o ter sido a prazo.

204 - De tudo isto decorre que se encontra excluída a possibilidade de constituição de usufrutos sucessivos a favor de concepturos.

Há que fazer, portanto, aqui, uma restrição àquela norma da capacidade sucessória que, no domínio da sucessão testamentária, permite instituir, como legatários ou herdeiros, concepturos, filhos de pessoas vivas e determinadas ao tempo da morte do autor da sucessão.

Só podem - acentue-se - beneficiar da instituição de um usufruto sucessivo ou simultâneo pessoas que existam, ao tempo em que o usufruto se tornou efectivo.

Por esta forma pretende a lei obstar aos inconvenientes já referidos.

Pode pôr-se agora o problema dos nascituros já concebidos. Poderão estes ser beneficiários da constituição de um usufruto?

Literalmente a lei parece excluir essa hipótese, ao referir-se a uma ou mais pessoas existentes ao tempo, e não há hoje nenhuma norma do tipo do art. 6.º do antigo Código Civil que diga ter o nascituro já concebido uma personalidade que retroage ao momento da concepção, aos trezentos dias anteriores ao nascimento.

Rigorosamente, nos termos da lei, o nascituro não é uma pessoa existente, não podendo, por isso, ser beneficiário de um usufruto.

A "ratio" do preceito, porém, não exclui que os nascituros possam ser beneficiários desse direito.

De facto, se se pode deixar um usufruto a uma pessoa que acabou de nascer, porque não a um nascituro já concebido? Esta possibilidade não alarga incomportàvelmente o prazo do usufruto.

Por outro lado, também a própria situação de pendência do usufruto não é muito dilatada, uma vez que, no caso de nascituros já concebidos, o seu nascimento será questão de pouco tempo, enquanto, na hipótese de concepturos, a situação de incerteza poderia prolongar-se por muitos anos.

A "ratio" não exclui, portanto, que os nascituros já concebidos possam ser beneficiados com a instituição de um usufruto simultâneo ou sucessivo.

De qualquer forma - acrescente-se - é esta uma questão duvidosa. Com inteira segurança pode apenas afirmar-se que os concepturos - esses sim - estão totalmente excluídos da possibilidade de serem instituídos usufrutuá-

rios.

205 - Diga-se, por último, a terminar a exposição da problemática ligada à constituição do usufruto que, no usufruto simultâneo, existe um direito de acrescer, não só quando esse direito resulte de testamento, mas também quando seja constituído por contrato.

Assim, se alguém deixa um usufruto simultâneamente a duas pessoas e uma delas falece, a outra adquire o usufruto de toda a coisa. O falecimento de um dos co-usufrutuários não atribui ao outro apenas metade do usufruto. O outro adquire-o na sua totalidade.

O fundamento material desta solução é uma presunção correspondente à vontade presumida das partes. Presume-se com efeito que, constituindo-se por testamento ou contrato um usufruto simultâneo sobre um prédio, pretendeu-se fazer incidir virtualmente, sobre toda a coisa, o direito das pessoas instituídas.

Figure-se, assim, que um indivíduo atribui por testamento aos seus dois únicos sobrinhos um usufruto sobre o único prédio que lhe pertence.

No fundo, o testador pretende deixar-lhes a totalidade do usufruto. Como são dois os instituídos, divide o direito ao meio, mas, se tivesse um único sobrinho, este seria o beneficiário da totalidade do usufruto.

O testador pretende, portanto, que cada um dos seus sobrinhos tenha, neste caso, um direito de usufruto virtualmente extensível à totalidade da coisa usufruída.

É com este fundamento material que o art. 1442.º vem consagrar o direito de acrescer destes usufrutuários simultâneos, quer o seu direito resulte da disposição testamentária, quer de um contrato.

F - DIREITOS DO USUFRUTUARIO

I - DOUTRINA GERAL

206 - Vamo-nos referir agora aos direitos do usufrutuário, começando por referir o usufruto em geral.

Vamos, assim, falar dos poderes do usufrutuário sobre a coisa usufruída.

Poderia pôr-se antes a questão dos poderes do usufrutuário relativamente ao próprio usufruto. Já atrás nos referimos, porém, a este ponto.

Dissemos, então, que o usufrutuário pode alienar ou hipotecar o seu direito de usufruto; pode defender esse seu direito, exercitando acções possessórias ou acções do

tipo da acção de reivindicação - a chamada acção confessória do usufruto (uma "vindicatio usufrutus").

Não é este o ponto que agora temos em vista, mas antes o de focarmos os direitos do usufrutuário sobre a coisa usufruída.

207 - Como regra geral poderá citar-se o art.1445.º que apela para o título constitutivo do usufruto.

É o que decorre desta disposição, ao estatuir que "os direitos e obrigações do usufrutuário são regulados pelo título constitutivo do usufruto; na falta ou insuficiência deste, observar-se-ão as disposições seguintes".

Significa esta disposição que há uma certa variabilidade do conteúdo do usufruto, uma vez que é possível estipular-se uma dimensão de poderes e um conteúdo do usufruto, variáveis de caso para caso.

Não existe, por isso, uma configuração rígida do usufruto.

Normalmente, contudo, o que se verifica é uma ausência de estipulação das partes, havendo então lugar à aplicação de normas dispositivas. Nessa altura o usufruto vê o seu conteúdo delimitado e conformado pelas normas supletivas.

Aliás, no tocante aos poderes das partes de conformarem o conteúdo do usufruto, cremos que se pode excluir uma ou outra utilidade, um ou outro produto útil, não implicando, porém, esta faculdade o poder-se ir ao ponto de fazer incidir o usufruto sobre a fruição de uma só utilidade.

Cremos, com efeito, que esta solução significaria o subverter-se o princípio segundo o qual não há servidões pessoais.

Há - é certo - uma certa liberdade de conformação interna do usufruto, mas isto não quer dizer que se possam criar usufrutos, incidindo apenas sobre a fruição de uma utilidade. Isto porque, admitir-se esta possibilidade, implicaria a concessão de uma ampla liberdade de criação de servidões pessoais.

Sendo assim, então, esta liberdade de conformação interna do usufruto significa que, em princípio, o usufruto incide sobre todas as utilidades da coisa, podendo, porém, como dissemos, excluir-se uma ou outra utilidade da coisa.

É nesta medida que pode dizer-se que o conteúdo do usufruto é variável.

208 - Quais são então - pergunta-se - essas normas supletivas que definem o conteúdo do usufruto?

Responde-nos o art. 1445.º ao estatuir que "o usu-

frutuário pode usar, fruir e administrar a coisa ou o direito como o faria um bom pai de família, respeitando o seu destino económico ".

Decorre desta disposição que o usufrutuário pode usar a coisa para seu uso pessoal, fruí-la, colhendo directamente os frutos respectivos ou arrendando-a, se, por exemplo, se tratar de um prédio - aliás, os arrendamentos feitos pelo usufrutuário nos termos da al. c) do art. 1051.º caducam no termo do usufruto -, e administrá-la como um bom pai de família, ressalvando o seu destino económico.

Esta referência ao padrão do pai de família implica o recurso a uma cláusula geral, a um "standard". O Código anterior referia-se a um proprietário prudente, como o faria um bom administrador mas, no fundo, esta diferente formulação equivale à do Código actual.

Nesta linha, o usufrutuário não pode, como é óbvio, deixar de fazer obras de conservação ou, pelo uso excessivo e imoderado da coisa, prejudicar a sua normal rentabilidade.

Do mesmo modo, não pode abster-se de utilizar processos técnicos de cultura da terra, que se apresentem como os mais convenientes à conservação da coisa.

Tudo isto significa que o usufrutuário tem de proceder como procederia um bom administrador, sendo este o

sentido que, em última análise, se deve atribuir ao padrão do "bonus paterfamilias".

Dentro destes poderes de usar, fruir e administrar que competem ao usufrutuário estão abrangidas, nos termos do art. 1449.º já referido, não só as coisas acessórias ou as acessões que vêm acrescer à coisa, mas também todos os direitos inerentes à coisa usufruída. Será este o caso das servidões, por exemplo.

209 - Uma outra nota a que o princípio geral enunciado no art. 1446.º alude, é a de que o usufrutuário tem de respeitar o destino económico da coisa ou seja que o usufrutuário pode usar e fruir a coisa desde que respeite o seu destino económico.

Daí decorre, "a contrario sensu", que o usufrutuário não pode alterar o destino económico da coisa usufruída. Não pode, por exemplo, transformar um pomar ou um prédio rústico num campo de jogos ou, v.g., uma casa de habitação num estábulo.

O destino económico que a coisa tem, deve, assim, ser conservado; o usufrutuário tem que respeitar esse elemento de carácter teleológico.

Esta vinculação do usufrutuário, que acabamos de referir, não é, em última análise, mais do que uma expres-

são da falta do "jus abutendi", ou seja, da falta do direito de dispor da coisa, direito que precisamente existe no domínio da propriedade plena.

210 - Ainda no tocante aos poderes do usufrutuário cumpre referir a possibilidade de se levantarem vários problemas a propósito quer do início, quer do termo do usufruto.

Assim, pode, desde logo, perguntar-se qual o regime aplicável ao usufrutuário, quer no início quer no termo do seu direito, no tocante aos frutos da coisa usufruída.

Poderia pensar-se, aqui, num princípio de reciprocidade conducente a que, v.g., o usufrutuário tivesse direito aos frutos pendentes no início do usufruto e deixasse de os ter quanto aos de idêntica natureza no termo do seu direito, ou valesse em ambos os momentos a solução contrária.

Não é, porém, esta a solução da lei. Esta não consagra qualquer princípio de reciprocidade, como resulta claramente do disposto na primeira parte do art. 1447.º, ao estatuir que "o usufrutuário, ao começar o usufruto, não é obrigado a abonar ao proprietário despesa alguma feita; ...".

Resulta desta disposição que os frutos que estejam já em maturação, como será por exemplo o caso de uma vinha próxima da colheita, no momento em que se constitui o usufruto, esses frutos podem ser integralmente colhidos pelo usufrutuário, sem que este tenha, não obstante, de abonar qualquer despesa feita.

Esta solução baseia-se numa presunção de vontade. A lei presume que a vontade do instituidor se manifestaria no sentido de pretender que o beneficiário do usufruto passe, logo após a instituição, a colher os frutos da coisa.

No tocante ao termo do usufruto, a lei estabelece na segunda parte do art. 1447.º citado que "... findo o usufruto, o proprietário é obrigado a indemnizar aquele (o usufrutuário) das despesas de cultura, sementes ou matérias primas e, de um modo geral, de todas as despesas de produção feitas pelo usufrutuário, até ao valor dos frutos que vierem a ser a colhidos".

Decorre deste preceito que, no termo do usufruto, a solução consagrada conduz a um resultado inverso do verificado no início desse direito.

Efectivamente, no termo do usufruto, o proprietário é que vai colher os frutos, tendo, porém, que abonar as despesas de cultura, sementes e matérias primas, etc., realizadas pelo usufrutuário.

Esta solução justifica-se pelo intuito de evitar um locupletamento do proprietário da raiz à custa do usufrutuário, que se verificaria com outra solução que não a legal. Por outro lado, o regime da lei afasta o inconveniente de, no último ano do usufruto, o usufrutuário se quedar numa atitude inércia. É que ele seria, nesse momento, naturalmente sugestionado no sentido de se manter inactivo, se o usufruto terminasse antes da colheita, uma vez que não seria indemnizado das despesas realizadas com a produção.

Não há, por isso, reciprocidade. Isto porque, como vimos, o usufrutuário recebe desde logo os frutos que possam ser colhidos após o início do usufruto, sem ter que indemnizar qualquer despesa, enquanto no termo do usufruto, os frutos produzidos pertencem ao proprietário, mas este tem que indemnizar aquele das despesas realizadas para a sua produção.

211 - O usufrutuário tem pois, o direito de usufruir, uma vez que o usufruto abrange, além do direito de uso, o direito aos frutos.

O que são frutos ? - pode perguntar-se.

A noção de frutos encontra-se na parte geral do Código Civil, definindo-os o n.º 1 do art. 212.º desse di-

ploma ao estatuir que "diz-se fruto de uma coisa tudo o que ela produz periòdicamente, sem prejuizo da sua substância".

"Os frutos são naturais ou civis"; continua o n.º 2 dessa disposição, e "dizem-se naturais os que provêm directamente da coisa, e civis as rendas ou interesses que a coisa produz em consequência de uma relação jurídica".

Exemplificando estas duas categorias, podem enunciar-se para a segunda - frutos civis - os juros, foros, rendas, alugueres, etc., e para a primeira - frutos naturais - os que o terreno ou a coisa produz naturalmente.

Um ponto importante conexionado com esta matéria é o de que o usufrutuário tem direito aos frutos mas não tem direito aos chamados produtos.

Há, de facto, aqui uma importante distinção a fazer entre frutos e produtos.

Produtos são, também, derivações da coisa, mas que esgotam a sua substância, enquanto os frutos, como diz a lei, na disposição citada, sendo colhidos periòdicamente, não prejudicam a sua substância.

Assim, exemplificando, figure-se uma pedreira.

A pedra extraída do terreno não é um fruto, mas um produto, uma vez que a sua extracção implica, como é óbvio, o esgotamento do terreno. E o mesmo se diga a propó-

sito do corte de árvores de uma mata, salvo o caso de a exploração desta residir, precisamente, na madeira produzida. Neste caso as árvores, pertença de uma mata de corte ou de talhadiço, que tem mesmo este destino económico, constituem frutos. Mas se assim não acontece, se segundo os usos a mata não tem esse destino económico, então as árvores cortadas constituem produtos do terreno, não cabendo por isso ao usufrutuário.

212 - Também quanto à forma como os frutos são recolhidos há uma importante distinção a fazer.

É que nos termos do n.º 1 do art.º 213.º, os frutos naturais são adquiridos ou até um momento determinado ou a partir desse momento, pertencendo ao usufrutuário os frutos percebidos durante a vigência do seu direito.

Segue-se, portanto, aqui, a doutrina da percepção.

Pertencem ao usufrutuário os frutos naturais que se percebem, que se colhem dentro dos limites temporários do usufruto. O titular desse direito tem, assim, direito a todos os frutos que se vencem durante o usufruto.

É, assim, o momento da colheita, o momento da percepção, que vigora, prevendo a lei, para obstar a que esta disposição seja iludida, sanção para as colheitas prematuras.

Poderia pensar-se, aqui, num critério de proporcionalidade, segundo o qual o indivíduo que esteve na fruição do bem, por exemplo, por três meses, período correspondente a metade do ciclo produtivo desse bem, receberia também apenas metade dos frutos.

Não é porém esta a solução da lei.

Segundo esta, se a colheita se verifica num momento anterior aos seis meses, o usufrutuário recebe todos os frutos; se posteriormente, não tem direito a quaisquer deles, assistindo-lhe apenas, no caso de ter realizado despesas para a sua produção, o direito a ser indemnizado por essas despesas.

Já no tocante aos frutos civis, a lei não adoptou esse sistema, aceitando antes um critério de proporcionalidade. Os frutos distribuem-se "pro rata temporis".

Assim, no caso de uma renda anual de um prédio, se o usufruto dura apenas meio ano, o usufrutuário recebe apenas metade da renda.

Como se justifica esta diferença de regimes?

É que, no tocante aos frutos civis, pode-se estabelecer, com um grau suficiente de certeza, um critério de proporcionalidade - é uma pura questão aritmética.

Já no referente aos frutos naturais não é fácil determinar os resultados da aplicação desse critério de pro

porcionalidade. Daí que a lei tenha adoptado um sistema, embora mais drástico, mais seguro ou mais certo que é o de se atender ao momento da "perceptio" ou percepção dos frutos. Não é, por isso, quem semeia que tem direito aos frutos, mas quem colhe. Se o usufruto vigora durante o tempo da colheita, o usufrutuário é o dono dos frutos.

Aliás, doutro modo, poderia haver uma dificuldade, quanto aos frutos naturais, mormente quanto a saber a que período se atendia - se ao ano civil, se ao ciclo produtivo do bem em questão.

Por outro lado, este período pode variar consoante os usos locais e respectivos costumes, ou segundo a técnica de produção, etc., o que se traduz num elemento de incerteza.

Daí que a lei prefira seguir um critério mais claro e mais seguro que é o de atender ao momento da percepção. Tem os frutos quem detém a coisa no momento da percepção, quem a frui no momento da percepção dos frutos.

213 - Pode também o usufrutuário realizar benfeitorias na coisa usufruída, quer úteis, quer voluptuárias, desde que, nos termos do art. 1450.º "não altere a sua forma e substância, nem o seu destino económico".

Aplica-se, quanto às benfeitorias, o mesmo regime do

possuidor de boa fé.

213-a - Finalmente, importa focar o estabelecido no art. 1448.º sobre a alienação dos frutos antes da colheita.

O que decide é, como vimos, o momento da "perceptio", mas, se o usufrutuário alienar frutos antes da colheita e o usufruto se extinguir antes desta, a alienação subsiste, revertendo o seu produto a favor do proprietário.

É esta uma regra que se destina a dar conteúdo prático ao princípio de que o que releva neste domínio, é o momento da colheita, ou seja, da percepção dos frutos, reagindo, assim, contra uma alienação prematura. O facto de o usufrutuário alienar antecipadamente os resultados da colheita não lhe traz quaisquer benefícios, uma vez que, por força dessa disposição legal, o produto recebido terá de ser integralmente entregue ao proprietário de raiz, deduzidas, porém, as despesas realizadas com o cultivo no caso de haver lugar a isso.

II - CASOS ESPECIAIS

214 - Referimo-nos até agora ao usufruto em geral, seguindo-se analisar o usufruto em especial, ou seja, incidente sobre determinadas coisas ou determinadas categorias de bens.

A lei regula entre os art.s 1451.º e 1467.º, que iremos passar em revista na sua totalidade, o usufruto de certas coisas, de determinadas categorias de bens, isto porque era necessária uma previsão especial do usufruto que incida sobre certos objectos.

É que a natureza e a constituição destes objectos criam problemas específicos, maxime no que se refere à individualização, à determinação dos frutos.

Surgem, por exemplo, problemas específicos na hipótese de o usufruto incidir, por exemplo, sobre um rebanho, sobre uma quota de uma sociedade, sobre x pipas de vinho, problemas contrastantes com os suscitados pelo usufruto de, por exemplo, um prédio.

215 - A lei regula, desde logo, nesta linha de especificidade, o usufruto de coisas consumíveis, no art. 1451.º.

Pode surgir liminarmente uma dúvida neste domínio. É que parece, à primeira vista, que o usufruto é incompatível com as coisas consumíveis.

De facto, se nas coisas consumíveis o "usus" se confunde com o "abusus" - se o uso delas implica o seu desaparecimento - então, parece que o usufruto não devia sequer abranger essa categoria de coisas.

A doutrina tradicional fala realmente aqui em quase-usufruto ou usufruto impróprio, porque, como resulta da própria natureza da coisa, a substância desta parece não se poder, pelo menos especìficamente, manter quanto ao usufruto de coisas consumíveis.

Ora, a lei, todavia, dá a possibilidade prática de se constituirem usufrutos de coisas consumíveis, tornando esta dificuldade ao estatuir que o usufrutuário se pode servir das coisas ou aliená-las constituindo-se, porém, na obrigação de restituir o seu valor, findo o usufruto, no caso de as coisas terem sido estimadas.

Assim, se um indivíduo é usufrutuário de uma herança e nesta estão incluídos, por exemplo, cereais ou vinho, o usufruto incide também sobre estes.

Pode-se, nesta hipótese, determinar o valor desses bens e é esse valor que o usufrutuário tem que restituir, terminado o seu direito.

Pode, porém, acontecer que essa estimativa não tenha sido efectuada. Neste caso o usufrutuário é obrigado a

restituir coisas do mesmo género, qualidade ou quantidade.

Não é, portanto, em hipóteses deste tipo, a própria coisa que é restituída, mas outra equivalente.

Daí que se fale aqui, como já dissemos, em quase--usufruto ou usufruto impróprio.

Por outro lado, o n.º 2 do citado art. 1451.º consagra um princípio que apresenta alguma importância: o usufruto de coisas consumíveis não importa transferência de propriedade para o usufrutuário.

Esta solução pode apresentar relevância para vários efeitos.

Desde logo, para efeitos de risco pela deterioração da coisa. É que, em face daquele princípio, o proprietário é o chamado proprietário da raiz. Em caso de deterioração, o usufrutuário deixa de poder gozar a coisa e, simultâneamente, o proprietário deixa de poder exigir a sua restituição.

É precisamente para conseguir uma solução deste tipo que a lei diz que o usufruto de coisas consumíveis não atribui a propriedade ao usufrutuário, embora este princípio se apresente como pouco lógico quando encarado na perspectiva de um logicismo jurídico puro.

É que, numa consideração puramente lógica, é difícil admitir-se que um indivíduo não seja proprietário de uma

coisa que pode, porém, consumir, destruindo-a. Em lógica jurídica pura, o usufrutuário devia ser proprietário desses bens em espécie.

De facto, podendo consumi-los, tudo se passará como na hipótese de um indivíduo comprar uma coisa que, passando a ser sua, pode livremente gastar, alienando-a ou consumindo-a.

A lei considerou, porém, que seria injusto tornar o usufrutuário proprietário.

Assim, em matéria de risco, se ele fosse proprietário, perecida a coisa, o risco corria por conta dele e, uma vez extinto o usufruto, o proprietário da raiz poderia exigir-lhe a restituição do respectivo valor.

É, portanto, uma situação deste tipo que a lei teve em vista, ao estatuir que o usufruto não importa, aqui, o direito de propriedade, donde resulta suportarem os dois o risco. O proprietário da raiz porque, perecendo a coisa, esta perece por sua conta o risco; o usufrutuário porque perde o usufruto, não estando, porém, adstrito à restituição do valor correspondente, diversamente do que aconteceria se ele fosse o proprietário das coisas. Neste caso o risco seria, como já dissemos, totalmente suportado por ele. Logo, quando se extinguisse o usufruto, teria de restituir o seu valor ao proprietário da raiz que, por

seu turno,não suportaria risco nenhum.

216 - A lei refere-se, também, no art. 1452.º ao usufruto de coisas deterioráveis.

Podem, de facto, existir coisas que, não sendo consumíveis,não se destruindo, portanto, pelo seu uso, vão , não obstante, perdendo progressivamente o valor.

Será, v.g., o caso de um automóvel. O usufruto que incida sobre um automóvel vai diminuindo, pouco a pouco,o valor deste.

Ora, em casos como este, a lei regula a situação em termos algo diversos dos utilizados para a regulamentação das coisas consumíveis, ao considerar aplicável integralmente aqui a disciplina do usufruto.

Assim, diversamente do que vimos acontecer no domínio das coisas consumíveis, aqui não há lugar à restituição do valor das coisas objecto do usufruto. As coisas deterioráveis são restituídas pelo usufrutuário, findo o usufruto, no estado em que se encontram.

O usufrutuário de um automóvel usufruído durante dez ou vinte anos, não tem de restituir um automóvel de valor idêntico ao usufruído no início do direito de usufruto. Limita-se a restituir a coisa com o valor que esta tem no termo do usufruto, excepto se a sua deterioração resultou de utilização diversa da que lhe era própria.

Portanto, resumidamente, pode dizer-se que, do confronto de regimes aplicáveis ao usufruto de coisas consumíveis e ao de coisas deterioráveis, resulta não implicar o uso normal destas, segundo o seu próprio destino, qualquer obrigação de restituição de valor no termo do usufruto. Já o uso de coisas consumíveis acarreta, nesse momento, essa reposição de valor, se foram estimadas, ou a restituição de outras do mesmo género ou qualidade ou ainda o respectivo valor na conjuntura então existente.

217 - Seguidamente regula a lei muitas outras situações de usufruto.

Desde logo,dispõe nos arts. 1453.º a 1456.º sobre o usufruto de árvores e arbustos de matas, árvores de corte, plantas de viveiro. É que ocorrem problemas específicos relacionados com esta matéria, particularmente no tocante ao usufruto de matas e árvores de corte.

Assim, referindo-se-lhe, o n.º 1 do art. 1455.º dispõe que "o usufrutuário de matas ou quaisquer árvores isoladas que se destinem à produção de madeira ou lenha deve observar, nos cortes, a ordem e as praxes usadas pelo proprietário ou, na sua falta, o uso da terra".

Esta disposição vem ao encontro do que atrás disse-

mos sobre a destrinça entre frutos e produtos, no caso particular das árvores. É que estas, qualificando-se, em princípio, como produtos, devem, porém, na hipótese prevista no art. 1455.º, em que o usufruto incide sobre matas cuja utilização reside no corte periódico de madeira, ser consideradas como frutos. Tem, então, o usufrutuário direito a fazer esses cortes, segundo as praxes usadas pelo proprietário ou, na sua falta, segundo os usos da terra.

O usufrutuário pode, portanto, cortar árvores da mata sobre que incide o seu direito do usufruto, enquanto se possam considerar frutos, mas já não quando essas árvores revistam a natureza de capital. Pode dizer-se que, na hipótese de uma mata de talhadio, o usufrutuário só pode cortar as árvores-frutos, não podendo cortar todas as árvores existentes na mata, por parte delas constituirem capital (por exemplo, as árvores de renovação).

Será idêntica a aplicação destas considerações na hipótese de usufruto incidente sobre um pomar. Aqui o usufrutuário pode colher os frutos das árvores, mas já não as pode cortar por constituirem capital.

E o mesmo se diga no caso de usufruto incidente sobre uma mata utilizada pelo seu proprietário para fins ornamentais. Aqui não poderá o usufrutuário proceder ao

corte de árvores, uma vez que estas constituem, como se vê, capital.

218 - O art. 1457.º prevê a hipótese de usufruto incidindo sobre a exploração de minas.

Por sua vez o art. 1458.º ocupa-se do usufruto que incide sobre exploração de pedreiras.

O regime desta disposição inspira-se na ideia atrás referida de que a pedra é um produto, não tendo, por isso o usufrutuário direito a ela.

É precisamente esta ideia que justifica a proibição do n.º 1 do preceito citado, imposta ao usufrutuário, de abrir novas pedreiras, sem o consentimento do proprietário. Isto, porque a extracção da pedra altera a substância da coisa usufruída na medida em que esgota a terra.

Porém "... se elas já estiverem em exploração", continua o n.º 2 do art.1458º, "ao começar o usufruto, tem o usufrutuário a faculdade de explorá-las, conformando-se com as praxes observadas pelo proprietário".

Decorre desta disposição que, se o usufruto incide sobre algo que já é uma pedreira quando esse direito de usufruto se constitui, então, nesse caso, a pedra qualifica-se como fruto do bem usufruido.

Diversamente, se um indivíduo é tornado usufrutuário

de um terreno, não pode, nesta hipótese, começar a explorar uma pedreira nesse terreno, uma vez que a pedra nele contida só é classificável como produto.

219 - Por sua vez no art. 1462.º a lei estatui sobre o usufruto incidente sobre universalidades de animais.

Levantam-se neste domínio problemas particulares, nomeadamente o da qualificação das crias.. Deverão estas ser consideradas frutos ou produtos, destinando-se, neste caso, a compensar as espécies que, por qualquer motivo, vêm a faltar?

Os critérios, bastante minuciosos, para solução desta questão encontram-se enunciadas na disposição citada, dispensando-nos de desenvolvimentos.

220 - O mesmo se diga acerca do usufruto incidente sobre dinheiro, capitais levantados ou títulos de crédito. O usufrutuário tem direito aos juros correspondentes à duração do usufruto e à fruição dos prémios ou outras utilidades aleatórias produzidas pelo título (por exemplo um prémio atribuído por sorteio aos titulares de títulos de crédito emitidos por uma instituição bancária). Também a lei é clara quanto ao usufruto de títulos de participação (v.g., usufruto de um lote de acções).

Toda esta matéria se encontra respectivamente regulada nos arts. 1464.º a 1467.º C.C.

G - OBRIGAÇÕES DO USUFRUTUÁRIO

221 - Cabe ocuparmo-nos, agora, de uma outra matéria, versando sobre as obrigações do usufrutuário.

Quais são as obrigações do usufrutuário? - pergunta-se.

As obrigações do usufrutuário iniciam-se, cumpre dizê-lo, mesmo antes do começo do usufruto.

O usufrutuário deve, com efeito, nos termos do art. 1468.º, proceder a um inventário, isto é, deve relacionar os bens, declarando o seu estado, bem como o valor dos móveis se os houver.

Seguidamente, de acordo com a al.b) da disposição citada, deve o usufrutuário prestar caução, se esta lhe for exigida.

Daí resulta òbviamente que ao proprietário é tão lícito exigir a caução como adoptar conduta inversa, nada exigindo.

A caução, porém, quando prestada, destina-se a co-

brir a responsabilidade do usufrutuário pela restituição da coisa no termo do usufruto ou por quaisquer deteriorações que venha a causar na coisa usufruida.

Ocorrem, todavia, certas situações em que há dispensa de caução, situações essas previstas no art. 1469.º.

Assim acontecerá, em primeiro lugar, na hipótese de constituição de usufruto "per deductionem", ou seja, nos casos de alienação de uma coisa com reserva de usufruto.

A lei entende haver aqui dispensa de caução como, aliás, acontece nos usufrutos legais, no caso do usufruto dos pais nos bens de filhos menores.

A lei confere, nos termos do art. 1893º, aos pais o usufruto legal dos bens dos filhos menores, salvas as excepções aí enunciadas, dispensando-os de prestar caução pelo estatuido nos n.ºs 1 dos arts. 1469.º e 1897.º, Consagrando-se porém, nesta última disposição, algumas situações de excepção.

Finalmente, como já aludimos, o usufrutuário pode, nos termos do n.º 2 do art. 1469º, ser dispensado no título constitutivo, de prestar caução.

222 - Pode, porém, a caução não ser prestada, perguntando-se, então, quais as consequências que a lei liga a essa circunstância.

Poderia pensar-se, desde logo, numa medida drástica do tipo de extinção do usufruto por falta de caução.

Não foi, porém, esta a solução adoptada.

As consequências da não prestação de caução vêm enunciadas no n.º 1 do art. 1470.º que estatui: "Se o usufrutuário não prestar a caução devida, tem o proprietário a faculdade de exigir que os imóveis se arrendem ou ponham em administração, que os móveis se vendam ou lhe sejam entregues, que os capitais, bem como a importância dos preços das vendas, se dêem a juros ou se empreguem em títulos de crédito nominativos, que os títulos ao portador se convertam em nominativos ou se depositem nas mãos de terceiro, ou que se adoptem outras medidas adequadas".

Uma vez adoptadas as várias providências previstas para as diferentes categorias de bens, o usufrutuário limitar-se-à, então, a receber os rendimentos, em vez de usufruir directamente os bens.

Neste caso o usufrutuário deixa, como é óbvio, de se encontrar numa situação que possa envolver responsabilidade. Esta só surgiria, se se encontrasse na posse das coisas e não na mera situação de receber, v.g., as rendas, os juros, etc.

223 - Como restantes obrigações só há a salientar o prescrito nos arts. 1472.º e 1473.º, versando sobre matéria de reparações.

O princípio enunciado na primeira dessas disposições relativa às reparaçõec ordinárias é o de que cabem ao usufrutuário as reparações ordinárias indispensáveis para a conservação da coisa e as despesas de administração.

A lei define, por outro lado, esse tipo de reparações de acordo com um critério teleológico, de finalidade. Ordinárias são aquelas reparações necessárias à conservação da coisa.

A lei estabelece-lhes, porém, um limite baseado num critério de valor ao estatuir no n.º 2 da disposição citada que "não se consideram ordinárias as reparações que,no ano em que forem necessárias, excedam dois terços do rendimento líquido desse ano".

Da conjugação destas duas estatuições resulta, assim, que qualquer despesa realizada em vista à conservação da coisa usufruida é qualificável como despesa de reparação ordinária, excepto se comprometer mais de dois terços do rendimento líquido, da coisa usufruida no ano em que são necessárias.

Por último, tal como acontece com outras obrigações "propter rem", pode o obrigado eximir-se do encargo por

abandono liberatório do seu direito, ou seja, no caso concreto, "o usufrutuário pode", nos termos do n.º 3 do art. 1472.º referido ,"eximir-se das reparações ou despesas a que é obrigado, renunciando ao usufruto".

Quanto às reparações extraordinárias, essas cabem ao proprietário. O usufrutuário não tem, assim, o dever de as realizar, cumprindo-lhe apenas avisar o proprietário para que este as efectue.

Porém - note-se - este não é obrigado à fazê-las directamente.

Só que, se, uma vez notificado, o proprietário não realiza as reparações extraordinárias se elas forem de utilidade real, o usufrutuário pode então, efectuá-las a expensas daquele. Melhor, a expensas suas,mas virá a ser reembolsado do montante dispendido ou será pago, no fim do usufruto, do valor que as benfeitorias tiverem nesse momento.

Não há, portanto, aqui pròpriamente uma obrigação que tenha de ser executada em espécie pelo proprietário.O usufrutuário avisa-o, o proprietário não procede às reparações, e, então, aquele procede a elas a expensas suas, exigindo ao proprietário a sua importância ou exigindo,no termo do usufruto, o valor das benfeitorias que resultaram dessas reparações para o bem usufruido.

H - EXTINÇÃO

224 - A terminar a exposição do direito real de usufruto, de que nos temos vindo a occupar, cabe referir, agora, a problemática ligada à sua extinção que não apresenta, aliás, especial complexidade.

As causas de extinção do usufruto vêm referidas no art. 1476.º C.C.

I - MORTE OU DECURSO DO TEMPO

225 - Assim, a al. a) do n.º 1 desta disposição enuncia uma primeira causa de extinção, ao estatuir que o usufruto se extingue "por morte do usufrutuário, ou chegado o termo do prazo por que o direito foi conferido, quando não seja vitalício".

É esta uma manifestação do carácter pessoal do usufruto. De facto, sendo este constituido " intuitu personae" é lógico que, falecido o usufrutuário, se extinga esse seu direito.

Por outro lado, tratando-se de um usufruto constituído por tempo determinado o decurso desse prazo acarreta necessàriamente o termo do usufruto.

II - CONFUSÃO

226 - Seguidamente a al. b) do mesmo preceito dispõe que o usufruto se extingue "pela reunião do usufruto e da propriedade na mesma pessoa".

Ocorre, aqui, uma situação semelhante à que, no âmbito dos direitos de crédito, se designa por confusão. Assim, tal como as obrigações se extinguem pela reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor, também, no domínio do usufruto, a atribuição a um mesmo titular da propriedade de um bem e de um direito do usufruto sobre este acarreta, lògicamente, a extinção deste. Isto porque não pode haver encargos sobre coisa própria.

Note-se, aliás, que clàssicamente o usufruto era visto como uma servidão pessoal e, segundo a fórmula clássica "numinem res sua servit".

III - NÃO USO

227 - Pode, também, o usufruto extinguir-se nos termos da al. c) do n.º 1 do art. 1476.º que estamos a referir, "pelo seu não exercício durante vinte anos, qualquer que seja o motivo".

Assim, se por esse lapso de tempo, o usufrutuário

não exercer os poderes que lhe competem o usufruto extingue-se.

Uma nota importante a referir é a da não aplicabilidade, neste domínio, do regime da prescrição extintivao que implicaria serem aplicáveis as causas de interrupção ou suspensão que sabemos valerem no campo da proscrição extintiva.

Aqui - na hipótese do não uso - os vinte anos previstos na lei importam necessàriamente a extinção do usufruto, independentemente de quaisquer considerações sobre o motivo do não exercício.

Diversamente, no campo dos direitos de crédito, o prazo normal de prescrição pode ser insuficiente para que esta ocorra, para tanto bastando que se tenha verificado a interrupção ou suspensão da prescrição.

A razão desta discrepância de regimes poderá fundar-se num interesse público orientado no sentido do termo dos direitos reais limitados.

É verdade que esses direitos reais correspondem ao reconhecimento de certas vantagens e, nessa medida, são aceites tipificadamente, mas logo que não estejam a cumprir a sua função a lei põe-lhes um termo.

É, precisamente, esse interesse em fazer caducar os "jura in re aliena" que - já o dissemos - está patente

na circunstância de o usufruto se extinguir pelo seu não exercício durante vinte anos.

IV - PERDA

228 - Uma outra causa de extinção do usufruto é a enunciada na al. d) do n.º 1 do art.º 1476.º, ou seja, o usufruto extingue-se "pela perda total da coisa usufruída".

Assim, se um indivíduo detém um direito de usufruto sobre um objecto e este desaparece totalmente, neste caso, segundo a lei, o usufruto extingue-se.

Conexionado com a hipótese de perda total da coisa poderá referir-se o regime aplicável à perda parcial, regime que se estatui no art. 1478.º.

Segundo o n.º 1 desta disposição "se a coisa ou direito usufruido se perder só em parte, continua o usufruto na parte restante".

Ocorre, portanto, aqui, uma redução do usufruto.

Por sua vez o n.º 2 dessa disposição prevê um hipótese da maior importância ou seja a da chamada "rei mutatio", da transformação da coisa.

Figure-se que a coisa usufruída não se perdeu to-

talmente, nem sequer parcialmente, mas antes foi objecto de uma mutação qualitativa,como ocorrerá, v.g., no caso de um automóvel, objecto do usufruto, ser reduzido, por sua destruição, a uma amálgama de sucata ou na do desmoronamento de uma casa da qual só reste o entulho.

"Quid juris" nestas hipóteses? O usufruto extinguir-se-à?

A solução tradicional, vigente no direito romano,apontava para essa solução como resultande de uma idéia de predestinação económica da coisa usufruída.

Só havia - entendia-se - manutenção do usufruto, quando, embora ocorrendo alteração, se mantinha o destino económico da coisa.

Diversamente, nos exemplos indicados, esse destino económico da coisa não se mantém. Nem o automóvel pode ser utilizado como tal, nem a casa é, agora, susceptível de ser habitável.

Daí que, na lógica do destino económico da coisa, o usufruto se devesse extinguir. Isto, porque sendo as coisas concedidas para serem usadas dentro de um certo destino económico, destino que o usufrutuário devia ressalvar, então, quando ocorria uma alteração desse elemento teleológico o usufruto tinha necessàriamente de se extinguir.

O Código Civil afastou-se, porém, desta orientação

consagrando uma outra mais aceitável.

É que, com efeito, não parece justo que o proprietário da raiz adquira imediatamente aqueles bens - a sucata ou o entulho -, quando tenham algum valor, nem que o usufrutuário os perca.

Daí que a lei estatua no n.º 2 do art. 1478.º referido que o usufruto se mantém "... no caso de a coisa se transformar noutra que ainda tenha valor, embora com finalidade económica distinta".

Assim, nas hipóteses figuradas atrás, o usufrutuário mantém o seu direito sobre a sucata ou sobre o entulho, só que agora incide sobre coisa consumível, uma vez que esses resíduos só poderão ser utilizados para outros fins mediante a sua recuperação, aplicando-se-lhes, nessa altura, o regime previsto na lei para o usufruto de coisas consumíveis.

O usufrutuário pode, por isso, consumir a coisa ou aliená-la, constituindo-se na obrigação de,no termo do seu usufruto, restituir coisa do mesmo género e espécie ou o seu valor.

Resulta também de uma aplicação destes princípios o regime previsto para a destruição de edifícios objecto do usufruto.

Nem outra coisa decorre do n.º 1 do art. 1479.º, ao

estatuir que, "se o usufruto for constituído em algum prédio urbano e este for destruído por qualquer causa, tem o usufrutuário direito a desfrutar o solo e os materiais restantes".

V - RENÚNCIA

229 - Como derradeira forma de extinção do usufruto a lei prevê na al. e) do n.º 1 do art. 1476.º, de que nos ocupamos, a renúncia.

Esta renúncia não é, òbviamente, um contrato, mas antes um mero negócio jurídico unilateral, que não requer, nos termos do n.º 2 da mesma disposição, aceitação do proprietário.

Esta figura da renúncia, como forma de extinção do usufruto, vigora em relação a todos os tipos que possa revestir, excepção feita para um ou outro ressalvado na lei.

Assim, o usufruto legal dos pais nos bens dos filhos referido no art. 1893.º, já citado, é irrenunciável nos termos do art. 1896.º, ao estatuir que "o usufruto legal é inalienável e impenhorável não podendo os pais renunciar a ele em benefício do filho".

Esta disposição integra-se no mecanismo complexo do poder paternal, sendo uma manifestação da natureza de poderes-deveres, que caracteriza os direitos atribuídos aos pais para a regência da pessoa e dos bens dos filhos menores.

VI - MAU USO

230 - Fora da enumeração do art. 1476.º uma outra causa de extinção do usufruto - mas extinção apenas do usufruto específico - encontra-se no art. 1482.º

Estatui, com efeito, esta disposição que "o usufruto não se extingue, ainda que o usufrutuário faça mau uso da coisa usufruída; mas, se o abuso se tornar consideràvelmente prejudicial ao proprietário, pode este exigir que a coisa lhe seja entregue ... obrigando-se... a pagar anualmente ao usufrutuário o produto líquido dela, depois de deduzidas as despesas e o prémio que pela sua administração lhe for arbitrado".

Este abuso considerável não extingue, portanto, o usufruto, mas pode extingui-lo em espécie, uma vez que o proprietário pode exigir que a coisa lhe seja entregue, pagando, anualmente, a importância do respectivo rendimento

ao usufrutuário.

I - RESTITUIÇÃO

231 - A terminar a matéria de usufruto cabe referir a restituição da coisa usufruída, à qual se refere o art. 1483.º ao estatuir que "findo o usufruto, deve o usufrutuário restituir a coisa ao proprietário, sem prejuízo do disposto para as coisas consumíveis e salvo o direito de retenção nos casos em que possa ser invocado".

Decorre desta disposição que o usufrutuário, como já várias vezes referimos, deve, findo o usufruto, restituir ao proprietário a coisa usufruída. Exceptua-se a hipótese de coisa consumível, em que deve ser prestado o valor, como oportunamente dissemos. Igualmente se deve ressalvar o caso de haver lugar ao exercício do direito de retenção, como garantia do reembolso do usufrutuário de, v.g., despesas extraordinárias que, nos termos dos art. 1473.º, tenha realizado (*).

(*) - Cfr., sobre o usufruto, o respectivo anteprojecto do Código Civil e correspondentes notas de autoria de PIRES DE LIMA, in Bol. Min. Just., n.º 79.

CAPÍTULO VII

USO E HABITAÇÃO

232 - Para terminar este Curso de Direitos Reais cabe referir agora, segundo a sistematização adoptada, estes dois diminutivos do usufruto que são, como já dissemos, o uso e habitação.

A noção destes dois diversos direitos, aliás bastante raros na prática jurídica, consta do art. 1484.º que se lhes refere, estatuindo que "o direito de uso consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos frutos, na medida das necessidades, quer do titular, quer da sua família "continuando o n.º 2 dessa disposição que "quando este direito se refere a casas de moradia, chama-se direito de habitação".

Este direito abrange não só o "usus", mas também o "fructus", embora a sua designação como direito de uso pu-

desse sugerir uma limitação do seu âmbito, correspondente a terminologia empregue.

Não é assim. Este direito abrange o "usus" e o "fructus", mas apenas na medida das necessidades pessoais do seu titular e da família.

Daí que, se o direito de uso incidir sobre uma casa – direito de habitação neste caso – esta não possa ser arrendada, dado que o direito não engloba os frutos civis dela, traduzindo-se antes num mero direito de habitar a casa.

No tocante, porém, ao direito de uso de um prédio rústico compreendem-se no seu âmbito, tanto a possibilidade de o cultivar, como a de colher os respectivos frutos, possibilidades também limitadas pela medida das necessidades do titular do direito e da sua família.

Dado que as necessidades da família constituem o elemento pelo qual se afere o âmbito do exercício do direito de uso pelo seu titular, importa delimitar o agregado familiar. É esta a função do art. 1487.º, ao estatuir que "na família do usuário ou do morador usuário compreendem-se apenas o cônjuge, não separado judicialmente de pessoas e bens, os filhos solteiros, outros parentes a quem sejam devidos alimentos e as pessoas que, convivendo com o respectivo titular, se encontrem ao seu serviço ou

ao serviço das pessoas designadas".

Uma nota fundamental do direito de uso e habitação é, assim, o de se pautar pelas necessidades pessoais, diversamente do que se verifica no domínio do usufruto que concede uma fruição e um uso globais e, em princípio, ilimitados.

233 – Diversamente também do que se verifica no usufruto em que este direito pode ser trespassado, onerado, arrendando, etc, no direito de uso e habitação não existe idêntica possibilidade a favor dos respectivos titulares, como resulta do art. 1488.º ao estatuir que "o usuário e o morador usuário não podem trespassar ou locar o seu direito, nem onerá-lo por qualquer modo".

234 – Todo este regime reforça a ideia já referida: os direitos de uso e de habitação são diminutivos do usufruto. É, aliás, em conexão com esta sua natureza que o art.1490º estatui que "são aplicados aos direitos de uso e de habitação as disposições que regulam o usufruto, quando conformes à natureza daqueles direitos".

Exceptuam-se, como é óbvio, aquelas disposições específicas, especialmente previstas a propósito do direito de uso e habitação, v.g., as disposições sobre o trespas

se, a locação, a oneração da coisa. Aplicam-se as regras do usufruto que não se revelem incompatíveis com a natureza do uso e habitação.

Qual é essa natureza? - pode perguntar-se.

Aqui, a natureza do direito de uso e habitação parece ser no fundo, a afectação destes direitos à função de satisfazer necessidades pessoais.

Ser-lhe-ão, portanto, aplicáveis todas as regras do usufruto que não se revelem incompatíveis com a natureza do uso e da habitação, entendida esta como a afectação destes direitos à satisfação das necessidades pessoais do seu titular.

* * *

INDICE

pp.

NOTA PREVIA 3

BIBLIOGRAFIA 5

I N T R O D U Ç Ã O

CAPITULO I

AMBITO DE APLICAÇÃO E SENTIDO DO DIREITO DAS COISAS, ISTO É, DA DISCIPLINA DOS DIREITOS REAIS

1 - Função dos direitos reais 11

2 - Sua ligação às directrizes sócio-político-económicas 15

3 - Os direitos reais e o estatuto jurídico das coisas 17

*

CAPITULO II

EXEMPLIFICAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO LEGAL E TERMINOLOGIA

4 - Exemplificação e sede legal 19

5 - Terminologia: direitos reais e direitos das coisas 23

TÍTULO I

CAPÍTULO I

CONCEITO DE DIREITO REAL

pp.

6 - Doutrina tradicional 27

7 - Crítica 30

8 - Teoria personalista 34

9 - Concepção de DEMOGUE: identificação entre direitos reais e direitos de crédito 35

10- Outra concepção identificadora 36

11- Concepção preferível 37

*

CAPÍTULO II

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS REAIS. CONFRONTO COM OS DIREITOS DE CRÉDITO

12 - Sequência 43

a) Eficácia Absoluta

13 - Eficácia "erga omnes" 43

b) Direito de Sequela ou de Seguimento

14 - Noção; sua ligação com a acção reivindicatória 46

15 - Outras manifestações suas para além da reivindicação 49

16 - Nota privativa dos direitos reais 51

pp.

17 - Excepções 54

18 - Inexistência do princípio geral "posse vale título". 54

19 - Excepções no domínio dos imóveis 59

c) Direito de Preferência ou de Prevalência

20 - Noção 61

21 - Uso dos direitos reais para fortalecer posições creditórias 65

22 - Excepções ao direito de preferência 68

23 - Manifestações de preferência no domínio dos direitos de crédito 71

d) Permanência dos Direitos Reais e Transitoriedade dos Direitos de Crédito. Rejeição desta Ideia

24 - Desenvolvimento desta ideia 77

e) Inerência da Coisa ao seu Titular

25 - Desenvolvimento desta ideia 82

f) Características do Objecto dos Direitos Reais

26 - Coisa certa e determinada 82

27 - Totalidade da coisa 84

pp.

g) Outras Características

28 - Possibilidade de usucapião. Excepções 89

29 - Características da violação dos direitos reais 90

*

CAPITULO III

PRINCÍPIOS REGULAMENTADORES DA CONSTITUIÇÃO E DA VIDA DOS DIREITOS REAIS

30 - Fundamentação básica numa opção político-ideológica 95

a) Princípio da Especialidade

31 - Desenvolvimento desta ideia 98

b) Princípio da Transmissibilidade

32 - Carácter tendencial 103

33 - Excepções: usufruto; uso e habitação 104

34 - Excepções: regime das servidões 106

35 - Cláusulas de inalienabilidade 111

c) Princípio da Elasticidade

36 - Desenvolvimento desta ideia 113

d) Princípio da Tipicidade

37 - Desenvolvimento desta ideia 114

pp.

38 - Tipicidade dos modos de constituição 117

e) Princípio da Publicidade

39 - Desenvolvimento desta ideia 119

f) Princípio da Consensualidade

40 - Desenvolvimento desta ideia 123

*

CAPITULO IV

CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS REAIS

41 - Distinção clássica entre direitos reais de gozo e direitos reais de garantia 125

a) Posse

42 - Direito real provisório 126

b) Propriedade

43 - Formas de propriedade 129

c) Direitos Reais Limitados

44 - Subdistinção 133

I - Direitos Reais de Gozo

45 - Caracterização geral 134

II - Direitos Reais de Garantia

46 - Caracterização geral. São acessórios dos créditos? 135

pp.

III - Direitos Reais de Aquisição

47 - Noção geral 137

∝) Direito de Preferência

48 - Caracterização. Mafestações 138

β) Contrato Promessa com Eficácia Real

49 - Desenvolvimento desta ideia 141

*

CAPITULO V

HIPOTESES DE QUALIFICAÇÃO REAL DUVIDOSA OU CONTROVERTIDA

50 - Sequência 147

a) Direito do Locatário

51 - Posições existentes 147

52 - Existência do direito de sequela 148

53 - Existência do direito de preferência 150

54 - O argumento da falta de ligação imediata com a coisa 151

55 - O argumento do pagamento da renda ou do aluguer 154

56 - O argumento do artigo 1037.º 155

57 - Recapitulação 156

58 - O problema da usucapião 157

59 - Continuação do número anterior. Conclusão 160

pp.

b) Direito de Retenção

60 - Solução do novo Código Civil 166

c) O Direito do Destinatário de uma Proposta Irrevogável de Alienação de uma Coisa

61 - Rejeição da qualificação real 167

d) Ónus Reais

62 - Desenvolvimento 168

*

TITULO II

DIREITOS REAIS EM ESPECIAL

CAPITULO I

INDICAÇÃO DE SEQUÊNCIA

63 - Sequência 175

*

CAPITULO II

A POSSE

A) Noção

64 - O artigo 1251.º C.C. 177

65 - Posse e propriedade 177

pp.

B) Elementos da Posse

66 - "Corpus" e "animus" 180

I - Elemento Material (Corpus)

67 - Noção. Desenvolvimento 181

II - Elemtno Psicológico ("Animus")

68 - Noção. Desenvolvimento 183

III - Necessidade de Coexistência do "Corpus" e do "Animus"

69 - Problema 185

α) Concepção Objectiva

70 - A posição de IHERING 186

β) Concepção Subjectiva

71 - A posição de SAVIGNY 186

γ) Posição Legal

72 - Os artigos 1251.º e 1253.º 187

C) Fundamento da Tutela Jurídica da Posse

73 - O problema 191

I - Defesa da Paz Pública

74 - Desenvolvimento 192

II - Dificuldade de Prova do Direito Definitivo

75 - Desenvolvimento 193

pp.

III - Valor Económico da Posse

76 - Desenvolvimento 194

D) Objecto da Posse

77 - Desenvolvimento 195

(67→) E) Caracteres da Posse

78 - Sequência 198

I - Posse Titulada e não Titulada

79 - Distinção 198

II - Posse Pacífica e Posse Violenta

80 - Distinção 200

III - Posse Pública e Posse Oculta

81 - Distinção 200

IV - Posse de Boa Fé e Posse de Má Fé

82 - Distinção 201

(75→) F) Efeitos da Posse

83 - Razões da eficácia da posse 202

I - Valor Probatório da Posse

84 - Desenvolvimento 204

II - Direitos do Possuidor em Relação aos Frutos

85 - Desenvolvimento 206

pp.

III - Direitos do Possuidor Relativamente a Benfeitorias

86 - Desenvolvimento 206

IV - Contencioso Possessório

87 - Acções possessórias 207

∝) Acção de Prevenção

88 - Caracterização 208

β) Acção de Manutenção da Posse

89 - Caracterização 209

χ) Acção de Restituição da Posse

90 - Caracterização 209

δ) Acção de Restituição no Caso de Esbulho Violento

91 - Caracterização 211

ε) Embargos de Terceiro

92 - Caracterização 211

93 - Meios extra-judiciais 213

V) A Posse como Criadora de Direitos

94 - A usucapião 213

G) Natureza Jurídica da Posse

95 - Direito real provisório 214

pp.

CAPÍTULO III

A PROPRIEDADE

S U B C A P I T U L O I

A PROPRIEDADE EM GERAL

A) Controvérsia entre a Propriedade Individual e a Propriedade Comunitária

96 - Desenvolvimento 217

B) Fenomenologia da Propriedade ao Longo da História e no Momento Actual

97 - As sociedades primitivas 221

98 - Direito romano 223

99 - Feudalismo medieval 224

100- Superação do regime feudal 224

101- Sistemas socialistas 227

C) Características do Direito de Propriedade no Nosso Sistema

102 - O artigo 1305.º 233

103 - Poderes indeterminados 234

104 - Elasticidade 235

105 - Direito perpétuo 235

106 - Bens incorpóreos ou imateriais 236

107 - Modos de aquisição 237

pp.

108 - Garantia Jurídica 238

109 - Sequência 239

*

S U B C A P Í T U L O II

PROPRIEDADES DE IMÓVEIS

A) Conteúdo

110 - Localização na lei 241

111 - Inexistência de "res nullius" imóveis 242

112 - Sequência 243

B) Limitações aos Poderes do Proprietário

I - Restrições de Direito Público

113 - Remissão..... 243

II - Restrições de Interesse Particular

114 - Manifestações 244

115 - Propriedade de águas 248

116 - Remissão 249

*

S U B C A P Í T U L O III

COMPROPRIEDADE

A) Noção

117 - Características 251

pp.

B) Distinção da Sociedade

118 - Desenvolvimento 252

C) Natureza Jurídica

119 - Posições existentes 254

120 - Concepção preferível 256

121 - Crítica a outras posições 257

122 - Idem 257

123 - Conclusão 258

D) Regime Jurídico

124 - Problemas possíveis 259

125 - Actos que podem ser praticados isoladamente por um dos consortes 260

126 - Actos que podem e devem ser praticados pela maioria 263

127 - Actos que exigem a unanimidade 264

E) Extinção da Compropriedade

128 - Desenvolvimento 265

*

S U B C A P Í T U L O IV

PROPRIEDADE HORIZONTAL

A) Referência Histórica e Determinantes do Instituto

129 - Manifestações anteriores 269

	pp.
130.- Causas do incremento actual	270
B) Noção e Domínio de Aplicação	
131 - Noção	271
132 - A "propriedade vertical"	272
C) Natureza Jurídica	
133 - Concurso de direitos	273
B) Modos de Constituição	
134 - Desenvolvimento	275
E) Direitos e Obrigações ou Encargos dos Condóminos	
135 - Interpenetração das esferas patrimoniais ...	279
136 - Propriedade plena de cada condómino	280
137 - Limitações específicas	281
138 - Compropriedade das partes comuns	282
F) Administração das Partes Comuns do Edifício	
139 - Órgãos de administração	284
140 - A assembleia dos condóminos	285
141 - O administrador	286

*

pp.

CAPITULO IV

DIREITO DE SUPERFICIE

A) Noção Legal	
142 - Direito de construir e direito de fazer plantações	289
143 - Dois direitos de diferente natureza: concessão "ad plantandum" ou "ad aedificandum" e propriedade da obra reparada do solo	290
B) A PROPRIEDADE DO SOLO	
144 - Significado da propriedade do solo	293
145 - Interesses do proprietário do solo antes da construção	294
146 - Interesses do proprietário do solo durante a construção	294
147 - Interesses do proprietário do solo depois de feita a construção	295
C) Objecto do Direito de Superfície	
148 - Caracterização	296
D) Constituição	
149 - a) Contrato; b) Testamento; c) Usucapião; d) Alienação de obra existente	297

pp.

E) Direitos e Deveres do Superficiário e do Proprietário do Solo

150 - Principais direitos e deveres 299

151 - Excepção ao princípio geral da acessão 300

F) Extinção

152 - Caducidade de reunião na mesma pessoa; desaparecimento ou inutilização do solo; expropriação. Libertação do encargo de pagar as prestações 301

*

CAPITULO V

SERVIDÕES PREDIAIS

A) Noção

153 - Rejeição pelo nosso direito das servidões pessoais 305

B) Características

154 - Indicação de sequência 309

I) Inseparabilidade

155 - Ligação ao prédio dominante 309

156 - Possibilidade de existência de servidões atribuidoras de poderes de fruição de um prédio 310

pp.

II - Indivisibilidade

157 - Expressão de aderência da servidão ao prédio 315

III - Atipicidade do Conteúdo

158 - Possibilidade de incidir sobre quaisquer utilidades, mesmo futuras ou eventuais 317

IV - Ligação Objectiva da Servidão

159 - Necessidade de um benefício para outro prédio 318

C) Constituição

160 - Modos de constituição 319

I - Contrato

161 - Breve referência 320

II - Testamento

162 - Breve referência 320

III - Usucapião

163 - Limitação às servidões aparentes. Justificação. 320

IV - Destinação do Pai de Família

164 - Características. Presunção de um acordo tácito 322

pp.

V - Sentença Judicial

165 - Servidões legais 323

166 - Hipóteses previstas na nossa lei 324

167 - Direito potestativo de constituir a servidão e servidão já constituída 328

D) Modalidades

168 - Sequência 329

I - Voluntárias e Legais

169 - Os termos da distinção 329

II - Positivas, Negativas e Desvinculativas

170 - Os termos da destinção 330

E) Exercício

171 - Definição no título constitutivo. Regras supletivas 332

F) Mudança

172 - Conciliação de interesses 335

G) Extinção

173 - Sequência. O art. 1569.º 336

I - Confusão

174 - Características 336

pp.

II - Não Uso

175 - Razão de ser 337

176 - Não uso e prescrição extintiva 338

177 - Exercício parcial da servidão. Exemplo: "servidão de pé-e carro" 339

III - "Usucapio Libertatis

178 - Características 340

IV - Renúncia e Decurso do Prazo

179 - Breve referência 341

V - Desnecessidade

180 - Não aplicação às servidões voluntárias, não adquiridas por usucapião..... 342

VI - Remição

181 - Aplicação a certas servidões de águas 345

*

CAPÍTULO VI

O USUFRUTO

A) Indicação de Sequência

182 - Direito de usufruto, direito de uso e direito de habitação 349

pp.

B) Noção

183 - Direito de usar e fruir, "salva rerum substantiae" 350

184 - Usufruto e servidão pessoal 352

C) Características

185 - Análise do art. 1439.º 354

I - Temporaricdade

186 - Extinção pelo decurso do prazo ou pela morte do usufrutuário 354

187 - Razões desta característica: os inconvenientes do usufruto 356

188 - Vantagens do usufruto 358

II - Plenitude do Gozo do Objecto

189 - Gozo pleno do objecto 360

α) Alienabilidade do Usufruto

190 - Possibilidade de o usufrutuário trespassar o seu direito 361

191 - Possibilidade de onerar. O "intuitus personae" 362

192 - Restrições à possibilidade de disposição do usufruto 364

193 - Responsabilidade do usufrutuário que transmitiu o seu direito 365

pp.

β) Ausência de Especial Limitação pelo Fim

194 - Inexistência de uma afectação teleológica 366

201 III - Princípio da Conservação da Forma e Substância

195 - Carácter imperativo do princípio 367

196 - O usufruto de coisas consumíveis, visto nesta perspectiva 368

IV - Usufruto sobre Direitos

197 - Indicação da respectiva possibilidade 369

190 D) Constituição

198 - Indicação de sequência. O Art. 1440.º 369

I - Contrato

199 - a) Constituição "per translationem";
b) Constituição "per deductionem". Interesse prático 370

II - Testamento

200 - Breve referência 373

III - Usucapião

201 - A pretensa impossibilidade de usucapião do direito de usufruto 374

pp.

(192) IV - Disposição da Lei

202 - Exemplos 376

E) Usufrutos Sucessivos ou Simultâneos

203 - Limitações a esta possibilidade. Razão de ser 376

204 - Possibilidade de constituição a favor de nascituros já concebidos 378

205 - Existência de um direito de acrescer 380

F) Direitos do Usufrutuário

(202) I - Doutrina Geral

206 - Poderes do usufrutuário relativamente ao próprio usufruto 381

207 - O título constitutivo 382

208 - O modelo do "bom pai de família" 383

209 - Respeito pelo destino económico da coisa 385

210 - Direito aos frutos no início e no termo do usufruto 386

211 - Frutos e produtos 388

212 - Doutrina da percepção para os frutos naturais e critério da proporcionalidade para os frutos civis 390

213 - Benfeitorias: regime do possuidor de boa fé .. 392

213-a - Alienação de frutos antes da colheita 393

pp.

(203) II - Casos Especiais

214 - Especificidade de determinadas categorias de bens 394

215 - Coisas consumíveis 394

216 - Coisas deterioráveis..... 398

217 - Árvores, arbustos, matas, árvores de corte, plantas de viveiro 399

218 - Concessões mineiras; pedreiras 401

219 - Universalidades de animais 401

220 - Capitais levantados, títulos de crédito, títulos de participação 402

(204) G) Obrigações do Usufrutuário

221 - Inventário e prestação de caução 404

222 - Consequências de não prestação de caução 406

223 - Reparações ordinárias e extraordinárias 406

(193) H) Extinção

224 - Indicação da sequência. O art. 1476.º 408

(194) I - Morte ou Decurso do Tempo

225 - Carácter pessoal do usufruto 409

(197) II - Confusão

226 - A reunião do usufruto e da propriedade na mesma pessoa 409

pp.

III - Não Uso

227 - Não uso e prescrição extintiva 411

IV - Perda

228 - Perda total, perda parcial e transformação da coisa ("rei mutatio") 414

V - Renúncia

229 - Negócio jurídico unilateral . Usufrutos irrenunciáveis..... 415

VI - Mau Uso

230 - Possibilidade de extinção em espécie por abuso consideràvelmente prejudicial 416

I - Restituição

231 - Obrigações de restituição no termo do usufruto. Excepções: as coisas consumíveis; o direito de retenção 417

*

CAPITULO VII

USO E HABITAÇÃO

232 - Limitação às necessidades do titular ou da família 419

233 - Intransmissibilidade do direito 419

234 - As normas de usufruto como normas supletivas. Limitação pela natureza daqueles direitos 419

ERRATA 447